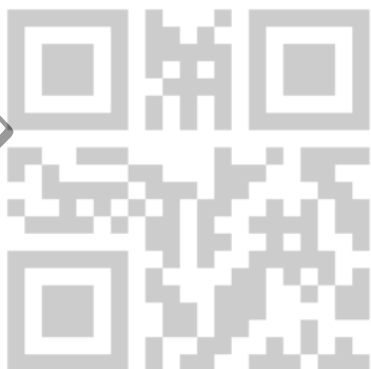




عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

2024/2025

2. 22



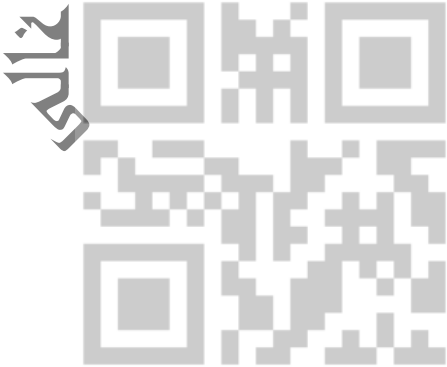


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





2024/2025

4/2025

مكتبة المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي



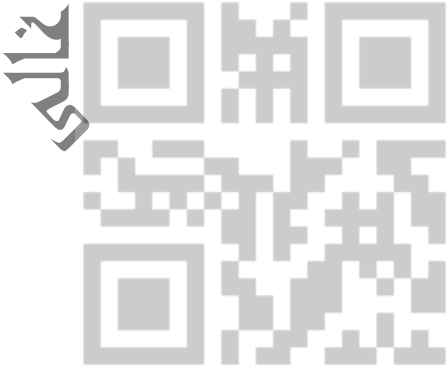


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



مقدمه

تمهيد :

يعتبر حق الملكية أهم الحقوق العينية الأصلية وأوسعها نطاقاً إذ يخول هذا الحق لصاحبه جميع السلطات الممكنة على محله فهو يعطى للمالك سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والمالك هنا يستأثر بهذه السلطات وحده ولا ينازعه فيها أحد. كما أن حق الملكية يعتبر أساس الحقوق العينية الأصلية التي تعد فروعاً له إذ نفترض جميعها وجود حق ملكيه وعلى هذا فإن وجود هذه الحقوق وانتهاءها يرتبط وجوداً وعدمياً بحق الملكية^(١).

وقد أدرك المشرع المصرى جيداً أهمية حق الملكية ولذلك فإنه قد خصص له باباً مستقلاً فى القانون المدنى لبيان فيه أحكام هذا الحق من حيث مفهومه ونطاقه ووسائل حمايته والقيود التى ترد عليه، كما خصص المشرع فصلاً مستقلاً لبيان أسباب كسب الملكية. وستنقسم الدراسة إذاً إلى بابين:

الباب الأول : أسباب كسب الملكية.

2024/2025

2024/2025

الباب الثانى : أحكام حق الملكية.

(١) د/ حسن كيرة : الموجز فى أحكام القانون المدنى، الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها، الطبعة الثالثة منشأة المعارف ١٩٩٤. ص ٥٩ رقم ٢١. د/ رمضان أبو السعود، الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية، أحكام الحقوق العينية الأصلية ومصادرها. دار المطبوعات الجامعية ١٩٩٧. ص ٢٧. د/ نبيلة رسلان الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها. مطبعة جامعة طنطا. ١٩٩٩. ٢٠٠٠ ص ١٤ رقم ٥.

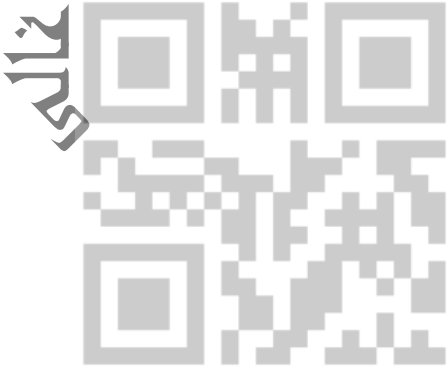


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الباب الأول

أسباب كسب الملكية

يقصد بأسباب كسب الملكية الوسائل أو المصادر التي بمقتضاها يتم اكتساب حق الملكية بصفة عامة، على شئ معين بالذات. وقد وردت أسباب كسب الملكية في القانون المدني على سبيل الحصر وهي الاستيلاء والالتصاق - والعقد الوصية والميراث والشفعة والحيازة.

ولا تخرج هذه الأسباب عن الطائفتين الأساسيتين لمصادر الحقوق وهي. الواقعة القانونية والتصرف القانوني. فالميراث مثلاً بعد واقعة طبيعية أما الاستيلاء والالتصاق والحيازة فهي أعمال مادية ترتبط بها نية التملك. ومن أسباب كسب الملكية أيضاً ما يمثل تصرفاً قانونياً من جانب واحد كالوصية ومنها ما ينتج عن تلاقى إرادتين كالعقد. وتعتبر الشفعة من قبيل الوقائع المركبة أو المختلطة حيث تقترن فيها الواقعة المادية بالعمل القانوني أو التصرف القانوني^(١).

2024/2025 تنقسم أسباب كسب الملكية إلى أسباب تكسب الملكية ما بين الأحياء 2024/2025 وهي الشفعة والعقد والحيازة والالتصاق، والاستيلاء، وأسباب تكسب الملكية بسبب الوفاة وهي الميراث والوصية.

والمرجع المصري في القانون المدني قد رتب أسباب كسب الملكية ترتيباً منطقياً بأن ميز بين أسباب كسب الملكية ابتداءً وهي الاستيلاء، وبين كسبها انتقالاً من مالك سابق، وقد يكون ذلك بسبب الوفاة، ويندرج تحتها الميراث والوصية، أو يكون انتقالاً ما بين الأحياء ويتم ذلك بالالتصاق والعقد والشفعة والحيازة.

(١) نقض مدني ١٧-١-١٩٧٩، طعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٥ ق، ص ٢٣٧.

تقسيم :

وفى دراستنا لأسباب كسب الملكية أو مصادرها سوف نقسمها إلى
فصول ثلاثة على النحو التالى:

الفصل الأول : أسباب كسب الملكية ابتداء « الاستيلاء ».

الفصل الثانى : أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة « الميراث - الوصية »

الفصل الثالث : أسباب كسب الملكية فيما بين الأحياء « الالتصاق -
العقد - الشفعة - الحيازة ».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفصل الأول

الاستيلاء

التعريف به :

الاستيلاء هو وضع اليد على الشيء، فأول من يضع يده ويشتمل أى عنصر من عناصر الطبيعة فإنه يكتسب بمقتضى هذه الواقعة حق ملكية على هذا الشيء، سواء كان منقولاً أم عقاراً، ويصبح المالك الشرعى له وعلى الغير احترام ملكيته.

غير أن هذه النظرية التى تبرر شرعية الملكية على أساس وضع اليد أو الاستيلاء تعرضت للنقد^(١). فمن ناحية لا تصلح فكرة وضع اليد لتبرير شرعية الملكية، فهى قد تصلح فى مجال تحديد أسباب كسب الملكية أو كمعيار عند تنازع شخصين على الملكية حيث يفضل من له الحياة ووضعه اليد. أما الاستيلاء أو وضع اليد فلا يصلح فى ذاته كأساس وسند للملكية بل هو على العكس نتيجة للملكية أى أن المالك له الحق فى الحياة ووضعه اليد على الشيء محل الملكية.

2024/2025

2024/2025

ومن ناحية أخرى فإن فكرة وضع اليد لا تصلح لتبرير كل أشكال الملكية، فعلى فرض صلاحيتها لتبرير ملكية المنقول، فهى لا تصلح لتبرير الملكية العقارية. فهذه الفكرة تفترض عقاراً لا مالك له ثم يأتى شخص ويضع يده عليه وبذلك يصبح مالكا له، الأمر الذى لا يمكن تصوره قانوناً، لأن التاريخ يشير إلى أن الأرض لم تكن أبداً شيئاً لا مالك له.

ولقد كانت المادة ٨٧٤ مدنى تنظم الاستيلاء كسبب لكسب ملكية العقار، ولكن بصدور القوانين المنظمة للملكية الخاصة للدولة وخصوصاً القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية،

^(١) Connard: La propriété dans la doctrine et dans l'histoire. Raris 1943, p. 58 at suip.

فإن الاستيلاء لم يعد ممكناً قانوناً على العقارات. فقد أصبحت كافة العقارات التي لا مالك لها مملوكة للدولة. ولا يجوز تملكها إلا وفقاً للقواعد الواردة في القوانين الخاصة^(١). ولا يجب كذلك إغفال المادة ٩٧٠ من القانون المدني والمعدل بموجب القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ والتي تنص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم.

وعلى هذا فالاستيلاء يقتصر على المنقول دون العقار، وقد عرفه القانون المدني المصري في المادة ٨٧٠ منه بأنه «وضع اليد على منقول لا مالك له بنية تملكه».

ونبدأ بدراسة شروط تملك المنقول بالاستيلاء. ثم نعرض لبعض التطبيقات للاستيلاء كسبب مكسب للملكية.

المبحث الأول

شروط تملك المنقول بالاستيلاء

هناك شروط يجب توافرها لتملك المنقول بالاستيلاء. وهي أن ترد الحياة على منقول مادي لا مالك له. وأن يتم الإحراز أو السيطرة المادية على المنقول، مع توافر نية التملك وذلك على الإيضاح التالي:

الشرط الأول - حيازة منقول مادي لا مالك له:

الاستيلاء لا يرد على العقار، بل يجب وروده على منقول، وهذا المنقول لا بد أن يكون مادياً. فالمنقولات المعنوية لا يرد عليها الاستيلاء. فمن يجد صورة ممزقة في سلة المهملات فإنه لا يملك بالاستيلاء إلا تلك الأجزاء الممزقة فقط، ولا يجوز له إعادة تكوين الصورة وبيعها. فالاستيلاء لا يكسب

(١) جرى قضاء محكمة النقض على أن الأراضي الداخلة في زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضي غير المنزرعة التي كان يجوز تملكها بالاستيلاء طبقاً للمادة ٨٧٤ مدني. وبالتالي فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هي الترخيص أو التعمير». نقض مدني ٢٧-١-١٩٨٨ طعن رقم ٣٦٨ لسنة ٥٤ هـ.

سوى ملكية القماش أو الورقة، أما الحق المعنوى أو المالى للمؤلف أو الفنان فيظل بعيداً عن الاستيلاء^(١).

والاستيلاء لا يرد إلا على المنقولات المادية التى لا مالك لها. وهى إما أن تكون كذلك ابتداء، وإما أن تكون مملوكة لأحد من الناس ثم يتخلى عنها صاحبها بقصد النزول عن ملكيتها.

والأشياء التى لا مالك لها ابتداء تكون كذلك لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لحق الملكية مثال المال والهواء. وقد يتخلى شخص عن منقول يمتلكه ويكون ذلك بقصد النزول عنه، فعندئذ يصبح المنقول سائبة، ولمن يستولى عليه الحق فى تملكه، بشرط أن يكون تخلى مالكه عن حيازته بإرادته، وأن تتوافر لديه نية النزول عن الملكية.

وإذا توفى شخص ولم يكن له ورثة آلت التركة وما بقى منها إلى الخزانة العامة. فالمنقول الذى يتركه المتوفى الذى لا وارث له لا يصبح مالاً مباحاً يمكن للأفراد تملكه بالاستيلاء، بل يؤول إلى الخزانة العامة. فالدولة تملك تلك المنقولات بحكم القانون^(٢).

2024/2025

2024/2025

الشرط الثانى - الأحرار أو وضع اليد على المنقول :

ويجب فى الاستيلاء على المنقول المادى الذى لا مالك له أن يتم السيطرة المادية أو الفعلية عليه، فلا يكفى بحسب الأصل أن تكون الحيازة حكمية. وعلى ذلك فمن يجد حيواناً متروكاً فى الطريق العام لا يكفى لملكه بالاستيلاء أن يضع فى عنقه طوقاً عليه اسمه، بل يجب أن يحوزه فعلاً بأن يمسك به، أو أن يضعه فى مكان خاضع لسيطرته الفعلية، كمنزل أو حديقة.

وبالنسبة للصيد لا يلزم لتحقيق الاستيلاء أن يتم الإحراز المادى للصيد، بل يكفى الإحراز الحكمى. فالسمك أو الطير أو الحيوان الذى يقع فى الشباك

(١) د السنهورى الوسيط ٩، ص ١٦؛ د منصور مصطفى: ص ٢٧٦.

(٢) د السنهورى الوسيط ٩ ص ٤٤، د حسام الأهوانى: ص ٦٢٢.

التي ينصبها الصائد يعتبر في حيازة الصائد بمجرد وقوعه في الشباك حتى ولو لم يكن الصائد قد سحب الشباك بعد أو عرف بوقوع الصيد.

ويحقق الإحراز الحكمي بإصابة الصيد إصابة قاتلة حتى ولو ظل يعدو أو يطير فترة لاحقة، والغير الذي يستولى عليه يعتبر سارقاً، لأنه بالإحراز قد تملكه بالاستيلاء من قبل الصياد.

ولكن إذا كانت الإصابة غير قاتلة ولا تمنعه من الفرار وتمكن من الفرار فإن من يحزره بعد ذلك هو الذي يملكه، لأن الإصابة لم تحقق الإحراز ومن ثم لم يملكه الصياد الأول، فالجرح الخفيف لم يخرج الحيوان من حديدته.

الشرط الثالث - نية التملك :

ويجب أيضاً أن يتم الإحراز بنية التملك، أي الجانب المعنوي في الحيازة، وهذا واضح من نص المادة ٨٧٤ مدني التي تقضي بأن من حاز المنقول الذي لا مالك له بنية تملكه ملكه. فيجب أن يتوافر لدى واضع اليد نية التملك بجانب السيطرة المادية على المنقول. وتبعاً لذلك إذا دخل شيء في حيازة شخص ما ولم تكن لدى هذا الشخص نية تملكه فإنه لا يصبح مالكا له. ^{2024/2025}

2024/2025

وتستخلص نية التملك من الظروف والملابسات التي تم فيها وضع اليد على الشيء وما أعقب ذلك من تصرفات واضع اليد، وبصفة خاصة من نقل الشيء إلى مكان خاضع لسيطرة واضع اليد، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالمحافظة عليه، وبقائه تحت هذه السيطرة.

إذا تجمعت هذه الشروط منقول مادي لا مالك له، ووضع شخص يده عليه بنية تملكه تحققت الملكية لمن وضع يده بمقتضى الاستيلاء الذي يعتبر سبباً من أسباب كسب الملكية، ولا يشترط لاكتساب الملكية شروط أخرى كالسبب الصحيح أو حسن النية، إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان المنقول مملوكاً لغير المتصرف، والفرض هنا أن المنقول الذي يرد عليه الاستيلاء ليس مملوكاً لأحد.

المبحث الثانى

تطبيقات للاستيلاء كسب مكسب للملكية

أسلفنا أنه يشترط أن يرد الاستيلاء على منقول لا مالك له. والمنقول الذى لا مالك له إما أن يكون شيئاً لم يسبق لأحد تملكه، وإما أن يكون قد حصل تملكه لفترة من الزمن، ثم زال حق الملكية عن مالكه دون أن ينتقل إلى شخص آخر. فلم يكتفى المشرع المصرى بإيراد هذه القاعدة، وإنما تناول بالتنظيم أيضاً بعض تطبيقات لها. وهى مجموعتين:

المجموعة الأولى: المنقولات التى لم يسبق تملكها :

الأشياء المشتركة :

الأشياء المشتركة هى التى لا يملكها أحد ويعم نفعها على الجميع ويكون للكافة استعمالها. فيحق للكافة الاستفادة والانتفاع منها على قدم المساواة. والأصل هو أن تلك الأشياء تخرج عن دائرة التعامل حتى لا يستأثر بها أحد ويظل الانتفاع فى مكنة الجميع. ولكن يمكن أن تكون بعض هذه الأشياء محلاً للتعامل، وذلك إذا أمكن الاستئثار بجزء منها.

2024/2025

وأهم الأشياء المشتركة الهواء وأشعة الشمس وماء البحر ومع ذلك يمكن أن يكون قدر معين منها محلاً لملكية خاصة بالاستيلاء عليه. فمن حصر كمية من ماء البحر لاستخراج الملح أو لأغراض أخرى، يصير مالكاً لها بالاستيلاء. ومن يتمكن من حصر أشعة الشمس لاستعمالها فى أغراض الطاقة، فإن ما يحصره يعتبر ملكاً له بالاستيلاء.

الصيد :

الأصل أن الطير فى الهواء والسمك فى الماء لا مالك لهما، ويكون ملكاً لمن يصيده، والحق فى صيد البحر والبر تنظمه القوانين الخاصة (م ٨٧٣ مدنى) (١).

(١) راجع بياناً بهذه القوانين: د. السنهورى ج ٩ ص ١٩، هامش ٢.

ويشمل صيد البحر ما يحويه مائه من أسماك أو عنبر أو لؤلؤ، أو مرجان أو أسفنج أو أشياء أخرى. ويملك الصائد ما يصيده من كل ذلك بالاستيلاء، ولو كان مخالفاً للوائح الصيد، إذ يتعرض في هذه الحالة للعقوبات التي تقرها. ويخضع لذات القواعد الصيد في مياه النيل أو الترع العامة. أما السمك الذي يوجد في الترع أو المساقى الخاصة أو في مزارع الأرز فإنه يعتبر ملكاً لمالك التربة أو المسقاة أو المزرعة، ولا يجوز صيده إلا بإذنه وإلا كان الصائد سارقاً له^(١).

وصيد البر يشمل الطيور في الهواء والغزلان في الصحراء. ويثبت للكافة حق الصيد في الطريق العام شريطة مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لمباشرة هذا الحق.

ويتم الاستيلاء على الصيد وتملكه بصيده ووقوعه ميتاً ولو كان ذلك في أرض مجاوره، كما يتحقق الاستيلاء أيضاً على الصيد ولو لم يقع ميتاً مادام لم يعد باستطاعته الفرار.

الحيوانات غير الأليفة :

تنص المادة ٢/٨٧١ مدنى ^{2024/2025} على أنه «تعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها مادامت طليقة، وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً، أو إذا كف عن تتبعه، وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له».

ووفقاً لهذا النص فإن الحيوان لا يعود لا مالك له إلا إذا فقد من جهة عادة الرجوع إلى المكان المخصص له، وظل طليقاً من جهة ثانية وكف صاحبه عن تتبعه أو لم يتبعه أصلاً من جهة ثالثة.

المجموعة الثانية: المنقول الذى كان له مالك : الأشياء المتروكة :

تنص المادة ١/٨٧١ مدنى «يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عن مالكة بقصد النزول عن ملكيته».

(١) د السنهورى الوسيط ٩ ص ٢١، د منصور مصطفى: ص ٢٧٥.

من هذا النص يتبين أن الشيء المتروك هو الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه. فيعدو بذلك لا مالك له. كمن يلقى بأشياء تافهة بسلة المهملات أو بالطريق أو يلقى بالأتربة التى تستخرج من عمليات تطهير مسقى أو مصرف أو أوراق الدشت التى تتركها المصالح الحكومية أو البراميل العائمة فى البحر.

ولا يشترط لاعتبار الشيء متروكاً إلا تكون له قيمة، فقد تكون له قيمة وينزل مالكة عن حقه عليه. فكل ما يشترك لاعتبار الشيء متروكاً أن يتخلى المالك عن حيازة الشيء وتنصرف نيته إلى النزول عن ملكيته.

ومن القرائن التى يستعان بها لاستخلاص تلك النية قيمة الشيء، فإذا كان تافه القيمة فإنه يسهل استخلاص نية النزول عن الملكية، أما إذا كانت قيمته مرتفعة فلا تتوافر تلك النية ويعتبر الشيء مفقوداً وليس متروكاً. لهذا فإن النية تلعب دوراً هاماً فى التفرقة بين الشيء المفقود والشيء المتروك.

الأشياء الضائعة (اللقطة):

الشيء الضائع هو الشيء الذى يفقده صاحبه دون أن تتوافر لديه نية النزول عن ملكيته، ومن ثم فإن هذه الأشياء تظل على ملك صاحبها ولا تصبح إطلاقاً منقولاً لا مالك له، حتى ولو فقد صاحبها الأمل فى العثور عليها ومن ثم لا تتملك بالاستيلاء.

والأشياء الضائعة لا تقع تحت حصر فیدخل فيها الودائع المتروكة فى خزائن المحاكم، والأمتعة المتروكة فى المحطات وفى وسائل المواصلات، والظروف التى لا يتقدم أحد لاستلامها من مكاتب البريد والبضائع التى توجد فى مخازن الجمارك.

ولقد أحال القانون المدنى إلى القوانين الخاصة لتقوم بتنظيم مصير تلك الأشياء الضائعة م ٨٧٣ مدنى. ويتعلق ذلك التنظيم بأمرين: الأول: حقوق من يجد الشيء ويسلمه إلى صاحبه، ويخوله القانون الحق فى مكافأة قدرها عشر

في المائة من قيمة الشيء الضائع. **والثاني:** إذا احتفظ بالشيء الضائع لدى جهة الإدارة ولم يستدل على صاحبه فمصير هذه الأشياء وتباع بالمزاد.

وملتقط الشيء لا يستطيع أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وذلك لعدم توافر حسن النية ولعدم وجود السبب الصحيح، ومن ثم يحق لمالك الشيء أن يسترده حتى ولو مضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الضياع، ولكن يستطيع ملتقط الشيء الضائع التمسك بالتقادم المكسب إذا توافرت شروطه.

ويختلف الشيء الضائع عن الكنز في أن الكنز هو الشيء يخفيه صاحبه عمداً ولهذا يكون مخبئاً أو مدفوناً، أما الشيء الضائع فهو عادة يفقد نتيجة الإهمال أو النسيان، ويعثر عليه عادة على سطح الأرض وليس في باطنها. ولكنهما يتفقان في أن صاحب الكنز وصاحب الشيء الضائع لم ينزلا عن ملكية الشيء.

الكنز :

2024/2025 ^{2024/2025} يقصد بالكنز المنقول الذي يوجد مدفوناً أو مخبئاً في باطن الأرض ولا يعرف له مالك، وعلى هذا يشترط لوجود الكنز بالمعنى القانوني أن يكون الشيء مخبئاً أو مدفوناً، وأن يكون من المنقولات، وألا يعرف مالك هذا الشيء.

الشرط الأول :

أن يكون مدفوناً أو مخبئاً سواء في باطن الأرض أو أسفل الأرضية أو الجدران أو السقف، والدفن أو الإخفاء يجب أن يتم عن قصد، لأنه يعني أن المالك أراد حفظ الشيء وإبعاده عن الأعين، ولهذا حرص على دفنه.

ولا يشترط أن يكون الكنز مدفوناً في عقار فقد يكون مدفوناً في منقول، فلا أهمية لطبيعة الشيء الذي أخفى فيه الكنز. فقد يدفن في عقار كباطن الأرض أو حائط في منزل. وقد يخبئ في منقول مثل إخفاء نقوداً أو طابع تذكاري في كتاب، أو مجوهرات في درج سرى في مكتب أو خزانة للملابس.

وبلاحظ أنه لا تعتبر المنقولات التي يعدها القانون من الآثار كنوزاً لأن لها مالك هو الدولة (١).

الشرط الثاني:

أن يكون المنقول غريباً عن الأرض التي عثر فيها عليه. وعلى ذلك لا تعتبر المعادن والأحجار الموجودة في الأرض كنوزاً، فهي عقارات تكون بطبيعتها جزءاً من الأرض، فلا ينطبق عليها كونها مدفونة أو مخبأة وإنما هي من عناصرها.

الشرط الثالث:

ألا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لهذا المنقول فإن أثبت أحد ملكيته له وإن كان قد دفنه حفاظاً عليه، فلا يعد المنقول كنزاً ولما لکه أن يسترده من مالك العقار بدعوى الاستحقاق.

والذى يضاف على المنقول صفة الكنز هو عدم العلم بمكانه ودخول الأمر في طى النسيان مع مرور الزمن. مالك المنقول يخبئه دون أن يطلع ورثته على المكان الذى أخفى فيه الشئ، أو أن الورثة يعلمون بذلك ولكنهم لا يتمكنون من العثور عليه.

وبناء عليه إذا تمكن مالك المنقول المخبأة أو ورثته من إثبات ملكيتهم له، فإن صفة الكنز تنتفى عن الشئ ويكون ملكاً لهم دون منازع، ويجوز لهم إثبات الملكية بكافة طرق الإثبات.

إذا توافرت الشروط السابقة كان المنقول المدفون كنزاً. ولكن نظراً لعدم معرفة مالك الكنز، ولعدم استطاعة أحد أن يثبت ملكيته له، فقد نظم القانون ملكية الكنوز.

(١) د. لبيب شنب: ص ١٨٨، د. حسام الأهوانى: ص ٦٢٦.

[١] لمالك العقار الذى يوجد فيه م ١/٨٧٢ مدنى حتى ولو كان العقار مؤجراً. وعلى ذلك إذا عثر على كنز فى عقار ما، فإن ملكية هذا الكنز لا تثبت لمن عثر عليه (١)، بل لمالك العقار، فإن تعدد الملاك وكانت ملكيتهم شائعة، كان الكنز ملكاً لهم ملكية شائعة.

[٢] إذا عثر على الكنز فى عقار وكان مقررراً عليه حق انتفاع كانت ملكية الكنز لمالك الرقبة.

[٣] إذا عثر على الكنز فى عين موقوفة فإن يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته م ٢/٨٧٢ مدنى لا للمستحقين فى الوقف، ولا للوقف ذاته باعتباره شخصاً معنوياً.

وإذا حدث أن ظهر مالك الكنز وكان غير مالك العقار الذى عثر عليه فيه، واستطاع ذلك المالك أن يثبت ملكيته، فإنه يستطيع أن يسترده فى أى وقت، باعتباره مازال مملوكاً له، وأن مالك العقار لم يملكه فى أى وقت (٢).

على أنه يجوز لمالك العقار أن يملك الكنز بالتقادم الطويل أى بوضع يده عليه مدة خمس عشر سنة، وفى هذه الحالة يكون له أن يمتنع عن رده إلى مالكه الأصلي. وإذا كان مالك العقار قد تصرف فى الكنز كأن باعه إلى مشتري حسن النية، لا يعلم بأنه يشتري كنزاً، فإن هذا المشتري يستطيع أن يمتنع عن رد الكنز إلى مالكه الأصلي استناداً إلى قاعدة الحياة فى المنقول سند الحائز (٣).

الأشياء الأثرية :

تنص المادة ٨٧٣ مدنى على أن الأشياء الأثرية وملكيتها تنظمها لوائح خاصة. والقانون الذى ينظم حماية الآثار هو القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

(١) بعض القوانين تشرك من يعثر على الكنز فى ملكيته مع مالك العقار الذى وجد فيه بنسبه معينه هى النصف فى القانون الفرنسى م ١/٧١٦ من القانون المدنى الفرنسى.

(٢) د لبيب شنب: ص ١٨٩.

(٣) مالك العقار لا يستطيع التمسك بهذه القاعدة، لأنه ليس لديه سبب صحيح لتمام الكنز. فهذا السبب يجب أن يكون تصرفاً قانونياً. د السهنورى ح ٩، ص ٣٤.



ووفقاً لهذا القانون يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية (م ١).

كذلك يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة (م ٢).

وتعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة (م ٣).

وتعتبر مبان أثرية المباني التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة (م ٤).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإذا كانت الآثار تشترك مع الكنز فى أن كلاً منهما مدفون أو مخبوء إلا أن الآثار ليست فقط شيئاً له قيمة كالكنز، بل هى من طبيعة خاصة، فهى نتاج حضارات ثقافية ولها أهميتها البالغة من الناحية التاريخية والحضارية والمصالح القومية (١). لذلك فإنها لا تترك سائبة يأخذها أول من يستولى عليها تطبيقاً لقواعد الاستيلاء بل أخرجها القانون من هذا النطاق.

فالآثار : لا تكون محلاً للاستيلاء، وكل من يعثر على أثر منقول أو عقارى على سطح الأرض أو فى باطنها، أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر

(١) د. السنهورى الوسيط ٩، ١٢، د. لبيب شنب: ص ١٩٠.



٢٠

ثابت لا يحق له الاستيلاء عليه. ويصبح الأثر ملكاً للدولة أو للهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عشر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة (م ٢٤ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣).

ويترتب على اعتبار المنقولات الأثرية مملوكة للدولة، أن من يضع يده على منقول أثرى بنية تملكه، لا يملكه. وقد يعاقب إذا كان يعلم بأن هذا المنقول أثرى، أو إذا كان قد عشر عليه نتيجة تنقيبه في منطقة أثرية بدون ترخيص.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

عالي



الفصل الثانى أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة « الوصية - الميراث »

تقسيم :

أُسلفنا أنه بصدد بعض أسباب كسب الملكية التى وردت فى القانون المدنى وهى الوصية والميراث فقد أحال المشرع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الخاصة فى هذا المجال، لذلك فسوف نقسم هذا الباب للفصلين التاليين :

المبحث الأول : الوصية .

المبحث الثانى : الميراث .

المبحث الأول الوصية

الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، بمقتضاه ينقل أو يرتب الموصى على سبيل التبرع حقاً مالياً فى تركته إلى الموصى له^(١).

وقد عرفت المادة الأولى من قانون^{2024/2025} الوصية بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت. فإذا كان الموصى به شيئاً معيناً عقاراً أو منقولاً، ترتب على الوصية انتقال ملكيته إلى الموصى له، واعتبرت لهذا سبباً لكسب الملكية.

والوصية تصلح كذلك طريقاً لانتقال أو إنشاء الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية. فيجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذ كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية. كما تجوز للحمل المستكن.

وما يسرى فى شأن الانتفاع يسرى على حق الاستعمال والسكنى، والإرتفاق كذلك يمكن أن يكسب بالوصية وذلك إما بصفة أصلية وإما بصفة

(١) د عبد المنعم الصده: ص ٨٠٥، د زكى: ص ٣٣١.



تبعية. فاكنتسابه أصلياً يتأتى عن طريق إيصال شخص لآخر بحق ارتفاق على عقاره، واكتسابه تبعياً يأتى عن طريق إيصال شخص لآخر بعقار يملكه وثابت به ارتفاق على عقار آخر. إذ بالوصية يكتسب الموصى له ملكية العقار ويكسب بالتالى ما هو مقرر لصالح العقار من ارتفاق.

وقد أقر الشارع الوصية مع تقيدها بحدود معينة، فأجاز الوصية فى حدود قدر معين من التركة هو الثلث، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم «أن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلاث أموالكم فى آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه حيث شئتم». وقد أجاز القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن يوصى الشخص فى حياته بما لا يزيد على ثلث تركته لوارث أو لغير وارث^(١).

وتسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها «م ٩١٥ مدنى»، أى يسرى القانون ٧١ لسنة ١٩٤٦، فإن لم يوجد به نص تعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

24/2025 ولئن نتعرض فى هذا المقام ~~للكل~~ 4/2025 لأحكام الوصية، وإنما نتناول منها فقط 2024/2025 ما تقتضيه دراستها باعتبارها سبباً لكسب الملكية.

المطلب الأول

انعقاد الوصية

الوصية تصرف بإرادة منفردة، فتنعقد بإرادة الموصى وحده دون أن يتوقف انعقادها على قبول الموصى له.

وإن لم يكن القبول ركناً لانعقاد الوصية فهو شرط للزومها. وهذا ما نصت عليه المادة ١/٢٠ من قانون الوصية «تلزم الوصية بقبولها من

(١) «إذ تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة، فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة». نقض مدنى ١٩٨٥/١/٣ طعن رقم ١٢ س ٥١ ق.

الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى. ومعنى هذا أن مصدر الحق العيني الموصى به ليس في الحقيقة تصرفاً قانونياً خالصاً بالوصية، وإنما هو مصدر مركب من إرادة الموصى وواقعة الوفاة^(١). وفي هذا قضى بأن مفاد نص المادتين ٢٠، ٢٢ من القانون ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع الوضعى أخذ بالرأى المعمول عليه فى المذهب الحنفى من أن وقت قبول الموصى له الوصية إنما يجب أن يكون بعد وفاة الموصى حتى يثبت له الملك^(٢).

ويترتب على التأصيل السابق أن الموصى له لا يستحق ثمار الشئ الموصى به قبل وفاة الموصى، ويستحقها من هذه الوفاة باعتبارها ثمار ملكه، ولذلك لا تدخل هذه الأخيرة فى حساب القدر الجائز الإيصاء به.

وإذا كان نشوء الحق العيني أو انتقاله بالوصية محدداً فى الأصل بتاريخ وفاة الموصى. فمع ذلك يجب فى هذا الصدد التفرقة بين المنقول والعقار.

إذا وردت الوصية على منقول، فإن الحق العيني الموصى به ينتقل إلى الموصى له فور الوفاة بلا حاجة إلى أى إجراء آخر، ما لم يتفق على إرجاء نقل الحق. فإذا كانت الوصية بمبلغ من النقود فإن المال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى. فيلتزم الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له بفوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية عملاً بالمادة ٢٢٦ مدنى^(٣).

أما إذا كان الموصى به حقاً عقارياً فلا بد من التسجيل وهذا ما نصت عليه صراحة المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى بقولها «جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو زواله» ثم ترون بالتأكيد على الوصية بقولها «ويدخل فى هذه التصرفات الوصية».

(١) د حسن كيرة: الحقوق العينية ص ٣٤٢، د مصطفى الجمال: ص ٤١٠.

(٢) نقض مدنى ١٩٧٢/٢/١٥ مجموعة الأحكام س ٢٣، ص ١٧٦.

(٣) نقض مدنى ١٦-٢-١٩٦٧ مجموعة الأحكام س ١٨، ص ٤٠٦.

وعلى هذا النحو فملكية العقار الموصى به لا تنتقل إلا بالشهر وفقاً للمادة ٩ من قانون الشهر العقارى (١). فلا يترتب على الوصية غير المشهورة انتقال ملكية العقار إلى الموصى له، وإنما يكون هذا العقار على ملك الورثة. ولذلك يكون هناك التزام على الورثة بالقيام بما يلزم لتسجيل الوصية حتى تنتقل الملكية إليه، وكذا الترامهم بتسليم العقار الموصى به.

ويتم شهر الوصية بتسجيل المحرر المثبت لها، سواء كان ذلك أثناء حياة الموصى (٢) أو بعد وفاته. والمحرر المثبت للوصية قد يكون ورقة رسمية أو ورقة عرفية مصدقاً على توقيع الموصى فيها. ولا صعوبة فى تسجيل الاثنين. أما إذا كان المحرر ورقة مكتوبة كلها بخط الموصى، فلا يمكن تسجيل المحرر لأن المادة ٢٩ من قانون الشهر العقارى تشترط لشهر المحررات العرفية أن يكون مصدقاً على توقيعات ذوى الشأن فيها. ويتعين على الموصى له فى هذه الحالة أن يحصل على إقرار من الورثة بالوصية مصدقاً على توقيعاتهم فيه، أو يستصدر حكماً ضد الورثة بصحة الوصية.

2024/2025

وإذا لم تكن الوصية ثابتة فى محرر بصورة من الصور السالفة فليس معنى ذلك بطلانها، لأن وجود الكتابة مجرد شرط لسماع الدعوى عند الإنكار (٣). لذلك يستطيع الموصى له فى هذه الحالة الحصول على إقرار من الورثة بالوصية مصدق على توقيعاتهم به ويقوم بتسجيله.

(١) كما أوجبت المادة ٢٦ من قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ قيد الوصية بعقار فى السجل العينى.

(٢) تسجيل الوصية فى حياة الموصى جائزة بنص المنشور رقم ٧٠٠ لسنة ١٩٤٧ شهر عقارى ، و م ١٥٣ من تعليمات الشهر العقارى لسنة ١٩٦٩، إلا أنه يكون باتاً ولا يؤشر على الوصية بختم ناقل للتكليف إلا بعد وفاة الموصى.

(٣) الإنكار الذى عناه المشرع الوضعى هو الإنكار المطلق، سواء فى مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة، فإذا أقر المدعى عليه الوصية بكتابة عليها إمضاه أو أمام قاضى فى مجلس القضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار وتعين سماعها. نقض مدنى ٨-١-١٩٧٠، مجموعة أحكام س ٢١، ص ٢٥٠.



المطلب الثانى

حماية الورثة من الوصايا المستترة

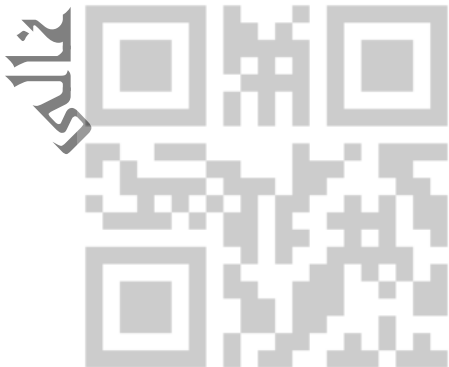
حق الإيصاء محدد فى حدود الثلث، بحيث يتوقف نفاذ الوصية فيما يزيد على الثلث على إجازة الورثة م ٣٧ من قانون الوصية. وهذا التحديد كثيراً ما يدفع إلى التحايل على حكمه عن طريق إعطاء الوصية مظهر التصرفات المنجزة حالة الحياة التى لا تخضع لمثل هذا التحديد.

فالوصايا المستترة هى تصرفات يعمد الموصى فيها إلى إخفاء نية الإيصاء وإظهار نية تصرف آخر بقصد التحايل على أحكام الميراث وعندئذ يكون التصرف الخفى هو الوصية، أما التصرف الظاهر فقد يكون بيعاً أو هبة أو إقرار بدين أو غير ذلك.

فى مثل هذه الأحوال يحق للوارث - بوصفه من الغير - أن يتمسك بالصورية وأن التصرف فى حقيقته ليس إلا وصية. ووفقاً للقواعد العامة يلتزم من يدعى الصورية بإثباتها، فيكون عليه أن يثبت قصد المورث فى التبرع من ناحية^{٢٠٢٤/٢٠٢٥}، وقصده إلى إضافة التملك^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} إلى ما بعد الموت من ناحية أخرى. 2024/2025

ومن القرائن الدالة على قصد التبرع إثبات أن المتصرف لم يقبض عوضاً عما تصرف فيه، أو إثبات أن المتصرف له لم يدفع عوضاً لما آل إليه بالتصرف، أو إثبات عدم جدية الثمن أو بخس هذا الثمن، أو عدم قدرة المتصرف له على دفعه. أو إثبات تحرير العقد فى غيبة المشتري أو غير ذلك من القرائن.

(١) «نية التبرع يتعينها دفع الثمن إلى المورث حتى ولو تضمن العقد شرطاً باحتفاظ المورث بالانتفاع حتى وفاته، ذلك أن واقعة دفع الثمن بالكامل تتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات، نقض مدنى فى ١٤-١١-١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩، ص ٢٦٢.



ويستدل على إضافة التملك إلى مابعد الموت من عدة قرائن منها إثبات بعض الورثة بالتركة كلها أو بعضها، عدم تنفيذ التصرف قبل وفاة المتصرف، عدم تسجيل التصرف، وغير ذلك من القرائن.

وقد يسر المشرع على الورثة الإثبات في هذه الأحوال بإقامة قرينتين قانونيتين على اعتبار بعض تصرفات المورث المنجزة في حكم الوصية المضافة إلى ما بعد الموت. الأولى في حالة التصرف في مرض الموت، أما القرينة الثانية في حالة التصرف لوارث مع احتفاظ المتصرف بحيازة العين والانتفاع بها مدى حياته.

حالة التصرف في مرض الموت :

تنص المادة ٩١٦ مدنى على أن «١- كل قانون يصدر من شخص مريض مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيّاً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. ٢- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مريض مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذ لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. ٣- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، أعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

ومرض الموت الذى أشارت إليه المادة ٩١٦ مدنى هو المرض الذى يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله، ثم يتصل الموت به سواء بسبب المرض أم بسبب آخر خلال سنة من بدء المرض.

فإذا استطال المرض لأكثر من سنة - كالأأمراض المزمنة - فلا يعتبر مرض موت مهما كان من خطورة المرض أو احتمال عدم برء صاحبه منه،





وتكون تصرفات المريض مرضاً مزمناً في هذه الفترة صحيحة، إلا في فترة اشتداد وطأة هذا المرض حيث تعد حالة من حالات مرض الموت.

والعبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة (١). وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

يخلص من ذلك أن التبرعات الصادرة من المورث في مرض الموت تعتبر وصية، فلا تنفذ في حق الوارث إلا في حدود الثلث، ومن ثم فالوارث يعتبر غيراً بالنسبة لهذه التبرعات. على أنه يشترط لكي يعتبر الوارث غيراً فلا يلزمه تصرف المورث إلا في حدود ما تلزمه وصيته، أن ينجح الوارث في إثبات أن التصرف قد تم أثناء مرض الموت، فإذا ما كان للتصرف تاريخ ثابت سابق على مرض الموت كان هذا التاريخ حجة على الوارث.

أما إذا كان تاريخ التصرف تاريخاً عرفياً فهو حجة أيضاً على الوارث وإن كان لهذا الأخير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن هذا التاريخ قد قدم عمداً لإخفاء أن التصرف قد صدر في مرض الموت.

2024/2025 ورغماً عن أن المشرع نص في المادة ٢/٩١٦ مدني على أن تاريخ التصرف لا يعتبر حجة على الوارث إلا إذا كان هذا التاريخ ثابتاً.

إلا أن الفقه المصري مجمع (٢) على أن هذا النص معيب وأن الوارث لا يعتبر غيراً بالنسبة للتاريخ العرفي حتى تمتنع محاجاته به وإنما هو خلف عام حكمه بالنسبة لهذا التاريخ حكم سلف المورث سواء بسواء. غاية ما في الأمر

(١) «لا يشترط في مرض الموت ملازمة الفراش على وجه الاستمرار» نقض مدني ٩-٦-١٩٨٨، طعن ١٩٩٤، س٥٧ق.

(٢) د. السنهوري الوسيط ٩ ص ٢٢٣؛ د. جمال زكي: ص ٣٣٥؛ د. مصطفى الجمال: ص ٤٠٨؛ د. حسن كيرة: ص ٣٤٩؛ د. محمد عمران: ص ٦٩، د. الصدة: ص ٨٣٣.



أنه يملك أن يفيد من الاستثناء الذى يجيز إثبات عكس ما هو مدون بالكتابة بكافة طرق الإثبات متى كان المراد إثباته هو التحايل على القانون (١).

كذلك يشترط أن يكون الغرض من التصرف هو التبرع. وقد تدخل المشرع وأقام قرينة فى المادة ٩١٦ تسهل عبء الإثبات على الورثة، فاعتبر كل تصرف يصدر فى مرض الموت بمثابة تبرع (٢). ولكنه أجاز لمن صدر له التصرف أن يثبت أن التصرف كان بمقابل رغم صدوره فى مرض الموت.

ومن القرائن الدالة على قصد التبرع إثبات أن المتصرف لم يقبض عوضاً عما تصرف فيه، أو إثبات أن المصرف له لم يدفع عوضاً لما آل إليه بالتصرف، أو إثبات عدم جدية الثمن فى عقد البيع، أو إثبات تحسين هذا الثمن، أو إثبات عدم قدرة المتصرف له على دفع ثمن المبيع، أو إثبات عدم حاجة المتصرف إلى إبرام التصرف أو إلى عوض عن الشئ المتصرف فيه. أو إثبات تحرير العقد فى غيبة المشتري أو غير ذلك من القرائن.

التصرف إلى وارث مع الاحتفاظ بالحياة والانتفاع :

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لمحابة بعض الورثة شاع فى العمل أن يتصرف الشخص إلى أحد ورثته المحتملين تصرفاً منجزاً فى الظاهر ولكن يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فى الواقع.

لذلك أقام المشرع تيسيراً على الورثة فى عبء الإثبات قرينة قانونية على اعتبار مثل هذا التصرف فى حكم الوصية إذا كان المتصرف إليه وارثاً، وظل التصرف رغم تصرفه المنجز فى الظاهر محتفظاً بحياة العين وبالانتفاع بها طوال حياته.

(١) نقض مدنى ١٢-٦-١٩٧٧ مجموعة الأعمال، س ٢٨ ص ١٧٤٣.
(٢) نقض مدنى ١١-٤-١٩٨٤ طعن رقم ٧٦٨ لسنة ٤٩ق، حيث قضت بأن «استظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التى سردها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى إلى النتيجة القانونية التى قررتها».

فنص في المادة ٩١٧ مدنى على «إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحياسة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقد دليل يخالف ذلك».

يتضح من هذا النص أن هناك ثلاث شروط لإقامة القرينة القانونية بأن التصرف المنجز قد خرج مخرج الوصية:-

(١) أن يكون المتصرف إليه وارثاً^(١). فلا تقوم القرينة إذا كان المتصرف إليه غير وارث، وإن كان ذلك لا يمنع الوارث من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه على المتصرف بأنه يستتر وصية^(٢).

(٢) أن يحتفظ المتصرف لنفسه بحياسة العين المتصرف فيها. والحياسة المقصودة هنا هى الحياسة المادية ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومثال ذلك أن يوقع المتصرف على عقود إيجار العين أو أن يستبقى فى يده العقد ولا يسجله.

(٣) أن يحتفظ المتصرف لنفسه بالحق^{2024/2025} فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته^{2024/2025}. أما إذا احتفظ المتصرف بحق الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدة معينة، وكان من المتوقع بحسب المجرى العادى للأمور أن يعيش المتصرف بعد انقضاء هذه المدة، فلا يكفى ذلك لقيام القرينة ولو مات المتصرف قبل انقضاء هذه المدة.

ويجب أن يستند حق المتصرف فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها إلى مركز قانونى يجبر المتصرف إليه على احترامه. مثال ذلك أن يتقرر

(١) لا تتحد صفة المتصرف بأنه وارث إلا عند وفاة المتصرف. نقض مدنى ١٩٧٩/٤/٥ طعن رقم ١١٣، س٤٦ق.

(٢) نقض مدنى ١٩٦٩-١-٢ مجموعة الأحكام س٢٠.

(٣) نقض مدنى ١٩٨١-١١-١١ طعن رقم ٦٠٨ س٤٨ق.

للمتصرف حق انتفاع على العين المتصرف فيها طوال حياته أو حق استعمال أو سكن. فمجرد الانتفاع الفعلى لا يكفى فى حد ذاته^(١).

فإذا أثبت الوارث أو الورثة^(٢) هذه الشروط وجب إعمال مقتضى القرينة وهو اعتبار مثل هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية. ولكن ينبغى مراعاة أن هذه القرينة مجرد قرينة بسيطة كما هو الأصل فى القرائن القانونية. فيكون للوارث المتصرف إليه إثبات عكس مقتضاها. فقد قضى بأنه «لا يقدم فى تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المباعة مدى حياته وشرط منع المتصرف إليه فى التصرف فى هذه العين، إذا ثبت أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات^(٣)».

فإذا لم يقدّم الدليل العكسى، وجب معاملة التصرف معاملة الوصية. بحيث ينفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة إذا كانت قيمته فى حدود ثلث التركة، أما إذا كانت قيمته تجاوز الثلث فيعلق نفاذ الجزء الزائد على الثلث على إجازتهم.

2024/2025

2024/2025

وكل من إثبات شروط القرينة أو التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، طالما استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ولهذا لا يجوز التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض^(٤).

(١) د. السنهورى الوسيط ٩ ص ٢٢٩، د. الصدة: ص ٨٤٦؛ د. حسن كيرة: ص ٣٥٢. نقض مدنى ٧-٣-١٩٧٢ طعن ٨٩ س ٣٧ق.

(٢) «لوارث أن يطعن بصورية التصرف الصادر من مورثه إضراراً بحقه فى الميراث، وله إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات، لأنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث باعتباره خلفاً عاماً وإنما يستمد من القانون مباشرة. نقض مدنى ٩-٦-١٩٨٨، طعن ١٧٥٨ س ٥٢ق.

(٣) نقض مدنى ١٤-١١-١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ ص ١٣٦٢.

(٤) نقض مدنى ١٤-٣-١٩٧٨ طعن ٣٩٤ س ٤٤ق.

المبحث الثانى

الميراث

تنص الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ مدنى على « تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها ». وقد تعرض هذا النص للمسائل الثلاث الرئيسية التى يشتمل عليها الميراث .

وهى تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث ، وانتقال ملكية هذه الأنصبة . وذكر أن الشريعة الإسلامية وما يصدر من قوانين خاصة هى التى تسرى على هذه المسائل .

ولا يعنينا هنا الوقوف على أحكام الموارث الموضوعية من حيث تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث فهى موضوعات تدخل فى دروس الشريعة الإسلامية .

وإنما يعنينا هنا فحسب الميراث باعتباره من مصادر الحقوق العينية الأصلية .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

والميراث سببا من أسباب كسب الملكية، تنتقل به ملكية التركة من المورث إلى الوارث، فهو يدخل فى الأحوال العينية لا فى الأحوال الشخصية . ولكن طبقا للمادة ٨٧٥ مدنى فإن أحكام الشريعة الإسلامية مع ذلك هى التى تسرى فى شأنه^(١) .

ونظراً لأن أحكام الميراث يتم دراستها فى مادة الشريعة الإسلامية، لذلك نحيل إليها منعاً للتكرار .

(١) د السنهاورى الوسيط، ج٩ ص ٨٧ ، د جمال زكى: الحقوق العينية ص ٢٨٣ ، د منصور مصطفى منصور ص ٤٥٨ .



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الثالث

أسباب كسب الملكية

نعرض في هذا الفصل لأسباب كسب الملكية فيما بين الأحياء، وذلك على النحو:

المبحث الأول : العقد.

المبحث الثاني : الالتصاق.

المبحث الثالث : الشفعة.

المبحث الرابع : الحيازة.

المبحث الأول

العقد

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، أيًا كان هذا الأثر. ويتم العقد بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين. وإذا تم ذلك فإن العقد ينعقد في الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجب، إلى غير ذلك من الأحكام الموضوعية للعقد والتي هي محل دراستها النظرية العامة للالتزام.

2024/2025

2024/2025

والذي يعنينا في هذا المقام هو العقد باعتباره مصدراً للحقوق العينية الأصلية، أو باعتباره سبباً من الأسباب المنشأة للحقوق العينية، بل هو أهم هذه الأسباب جميعاً. والتقنين المدني قد نص على اعتبار العقد مصدراً للحقوق العينية عموماً بقوله «تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للتصرف وطبقاً للمادة ٢٠٤ مدني، مع مراعاة النصوص التالية (م ٩٣٢ مدني).

يخلص من هذا النص أن الملكية في المنقول والعقار على السواء تنتقل بالعقد، على أن يرد العقد على عين معينة بالذات ومملوكة للتصرف.

وقد سبق دراسة نقل الملكية في المنقول والعقار في مقرر الفرقة الثالثة فنحيل عليه.

المبحث الثانى الالتصاق

يعرف الالتصاق بأنه اتصال أو اندماج شيئين أو امتزاجهما بفعل الطبيعة أو الإنسان بطريقة تجعل من المتعذر الفصل بين الشيئين دون تلف يلحقهما أو يخلق أحدهما^(١). والالتصاق على هذا التحديد واقعة مادية يترتب عليها القانون مركزاً قانونياً هو اكتساب الملكية، ولكون الالتصاق واقعة مادية، فإنه يؤدي بحسب الأصل إلى كسب الملكية بقوة القانون دون حاجة لإبداء الرغبة فى التملك وهو بهذا يختلف عن الشفعة.

وقد جعل المشرع الملكية فى الالتصاق لمالك الشئ الأصلى، ليقصر على التعويض حق مالك الشئ التبعى. وتعتبر الأرض فى كل الأحوال هى الشئ الأصلى حتى ولو كان ما التصق بها يزيد كثيراً فى القيمة عليها. فالأرض تظل أصلاً حتى ولو كانت قيمتها أقل بكثير من قيمة المبانى المقامة عليها.

القاعدة العامة فى مجال التصاق منقول بالأرض أن الأصل هو الأرض^{2024/2025} وما عداها هو فرع، واعتبار الأرض هى الأصل وأن كل ما يلتصق بها يتبعها يرجع إلى طبيعة الأرض وليس لقيمتها. فتتميز الأرض عن باقى العقارات بأنها ثابتة ودائمة بصورة مطلقة. أما البناء والغراس فبالرغم من أنهما من العقارات بالطبيعة إلا أن ثباتهما وديمومتها أمر نسبي، فالنبات يموت والبناء قد يهدم ويتحول إلى أنقاض. أما الأرض فتظل باقية لا تموت حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن «المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ إنشائها والتصاقها بالأرض المؤجرة، ويكون الاتفاق على تعليق

(١) د. السنهورى: الوسيط حـ ٩ ص ٢٤٣، د. حسن كيرة: ص ٣٩٥، د. الصدة: ص ٣٠٣، د. جمال زكى: ص ٣٤٣، د. محمد عمران: ص ٧١.

أيلولة المباني على انتهاء العقد مجرد إرجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لمليكتها التي تحققت منذ الإنشاء أو الالتصاق^(١).

وطبقاً لنصوص القانون المدني فإن الالتصاق فى واقع الأمر يقوم بوظيفتين متميزتين، الوظيفة الأولى، تتمثل فى أن الالتصاق يعتبر مجرد سند للملكية، أما الوظيفة الثانية تتمثل فى أن الالتصاق يعتبر سبباً جديداً لكسب الملكية. ونعرض لكل من الوظيفتين كل فى مطلب مستقل.

المطلب الأول

الالتصاق كسند للملكية

إذا كان مالك الأرض هو الذى أقام على نفقته البناء أو الغراس أو غيرها من المنشآت اعتبر الالتصاق سنداً للملكية ودليلاً عليها. فملكية الأرض، وفقاً للمادة ٨٠٣، تشمل ما تحت الأرض وما فوقها إلى الحد المفيد فى التمتع بها وفقاً للمألوف^(٢).

(١) ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مدينى ١٦-١-١٩٨٧-١٩٨٧ طعن رقم ٨٨٩ لسنة ٥٠٠ ق. ولقد تعاظم دور الالتصاق فى الواقع المصرى لعدة أسباب. فقد نص قانون إيجار الأماكن على التزام المالك الذى يشيد البناء بتأجير ثلث الوحدات. ولتفادى ذلك لجأ إلى تكوين اتحاد الملاك، وتسجيل الأرض باسم أعضاء الاتحاد. وتكون رسوم التسجيل حينئذ ضئيلة لقلّة قيمة الأرض مقارنة بقيمة البناء ككل بعد إتمامه. وعند الانتهاء من البناء فإنه إعمالاً لقواعد الالتصاق تنتقل ملكية البناء إلى مالك الأرض. ثم يلجأ الملاك إلى قسمة البناء فيما بينهم بحيث يختص كل عضو فى الاتحاد بالشقق التى تتناسب مع حصته فى الأرض، وبهذا يتم تفادى رسوم التسجيل الباهظة وكل ما هناك هو تسجيل القسمة التى تكون رسومها ضئيلة. كما يتم تفادى ضرائب التصرفات العقارية والأرباح التجارية لأنه لا توجد تصرفات وإنما ملكية بناء على واقعة مادية. راجع فى هذا المعنى د. حسام الأهوانى: ص ١١.

(٢) تنص المادة ٨٠٣ مدينى على أنه «١- مالك الشئ يملك كل ما بعد عن عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. ٢- وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً وعمقاً».



ولما كان مالك الأرض يمتلك سطح الأرض وما تحته وما فوقه، فإن ما يوجد فوق الأرض أو تحتها من منشآت أو غراس يكون داخلاً في نطاق ملكية صاحب الأرض. وهذا ما نصت عليه المادة ٩٢٢ من أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك، وتلك القرينة ليست إلا نتيجة حتمية للمبدأ العام الوارد في المادة ٨٠٣ مدنى. فإذا كان مالك الأرض قد قام بممارسة حقه في البناء أو الغراس في أرضه وبمواد مملوكة له، فإن المنشآت أو الغراس تكون مملوكة له باعتبارها من توابع الشيء الأصلي، وهو الأرض. فنطاق حق الملكية يشمل الشيء الأصلي وتوابعه باعتبارها من ملحقات الشيء الأصلي نفسه. والالتصاق لا يعتبر حينئذ سبباً لكسب ملكية جديدة وإنما يعتبر سنداً ودليلاً على ملكية صاحب الأرض لهذه المنشآت^(١).

ويكفى في هذه الحالة أن يثبت مالك الأرض ملكيته للأرض حيث يعتبر ذلك في حد ذاته دليلاً وسنداً كافياً لملكيته للمنشآت المقامة على الأرض أو تحتها. ولا يلزم بإقامة دليل غير الدليل الذى قدمه على ملكيته للأرض^{2024/2025}.

2024/2025

فملكية الأرض تشتمل بالضرورة ويدخل في نطاقها الطبيعي، ملكية ما يقام عليها من منشآت أى ملكية ما يلتصق بها من منشآت يقيمها المالك. ولهذا فإن المالك الذى يبنى على أرضه بمواده لا يحتاج لتسجيل ملكية المبانى، فمتى كانت ملكية الأرض مسجلة فإن الملكية نفسها تمتد لتوابع الأرض ومن ثم تكون المنشآت ملكاً لمن يملك الأرض. فلا يوجد سبب جديد لكسب الملكية وإنما امتداد لنطاق الملكية القائمة.

وتيسيراً على صاحب الأرض فى إثبات أن المنشآت من عمله وأقامها على نفقته، أقام المشرع قرينة تتكون من شقين لمصلحة صاحب الأرض،

(١) د. السنهورى : الوسيط ٩ ص ٢٦١، د. حسام الأهوانى: ص ٢٤.



الشق الأول من القرينة يفيد أن المنشآت من عمل صاحب الأرض، والشق الثاني أنه قد أقامها على نفقته. وهذه القرينة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

فإذا كان الأصل الوارد في المادة ٨٠٣ مدنى هو أن ملكية الأرض تشمل ملكية ما يوجد فوقها وما تحتها، فإن هذه المادة ذاتها قد أجازت أن تكون ملكية السطح منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها أما بمقتضى القانون أو الاتفاق، فمثل هذه الاتفاقات غير مخالفة للنظام العام. وعلى هذا لا محل لإعمال أحكام الالتصاق إذا أثبت الأجنبي أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة المنشآت وتملكها، أو إذا أثبت أن هناك اتفاق بينهما على أنه يمتلك الأجنبي الأبنية المقامة فوق سطح الأرض أو المشيدة تحت السطح والتي كانت قائمة من قبل أى حتى ولو لم يكن الأجنبي هو الذى أقامها^(١). وهو ما يحدث فى حالة ملكية الطبقات، فقد يقيم المالك الطوابق ويتولى بيعها إلى مشتريين، أو قد يخول مالك الأرض مجموعة من الأشخاص بناء طوابق على الأرض وتملكها مع احتفاظ البائع لنفسه بملكية الأرض وهو ما يسمى ببيع حق التعلية. وفى هذه الحالة تنتشت عناصر الملكية، وعند تحقق ذلك فلا محل لإعمال الالتصاق الذى يقوم على تجميع عناصر الملكية، ويستبعد الالتصاق سواء باعتباره سنداً للملكية أو سبباً لكسبها.

ويستبعد الالتصاق كسند للملكية إذا ثبت عدم توافر شروط إعمال القرينة الواردة فى المادة ٩٢٢ مدنى. فتلك القرينة تقوم على ركيزتين الأولى أن البناء من عمل مالك الأرض، والثانية أنه قد أقامه على نفقته. والغالب هو أن صاحب الأرض هو الذى يقيم البناء لحسابه هو وليس لحساب غيره، وأنه يقيم البناء على نفقته أو بمواد مملوكة له. ومن ثم لا تقوم القرينة إذا أثبت الأجنبي أنه قد أقام البناء على نفقته أو بمواد مملوكة له سواء بناء على وجود اتفاق بذلك مع مالك الأرض أو دون وجود أى اتفاق بينهما ففى هذه الحالة يكون الباني قد أقام المنشآت لحسابه هو وعلى نفقته.

(١) د. السنهورى: الوسيط ح ٩، ص ٢٦٢، ود. محمد على عرفه، ص ١٢٩.



المطلب الثانى

الاتصاق كسب لكسب الملكية

أسلفنا أنه يمكن تعريف الاتصاق بأنه اتصال أو اندماج شيئين أو امتزاجهما بفعل الطبيعة أو الإنسان بطريقة تجعل من المتعذر الفصل بين الشيئين دون تلف يلحقهما أو يلحق أحدهما، وأن يكونا غير مملوكين لشخص واحد، ودون أن يوجد اتفاق سابق على تحقيق هذا الاندماج.

وينقسم الاتصاق من حيث طبيعة الشئ الملتصق به إلى التصاق منقول بعقار، والتصاق منقول بمنقول^(١). وقد يكون الاتصاق طبيعياً أو صناعياً، ونعرض لكل منهما.

الفرع الأول

الاتصاق الطبيعى

الاتصاق الطبيعى بالعقار هو الذى يؤدى إلى زيادة رقعة الأرض بفعل ~~المياه~~ أو تحول الأرض عن موقعها ~~بفعل~~ حادث طارئ، أى يتم الاتصاق الطبيعى بغير تدخل من الإنسان. وقد عنى المشرع فى التقنين المدنى فى المواد من ٩١٨ إلى ٩٢١ ببيان الأحكام الخاصة بهذا النوع.

طمى النهر:

تنص المادة ٩١٨ مدنى على أنه «الأراضى التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقه تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاك المجاورين»، فحتى تكون الأرض التى تتكون من طمى النهر ملكاً للملاك المجاورين يجب أن تتوافر عدة شروط:

(١) د. السنهورى: الوسيط حـ ٩ ص ٢٤٥، ود. منصور مصطفى منصور: ص ٢٨١.



الأول: أن يكون الجزء الزائد من الأرض قد تكون من الطمي الذى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة على مر الزمن^(١). فإذا كان هذا الجزء قد تكون فجأة، أى دفعة واحدة بسبب تحويل النهر له من مكان آخر، فإنه يكون من قبيل طرح النهر الذى يعتبر من أملاك الدولة الخاصة ويخضع لأحكام أخرى.

الثانى: أن يرتفع الطمي عن أعلى منسوب للمياه وقت الفيضان أما إذا ظلت الأرض المكونة بفعل الطمي مطمورة تحت سطح الماء، فلا ينطبق الحكم الوارد فى المادة ٩١٨ مدنى. ولا يكفى أن ترتفع هذه الأرض عن منسوب المياه فى الأوقات العادية، بل يجب أن ترتفع عن أعلى منسوب للمياه فى أوقات الفيضان العادى^(٢).

الثالث: ويشترط أيضاً أن تكون الزيادة قد تكونت بفعل المياه دون أن يكون للإنسان يد فى ذلك. فلو وضع المالك بجوار أرضه أخشاباً أو أحجاراً تساعد على ترسيب الطمي كان هذا تعدياً على مجرى النهر الذى يعتبر من الأموال العامة. أما إذا كان وضع هذه الأخشاب أو الحجارة بترخيص من السلطة المختصة لحماية أرضه من خطر الفيضان فإن الزيادة التى تتكون نتيجة ذلك له.

رابعاً: أن تلتصق الأرض المتكونة بفعل الطمي بالأراضى المجاورة، فإذا لم يلتصق الطمي المتكون بالأراضى الملاصقة لمجرى النهر التصاقاً تاماً لا يفصله فاصل ولو كان ضيقاً فإن أرض الطمي لا تعتبر ملكاً للملاك المجاورين بل تعتبر ملكاً للدولة.

وقد قضت محكمة النقض^(٣)، بأنه إذا كان دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهما للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا

(١) د. محمد على عرفه: ص ٢٨٥، د. الصدة: ص ٣٠٥.

(٢) د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٥٤، د. محمد عمران: ص ٧٣.

(٣) نقض مدنى ١٩٦٠/١٢/١١ س ١١ ص ٢٤٨ طعن رقم ٢١٣ س ٢٥ ق.

الالتصاق كان نتيجة لطمى جلبة نهر النيل، مما يلقي على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق، ومن بينهما أن يتكون الطمى بصفة نهائية وتكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الارتفاع حداً يجاوز منسوب ارتفاع المياه في وقت الفيضان العادي، وكان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه اعتد بهذا الشرط في قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التي أوردتها الخبير في تقريره. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

أما إذا تكونت الزيادة مستوفية الشروط صارت ملكاً لصاحب الأرض المجاورة بحكم الالتصاق^(١)، وإذا كانت الزيادة التي تكونت من الطمى ملاصقة لأراضى ملاك مختلفين فإن كل واحد منهم يمتلك الجزء المقابل لأرضه أيًا كانت مساحته، وهو الجزء الواقع بين خطين عموديين مقيمين في نهايتي كل أرض لجهة النهر.

وإذا أرادت الحكومة أن تقوم بأعمال التطهير لتوسيع مجرى النهر، وكان في ذلك اعتداء على أرض الطمى فلا تستطيع ذلك إلا بإتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

طرح النهر:

تنص المادة ٩٢١ مدنى على أن الأراضى التي يحولها النهر عن مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها^(٢).

(١) «لا يؤثر في حق الطاعن في تملك الزيادة التي يضيفها طمى النهر بطريقة الالتصاق الطبيعي لأرضه يكون قد استأجرها خشية أن تضيع عليه ثمرة جهده وماله اعتقاداً منه أنه يستأجر ملك غيره، لأن استجاره الإنسان عيناً مملوكة له لا يسقط حقه في ملكيتها». نقض مدنى ١٩٦٩/٣/٢٥ س ٢٠، ص ٤٧٠.

(٢) راجع هذه القوانين د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٥٦ - ٢٦٠.

ويقصد بطرح النهر الأراضى التى يحولها النهر عن مكانها أو ينكشف عنها، ويحدث ذلك فى أوقات الفيضان غير العادية، يأكل النهر جزءا من مجراه أو من مجاورة ويلقى بها فى مكان آخر، وقد تلتصق هذه الأرض المكونة بفعل الطرح بأرض مملوكة للأفراد فتكون جزيرة فى مجرى النهر.

وفى كلتا الحالتين فإن هذه الأرض تكون مملوكة للدولة^(١)، وتخضع لما يضعه المشرع من قوانين خاصة. ويتميز طمى النهر عن طرحه أن الأول يتكون بطريقة تدريجية غير محسوسة، فى حين أن الثانى يحدث فجأة وتكون ملكية أرض الطمى للملاك الملاصقين، فى حين أن ملكية الأرض الناجمة عن طرح النهر تكون ملكاً للدولة وتنظمها قوانين خاصة.

الفرع الثانى

الالتصاق الصناعى

وردها المشرع أحكام الالتصاق بالعقار فى الفصل الخاص المنظم لأسباب كسب الملكية، فاعتبره مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية، وهو سبب يرتكز فى الأصل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق، وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها.

يتحقق هذا النوع من أنواع الالتصاق إذا بنى شخص على أرضه بمواد مملوكة لغيره، أو إذا أقام شخص منشآت على أرض الغير بمواد مملوكة له، أو إذا بنى شخص منشآت بأدوات ليست مملوكة له وعلى أرض ليست ملكاً له. كما أورد المشرع بالإضافة إلى ذلك أحكاماً خاصة ببعض صور الالتصاق، ونعرض لكل من ذلك فى الغصون التالية:-

(١) «وضع اليد على الأموال العامة مهما طالمت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها كما فى أرض طرح النهر التى استقرت وأصبحت ثابتة». نقض مدنى ١٩٧٤/٥/١٧ طعن ١٨٤ س ٣٨ ق.

تعددت الآراء الفقهية في هذا الشأن^(١) والذي نرجحه اعتبار حق الإزالة كأثر من آثار اكتساب الملكية بالاتصاق، فمالك الأرض لا يخير بين كسب ملكية البناء أو طلب الهدم، وإنما هو يمتلك البناء فوراً، ويتبقى بعد ذلك تنظيم العلاقة بين الباني والمالك وذلك التنظيم يدخل في آثار الملكية ولا شأن له بشروط التملك. فأى مالك يحق له هدم ما يملكه بمقتضى ماله من سلطة التصرف وكان من المفروض أن يتم الهدم على نفقة مالك البناء وهو مالك الأرض، ولكن نظراً لسوء نية الباني على سبيل الجزاء فقد قرر المشرع أن يكون الهدم على نفقة الباني الذي يجب أن يتحمل نفقات إعادة الشئ إلى أصله. يؤيد ذلك أن المادة ٩٢٢ مدنى اعتبرت أن كل ما يقام على الأرض يكون ملكاً لصاحب الأرض، أما المادة ٩٢٤ فهي تتعلق بآثار كسب الملكية لملكية البناء عن طريق تنظيم العلاقة بين مالك الأرض والباني من حيث نفقات الهدم والتعويض في حالة استيفاء البناء. فالمادة ٩٢٤ مدنى لا تخير مالك الأرض بين تملك البناء أو هدمه وإنما تعطيه حقاً شخصياً بطلب هدم البناء الذى يملكه. ويتميز هذا التأصيل بأن ملكية البناء تنتقل من مالك الأرض فور اندماجها ولا يتوقف ذلك على إبداء مالك الأرض لرغبته في ذلك.

الغص الأول

إقامة مالك الأرض منشآت على أرضه بمواد

2024/2025

2024/2025

ليست مملوكة له

قد يقيم شخص على أرضه منشآت بمواد ليست مملوكة له والقاعدة في هذا الشأن أن مالك الأرض مالك لما فوقها من منشآت. وهذا الحكم هو تطبيق للمادة ٢/٨٠٣ مدنى والتي تنص على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وذلك دون إخلال بأحكام القانون الخاص بالمحاجر والمناجم.

فإذا كانت ملكية الأرض شاملة لكل ما فوقها وما تحتها فهي تشمل بالضرورة ما على الأرض من بناء أو غراس وعلى ذلك نصت المادة ٩٢٣

(١) د محمد زهرة: المرجع السابق، ص ٢٤٤، د محمود جمال الدين زكى: الوجيز ص ٣٥٩، د السنهورى: الوسيط حـ ٩ ص ٢٩١، د حسام الأهوانى: مرجع سابق، ص ٣٨.

مدنى «يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدث فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره، إذ لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت. ٢- فإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض أن كان له وجه. إما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

يتضح من هذا النص أن صاحب الأرض إذا بنى بأدوات غيره يملك المنشآت التى بناها، وعليه أن يعرض صاحب الأدوات التى فقدها^(١)، وإن كان هذا هو الأصل إلا أنه يفرق فى هذا الصدد بين حسن نية وسوء نية صاحب الأرض.

حسن النية:

إذا كان صاحب الأرض حسن النية أى يعتقد أن هذه الأدوات هى ملك له فغالباً ما يملك هذه المواد بمقتضى قاعدة الحيازة فى المنقول بحسن نية وبسبب سند المالك. فالحيازة وحسن النية متوافران. وإذا توافر السبب الصحيح أنتجت الحيازة أثرها فى كسب الملكية. ويتم تملك صاحب الأرض للمواد بمقتضى أحكام الحيازة لا وفقاً لقواعد الالتصاق^(٢). وإذا تحقق اندماج المواد فى الأرض اندماجاً فعلياً بحيث تصبح المنشآت باتصالها بالأرض عقاراً بالطبيعة فإن هذه الصورة تحكمها مبدآن: الأول: تملك صاحب الأرض المنشآت أو الغراس. والثانى: التزام صاحب الأرض بتعويض المالك السابق للمواد.

(١) «الأصل أن ملكية ما يقام عليها من مبان يحكم الالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص». نقص مدنى ١٦/٢/١٩٨٣، س ٣٤ ص ٤٨٢ طعن رقم ٨٠٣ لسنة ٤٩ ق.

(٢) د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٦٨.

سيئ النية:

أما إذا كان صاحب الأرض سيئ النية بأن كان يعلم أن الأدوات غير مملوكة له، أو كان حسن النية ولكن لم يتوافر عنده السبب الصحيح لامتلاك الأدوات بالحيازة ففي هذه الحالة نفرق بين فرضين:

الأول: وفيه لا يكون من الممكن نزع ما أقيم من بناء أو غراس دون أن يصيب المنشآت أو الغراس ضرر جسيم، والضرر الجسيم يشمل الضرر الذي يلحق بالمنشآت والضرر الذي يلحق الأرض نفسها. ومثال المواد التي لا يمكن نزعها دون تلف الطوب والحجارة والأسمنت وغيرها من المواد المستخدمة في البناء وكذلك لا يجوز نزع المواد إذا كان من شأن ذلك الأضرار بالأرض أضراراً جسيماً، كما إذا كانت المزروعات من النوع الذي يزيد من خصوبة الأرض تفادياً لتبويرها فإذا نزعت الغراس تهددت الأرض بالبوار. ففي هذا الفرض يملك صاحب الأرض ما يقيمه من منشآت بمجرد إدماجها في الأرض ولو تم الإدماج على دفعات، ويصبح عقاراً بطبيعته ويكون سبب كسب الملكية هو الالتصاق.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإذا تملك صاحب الأرض الأدوات بالالتصاق يكون ملتزماً بالتعويض لصاحب الأدوات، فعليه أن يدفع له قيمتها وقت انتقال ملكية الأدوات إليه، أى وقت إدماج الأدوات في الأرض. كما يشمل التعويض ما عسى أن يكون قد أصاب صاحب الأدوات من ضرر بسبب عدم استردادها. وتقدير التعويض متروك للقاضي مراعيًا حسن نية صاحب الأرض وسوء نيته، فيزيد في حالة ما إذا كان صاحب الأرض سيئ النية يعلم أن الأدوات غير مملوكة له، عما إذا كان حسن النية يعتقد أن الأدوات مملوكة له ولكنه لا يملكها بالحيازة لعدم توافر السبب الصحيح^(١).

(١) د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٧٠.

الثانى: أن يكون ممكنا نزع الأدوات دون أن يلحق المنشآت ضرر جسيم، كالأدوات الصحية والبلاط والأخشاب المستخدمة فى أعمال الديكور. فى هذا الفرض لا يملك صاحب الأرض الأدوات بمجرد إدماجها فى الأرض، بل تبقى على ملك صاحبها، ويستطيع المطالبة بنزعها، ولكن ذلك مشروط بأن ترفع دعوى الاسترداد فى خلال سنة^(١) من اليوم الذى يعلم فيه أنها اندمجت فى المنشآت. وإذا رفعت الدعوى خلال سنة كان لصاحب الأدوات أن يستردها. وفى هذه الحالة يلتزم صاحب الأرض بقيمة نزع الأدوات أما إذا لم ترفع دعوى الاسترداد خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيها مالکها أنها قد اندمجت فى المنشآت فإنه لا يستطيع استردادها بعد ذلك ويملكها صاحب الأرض بالالتصاق.

وتنص المادة ٩٢٣ مدنى على أن لمالك المواد، سواء أستردها المواد أو تملكها صاحب الأرض مقابل قيمتها وقت الالتصاق، الحق فى التعويض إن كان له وجه. والتعويض يكون طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.

2024/2025

الغصن الثانى

2024/2025

2024/2025

إقامة منشآت على أرض الغير بمواد مملوكة لقيم المنشآت

فى هذا الغرض نجد أن من يقيم البناء أو الغراس أو المنشآت الأخرى إنما يقيمها بمواد يملكها، ولكنه يقيمها فى أرض غير مملوكة له ولحساب نفسه لا لحساب مالك هذه الأرض.

فقد يحدث أن يقيم شخص بمواد مملوكة له منشآت على أرض مملوكة للغير. والقاعدة فى هذا الشأن أن ملكية الأرض تشمل ملكية ما فوقها وما تحتها. فكل ما يقام على الأرض من بناء أو غراس مملوك لصاحب الأرض ما لم يتفق على غير ذلك. وإن كانت هذه القاعدة تحتاج إلى تحديد، وقد قام

(١) وهى مدة سقوط لا مدة تقادم، فلا يرد عليها الوقوف ولا الانقطاع د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٧١، د. حسن كيرة: ص ٤٠٧.

المشرع بهذا التحديد فى المادتين ٩٢٤، ٩٢٥ مدنى، حيث فرق بين حالة حسن نية البانى أو الغارس أو مقيم المنشآت وبين حالة سوء نيته، وهى تفرقة عادلة.

إقامة المنشآت فى أرض الغير بسوء نية:

عرضت المادة ٩٢٤ مدنى لحالة البناء أو الغراس أو إقامة المنشآت الأخرى بسوء نية فى أرض الغير فنصت على «إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا» صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقته من أقامها مع التعويض أن كان له وجه. وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت. أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

من هذا النص يتبين أن سوء النية يتحقق بتوافر شرطين:

الأول: علم البانى أو الغارس أو مقيم المنشآت أن الأرض التى يقيم فيها منشأته ليست مملوكة له بل مملوكة لغيره.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الثانى: علمه بأنه لا حق له فى إقامة المنشآت فى هذه الأرض، لعدم وجود اتفاق أو إذن من صاحب الأرض يخلوه إقامة المنشآت بها. فإذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما انتفى سوء النية لدى مقيم المنشآت. مع ملاحظة إن الوقت الذى يعتد فيه بسوء النية هو وقت البناء أو الغراس أو المنشآت دون اعتبار لما قد يطرأ على النية من تغير بعد هذا الوقت.

ونظراً لسوء نية مقيم المنشآت لقد أعطى المشرع حقاً لصاحب الأرض فى طلب إزالة هذه المنشآت على نفقة مقيمها، لأن فى إقامتها تعدياً على ملكه وتسلبه إحدى مزايا حق الملكية، وهى تحديد طريقة الاستغلال على غير رضائه وعلى خلاف ما يقضى به القانون. ولهذا فإن الإزالة رخصة خولها القانون لمالك الأرض ويترك تقدير استعمالها لمطلق اختياره، ولا يخضع فى



اختياره لأى رقابة قضائية، وأن كان هذا التنفيذ العيني للجزاء لا يخل بحق صاحب الأرض فى الرجوع كذلك على مقيم المنشآت بالتعويض أن كان له وجه. ويجب استعمال هذا الحق - طلب الإزالة - خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت وهذه المدة تعتبر مهلة يمنحها المشرع لصاحب الأرض ليتدبر الأمر ويتخذ قراره خلالها. وتبدأ هذه المدة من وقت علم صاحب الأرض بالمنشآت التى أقيمت وبشخصية الذى قام بالبناء. فلا يكفى العلم بالمنشآت إذ لم يكن قد تحقق العلم بالبانى لأن صاحب الأرض يمارس خياره فى مواجهة البانى^(١)، ولا يعتبر الميعاد مرجعاً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه^(٢).

أما إذا أراد صاحب الأرض استبقاء هذه المباني أو المنشآت فإنه يعتبر متملكاً إياها بحكم التصاقها بأرضه، فالالتصاق الصناعى لا يكسب الملكية إلا بمقابل^(٣)، ويجب فى هذه الحالة أن يدفع للبانى أقل القيمتين، قيمة هذه المنشآت مستحقة الإزالة، أى قيمتها كما لو كانت أنقاضاً وأما قيمة ما زاد فى ثمن الأرض نتيجة إقامة هذه المنشآت. والخيار فى القيمتين متروك لصاحب الأرض.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويبنى التزام مالك الأرض بدفع أقل القيمتين على القانون لا على أساس الإثراء بلا سبب. فلو كان الالتزام صاحب الأرض مبنياً على الإثراء بلا سبب لوجب عليه أن يدفع للبانى أقل القيمتين. قيمة ما افتقر به البانى، أى قيمة ما

(١) نقض مدنى ١٩٧٥/٢/٣ مجموعة النقض ص ٣١٩، نقض ١٩٧٤/١٢/٩ ص ١٢٧٣.

(٢) « لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر بتفسيره كلمة يطلب الواردة فى المادة ٩٢٤ مدنى بأنها تعنى مجرد الرغبة فى الإزالة ولو بشكوى تقدم إلى النيابة العامة، فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الذى تؤديه هذه الكلمة، ويكون بالتالى إذا رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الإزالة قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. نقض مدنى فى ١٩٨٥/٥/١٦، طعن رقم ٥٣٥ س ٢ ق، وكذا نقض ١٩٨٦/٣/٦، طعن رقم ٤٧١ س ٢ ق.

(٣) د. محمد زهره: الرسالة السابقة ص ٣٠٦.



أنفقه في البناء، أو قيمة ما أثرى به صاحب الأرض، وتمثل هذه القيمة الأخيرة قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء في حين أن القيمة الأولى وهي قيمة ما افتقر به الباني تزيد عما يلتزم به مالك الأرض، فهو لا يلتزم بدفع هذه القيمة بل يدفع قيمة المباني أنقاضاً، فالتزام المالك بالتعويض مصدره القانون^(١) وتتقدم الدعوى بمضى ١٥ سنة تطبيقاً للقواعد العامة.

وإذا كان لصاحب الأرض أن يطالب الباني سيئ النية بالإزالة أو أن يستبقى ما أقيم من منشآت مقابل دفع أقل القيمتين، فإن للباني أن يطلب نزع ما أقام من منشآت إذ كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرر. فلا يجبر على الانتظار مدة السنة ويكون على صاحب الأرض أن يحدد موقفه، فإما أن يوافق الباني على ما يطلب، وأما أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع القيمتين. أما إذا انتهت مدة السنة تملك صاحب الأرض ما أقيم من منشآت على أرضه تأسيساً على الأحكام الخاصة بالالتصاق.

إقامة منشآت في أرض الغير بحسن نية:

عرضت المادة ١/٩٢٥ مدني لحالة إقامة المنشآت المشار إليها في المادة السابقة (٩٢٤ م) 2024/2025 حالة ما إذا كان من أقام المنشآت يعتقد بحسن نية أن له الحق في أقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت. هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.

من هذا النص يتبين أن المقصود بحسن النية هو اعتقاد مقيم المنشآت أنه مالك الأرض التي يقيمها بها، أو على الأقل اعتقاده أن له الحق في إقامة هذه المنشآت فيها^(٢)، فيعتبر حسن النية من يشتري الأرض بعقد باطل طالما

(١) د. حسن كيرة: ص ٤١٢، د. محمد عمران: ص ٨٠.

(٢) «وكان الطاعنون قد برروا أقامتهم المباني على أرض بسبق شراء مورثهم لها بعقد مسجل وهو ما ينطوي على التحدى بحسن نيتهم وقت تشييدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء النية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون».

ومن الطبيعي أن يعامل المشرع الباني أو مقيم المنشآت حسن النية
معاملة أفضل من معاملة الباني أو مقيم المنشآت سيئ النية، لذلك نفرق بين

2024/2025

(١) د. السنهوري: الوسيط ٩ ص ٢٨٦، د. البدرأوى، ص ٢٥٦، د. حسام الأهلوانى: ص ٥٧.

(٢) محمد زهره: الرسالة السابقة ص ٢٨٦.

(٣) نقض مدني ١٩٧٤/١٢/٩ طعن رقم ٢٩٧ لسنة ٣٨ ق ص ١٣٧٣.

(٤) «حسن نية المبنى في أرض لا يملكها ليس إلا من أثر في تملك البناء وإنما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة ٩٢٤ مدني، وتخول الباني حقا في التعويض وفقا للضوابط الواردة بنص المادة ٩٢٥ مدني. نقض مدني ٨١/١/٢٨ طعن رقم ٣٥٤ لسنة ٥٠ ق.

لنظرية الإثراء بلا سبب، إلا أننا نؤيد الاتجاه الذى يرى واتساقا مع ما تقضى به قواعد الالتصاق أن التزام صاحب الأرض أيضا هنا مصدره القانونى^(١)، لا واقعة الإثراء بلا سبب. وتتقادم دعوى البانى تبعا لذلك بمضى ١٥ سنة لا ثلاث سنوات.

الثانى: وللبانى حسن النية أن يطلب بإزالة ما أقام على نفقته، ولا يستطيع صاحب الأرض إجباره على قبول التعويض. فإذا كان نزاع هذه المنشآت من شأنه أن يترتب عليه ضرر بصاحب الأرض، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن البانى لا يكون له نزاع ما أقام إذا كان ذلك من شأنه أن يحدث ضررا جسيما^(٢). فى حين يذهب جانب آخر ونرجحه إلى القول بأنه لا يكون للبانى المطالبة بنزع ما أقام من منشآت إذا كان ذلك من شأنه الأضرار بالأرض سواء كان الضرر جسيم أم غير جسيم^(٣).

أما إذا كانت المنشآت المقامة على الأرض قد بلغت حدا ممن الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل (م ٢/٩٢٥ مدنى). والفرض أن الذى يملك هنا هو صاحب المنشآت لا صاحب الأرض، وتبعا لذلك فإن هذا الحكم لا يعتبر تطبيقا للقواعد العام فى الالتصاق، وإنما يشترط لتطبيق هذا الحكم أن تكون قيمة المنشآت التى أقيمت بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عن هذه المنشآت بل يكفى أن يكون ذلك مرهقا له^(٤). والمعيار ذاتى لا موضوعى، أى أن الإرهاق لا يتمثل فى المقارنة بين قيمة الأرض وقيمة المنشآت، بل العبرة بالقدرة المالية لصاحب الأرض. فإذا كان فى تكليفه بأداء أقل القيمتين للبانى إرهاق له، جاز له أن

(١) د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٨٨، د. حسن كيرة: ص ٤١٣.

(٢) د. السنهورى الوسيط ج ٩ ص ٢٨٩ هامش/١.

(٣) د. حسن كيرة: ص ٤١٤، د. محمد عمران: ص ٨٣.

(٤) «فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره، فليس لمن أقام المنشآت أو الدائنين أن يجبروه على استعمالها». نقض مدنى ١٩٦٩/٦/١٩ س ٢٠ ص ١٠٠٦.

يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل. والتعويض العادل الوارد في النص ليس محض تطبيق للقواعد العامة لأنه إن كان كذلك لاكتفى المشرع بالإحالة إليها. فيجب إذن أن يراعى موقف المبانى عند تقدير التعويض، فلا يلزم بدفع قيمة الأرض وقت أن أقام عليها المنشآت، بل قد يكتفى بما افتقر به صاحب الأرض، أى بالقدر الذى اشتراها به أن كانت قد آلت ملكيتها إليه بطريق البيع مثلا.

وإذا تملك صاحب الأرض ما أقيم عليها من بناء، فإن ملكيته تكون معلقة على شرط واقف. والشرط الواقف هو ألا يطالب صاحب المنشآت بنزعها أو أن يطلب هو تملك الأرض لصاحب المنشآت^(١).

الفصل الثالث

إقامة منشآت فى أرض الغير بمواد غير مملوكة لقيم المنشآت

بينت المادة ٩٣٠ مدنى حكم هذه العلاقة حيث نصت «إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها، وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت.

من هذا يتضح أن صاحب المواد محروم من طلب استرداد مواده حتى ولو كان ممكنا نزعها دون أن يترتب على ذلك ضرر جسيم بالمنشآت، وذلك خلافا لحكم المادة ١/٩٢٣ فى شأن بناء الشخص فى أرضه بمواد مملوكة للغير. وحرمان صاحب المواد من طلب استرداد مواده سببه تعلق حق شخص ثالث هو صاحب الأرض بهذه المواد. ولكن يرتفع الحرمان إذا أزيلت المنشآت، أما بناء على طلب صاحب الأرض وإما بناء على طلب مقيمها. فيكون لصاحب المواد حينئذ استردادها ولكن فى حالة بقاء المنشآت وحرمان مالك

(١) د. السنهورى الوسيط ٩ ص ٢٨٨، د. محمد عمران: ص ٨٤.



المواد من استردادها يكون له حق الرجوع على مقيم المنشآت وفقا لأحكام ١/٩٢٣.

وإذا كان الأصل أنه لا توجد علاقة مباشرة بين صاحب المواد وصاحب الأرض، فلا يملك صاحب المواد الرجوع على صاحب الأرض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة مستعملا حق مدينه مقيم المنشآت فى المطالبة بما يكون مستحقا لهذا الأخير قبل صاحب الأرض. لكن المشرع رعاية لصاحب المواد من خطر مزاحمة دائنى مقيم المنشآت له عند الرجوع على صاحب الأرض عن طريق الدعوى غير المباشرة^(١). جعل لصاحب المواد دعوى مباشرة قبل صاحب الأرض ولكن فى حدود الباقي فى ذمة صاحب الأرض لمقيم المنشآت لذلك يكون من مصلحة مالك المواد المسارعة بإنذار صاحب الأرض بعدم الوفاء بالمستحق فى ذمته لمقيم المنشآت.

أما فيما يتعلق بعلاقة صاحب الأرض ومقيم المنشآت، فتطبق أحكام الالتصاق الواردة فى الفرض الثانى، فإذا كان مقيم المنشآت سيئ النية كان لصاحب الأرض طلب الإزالة فى بحر سنة من تاريخ علمه بإدماج المنشآت فى الأرض، وإلا تملك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويضه مقيمها بأقل القيمتين. أما إذا كان مقيم المنشآت حسن النية فليس لصاحب الأرض طلب إزالتها بل يملكها بالالتصاق إذ لم ينزعها مقيمها ويلتزم بأن يعرضه بأقل القيمتين. أما قيمة المواد وأجرة العمل وأما قيمة ما زاد فى ثمن الأرض. أى تحكم العلاقة المواد ٩٢٤، ٩٢٥ مدنى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. السنهورى الوسيط ٩: ص ٣٥٢، د. حسن كيرة: ص ٤٢٢، د. إسماعيل حاتم ص ٦٤.



الفصل الرابع

استبعاد بعض صور الالتصاق

إذا كانت أحكام الالتصاق تقضى باكتساب مالك الأرض ملكية ما يقيمه الغير فيها من أبنية أو غراس أو منشآت أخرى، سواء فى حالة سوء نية مقيمها أو حسن نيته على التفصيل الذى أسلفناه. فأن القانون المدنى أيضا قد نص على بعض الأحكام الخاصة ببعض صور الالتصاق نوجزها فيما يلى:

أولاً : أحكام الالتصاق لا تطبق فى المنشآت الصغيرة التى لا يقصد بقاؤها على وجه الدوام :

استثنى المشرع هذه المنشآت نظرا لصغرها وبقائها المؤقت من الخضوع لأحكام الالتصاق بقوله «المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها، تكون ملكا لمن أقامها» م ٩٢٩ مدنى.

فهذا النص قد جاء بالاستثناء يقضى بأن أحكام الالتصاق لا تطبق على الأكشاك والحوانيت والكباين والعشش والمآوى الأخرى التى تقام على أرض الغير، ولم يكن مقصودا بقاؤها على الدوام، فلا تملك لصاحب الأرض بالالتصاق بل تبقى ملكا لمن أقامها حتى لو كان لها أساس مستقر بالأرض استقرار قرار (١). إذ العبرة بالقصد من إقامة المنشآت، فإن انصرف قصد البانى إلى بقائها على الدوام طبقت عليها أحكام الالتصاق، أما أن لم يكن مقصودا بقائها على الدوام فلا تطبق أحكام الالتصاق (٢)، وتبقى على ملك من أقامها ولو كان سيئ النية، فله أن ينزعها بشرط أن يعيد الأرض إلى ما كانت عليه مع تعويض مالك الأرض إن كان هناك ضرر. ولمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشأة على نفقة من أقامها فيدفع بذلك الاعتداء الواقع على ملكه. وله أيضا

(١) د. السنهورى الوسيط ج ٩، ص ٣١٩، د. حسن كيرة: ص ٤٢١.

(٢) «لا ينطبق حكم المادة ٦٥ من القانون المدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراس ثم فلا مجال لأعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة». نقض ١٩٦٣/٥/٢ طعن ١٢٥ س ٢٨ ق.

أن يتفق وصاحب المنشأة على ما يتبع بشأنها.

ثانياً : الجور اليسير بحسن نية على أرض الجار:

قد يتجاوز الباني في أرضه بحسن نية حدود ما يملك ويجور على جزء من أرض الجار الملاصقة له. فلو قلنا بتطبيق قواعد الالتصاق لوجب تملك ما اعتدى به من منشآت مقامة على أرض الجار الملاصقة إلى هذا الأخير. وهذا الحكم وإن كان يوجب التطبيق الضيق لقواعد القانون، إلا أنه يجافى اعتبارات العدالة، إذ قد يكون الاعتداء على أرض الجار اعتداء يسيراً. لذا غلب المشرع المصري اعتبارات العدالة ونص في المادة ٩٢٨ مدني على: «إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك نظير تعويض عادل فيجب لا عمال هذا الحكم توافر شرطين:

الأول: أن يكون الباني إنما يبني أصلاً في أرضه ويجاوزها إلى جزء صغير من أرض الجار. ومن ثم لا محل لأعمال المادة ٩٢٨ مدني إذا لم يقيم الباني بأي بناء على أرضه وإنما يبنى جزءاً يسيراً على أرض الجار فالمشرع يواجه الصورة الغالبة وهي التعدى على أرض الجار بسبب عدم وضوح الحدود بين الجيران. فعبارة «جار» تفيد أن البناء أصلاً كان على أرض الباني ومناسبة لذلك البناء حدث التعدى على الأرض الملاصقة. أما من يبني على أرض جاره أياً كان مقدار التعدى فإنه يخضع لأحكام الالتصاق^(١).

الثاني: أن يكون هذه المجاوزة قد وقعت بحسن نية أي يعتقد أنه يبني على أرض مملوكة له أو يحق له على الأقل البناء عليها^(٢)، فإن ساءت نيته خاصة إذا نبهه الجار إلى ذلك فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة ٩٢٤ مدني.

(١) د. السنهوري: ص ٣١٧، د. منصور مصطفى ص ٢٩٥.

(٢) «جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وعلى ما جرى به نص المادة ٩٢٨ مدني مناطق إن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه» نقض ١٩٨٥/٤/٤. طعن رقم ٢٤٤ س ٥٤ ق.

إذا توافر الشرطان السابقان جاز للقاضي استبعاد تطبيق قواعد الالتصاق، وله أن يجبر صاحب الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل، فالأمر إذن جوازي للمحكمة لها أن تقضى به إذا توافرت شروطه، ولها أيضا ألا تقضى به وتطبق قواعد الالتصاق^(١).

الفرع الثالث

التصاق المنقول بالمنقول

تنص المادة ٩٣١ مدنى على « إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية فى ذلك الضرر الذى يحدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

هذه هى الحالة الثالثة من أحوال الالتصاق، ويكون الالتصاق فيها المنقول بمنقول، وهو نادر الوقوع فى العمل، وإذا وقع فأهميته محدودة، لذلك لم يقر له التقنين المدنى سوى نص واحد^{2024/2025} وكل فيه الأمر للقاضى.

2024/2025

ويلزم لانطباق الحكم الوارد فى المادة ٩٣١ مدنى توافر عدة شروط:

أولاً : أن يتم الالتصاق بين منقول ومنقول. والمنقول هو كل شئ غير مستقر فى حيزه بحيث يمكن نقله منه دون تلف يعيبه. أما إذا كان الالتصاق بين منقول وعقار وجب تطبيق الأحكام السالف الإشارة إليها.

ثانياً : أن يكون المنقولان مملوكين لمالكين مختلفين. أما إذا اتحد المالك فلا يكون هناك مجال لأعمال أحكام الالتصاق، إذ يكون المنقولان الملتصقان فى حالتهم الجديدة مملوكين لنفس المالك الواحد الذى كان يملك كل منهما، والصعوبة قد تتعلق بإثبات الملكية.

(١) د. السنهورى الوسيط ج ٩: ص ٣١٨، د. محمد عمران ص ٨٧.

ثالثاً : أن يندمج المنقولان بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ٩٣١ مدنى، أما إذا أمكن فصل المنقولين دون تلف فلا محل لأعمال قواعد الالتصاق ويكون كل منقول ملكاً لصاحبه.

رابعاً : ألا يكون هناك اتفاق سابق بين المالكين المختلفين فى شأن مصير المنقولين بعد الالتصاق. وهذا شرط جوهرى فإن وجد اتفاق سابق الذى يسوى ولا تسرى أحكام الالتصاق.

فإذا ما توافرت هذه الشروط الأربعة، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بالضوابط التى وصفتها المادة ٩٣١ مدنى ومن ذلك قواعد العدالة مراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

وقد لا يرى القاضى موجبا لجعل الملكية لأحد المالكين فيقضى عندئذ باعتباره مملوكا لهما على الشيوع بنسبة ما يملكه ولأى من المالكين رغبة منه فى إنهاء الشيوع أن يطلب من القاضى الأمر ببيعه ويقسم بعد ذلك الثمن عليهما كل بنسبة ما كان يملك.

2024/2025

المبحث الثالث 2024/2025

2024/2025

الشفعة

تعريف الشفعة :

نصت المادة ٩٣٥ من القانون المدنى على أن «الشفعة رخصة تجيز من بيع العقار الحلول محل المشتري فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية». ومفاد ذلك أن المشرع قد عرف الشفعة بأنها رخصة لا حق لأنها ليست بحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية، وقد تكون سبباً لكسب بعض الحقوق العينية الأصلية الأخرى.

والشفعة رخصة أى خيار للشفيع فله أن يستعمله أو لا يستعمله ومن ثم فلا يكره عليه ولا تجوز إلا فى العقار ومتى ثبت الحق فيها تملك العقار المبيع

ولو جبراً على المشتري بموجب حكم من القضاء يعتبر عقداً حقيقياً حلت فيه سلطة القضاء محل الإرادة^(١).

والشفعة وإن كانت سبباً من أسباب الملكية فهي أيضاً تعتبر قيداً هاماً على الملكية، فهي تحرم المالك من التصرف في ماله إلى الشخص الذي يختاره حيث يتم حلول الشفيع محل المشتري الذي اختاره المالك. ويتم ذلك الحلول بقوة القانون دون رضا من المالك، فالشفعة تؤدي إلى إقصاء المشتري عن العقد وحلول الشفيع محله، لذلك فهي تثبت على خلاف الأصل لأنها تنافي قاعدة اشتراط الرضا في انتقال الملك من شخص إلى آخر ولكن الشفعة لا تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون ولا تخالف مبدأ تكافؤ الفرص^(٢).

التكييف القانوني للشفعة وأهميته:

إذا كان المشرع قد عرف الشفعة بأنها رخصة لا حق، فإن هذا المصطلح رخصة له في هذا الخصوص أكثر من معنى، فأحياناً يقصد به معنى الحريات العامة كحرية التملك وحرية الزواج وحرية التنقل، وهي الحريات التي نصت للناس كافة دون حاجة إلى قيام سبب معين. وأحياناً يقصد به الحق في حق معين إذا وجد سبب خاص، كحق الموجه إليه الإيجاب بالبيع في أن يملك الشيء بأن يقبل الشراء، وحق الشفيع في أن يأخذ بالشفعة. وبهذا تكون الشفعة ليست مجرد رخصة بل هي أكثر من ذلك. ولهذا نجد الأستاذ السنهاوري يقول في التعليق على نص القانون المصري «الأدق أن يقال أن هذا المركز القانوني لا يتولد عنه مجرد رخصة في التملك بل يتولد عنه حق الشخص في أن يملك»^(٣).

(١) المستشار: أنور طلبية، التعليق على نصوص القانون المدني، الجزء الثاني، ص ٤٩٥.

(٢) نقض مدني ٥-٣-١٩٧٩، ص ٧٠٨، رقم ١٣١.

(٣) المذكرة الإيضاحية حـ ٦، ص ٣٥٠ ومابعد.

أثار التكليف القانوني للشفعة عدة أمور أهمها مدى إمكان استعمال الشفعة عن طريق الدعوى غير المباشرة، وحوالة الشفعة وأن الشفعة لا تقبل توريث التجزئة، هل يجوز أن تورث الشفعة أم أنها خاصة بالشفيع ولا تورث ونعرض لكل من هذه المسائل على التوالي :

كما أن الشفعة باعتبارها سبباً لكسب الملكية تؤدي إلى تحميل الشفيع بأعباء مالية تتمثل في الثمن والمصروفات، وقد لا يرغب في تحملها الشفيع ولا يصح أن يكتسب المدين مالاً بغير رغبته أو جبراً عنه مما يتعارض مع الشفعة نفسها التي تقوم على تخيير الشفيع بين طلب الشفعة أو تركها^(٤).

(١) د. السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج ١ ص ٤-٨.

(٧) سانت الارى هوان : حق الشفعة رقم ٥٠٧، ص ٤٦١ ومابعدھا.

(٣) د. السنهوري: الوسيط، ج ٩، ص ٤٥٢.

(٤) د. حسام الأهواني: الحقوق العينية الأصلية، طبعة ٩٨-٩٩ ص ١٢٢.

٢- لا يجوز للشفيع أن يحيل حقه في الشفعة إلى غيره لأن الشفعة متصلة بشخصه ومن ثم تتنافى طبيعتها مع جواز الحوالة شأن جميع الحقوق المتصلة بشخص الدائن.

٣- هل يجوز للشفعة أن تورث؟ أثارت مسألة انتقال الشفعة بالميراث من عدمه خلافاً فقهاء كبراً في الفقه الإسلامي^(١) وفي الفقه القانوني الوضعي^(٢). ولكن الفقه الغالب الآن^(٣) يذهب إلى أن الشفعة وإن كانت رخصة إلا أنها رخصة عينية يرتبط وجودها وبقاؤها بالعقار المشفوع به، فمن الطبيعي أن تلازم هذه الرخصة العقار. فإذا انتقل العقار المشفوع به إلى الورثة انتقلت الشفعة معه إليهم. يؤيد ذلك أن الشفعة تنتقل إلى ورثة الشفيع فهي وإن كانت متصلة بشخص الشفيع إلا أنها تتعلق أيضاً بالعقار المشفوع به ومتى انتقل هذا العقار المشفوع به إلى الورثة فإن الحق في الشفعة ينتقل أيضاً إليهم بالميراث حتى ولو لم يتوافر فيهم شروط الأخذ بالشفعة. ويضيف الفقه أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط بموته وإنما ينتقل إلى الورثة وهذا الانتقال يتحقق حتى لو مات الشفيع قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وقد استقر قضاء محكمة النقض على الرأي الأخير الذي ذهب إلى أن الشفعة من الحقوق المالية التي يجري فيها التوارث مجراه في المال^(٤).

٤- عدم قابلية الشفعة للتجزئة : استقر الفقه والقضاء على قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ بمعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة

(١) الأستاذ محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ١٨٠ ومابعداها.

(٢) د. السنهوري: الوسيط، ج ٩، ص ٤٦٩.

(٣) د. محمد علي عمران: الحقوق العينية الأصلية ص ١٠٦، د. حسام الأهواني: ص ١٣٣، د. منصور مصطفى: ص ٣٥٧، د. محمد لبيب شنب: موجز الحقوق العينية الأصلية، طبعة ١٩٧٢ ص ١١٢.

(٤) نقض مدني ٢٤-٢-١٩٨٢، طعن رقم ٩٠٣ لسنة ٥٠ ق، طعن رقم ٢٠٨ لسنة ٥٣ ق في ٢٨-٤-١٩٨٧، نقض مدني ١٧-١-١٩٨٩ لم ينشر بعد.

بعض المبيع دون البعض الآخر. وعلى ذلك فإن من يريد أن يشفع بأن يأخذ العقار المبيع كله وليس له الحق في تجزئته لما يترتب على التجزئة من ضرر يصيب البائع وهذا يفترض بطبيعة الحال أن يكون العقار المشفوع فيه قد بيع في صفقة واحدة. وأما إذا كان قد بيع في صفقات متعددة مجزئاً وطالب الشفيع بالشفعة في جزئ منه أى فيما ورد عليه البيع في صفقة من الصفقات فإن هذا لا يعتبر تجزئة للشفعة إذ أن العقار المشفوع فيه كان منذ البداية مجزئاً^(١).

المطلب الأول

أسباب الأخذ بالشفعة

حددت المادة ٩٣٦ مدنى أسباب الأخذ بالشفعة، وهى أسباب واردة على خلاف الأصل وهى حرية التعاقد، والاستثناء هو إجبار البائع على التعاقد مع غير من اختيار، لذلك يمكن القول بعدم جواز الشفعة فى غير هذه الحالات.

الفرع الأول

مالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الغرض من تقرير الشفعة فى هذه الحالة هو جمع شتات الملكية فى يد شخص واحد هو مالك الرقبة. فإذا كانت الملكية مجزأة - وهذا يتحقق إذا كانت ملكية الرقبة لشخص وملكية الانتفاع لشخص آخر - ثم بيع حق الانتفاع، فلمالك الرقبة أن يشفع فى حق الانتفاع المبيع. ويتم بذلك جمع شتات الملكية فى يد شخص واحد هو مالك الرقبة.

(١) وفى هذا قضت محكمة النقض بأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة والثابت بالحكم المطعون فيه أن شراء الأرض المشفوع فيها كان بعقد مستقل عن عقد شراء المسقاة فثمة صفقتان ويحق للشفيعين أن يأخذ الأرض بالشفعة دون المسقاة. نقض طعن رقم ٧٦٥ لسنة ٤٥ ق جلسة ٢٨-٥-١٩٨٠، وأيضاً طعن رقم ١٨٩ لسنة ٤٧ ق جلسة ٦-٣-١٩٨٣.

وقد يكون حق الانتفاع مملوكاً ملكية شائعة لشخصين أو أكثر. فإذا باع أحدهم ما يملكه كان لمالك الرقبة أن يشفع في هذا الجزء المبيع من حق الانتفاع، ولا يزاحم مالك الرقبة في هذا الفرض الشركاء الآخرين المشتاعين للبائع، إذ عند التزامه يفضل مالك الرقبة فهو في المرتبة الأولى.

فإذا كانت ملكية الرقبة لشخصين وبيع حق الانتفاع كله، وأراد كل منهما أن يشفع في حق الانتفاع المبيع، فإن كلاً منهما يشفع في الحق المبيع بقدر نصيبه في ملكية الرقبة. إذا لم يطلب الشفعة سوى أحد مالكي الرقبة، فإنه يشفع في حق الانتفاع في حدود النصف فقط لأنه هو القدر الملايس للنصف الذي يملكه في ملكية الرقبة، ويظل النصف الآخر مملوكاً للمشتري. وقد يكون هذا الوضع ضار بالمشتري ويكون له أن يطالب بعدم تجزئة الصفقة عليه، وله عندئذ مطالبة مالك الرقبة الذي شفع في النصف المبيع فقط أن يأخذ النصف الباقي حتى تثبت له ملكية حق الانتفاع كله، وأما أن ينزل عن الشفعة حتى لا تتجزأ الصفقة على المشتري^(١).

الفرع الثاني

2024/2025

2024/2025

2024/2025

صاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة

ويثبت أيضاً الحق في الشفعة لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملايسة لهذا الحق أو بعضها وهذا الحكم هو الذي نصت عليه المادة ٩٣٦/ب من القانون المدني. والغرض من تقرير الحق في الشفعة في هذا الفرض هو جمع شتات الملكية في يد شخص واحد. وفي أبسط فروض هذه الحالة أن تكون ملكية الرقبة لشخص وملكية الانتفاع لآخر. فإذا باع مالك

(١) د. عبد الرازق السنهوري: المرجع السابق، ص ٥٤٦، د. محمود جمال زكي: الحقوق العينية الأصلية طبعة ١٩٧٨ ص ٤٢٧؛ د. محمد علي عمران: الحقوق العينية الأصلية، طبعة ١٩٧٩، ص ١٠٨. نقض مدني ١٣-١٢-١٩٧٩ طعن رقم ١٠٣ لسنة ٤٨ ق.



الرقبة ما يمتلك فلصاحب حق الانتفاع المطالبة بالشفعة ويفضل على الأجنبي الذى يكون مالك الرقبة قد باع له.

أما إذا كانت ملكية الرقبة لشخصين على الشيوع وباع أحدهما ما يمتلك، فلصاحب حق الانتفاع المطالبة بالشفعة ما لم يطالب الشريك على الشيوع الأخذ بها، إذ يفضل الشريك على صاحب حق الانتفاع إذا ما بيعت ملكية الرقبة. فإذا ما قضى لمالك الانتفاع بالشفعة، فإنه يصبح مالكا أيضاً للنصف المبيع من الرقبة بها، وبذلك تجتمع شتات ملكية العقار فى نصفه إذ يصبح مالكا ملكية تامة لهذا النصف.

أما إذا كانت ملكية الرقبة لشخص واحد وملكية الانتفاع لشخصين وباع مالك الرقبة ما يمتلك فلصاحب حق الانتفاع الشفعة فيما بيع. ويشفع كل منهما فى ملكية الرقبة بالقدر الذى يمتلكه فى حق الانتفاع. أى يصبح كل منهما مالكا لنصف الرقبة ونصف الانتفاع، ومن ثم فإنهما يصبحان مالكين ملكية تامة للعقار مناصفة بينهما.

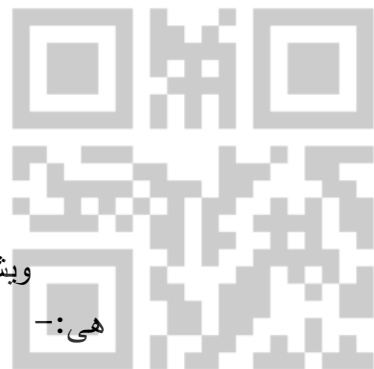
2024/2025

الفصل الثالث

2024/2025

الشريك فى الشيوع

تنص المادة ٩٣٦ مدنى على أن يثبت الحق فى الشفعة (ج) للشريك على الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبي. وإعطاء الشريك على الشيوع فى الملك حق الشفعة يستهدف تحقيق مصلحة خاصة للشفيع ومصلحة عامة للجماعة. فمن جهة، تحقق الشفعة مصلحة الشركاء على الشيوع باستبعاد دخول أجنبي بينهم فى الملكية. ومن جهة أخرى فإن الشفعة تحقق مصلحة اجتماعية واقتصادية هامة، فهى تؤدى إما إلى خلوص الملكية لشخص واحد أى إنهاء حالة الشيوع أو تقليل عدد الشركاء وكلاهما أمر مرغوب فيه اقتصادياً، وإذا كان الشركاء من أفراد أسرة واحدة فإن الشفعة تحقق هدفاً اجتماعياً بحماية وحدة الأسرة.



ويشترط لطلب الشفعة استناداً إلى النص السالف توافر عدة شروط

هي:

١- أن تكون ملكية العقار شائعة وعلى ذلك إذا انتهت حالة الشيوع بالقسمة وأفرزت الأنصبة لم يعد الشريك شريكاً وإنما أصبح جاراً فلا يكون له الحق في طلب الشفعة فيما يبيعه شريكه السابق إلا على أساس الجوار.

٢- أن يكون المبيع حصة شائعة. فإذا باع الشريك على الشيوع حصة شائعة تثبت الشفعة للشركاء المشتاعين الآخرين. وأما إذا كان البيع قد ورد على حصة مفرزة لا شائعة، فهل يثبت الحق في الشفعة للشركاء المشتاعين الآخرين، أم أن هذا الحق لا يثبت لهم؟

ذهب جانب من الفقه (١) إلى القول بأن بيع الشريك على الشيوع لحصة مفرزة في العقار الشائع لا يجيز لغيره من الشركاء المشتاعين المطالبة بالشفعة. فهذا البيع لا يسرى قبل القسمة في مواجهة باقي الشركاء على الشيوع.

2024/2025

وذهب جانب آخر من الفقه (٢) إلى جواز الأخذ بالشفعة في حالة بيع الحصة المفرزة، فإن نص المادة ٩٣٦/ب الذي يذكر من بين الشفعاء الشريك على الشيوع لم يقصر حقه في الأخذ بالشفعة على حالة بيع شائعة في العقار بل هو يذكر «إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي» فالشريك على الشيوع له الأخذ بالشفعة متى بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي سواء كان هذا الشيء المبيع حصة شائعة أو قدراً مفرزاً.

(١) د. السنهوري: الوسيط، ص ٥٥٠، د. منصور مصطفى منصور: ص ٢٣٠، د. محمد علي عمران، ص ١١٠.
(٢) د. عبد المنعم البدرأوى: حق الملكية، طبعة ١٩٧٣، ص ٣٤١، المستشار أنور طلبية: التعليق على نصوص القانون المدني، ح ٢، ص ٥٠٣، د. محمد علي عرفه: ص ٤٨.





وقد أخذت محكمة النقض بالرأى الأخير فقضت بأن نص المشرع فى المادة ٨٢٦ مدنى على أن «كل شريك فى الشيوخ يملك حصة ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة». ثم نص فى المادة ٩٣٦ مدنى على أنه «يثبت الحق فى الشفعة للشريك فى الشيوخ إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى الأجنبى» يدل على أن للمالك على الشيوخ أن يبيع ملكه محددًا ومفرزًا ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوخ. ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبى وكان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوخ طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فإنه يتعين هنا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة ٩٣٦ من القانون المدنى^(١).

2024/2025

^{2024/2025} ٣- أن يكون بيع الحصة الشائعة لأجنبى - ومفاد ذلك أن المشرع قد رأى تقيد استعمال النص بقصره على حالة البيع الحاصل للغير دون البيع الحاصل لأحد الشركاء فى الملك. والعلة من ذلك واضحة وهى أن البيع لأحد الشركاء لا يترتب عليه دخول أجنبى بين الشركاء فى الشيوخ ومن ثم فلا ضرر يعود عليهم من ذلك البيع.

(١) نقض ١-٥-١٩٨٠ عن رقم ٧٨٤ لسنة ٤٧ق. نقض ٢٣-١٢-١٩٨٦ طعن رقم ٥٣٨ لسنة ٥١ق. وفى هذا قضى أيضاً أن الشريك على الشيوخ له حق الأخذ بالشفعة إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كانا لبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً فله ذلك (المادتان ٨٢٦، ٩٣٦ مدنى). نقض ١١-٣-١٩٨٧ طعن رقم ١٤٦٦ لسنة ٥٣ق.



الفرع الرابع

الجوار كسبب للشفعة

اعتد المشرع المصرى بالجوار وجعله سبباً من أسباب الأخذ بالشفعة حيث نص على ذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة ٩٣٦ مدنى. بيد أن هذا الحق لا يثبت للجار المالك بصفة مطلقة، بل أنه يثبت فقط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة ٩٣٦ مدنى وهذه الحالات هى:-

الحالة الأولى : إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى. والتلاصق هنا بمفرده كاف للأخذ بالشفعة، شريطة أن تكون العقارات المتلاصقة مبان أو أراض معدة للبناء سواء أكانت هذه الأراضى داخل المدن أم فى القرى، فإذا كانت الأراضى تدخل فى هذا النطاق فهى أراض معدة للبناء حتى ولو كان صاحبها قد خصصها لغرض آخر^(١).

وفى هذا قضت محكمة النقض^(٢) أنه يشترط للأخذ بالشفعة فى هذه الحالة أمران الأول أن يكون محل البيع المشفوع فيه أرض داخلية فى نطاق المدينة أو القرية، والثانى أن تكون من الأراضى المعدة للبناء. والمناطق فى التعرف على الأمر الأول الرجوع إلى الخرائط التى تعين كردون المدينة أو القرية والقرارات المعدلة لتلك الحدود وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام الحكم المحلى، أما التعرف على الأمر الثانى فمرده استظهار موقع الأرض من الكتلة السكنية فى المدينة أو القرية وطبيعتها وسائر الظروف المحيطة بها لبيان ما إذا كان يصدق فى شأنها وصف الأرض المعدة للبناء من عدمه وهى مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها

(١) د عبد الرزاق السنهورى: المرجع السابق، ص ٥٦٥، د محمد على عمران، المرجع السابق، ص ١١٧، د عبد المنعم البدرأوى: المرجع السابق، ص ٤٣٩.

(٢) نقض مدنى ٦-٥-١٩٨٦، طعن رقم ١٢٤٧ لسنة ٥٢ ق.





قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.

الحالة الثانية : إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة ويكاد هذا الحكم أن يكون مقصوراً على الأراضي الزراعية. ويترتب على الأخذ بالشفعة زوال حق الارتفاق. وفي هذا قضت محكمة النقض^(١) أن النص في المادة ٥/٩٣٦ من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار على الأرض المبيعة يدل على قيام حق الارتفاق على الوجه المبين بالنص يكفي بذاته لثبوت حق الشفعة، وإذا كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير إلى قيام حق ارتفاق بالرى بأرضه على الأرض المشفوع فيها وكان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة لهذا السبب استناداً إلى تقرير الخبير السالف فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعى عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الحالة الثالثة: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين، فلا يكفي التلاصق من جهة واحدة بل يجب التلاصق من جهتين، وتكفي الملاصقة من جهتين ولو في شبر واحد.

كما لا تقل قيمة أرض الشفيع في القيمة عن نصف ثمن الأرض المبيعة، ويبرر هذا الشرط رغبة المشرع في ألا تكون الشفعة سبباً للمساومة والمضاربة، وحتى لا يتخذ منها بعض الناس وسيلة للحصول على مبلغ ما من المال نظير النزول عن طلب الشفعة. والعبرة بقيمة أرض الشفيع وقت إبرام عقد البيع الذي يؤخذ فيه بالشفعة، وبثمن الأرض المشفوع فيها الذي بيعت به ولو زاد عن الثمن الحقيقي.

(١) نقض ٢٥-٦-١٩٨٥ طعن رقم ١٧١٧ لسنة ٥٢ق.



الفرع الخامس

تزامم الشفعاء

قد يحدث أن يتعدد الشفعاء ويتزاحمون، وهذا هو ما تضمنته المادة ٩٣٧ مدنى والتي تنص على ما يأتى «إذا تزامم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة. وإذا تزامم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفعياً بمقتضى نص المادة السابقة. فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى. ويتخذ التزامم بين الشفعاء صوراً ثلاث:-

الصورة الأولى: التزامم بين الشفعاء من طبقات متعددة.

إذا تزامم الشفعاء وكانوا من طبقات متعددة، فضل منهم من يكون من طبقة أعلى من الآخر. وتتحدد الطبقات وفقاً للترتيب المنصوص عليه فى المادة ٩٣٦^{2024/2025} مدنى. فإذا رتب مالك العقار^{2024/2025} لشخصين حق انتفاع على العقار المملوك له. وكان هذا الحق شائعاً بينهما وباع أحد صاحبي حق الانتفاع حصته، فلمالك الرقبة وللشريك الآخر على الشيوع فى حق الانتفاع أن يشفعا، وإذا تزامم فضل مالك الرقبة على الشريك فى الشيوع إذ أنه يأتى فى المرتبة الأولى.

وكذلك أيضاً إذا كانت ملكية الرقبة لشخصين على الشيوع وملكية الانتفاع لشخص آخر، فإذا باع أحد الشركاء على الشيوع حصته فى ملكية الرقبة، فلا شك أن الشفعة تثبت فى هذا الفرض لشريكة الآخر فى ملكية الرقبة، كما تثبت أيضاً لصاحب حق الانتفاع. فإذا تزامم فإن الذى يفضل هو الشريك فى الشيوع لأنه يأتى فى المرتبة الثانية فى حين أن صاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة يأتى فى المرتبة الثالثة.



وإذا تزامم الجيران، فالذى يأخذ بالشفعة منهم هو الجار الذى تعود على ملكه من الشفعة منفعة أكثر من غيره. ويستقل القاضى بتقديم المنفعة التى تعود على كل جار توسلاً لتحديد الأفضل منهم. فإذا كان لأحد الجيران حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه، فإنه يفضل على الجار الآخر الذى لا يكون لعقاره حق ارتفاق. وعلى هذا استقر قضاء محكمة النقض (١).

الصورة الثانية : تزامم بين الشفعاء من طبقة واحدة:

إذا تزامم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم يكون على قدر نصيبه م ٢/٩٣٧ مدنى، فإذا تعدد الشركاء فى الشفوع، وباع أحدهم حصته الشائعة، استحق كل من الشركاء الآخرين بالشفعة فى العقار المبيع على قدر نصيبه. مع ملاحظة أنه يجب ألا يترتب على تعدد الشفعاء الذين هم فى مرتبة واحدة تجزئة العقار المبيع، إذ يجب على كل من الشفعاء، إذا ما طالب بالشفعة أن يتحدد طلبه بالعقار المشفوع فيه كله، لا أن يطالب بها بقدر نصيبه

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الصورة الثالثة : المشتري أحد الشفعاء:

إذا توافر فى المشتري شروط الأخذ بالشفعة فإنه يفضل على غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته (م ٣/٩٣٧ مدنى أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى من الطبقة التى ينتمى إليها المشتري فحق الشفعة ينشأ من وقت البيع، فالمشرع لم يمنعهم من الأخذ بالشفعة، بالرغم من أن المشتري تتوافر فيه صفة الشفيع ولكن لطبقة أدنى».

(١) نقض مدنى ٢٨-٥-١٩٩١، الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٥٨ ق منشور بمجلة القضاة س ٥ العدد ١ يونيه ١٩٩٢.



المطلب الثانى

أحكام الشفعة

بيننا فى المطلب الأول أسباب الأخذ بالشفعة، وسوف نعرض فى هذا المطلب لأحكام الشفعة، ونبدأ ببيان الشروط التى يجب توافرها فى الشفع، ثم ندرس العقود التى تجيز الشفعة والعقود التى لا تجيزها. ثم إجراءات الشفعة.

الفرع الأول

الشروط التى يجب توافرها فى الشفع

فضلاً عن توافر سبب من أسباب الأخذ بالشفعة يجب أن تتوافر فى الشفع عدة شروط أخرى، فيجب أن يكون الشفع مالاً للعقار أو للحق المشفوع به وقت البيع، وأن يظل مالاً له إلى حين تمام الأخذ بالشفعة، وأن تتوافر لدى الشفع الأهلية اللازمة للأخذ بالشفعة، وأخيراً يجب ألا يكون الشفع ممنوعاً من الأخذ بالشفعة سواء بالاتفاق أو بحكم القانون.

2024/2025

الشريط الأول : يجب أن يكون الشفع مالاً للعقار المشفوع فيه وقت البيع:

حتى تثبت الشفعة يجب أن يكون الشفع مالاً للعقار المشفوع فيه وقت بيع العقار المشفوع فيه. وهذا هو مضمون المادة ٩٣٦ مدنى التى حددت أسباب الأخذ بالشفعة، فإذا لم يكن الشفع مالاً لعقار المشفوع به وقت البيع فلن يتحقق بشأنه سبب من أسباب الأخذ بالشفعة الواردة بالمادة ٩٣٦ مدنى. ويشترط لذلك بطبيعة الحال أن يكون سند ملكية الشفع مسجلاً. فإذا لم يكن مسجلاً فلا يعتبر الشفع مالاً للعقار المشفوع فيه وبالتالي لا يجوز له أن يشفع، ويجب أيضاً أن يكون سند ملكية الشفع قد سجل قبل بيع العقار المشفوع فيه^(١). فإذا كان هذا السند قد سجل بعد البيع فلا تثبت به أيضاً

(١) وبهذا قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها نقض ١-٢-١٩٨٧ طعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٣ق، ٥-٢-١٩٧٨ طعن ١٩٧٩ لسنة ٥٢ق، ٢٥-٢-١٩٨٨ طعن رقم ٦١٠ لسنة ٢٢٦ لسنة ٥٤ق وأيضاً ١٠-٥-١٩٨٨ طعن رقم ٦١٠ لسنة



الشفعة استناداً إلى انعدام الأثر الرجعى للتسجيل^(١) إذ أن ملكية العقار لا تنقل إلى بالتسجيل ومن تاريخه سواء فى العلاقة بين البائع والمشتري أو فى مواجهة الغير.

وقد يكون من يشفع مالكاً تحت شرط واقف أو فاسخ. والقاعدة أن الشرط الواقف يترتب عليه وقف نشوء الحق أو الالتزام، ومن ثم فإذا كانت الملكية معلقة على شرط واقف، فلا يعتبر المالك تحت شرط واقف مالكاً فى الحال وبالتالي لا يجوز له أن يشفع لعدم كونه مالكاً وقت البيع. أما إذا كان الشفيع مالكاً تحت شرط فاسخ، فإن هذا لا يمنع من اعتباره مالكاً ويجوز له تبعاً لذلك أن يشفع. غاية ما فى الأمر أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ قبل بيع العقار المشفوع فيه، فلا تثبت الشفعة إذ تزول ملكية الشفيع. أما إذا تحقق الشرط الفاسخ بعد البيع ولم يعد الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به بأثر رجعى، فإن ذلك لا يؤثر فى ثبوت الحق فى الشفعة إذ أن الأثر الرجعى للشرط لا يعتد به فى نطاق الشفعة^(٢). وفى هذا قضت محكمة النقض أن الشفعة جائزة فى البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ لأن البيع فى هذه الحالة يكون موجوداً أو نافذاً من وقت إبرامه وعلى الشفيع أن يراعى مواعيد إجراءات الأخذ بالشفعة فيه فإن هو فوتها سقط حقه فى الأخذ بها ولا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط^(٣).

وإذا كان سند ملكية الشفيع باطلاً بطلاناً مطلقاً أو عقداً صورياً، فلا تصح به الشفعة. بل أنه يجوز للمشتري إذا ما أراد الشفيع المطالبة بالشفعة أن

٥٤ق. حيث قضت بأن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه شرط لأخذ العقار بالشفعة مشتري العقار الذى يؤشر منطوق الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقده على هامش تسجيل صحيفة دعواه لا يكون له الحق فى الشفعة لهذا العقار إلا من تاريخ هذا التأشير.

(١) د محمد على عمران: المرجع السابق، ص ١٢٤.

(٢) د السنهورى: الوسيط، ص ٥٨٦، د محمد على عمران ص ١٢٦، د البداروى، ص ٤٤٩.

(٣) نقض مدنى ١٣-٣-١٩٨١ طعن رقم ٧٨١، ٩٥٢ لسنة ٤٩ق.

يدفع ببطلانه سند ملكية الشفيع، إذ له مصلحة في التمسك بهذا البطلان والقاعدة في البطلان المطلق أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به (١).

أما إذا كان سند ملكية الشفيع قابلاً للإبطال فقط، فإن هذا لا يمنع من المطالبة بالشفعة، غاية ما في الأمر أنه يجب ألا يحكم بالبطلان قبل أن تثبت الشفعة نهائياً لمن طالب بها، فإذا قضى ببطلان سند ملكية الشفيع قبل تمام الأخذ بالشفعة سقط حقه فيها.

الشرط الثاني : يجب ألا يكون الشفيع ممنوعاً من شراء المال المشفوع فيه:

يترتب على الشفعة أن يحل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. فالشفيع يصبح هو المشتري أو على الأقل في حكمه. والحكمة التي من أجلها شرع منع بعض الطوائف من الشراء تتوافر بصدد الشفعة وتستلزم بالتالي منع هذه الطوائف من الأخذ بالشفعة. وندرس بإيجاز الطوائف الممنوعة من الشراء لنبين مدى توافر الحكمة من منع الأخذ بالشفعة.

2024/2025

فطبقاً للمادة ١٠٨ مدني لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه باسم من يئوب عنه. وتنص المادة ٤٨٠ مدني على أنه «لا يجوز للسماسة ولا للخبراء أن يشتروا ولو باسم مستعار الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. والحكمة من حظر الشراء هي تعارض مصلحة البائع والمشتري ومن ثم لا يصح أن يكون الشخص بائعاً ولو بصفته وكيلًا ومشترياً سواء لنفسه أو بصفته وكيلًا. فمن الصعب على الوكيل أن يوفق بين المصالح المتعارضة إذا كان يعمل لحساب الأطراف جميعاً. ونفس هذه الحكمة تستلزم منع هؤلاء الأشخاص من أن يطلبوا الشفعة في العقار أو المال الذي تم بيعه من قبلهم بصفته. فيخشى أن يتساهل الوكيل للبائع مع

(١) في هذا قضت محكمة النقض بأن «ملكية الشفيع وقت البيع لما يشفع به شرط لقبول دعواه، المادة ٩٣٥، ٩٣٦ - في - صورية العقد سند ملكية الشفيع ولو كان مسجلاً لا يجوز به الشفعة. نقض ٢٥-٢-١٩٨٨ طعن رقم ٦٢٦ لسنة ٤٥ق.

المشتري سواء في الثمن أو في باقى شروط البيع حتى يستفيد بعد ذلك إذا ما طلب الشفعة أى إذا حل محل المشتري.

فالحظر من الشراء يجب أن يمتد ليشمل بصفة عامة الحلول محل المشتري أى حظر الأخذ بالشفعة. فحظر الشفعة يحول دون تواطؤ النائب مع المشتري حتى يستفيد الأول إذا ما أخذ بالشفعة. ويضاف لذلك أنه في حالة النيابة الاتفاقية وحيث يقبل الوكيل بيع عقار الموكل إلى شخص أجنبي يكون قد نزل بذلك عن طلب الشفعة نزولاً ضمناً.

وطبقاً للمادة ٤٧١ مدنى لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتابة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا، ولو باسم مستعار حقاً متنازعا فيه وإلا كان العقد باطلاً. والحكمة من هذا الحظر إبعاد القضاء عن أى شبهة والمحافظة على حياده وسمعته، وقد يخشى أن يستغل رجل القضاء نفوذه في الحصول على الحق المتنازع عليه بثمن بخس أو قد يعتقد الناس أن القاضى أو أحد معاونيه قد حصل على المبيع بشروط ميسرة. لذلك حظر عليهم الشراء. وتلك الحكمة التى أملت حظر الشراء تظل متوافرة في حالة الشفعة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الشرط الثالث : يجب ألا يكون الشفيع وقفاً:

تنص المادة ٢/٩٣٩ مدنى على أنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة. وعدم السماح للوقف بأن يأخذ بالشفعة يرجع إلى اعتبارين :-

الأول : أن ناظر الوقف لا يعتبر مالكاً للعقار الموقوف ومن ثم لا يصلح أن يكون شفيعاً كما أن الموقوف عليه ليس مالكاً للعقار. فالوقف بصفة عامة هو حبس العين عن التملك وصرف منفعتها على وجه من وجوه البر والخير.

ومن جهة أخرى لو أبيح للوقف أن يأخذ بالشفعة لوجب أن يصبح العقار المشفوع فيه هو أيضاً وقفاً. وطبقاً للقانون لا يمكن أن ينشأ الوقف إلا بإشهاد

رسمى. أى أن السماح للوقف بأن يأخذ بالشفعة يؤدي إلى نشوء الوقف بغير طريق الإشهاد الرسمي وهو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع لإنشاء الوقف، وتقديراً لذلك لا يجوز للوقف بأن يأخذ بالشفعة. وإذا كان لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة، إلا أنه تجوز الشفعة عند بيع الوقف. فإذا بيع العقار الموقوف فى حالة الاستبدال فإن الشفعة تجوز فيه. فيجوز للمالك على الشيوع فى عقار أوقفت حصة منه أن يأخذ بالشفعة عند بيع الوقف لحصته الشائعة.

الفرع الثانى

التصرف الذى يجيز الشفعة

لا تجوز الشفعة إلا إذا كان التصرف فى العقار المشفوع فيه بيعاً. كما أن هناك ببوعاً لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة.

الفصل الأول

يجب أن يكون التصرف بيعاً

طبقاً للمادة ٩٣٥ مدنى لا شفعة إلا عند بيع العقار. وقد عرفت المادة ٤١٨ مدنى البيع بأنه «عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر لقاء ثمن نقدي». فأهم ما يميز عقد البيع عن غيره من العقود التى ترد على التملك أن الملك ينتقل مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري إلى البائع.

ولما كانت النقود أشياء مثلية، فإن الشفعة لا تؤدي إلى الإضرار بالبائع حيث يقبض من الشفيع نفس الثمن النقدي الذى اتفق عليه فى عقد البيع مع المشتري، وإذا كان المشتري قد سدد الثمن للبائع فإن الشفيع يدفع الثمن إلى المشتري ومن ثم فإن المشتري يسترد عين ما أداه للبائع ولا يضر من الشفعة. فالبيع يكفل إذن عدم الإضرار بالبائع أو المشتري. فحلول الشفيع محل المشتري لا يكون ممكناً إلا إذا كان فى إمكانه أن يقدم للبائع نفس الأداء الذى التزم به المشتري وذلك لا يتحقق إلا فى البيع. والبائع متى حصل على نفس



التمن الذي اتفق عليه مع المشتري لا تكون له مصلحة أن يشتري منه شخص بالذات. فيستوى لديه أن ينقل العقار إلى ملك المشتري أو إلى ملك الشفيع^(١).

ولكن إذا ثبت أن عقد البيع الصادر من البائع إلى المشتري قد روعى فيه إثثار المتصرف إليه بالذات لاعتبارات تتعلق إما بشخصه وما قام به من جهود في إصلاح الأرض مثلاً^(٢)، أو ما يتعلق بمصلحة اجتماعية أو اقتصادية مثل البيع لمحدودي الدخل أو لأعضاء جمعية إسكان تعاوني أو من الجامعة إلى جمعية الإسكان بالجامعة فلا تثبت الشفعة^(٣).

وبناء عليه لا تثبت الشفعة في المقايضة. فالمقايضة تبادل مال بمال لا يكون أيهما نقود. والقول بالشفعة في المقايضة يؤدي إلى الإضرار بالبائع الذي ما كان يقبل إلا المقايضة. فالحصول على الشيء الذي تمت المقايضة به قد تكون الذي دفع صاحب المال للتصرف فيه، أما لو كان المقابل نقداً لما أقدم أصلاً على التصرف. فالشفعة في المقايضة تؤدي إلى فقدان المتصرف للشيء الذي تعاقد من أجل الحصول عليه ويجبر على قبول مبلغ من النقود.

2024/2025 ولا شفعة في عقد الشركة. في 2024/2025 2024/2025 الشريك على الشيوخ حصته كحصة عينية في الشركة فإنه لا تجوز الشفعة في ذلك. فتقديم الحصة لا يعتبر بيعاً يحصل الشريك على مقابل نقدي له وإنما أصبح شريكاً في أرباح وخسائر الشركة. كما أن الشركة لا ترضى بديلاً نقدياً عن هذه الحصة العينية إذ قد يخل ذلك بأغراضها^(٤).

ولا يجوز الشفعة في عقد الصلح ولو كان الصلح قد تم ببديل نقدي. فإذا تملك الشخص العقار المشفوع فيه بناء على صلح في شأن مال كانت ملكيته

(١) د. البدر أوى: المرجع السابق، ص ٤٥٧، د. حسام الأهواني: المرجع السابق، ص ١٥٦.

(٢) نقض مدني ٢٦-٢-١٩٥٣، المجموعة، السنة ٤ رقم ٨٠ ص ٥٦١.

(٣) نقض مدني ٢٦-١٢-١٩٨٥، المجموعة، السنة ٣٦ رقم ٢٥٠ ص ١٢١٢.

(٤) د. السنهوري: المرجع السابق، ص ٤٩٧، د. الصدة: المرجع السابق، ص ٤٤٦.



محل نزاع فإن الشفعة لا تجوز. فالصلح من التصرفات الكاشفة للحق وليس ناقلاً للملكية. والبدل النقدي لا يمثل قيمة المال وإنما يمثل ما قد يكون للطرفين من حظ في كسب أو خسارة دعوى الملكية.

ولا شفعة كذلك في عقد الهبة حتى ولو كانت مقترنة بتكليف أو عوض نقدي إذ أن ذلك لا يخل بنية التبرع. فالهبة تقوم إلى حد كبير على الاعتبار الشخصي. ولا شفعة في الوصية إذ الملكية تنتقل بناء على تصرف من جانب واحد وتراعى فيها غالباً اعتبارات عائلية وشخصية محضة. ولا شفعة إذا انتقلت ملكية المال بغير تصرف قانوني وبناء على واقعة مادية مثل الميراث والالتصاق والتقادم.

ولما كانت الشفعة لا تجوز إلا في البيع، فقد يلجأ البائع والمشتري إلى ستر البيع في صورة عقد آخر خصوصاً الهبة، وذلك لحرمان الشفيع من الشفعة. وحينئذ يجوز للشفيع أن يثبت الصورية، وأن العقد في حقيقته بيع لا هبة ليتمكن من الأخذ بالشفعة وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات. أما إذا كان العقد الظاهر بيعاً ولكنه يستتر عقداً آخر كالهبة، فقد ثار الخلاف حول مدى حق الشفيع في التمسك بالعقد الظاهر أى البيع حتى يستطيع الأخذ بالشفعة.

استقر قضاء محكمة النقض على أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق في الأخذ بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع سبب الشفعة، ومن ثم لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر. يؤيد ذلك أن مفهوم الغير في قضاء النقض، هو كل من لم يكن طرفاً في العقد أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه^(١) ولا ينحصر في الدائن والخلف الخاص. ومن ثم فإن الشفعة جائزة في الهبة المستترة في صورة البيع، ولا يجوز للمشتري أن يرفض ما يعرضه الشفيع من الثمن الوارد في العقد بدعوى أنه أقل من الثمن الحقيقي، فالشفعة تكون بالثمن

(١) نقض مدني ٢٨-٤-١٩٨٢ طعن رقم ٣٤١ لسنة ٤٩ ق.

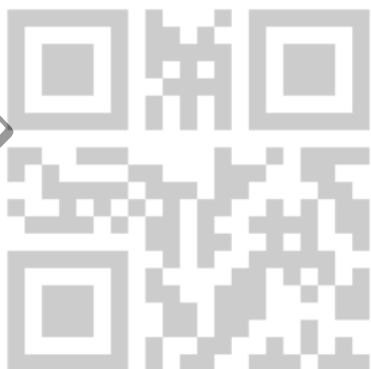


الظاهر الوارد فى العقد دون الثمن الحقيقى الوارد فى العقد المستتر. ولا يجوز أن يحاج بالعقد المستتر فى مواجهة الشفيع إلا إذا كان هذا العقد مسجلاً أو كان الشفيع عالماً بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة الضد وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة^(١). وفى جميع الأحوال يشترط لتمسك الشفيع بالعقد الظاهر أن يكون حسن النية أى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة.

ويجوز الأخذ بالشفعة فى حالة البيع الابتدائى. فالبيع الابتدائى بيع بات والأصل أن يبرم العقد النهائى بنفس شروط العقد الابتدائى. فلا يلزم انتظار الشفيع إلى حين تحرير العقد النهائى بل يمكنه طلب الشفعة منذ البيع الابتدائى وب نفس شروطه ولا يؤثر فى ذلك تغير شروط عقد البيع النهائى. وإذا لم يطلب الشفيع الشفعة فى البيع الابتدائى فيمكنه أن يطلب الشفعة فى البيع النهائى ما لم يكن قد أسقط حقه فى الشفعة بعد البيع الابتدائى. ولكن إذا نزل عن الشفعة فى البيع الابتدائى واختلف الثمن فى البيع النهائى عن البيع الابتدائى بإنقاصه فإن الشفيع يحق له الأخذ بالشفعة. فنزوله عن الشفعة مرتبط بشروط البيع الابتدائى فإذا تم البيع النهائى بشروط أخرى لا يسرى النزول بالنسبة للبيع الأخير^(٢). ومن أهم صور العقد الابتدائى عقد البيع العقارى غير المسجل.

واستقر قضاء محكمة النقض على جواز طلب الشفعة فى البيع العقارى غير المسجل. فلا يلزم لطلب الشفعة أن يكون المشتري قد سجل عقده أى لا يشترط انتقال الملكية من البائع للمشتري لقيام حق الشفيع. فعقد البيع العقارى غير المسجل عقد صحيح مرتب لكافة آثار عقد البيع عدا نقل الملكية. وحق

(١) نقض مدنى ١٩-١-١٩٥٣ المجموعة ١ لسنة ٤ رقم ٥٩ ص ٤١١، ٣٠-١٢-١٩٦٥، المجموعة السنة ١٦ رقم ٢١٧ ص ١٣٨٤.
(٢) د. السنهورى: الوسيط ح ٩ ص ٥٢ ومابعداها.



الشفعة يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً. ولا يشترط في البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون مسجلاً أو ثابت التاريخ^(١).

ويقع على عاتق الشفيع عبء إثبات البيع وأن البيع قد قام بعد أن توافر لدى الشفيع شروط الأخذ بالشفعة وأن البيع ظل قائماً حتى وقت طلب الشفعة. والشفيع يستطيع أن يثبت البيع بكافة طرق الإثبات لأن البيع واقعة مادية بالنسبة له لأنه من الغير بالنسبة لطرفى العقد^(٢).

الفصل الثانى

البيع الذى يشفع فيه عند توالى البيوع

تنص المادة ٩٣٨ مدنى على أنه إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة ٩٤٢، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثانى وبالشروط التى اشترى بها. يستفاد من المادة ٩٣٨ ضرورة التفرقة بين البيع الذى يتم قبل إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة للغير، والبيع الذى يتم بعد ذلك^{2024/2025}.

2024/2025

أولاً : تصرفات المشتري قبل إعلان الرغبة أو قبل تسجيل الرغبة:

للمشتري الحرية فى إجراء التصرفات التى يراها بالنسبة للمال الذى اشتراه. فاحتمال طلب الأخذ بالشفعة من جانب الشفيع لا يقيد من حرية المشتري فى التصرف فى المال. فللمشتري أن يبيع المال إلى شخص آخر، وأن يرتب عليه حقاً عينياً كالرهن، وله أن يهبه أو يقايض به أو يقدمه حصة عينية فى شركة.

فإذا تمت التصرفات السابقة قبل إعلان الشفيع لرغبته فى الأخذ بالشفعة، سواء لعدم علمه بالبيع أو بالرغم من علمه، أو إذا تمت بعد إعلان

(١) نقض مدنى ١٢-٢-١٩٨٠ طعن رقم ٣٥٢ لسنة ٤٦ ق ص ٤٨١.
(٢) نقض مدنى ٢٨-٤-١٩٩١ طعن رقم ٢٥٥٤ لسنة ٥٦ ق.

الرغبة فى الأخذ بالشفعة ولكن قبل أن يتم تسجيلها، فإن هذه التصرفات تنفذ فى مواجهة الشفيع. فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان. ويترتب على سريان هذه التصرفات فى حق الشفيع أنه إذا كان التصرف الذى أجراه المشتري مازال يفتح الباب فى الأخذ بالشفعة أمام الشفيع فإن الأخير لا يستطيع أن يشفع إلا فى البيع الثانى دون البيع الأول. ويكون الأخذ بالشفعة بطبيعة الحال بشروط البيع الثانى الذى قد يختلف عن شروط البيع الأول خصوصاً من حيث الثمن. ويكفى أن يرفع الشفيع دعواه فى مواجهة المشتري الثانى والبائع له، فلا يلزم اختصام البائع الأول^(١).

ولا يكون للشفيع حق الأخذ بالشفعة إلا فى البيع الثانى حتى ولو لم يكن البيع الأول قد سجل^(٢). فيجوز للشفيع أن يطلب الشفعة فى البيع غير المسجل، فبالرغم من أن المشتري الأول لم يصبح بعد مالكاً إلا أن تصرفه بالبيع إلى مشتري ثان يكون صحيحاً فيما بين المتعاقدين. وتكون الشفعة فى البيع الثانى حتى ولو كان المشتري الثانى لم يسجل عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإذا كان البيع الثانى صورياً، فإن للشفيع أن يثبت الصورية ويأخذ بالشفعة فى البيع الأول. وإذا كان حق الشفيع فى الشفعة قد سقط بالنسبة للبيع الأول لسبب أو لآخر، فإن البيع الثانى يفتح له من جديد باب الأخذ بالشفعة، فإذا كان البيع الأول قد تم لقريب حتى الدرجة الرابعة، وباع المشتري إلى

(١) نقض مدنى ٥-٥-١٩٨٢ طعن رقم ١٠٩ لسنة ٤٩ق.

(٢) فى هذا قضت محكمة النقض «لما كان بين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى ١٩٧٣/٤/٢٨ وكان المطعون عليهما قد اخطراه فى ١٩٧٣/٥/٥ بحصول البيع الثانى فإن الحكم إذا اعتد بهذا العقد والثمن الوارد به فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس».



شخص أجنبي عنه، فيحق للشفيع طلب الشفعة في البيع الثاني بالرغم من أنه كان يمتنع عليه الأخذ بالشفعة في البيع الأول.

ثانياً : تصرفات المشتري بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة:

إذا كان الشفيع قد أبدى رغبته في الأخذ بالشفعة وكان الإعلان قد سجل بعد البيع الأول وقبل البيع الثاني، فإن من حق الشفيع أن يأخذ بالشفعة في البيع الأول، فالبيع الثاني غير نافذ في مواجهته. ولما كان ذلك يفترض أن الشفيع قد بدأ إجراءات الشفعة في البيع الأول بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإنه يستمر في استكمال الإجراءات في البيع الأول ولا يعتد إطلاقاً بالبيع الثاني، فلا يلزم باختصام المشتري الثاني.

ولكن يلاحظ أن ذلك قد تقرر لمصلحة الشفيع ولهذا يجوز له أن يتوقف عن اتخاذ إجراءات الشفعة في البيع الأول، ويبدأ إجراءات جديدة في الأخذ بالشفعة في البيع الثاني إذا كان ذلك من الأفضل له، كما لو كان الثمن في البيع الثاني أقل منه في الأول.

2024/2025

الفرع الثالث

2024/2025

البيع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة

حددت المادة ٩٣٩ مدنى البيوع التي لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة وهى:-

أولاً : البيع الذى يتم بالمزاد العلنى:

البيع الذى يتم بالمزاد العلنى وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون لا تقوم فيه الشفعة منذ البداية. فالبيع بالمزاد العلنى يلغى الشفعة ابتداءً، وذلك على خلاف مسقط الشفعة الذى يلغى الشفعة بعد أن تقوم. والمقصود بالبيع بالمزاد العلنى الذى يمنع الشفعة هو البيع الذى يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانون. وقد



يكون البيع بالمزاد العلنى بيعاً جبرياً بناءً على طلب الدائنين طبقاً لقواعد قانون المرافعات، وقد يكون اختيارياً وفقاً للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧.

وقد يتم البيع بالمزاد طبقاً لقواعد قانون المرافعات إذا كانت قسمة المال الشائع غير ممكنة حيث تحكم المحكمة بيعه بالمزاد العلنى. وقد لا يكون البيع قضائياً وإنما إرادياً استيفاءً لحقوق الخزنة العامة، فالعبرة بضرورة أن يكون البيع بالمزاد العلنى طبقاً لإجراءات رسمها القانون، سواء قانون المرافعات أو غير من التشريعات.

أما البيع بالمزاد العلنى الذى يجريه الأفراد من تلقاء أنفسهم وبدون أن يتم تحت نظر القضاء فهو لا يمنع الشفعة لعدم توافر الضمانات التى توجد فى البيوع الحاصلة أمام القضاء.

والبيع بالمظاريف المغلقة لا يمنع من الأخذ بالشفعة. فهذا النوع من البيوع يتم بناءً على عطاءات سرية ومن ثم لا تتوافر الحكمة فى المنع من الأخذ بالشفعة فى البيع بالمزاد العلنى.

٢٠٢٤/٢٠٢٥ فالشفيع لا يستطيع أن يعرف الثمن الذى عرضه غيره حتى يعرض ثمناً ٢٠٢٤/٢٠٢٥ أعلى للمبيع ومن ثم لا يصح منعه من الأخذ بالشفعة.

والحكمة من منع الأخذ بالشفعة فى البيع بالمزاد العلنى تتمثل فى عدة اعتبارات أولها، البيع بالمزاد العلنى يوفر للشفيع العلم بالبيع ومن ثم يمكنه الدخول فى المزاد، وثانياً، جواز الأخذ بالشفعة فى مثل هذه البيوع يؤدى إلى إحجام الناس عن التقدم للمزايدة، والمنع من الشفعة يؤدى إلى الإقبال على الدخول فى المزاد ومن ثم التوصل لأعلى ثمن ممكن. ثالثاً، دخول الشفيع المزاد العلنى يؤدى إلى عرضه لثمن أعلى من غيره وذلك حتى يرسو عليه المزاد وهذا يحقق مصلحة البائع دون إضرار بالشفيع (١).

(١) د. السنهورى: الوسيط، ج ٩ ص ٥٣٣، د. منصور مصطفى: المرجع السابق، ص ٣٣٤.

ثانياً : البيع بين الأقارب:

لا شفعة إذا وقع البيع بين الأصل والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

والعلة في المنع هي أن الصلة التي تربط البائع بالمشتري كثيراً ما تؤثر في شروط البيع، بل قد تكون هي التي أدت بالبائع إلى البيع بحيث لولاها لما باع أو لما باع إلا بشروط أخرى. ويمنع الأخذ بالشفعة حتى لو كان الشفيع قريباً آخر من نفس درجة المشتري أو من درجة أعلى. فالاعتبارات الشخصية التي سيطرت على الصفقة تحول دون أخذ أى شخص آخر غير المشتري للمبيع. فقصر المنع من الأخذ بالشفعة في حالة البيع لقريب إلى درجة معينة ترجع إلى أن اعتبارات المجاملة وعائلية الصفقة أو الاعتبار الشخصي.

والفئات أو الأقارب الذين يتمتع الأخذ بالشفعة منهم هم: الأصول والفروع، فالبيع الذي يتم من الأصل للفرع مهما نزل، ومن الفرع للأصل مهما علا، يمنع من الأخذ بالشفعة، فلا يستلزم المشرع أن يكون الأصول أو الفروع ^{المؤقتة/2025} ^{المؤقتة/2025} وكذلك بيع الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. وبالنسبة للأقارب فإنه يمنع الأخذ بالشفعة في البيع الذي يتم بين أقارب لغاية الدرجة الرابعة.

ثالثاً : بيع العقار بقصد جعله محلاً للعبادة :

لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع لجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة كأن كان المشتري يقصد بشراء الأرض إقامة مسجد عليها أو توسعة مسجد قائم. ويحيط النص بمجال العبادة للأديان السماوية المعروفة ولا يقتصر على الدين الإسلامى، ولكن لا يشمل المنع بيع العقار لإقامة مستشفى خيرى أو ملجأ أو مؤسسة اجتماعية أخرى. فيجب أن يكون الغرض هو إقامة مكان لممارسة الشعائر الدينية دون غيرها ولكن يعتبر فى حكم دار العبادة الملحقات التى لا غنى عنها لحسن قيام الشعائر وممارستها مثل إقامة

مكان للوضوء باعتباره ضرورة لممارسة الشعائر. والعبرة بالغرض الأساسي من الشراء، فإذا اختلط غرض إقامة دار للعبادة مع غرض آخر. كانت العبرة بالغرض الأساسي دون الغرض الثانى. فمن يشتري أرضاً لإقامة عمارة سكنية ويقيم فى الدور الأرضى زاوية أو مسجداً صغيراً فإن القصد من الشراء لا يكون إقامة دار للعبادة، أما من يشتري أرضاً لإقامة دار للعبادة ويلحق بها مسكناً خاصاً لخدام الدار أو المسئول عنها فإن الشفعة لا تجوز.

المطلب الثالث

إجراءات الشفعة

نظم المشرع الطريقة التى يجب على الشفيع سلوكها إذا ما أراد الأخذ بالشفعة فى المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٤. فأوجب على الشفيع أن يعبر عن رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ميعاد قصير، كما أوجب عليه أيضاً أن يودع الثمن الذى تم به البيع خزانة المحكمة، وأن يرفع بعد ذلك الدعوى ويقيدها فى مواعيد قصيرة. والغرض من تحديد هذه المواعيد البالغة القصر وإخبار الشفيع بالوقت الذى عليه الالتزام بها هو أن يتحدد مركز المشتري للعقار المشفوع فيه، وألا يكون عرضة لمطالبة الشفيع مدة طويلة حتى تستقر المراكز القانونية.

الفرع الأول

إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة

تنص المادة ٩٤٠ من القانون المدنى على أنه «على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه البائع أو المشتري، وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك».

عادة ما تتفتح إجراءات الأخذ بالشفعة بهذا الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع، وإذا تعدد الشفعاء ولو كانوا من طبقة واحدة وجب أن يوجه الإنذار إليهم جميعاً، ويسمى هذا الإنذار بالإنذار بوقوع البيع،

وبه يخبر البائع أو المشتري الشفيع بوقوع البيع ليتسنى له أن يحدد موقفه منه إن شاء أخذ بالشفعة وإن شاء ترك.

ويجب أن يكون الإنذار رسمياً أن يتم على يد محضر، ولا يغنى عنه الكتاب المسجل ولو كان مصحوباً بعلم الوصول^(١). ويجب أن يشتمل هذا الإنذار على بيان بالعقار الجائر أخذه بالشفعة بياناً كافياً، وأن يتضمن بيانها بالثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم موطن كل من البائع والمشتري، وإلا كان الإنذار باطلاً (م ٩٤١ مدنى). ولا يفتح به ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة.

إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة :

متى أُنذر الشفيع إنذاراً مستوفياً لشروطه، وأراد الأخذ بالشفعة فعليه أن يعبر عن رغبته فى الأخذ بها. ويجب أن يتوافر فى هذا الإعلان عدة شروط حتى يكون صحيحاً.

الشرط الأول : يجب أن يكون إعلان الرغبة رسمياً وإلا كان باطلاً:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ورسمية الإعلان تقتضى إتمامه على يد محضر، فلا يغنى عن الرسمية أن يتم هذا الإعلان بكتاب مسجل ولو كان مصحوباً بعلم الوصول، ومعنى ذلك أن إعلان الرغبة - شأنه شأن إنذار الشفيع - يجب أن يتم بورقة من أوراق المحضرين، فلا يكفى أن يقع شفويّاً أو بخطاب ولو مسجل ويترتب على وقوع الإعلان بغير الطريق الرسمى بطلانه أى اعتباره كأن لم يكن^(٢).

(١) «علم الشفيع بالبيع عدم ثبوته إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه إليه البائع أو المشتري عدم سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار لا عبارة بعلمه بأية ورقة أخرى» نقض مدنى ٢٨-٤-١٩٨٧ طعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٥٦ ق.

(٢) «الشفيع وجوب إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره بحصول البيع أو خلال الأربعة أشهر التالية لتسجيله. لا يغنى عن وصول الرغبة فى هذا الميعاد مجرد إيداع صحيفة دعوى

الشرط الثاني: أن يوجه إعلان الرغبة إلى كل من البائع والمشتري:

فعلى كل من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري فإذا أعلن أحدهما دون الآخر سقط حقه في الشفعة وإذا أعلن أحدهما برغبته في الميعاد والآخر بعد الميعاد سقط حقه في الأخذ بالشفعة. ويلاحظ أن الإعلان يكون غير واجب إذا رفع الدعوى في خلال الخمسة عشر يوماً المقررة لإعلان الرغبة لأن القانون لا يوجب الفصل ما بين إعلان الرغبة ورفع الدعوى فيصح إن أن يجمع الشفيع بين إعلان الرغبة وصحيفة الدعوى وعندئذ يقوم إعلان صحيفة الدعوى كل من البائع والمشتري في الميعاد السابق مقام إعلان الرغبة الرسمي (١).

والعلة في توجيه طلب الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري هو أن كلاً من المشتري والبائع خصم في دعوى الشفعة إذا أخذت بالتقاضى، وطرف فيها إذا تمت بالتراضى. فالشفيع إذا ثبت له الحق في الشفعة يحل محل المشتري في مواجهة البائع فيكون له حقوق المشتري قبل البائع وعليه التزاماته نحوه ومن ثم كان طرفاً في الشفعة والطرف الآخر هو كل من المشتري والبائع (٢).

الشرط الثالث: أن يتم إعلان الرغبة في الميعاد القانوني:

عملاً بنص المادة ٩٤٠ مدنى فإن الحق في الأخذ بالشفعة يسقط إذا لم يعلن الشفيع رغبته في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإنذار الرسمي الموجه إليه من البائع أو المشتري ويزاد عليها عند الاقتضاء ميعاد المسافة. ويحسب هذا الميعاد وفقاً للقواعد العامة فلا يدخل فيه اليوم الذى يسلم فيه الإنذار الرسمي إلى الشفيع ولكن يدخل فيه اليوم الأخير فينقضى الميعاد بانقضائه إلا

الشفعة قلم الكتاب وجوب إعلانها إلى كل من البائع والمشتري خلالها». نقض

مدنى ٢٤-٢-١٩٨٥ طعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٥٤ ق.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى: المرجع السابق، ص ٤٦٩.

(٢) د. السنهورى: الوسيط ح ٩ ص ٦٢٩.



إذا وقع اليوم الأخير في عطلة رسمية حينئذ يمتد الميعاد إلى أول يوم بعد هذه العطلة وتطبق في الجملة على هذا الميعاد القواعد التي جاءت في تقنين المرافعات لإعلان أوراق المحضرين.

بيد أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي ينتهي عند ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يفترض بالضرورة وحتماً أن يتم إنذار الشفيع بحصول البيع المشفوع فيه. فإذا لم ينذر أى من البائع أو المشتري الشفيع بحصول البيع، فعلى الشفيع أن يعبر عن رغبته في الأخذ بالشفعة على النحو السابق بيانه خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع المشفوع فيه، سواء كان الشفيع حاضراً أم غائباً (المادة ٩٤٨/ب مدنى). فما دام أن الشفيع لم ينذر فإن حقه في طلب الشفعة لا يسقط إلا إذا مضت أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع. إلا أن فوات مدة أربعة أشهر من تاريخ التسجيل يؤدي إلى سقوط الحق في طلب الشفعة حتى ولو لم يعلم الشفيع فعلاً بالبيع. فعدم العلم ينسب إلى حد كبير إلى خطأ وإهمال الشفيع (١).

2024/2025

وإذا لم يكن البيع قد سجل، فلا يسقط حق الشفيع في المطالبة بالشفعة 2024/2025 إلا بمرور خمسة عشر سنة على وقت إبرام البيع المشفوع فيه تطبيقاً للقواعد العامة. ويلاحظ أن مدة الخمسة عشر يوماً أو الأربعة أشهر، وهي المدة التي يجب على الشفيع أن يعبر فيها عن رغبته في الأخذ بالشفعة، تعتبر مدة سقوط لا مدة تقادم، إذ أنها مدة حتمية يحب على الشفيع فيها أن يعلن عن رغبته في الأخذ بالشفعة وإلا سقط حقه فيها، ومن ثم فإن هذه المدة لا تقبل الوقف أو الانقطاع.

ويلاحظ أن تسجيل إعلان الرغبة ليس إجراءً من إجراءات الشفعة. فلا يلزم لطلب الشفعة أن يكون الإعلان قد سجل. وإنما يستهدف التسجيل جعل إعلان الرغبة حجة على الغير. فهو إجراء مقرر لمصلحة الشفيع ضد

(١) نقض مدنى ١٣-١٢-١٩٨١ طعن رقم ٢٠٣٣ لسنة ٥٠ق، نقض مدنى ٢٢-١٩٩٠-١٩٩٠ طعن رقم ١٠٨٨ لسنة ٥٨ق.

التصرفات التي يجريها المشتري على العقار المشفوع فيه. ولهذا فإن من مصلحة الشفيع المبادرة إلى تسجيل إعلان الرغبة عقب إعلانه مباشرة إلى البائع والمشتري حتى لا يتح الفرصة أمام المشتري للتصرف في العقار إلى شخص حسن النية لا يعلم بإبداء الرغبة^(١).

الفرع الثاني

إيداع الثمن

تنص المادة ٩٤٢ من القانون المدني في فقرتها الثانية على أن «وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزنة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة».

يستفاد من النص السالف أن بعد إبداء الشفيع لرغبته في الأخذ بالشفعة يجب عليه أن يودع خزنة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته وإلا سقط حقه. فالإيداع هو الإجراء التالي لإعلان الرغبة.

والإيداع يستهدف التأكد تماماً من قدرة الشفيع على الوفاء بالثمن وذلك حتى لا يفاجأ المشتري أو البائع بإعسار الشفيع. كما أن الإيداع لكامل الثمن يعتبر مظهراً من كظاهر التضييق في الشفعة حتى لا يفتح الباب إلا أمام الشفيع القادر خلال فترة وجيزة من إعلان رغبته. فضلاً عن أن تجريد الثمن المودع إلى حين الانتهاء من الفصل في دعوى الشفعة يؤدي للتأكد من جدية الشفيع وإصراره على الأخذ بالشفعة.

(١) د. الصدة: ص ٤٧٤، د. السنهوري: ج ٩ ص ٦٤٧.

ويجب أن يتم الإيداع خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، وقبل رفع الدعوى. ويبدأ سريان الميعاد من تاريخ آخر إعلان للرغبة إذا اختلف تاريخ إعلان المشتري عن تاريخ إعلان البائع^(١).

والذى يجب إيداعه هو الثمن الحقيقي فقط. والأصل هو أن الثمن المذكور فى العقد هو الثمن الحقيقي المتفق عليه بين البائع والمشتري فى عقد البيع. ولكن قد يكون الثمن المذكور فى العقد صورياً كأن يذكر فى عقد البيع ثمناً أكبر من الثمن الحقيقي منعاً للشفيع من الأخذ بالشفعة، فيكون للشفيع هنا الخيار بين أمرين: إما أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن المذكور فى عقد البيع وله بعد ذلك إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، وإما أن يودع ما يعتقد أنه الثمن الحقيقي للبيع، ويتعرض بعد ذلك لسقوط حقه فى الشفعة إذا عجز عن إثبات صورية الثمن.

وقد يذكر المتعاقدين فى البيع ثمناً أقل من الثمن الحقيقي رغبة منهما فى التحايل مثلاً على قيمة رسوم التسجيل الواجب أدائها فيما لو ذكر فى العقد الثمن الحقيقي للبيع، وهنا فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن للشفيع أن يتمسك بالثمن الظاهر باعتبار أنه من الغير شريطة أن يكون حسن النية معتقداً بجدية الثمن الظاهر^(٢).

ويجب على الشفيع إيداع الثمن الحقيقي كاملاً ولو كان الثمن مؤجلاً. فالشفيع لا يستفيد بحسب الأصل من أجل الوفاء الممنوح للمشتري. فإيداع الثمن الحقيقي شرط لقبول دعوى الشفعة، ولا يملك البائع إعفاء الشفيع من

(١) «إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة فى الميعاد وقبل رفع الدعوى إجراء من إجراءات الدعوى مخالفة ذلك أثره سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة». نقض مدنى ٢٥-١٠-١٩٨٨ طعن رقم ١٠٧١ لسنة ٥٥ق.

(٢) «الثمن الواجب على الشفيع إيداعه هو الثمن الحقيقي م ٩٤٢ مدنى - الشفيع الطعن بصورية الثمن المسمى بالعقد وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات تمكنه من ذلك أثره - تحقق الإيداع المفروض عليه قانوناً». نقض مدنى ٧-٤-١٩٨٨ طعن رقم ٣٤٢ لسنة ٤٥ق.

شرط أوجبه القانون. ولا يتعارض ذلك مع ما ورد في المادة ٢/٩٤٥ من أنه يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري من دفع الثمن برضاء البائع. ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع في الشفعة رضاء أو قضاء، وحيث يصبح الثمن من حق البائع وحده. أما قبل ذلك فلا يحق للبائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون لقبول الدعوى^(١).

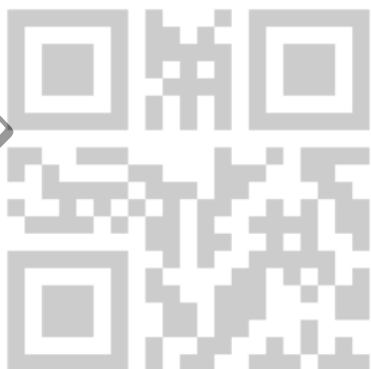
أما إذا كان الشفيع لم يتم إنذاره بالبيع، ولم يسجل العقد، فليس أمامه بالتالي من سبيل لمعرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع، وهنا نجد محكمة النقض - بما ينطوي على عدول عن قضائها السابق^(٢) - بأنه يجوز للشفيع إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع، على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع^(٣). وهذا القضاء يفتح الباب أمام الشفيع ليأخذ دوراً هجومياً في طلب الشفعة بمجرد علمه بالبيع والذي قد يستدل عليه من العديد من المظاهر المادية والتي يحق له إثباتها بكافة الطرق. فالبيع بالنسبة للشفيع واقعة مادية باعتباره من طائفة الغير في عقد البيع. ولم يعد الجهل بالثمن يهدده بسقوط الشفعة إذ فتح أمامه باب تكملة الثمن أثناء الدعوى على خلاف ما هو مقرر في حالة إيداع الثمن الظاهر متى يثبت أن الثمن الحقيقي يزيد عنه.

ويترتب على عدم الإيداع في الميعاد المحدد سقوط الحق في الشفعة، وللمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها بل وحتى لو نزل عنه صراحة صاحب الحق في التمسك به. فأسباب السقوط تتعلق بالنظام العام لأنها من

(١) نقض مدني ٧-١١-١٩٦٣ المجموعة السنية ١٤ ص ١٠١١، رقم ١٤٤.

(٢) «مبادرة الشفيع برفع دعوى الشفعة اعتماداً على علم تلقائي دون انتظار انذار الرغبة من البائع أو المشتري وقيامه بإيداع ما ظنه الثمن الحقيقي يجعله مجازفاً وعليه حظر الإيداع ظهور نقص الإيداع يعرض حقه للسقوط». نقض مدني ١٠-٢-١٩٥٥ طعن رقم ٥٤ لسنة ٢٢ق.

(٣) نقض مدني ٢٩-١٢-١٩٨٣ منشور في عزت حنورة ص ٢٥٧.



قبيل التوفيق بين رأى المعارض للإبقاء على الشفعة والرأى الذى يؤيد الإبقاء عليها. فهو لم يتقرر لمصلحة طرف وإنما من أجل المصلحة العامة^(١).

الفرع الثالث

رفع دعوى الشفعة

تنص المادة ٩٤٣ مدنى على أنه «ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة».

يتضح من النص السالف أن المدعى فى دعوى الشفعة هو الشفيع. ويلزم أن يتوافر فيه أهلية التصرف حتى يمكنه رفع الدعوى بنفسه، فالشفعة من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة. وإذا كان الشفيع غير كامل الأهلية فإن الدعوى ترفع من قبل الولي أو الوصى طبقاً للأحكام المقررة فى مسائل الولاية على المال. والمدعى عليه هو كل من البائع والمشتري، ولهذا يجب رفع الدعوى على كل منهما خلال المدة المحددة فى المادة السابقة، لأن الحكم بالشفعة يمس كل من البائع والمشتري ولهذا فإنه من الطبيعى اختصاصهما معاً فى دعوى الشفعة. ويسرى ذلك على كافة درجات التقاضى وفى الطعن بالنقض^(٢).

2024/2025

(١) د. السنهورى: الوسيط حـ٩ رقم ٢١٦ ص ٦٦٨، نقض مدنى ١٩٧٨/٦/٢٨ ص ١٥٩٥، نقض مدنى ١٩٨٠/١٢/٢ طعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٤٩ق، نقض مدنى ١٩٨٥/١٠/٣٠ طعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٤٩ق، نقض ١٩٨٨/١٠/٢٥ طعن رقم ١٠٧١ لسنة ٥٥ ق حيث ذهبت المحكمة إلى «إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة فى الميعاد وقبل رفع الدعوى إجراء من إجراءات الدعوى مخالفة ذلك أثره سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة».

(٢) دعوى الشفعة وجوب اختصاص الشفيع والبائع والمشتري فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض تعدد أى منهم يوجب اختصاصهم جميعاً. كما يوجب اختصاص ورثة من يتوفى منهم - مخالفة ذلك أثره عدم قبول الدعوى». نقض مدنى ٤-٥-١٩٨٨ طعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٥٤ق.

ويجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيع أن يستعمل حقه قبل المشتري الثانى متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد قتم قبل صيرورة إعلان الرغبة حجة على الغير.

إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة خلال الميعاد المحدد فإن حق الشفيع لا يسقط فيتربط على رفع الدعوى فى الميعاد ترتيب آثار المطالبة القضائية ومنها قطع مدة التقادم. ولقد جرى العمل فى القضاء على امتداد ذلك إلى مدة السقوط طالما أن الدعوى رفعت فى الميعاد أمام محكمة غير مختصة. ويبقى الانقطاع قائماً إلى أن يصدر الحكم بعدم الاختصاص، ويزول الانقطاع بصور هذا الحكم بحيث يجب على الشفيع أن يرفع دعوى من جديد أمام المحكمة المختصة خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص وإلا سقط حقه فى الشفعة^(١).

ويجب أن ترفع الدعوى بعد إيداع الثمن خزانة المحكمة بإيداع الثمن شرط لقبول دعوى الشفعة. ولم يكتف باليداع ورفع الدعوى خلال ٣٠ 2024/2025 يوماً من إعلان الرغبة بل استلزم أن يتم الإيداع قبل رفع الدعوى. وعلى هذا لا تقبل الدعوى إذا ما رفعت قبل إيداع الثمن حتى ولو تمكن الشفيع من إيداع الثمن قبل انقضاء المهلة. فالإيداع اللاحق يسقط الحق فى الشفعة، والإيداع المسبق شرط لقبول الدعوى. على أن أسبقية الإيداع قبل رفع الدعوى لا تعنى ضرورة وجود فاصل زمنى معين بينهما، فلا يلزم على وجه الخصوص أن يكون الإيداع فى اليوم السابق على رفع الدعوى.

(١) نقض مدنى ١٧-٢-١٩٨٢ طعن رقم ٤٩١ لسنة ٤٩ق.



المطلب الرابع آثار الشفعة ومسقطاتها

تنص المادة ٩٤٥ مدنى على «١- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري فى جميع حقوقه والتزاماته. ٢- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري فى دفع الثمن إلا برضاء البائع. ٣- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع. يتضح من هذا النص أن أطراف الشفعة ثلاثة، الشفيع، والمشتري، والبائع. والشفعة تنتج آثاراً بين هؤلاء الأطراف جميعاً.

الفرع الأول آثار الشفعة

أسلفنا أن للشفعة آثاراً بين أطرافها الثلاثة (الشفيع - المشتري - البائع) وسوف نعرض على التوالى العلاقة بين كل من هذه الأطراف، كل فى غصن مستقل.

الغصن الأول

2024/2025

علاقة الشفيع بالمشتري

2024/2025

نظمت المادة ٩٤٥ مدنى علاقة الشفيع بالمشتري حيث نصت على حلول الشفيع محل المشتري فى جميع حقوقه والتزاماته كما وردت تماماً فى العقد المبرم بين البائع والمشتري. فإن كان عقد البيع قد أوجب على المشتري التزامات خاصة فإن الشفيع يلتزم بها. لأن الحلول فى العقد بشروط تماماً يعتبر المقابل لحرمان المالك من اختيار المتصرف إليه، وحتى لا تكون الشفعة مصدرراً للإضرار بالبائع، فيجب أن يحصل البائع على نفس الأداء والمزايا التى كان يخولها له العقد المبرم مع المشتري (١).

ويترتب على الحلول أن البائع يستطيع أن يتمسك فى مواجهة الشفيع بكافة الدفوع التى كان يستطيع أن يتمسك بها فى مواجهة المشتري مثل بطلان

(١) د. السنهورى: الوسيط ح ٩ ص ٧٥٨ هامش ٣ والأحكام التى أشار إليها.



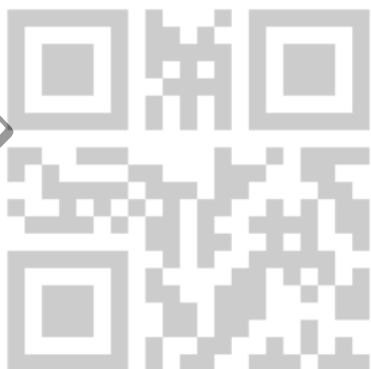
البيع بسبب الغلط أو غير ذلك. كما يستطيع أن يتمسك في مواجهته بالفسخ أو بالدفع بعدم التنفيذ في حالة عدم تنفيذ التزام من الالتزامات التي يفرضها العقد على عاتق المشتري.

وقت الحلول ، يذهب الرأي الراجح في الفقه والذي تزعمته محكمة النقض^(١) إلى أن الشفيع يحل محل المشتري من وقت صدور الحكم له بثبوت حقه في الشفعة. ولما كانت الملكية في العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل فإن الملكية لا تنتقل إلى الشفيع إلا منذ تسجيل الحكم النهائي بثبوت الشفعة. أما باقى الحقوق والالتزامات فإنها تنتقل إلى الشفيع من وقت صدور الحكم وقبل تسجيله.

ويستند القضاء المصرى المستقر إلى أن عبارة «سندا» لملكية الواردة في نص المادة ٩٤٤ مدنى «الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع». يقصد بها السند القانونى المنشئ لحق الملكية ولا يقصد به دليل الملكية وحجيتها. ومتى كان حكم الشفيع فى نظر القانون هو سبب ملكية الشفيع ومنشئها، فإن مقتضى هذا النظر ولازمة ألا يصير المشفوع فيه إلى ملك الشفيع إلا بعد الحكم، أما قبله فلا، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه^(٢)، ولأن ما جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضى. ولهذا فإن حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع لا كاشف له. ولا يعتبر ذلك افتتاتاً على القاعدة التى تقضى بأن الأحكام مقررّة لا منشئة للحقوق، فالمشرع نفسه هو الذى جعل حكم الشفعة منشئاً لحق الشفيع، ولا مفر من النزول على رغبة المشرع فى استثناء حكم الشفعة من قاعدة أن الأحكام كاشفة لا منشئة.

(١) نقض مدنى ٣١-١٠-٩٤٦ طعن رقم ٨٥ لسنة ١٥ق، نقض مدنى ١٤-٥-١٩٥٩ طعن رقم ٩٢ لسنة ٢٥ق، نقض ١٣-٣-١٩٨١ طعن رقم ٧٨١، ٩٥٢ لسنة ٤٩ق.

(٢) نقض مدنى ١٩-١-١٩٨٤ طعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٤٩ق.



نخلص من ذلك أن الحكم بالشفعة ليس فقط سنداً لملكية الشفيع، وإنما يعتبر سنداً لكافة حقوق والتزامات الشفيع. ولا يقدح في هذا أن تصرفات المشتري التي تمت قبل إعلان الرغبة تسرى في حق الشفيع، وتلك التي تتم بعد إبداء الرغبة تكون غير نافذة في حق الشفيع، لأن نص المادة ٩٣٨ تستهدف حماية الشفيع من تصرفات المشتري سئ النية إذا ما ثبتت أحقية الشفيع في طلب الشفعة. فلا يجوز الخلط بين عدم نفاذ التصرفات وتاريخ انتقال الملكية واكتساب الحقوق^(١). فالمشرع يملك أن يقرر الحماية في لحظة سابقة على اكتساب الحق، ولو كانت الملكية تثبت للشفيع منذ البيع لما كانت هناك حاجة للمادة ٩٣٨ مدني.

عدم انتفاع الشفيع بالأجل الممنوح للمشتري. تنص المادة ٢/٩٤٥ على أنه «إنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع» ولقد جاءت تلك الفقرة استثناء على قاعدة حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. والحكمة من هذا الاستثناء أن البائع يمنح المشتري أجلاً بسبب ثقته فيه أو لاعتبارات شخصية بينهما قد لا تتوافر في الشفيع. ولو قبل البائع اعطاء الشفيع الأجل الذي كان قد منح للمشتري، فإن ذلك لا يخل بالتزام الشفيع بإيداع الثمن كاملاً قبل رفع الدعوى. ولكن منح الأجل يكون بعد صدور الحكم بالشفعة عن طريق قبض البائع للثمن من خزانة المحكمة ثم تسليمه إلى الشفيع، أو أن يخول البائع الشفيع في سحب المبلغ المودع ليقوم بعد ذلك بالوفاء بالثمن طبقاً لما اتفق عليه^(٢).

حقوق المشتري في حالة البناء أو الغراس على المال المشفوع فيه. إذا كان المشتري قد أقام بناء أو غراس على المال المشفوع فيه فإن المشرع قد فرق في الحكم قبل إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو بعده.

(١) د منصور مصطفى منصور: رقم ١٥٢ ص ٣٦٠.

(٢) د السنهوري: الوسيط ح ٩ ص ٧٥٥، نقض مدني ٢٩-١-١٩٧٦، طعن رقم ٧١٨ لسنة ٤١ ق.

الفرض الأول : حصول البناء أو الغراس قبل إعلان الرغبة فى الشفعة، وهنا نجد المادة ١/٩٤٦ تنص على أنه «إذا بنى المشتري فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له، أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس، فالخيار للمشتري فيختار أكبر القيمتين^(١)».

الفرض الثانى: حصول البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة، وهنا نجد المادة ٢/٩٤٦ تنص على «أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزالة، فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس». ويلاحظ أنه فى هذه الحالة يتساوى المشتري مع الحائز سبب النية. فإذا استبقى الزيادة، يلتزم الشفيع بأن يدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس^(٢).

الفصل الثانى

علاقة الشفيع بالبائع

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يحل الشفيع كما أسلفنا محل المشتري فى علاقته بالبائع ويتحمل البائع فى مواجهة الشفيع بكافة الالتزامات التى كان يتحمل بها فى مواجهة المشتري. والبائع ضامن للشفيع فى كل ما يحدث له من تعرض واستحقاق، كما يضمن أيضاً خلو المبيع من العيوب الخفية. فعلى البائع أن ينقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع، وأن يقوم بكل ما هو لازم لنقل الملكية إليه. كما يجب على البائع أن يسلم العقار المشفوع فيه إلى الشفيع، وهذا يفترض بالضرورة أن يكون العقار المشفوع فيه تحت يد البائع ولم يسلمه للمشتري. وعليه أن يسلمه بحالته التى كان عليها وقت البيع، وبنفس المقدار ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وليس هذا سوى تطبيق للقواعد المنصوص عليها فى عقد البيع (مادة ٤٣١ مدنى).

(١) نقض مدنى ٢٧-١-١٩٨٢ طعن رقم ٤٢٨ لسنة ٤٤ ق.
(٢) نقض مدنى ١٥-٧-١٩٩١ طعن رقم ٢٢٦٢.

وإذا هلك العقار المشفوع فيه بعد تسلم الشفيع له، فإن تبعة الهلاك تقع على عاتق الشفيع إذ يربط المشرع بين تبعة الهلاك والتسليم.

وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع (م ٩٤٥/٣ مدنى). فالبائع ملزم فى مواجهة الشفيع بضمان التعرض والاستحقاق. فإذا استحق المبيع (العقار المشفوع فيه) من تحت يد الشفيع، فلهذا الأخير أن يرجع على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق. وله مطالبته بالتعويض.

والبائع ضامن لتعرض هو سواء كان هذا التعرض مادياً أو قانونياً فمن وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. وهو ضامن لتعرض الغير القانونى ولكنه لا يضمن التعرض المادى الصادر من الغير. فضلاً عن ذلك يلتزم البائع أيضاً فى مواجهة الشفيع بضمان خلو العقار المشفوع فيه من العيوب الخفية.

أما فيما يتعلق بالتزامات الشفيع فى مواجهة البائع فإذا تمت الشفعة اتفاقاً، وجب على الشفيع أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه فى عقد البيع. وأما إذا تمت الشفعة قضائياً. وهذا هو الفرض^{2024/2025} الغالب - فالواجب على الشفيع أن يودع الثمن خزانة المحكمة فى مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة. وما على البائع بعد أثبتت الشفعة للشفيع إلا أن يسحب الثمن المودع من خزانة المحكمة.

الفصل الثالث

علاقة الشفيع بالغير

تنص المادة ٩٤٧ مدنى على أنه «لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو إى حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أى بيع صدر من المشتري ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمار العقار».

تفرق هذه المادة بين التصرفات الحاصلة قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة والتصرفات الحاصلة بعد تسجيل إعلان الرغبة.

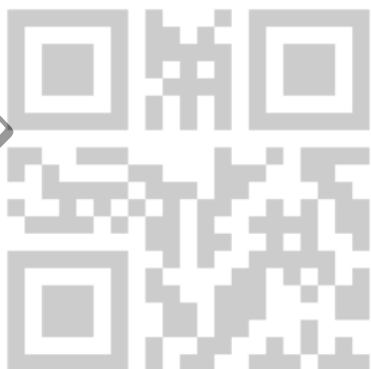
بالنسبة للتصرفات الحاصلة قبل تسجيل إعلان الرغبة فإن المشتري إذا تصرف في هذه الفترة أو اكتسب الغير على العقار حقاً عينياً كرهن أو اختصاص أو ارتفاق فإن الحق يكون قد ترتب على عقار يملكه المشتري. ومن ثم فإن التصرف صحيح ويحتج به على الشفيع ويشترط لذلك أن تكون السندات المنشئة لهذه الحقوق قد أشهرت وفقاً للقانون أى سجلت أو قيدت قبل تسجيل إعلان الرغبة.

ويلاحظ أنه يجب أن يتم إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشتري الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الصادر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه فى دعوى الشفعة^(١)، مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً فى الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التدخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية وبصودر حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثانى تصح إجراءات طلب الشفعة فى البيع الأول^(٢).

أما التصرفات الحاصلة بعد تسجيل إعلان الرغبة فعملاً بنص المادة ٩٤٧ مدنى فإنه لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أى بيع صدر من المشتري ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان

(١) «لا يحق للشفيع ان يتحلل من واجب إدخال المشتري الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفعة»
نقض مدنى ٢٨-٥-١٩٨١ طعن رقم ٣٧١ لسنة ٤٨ ق.

(٢) نقض مدنى ١١-٣-١٩٨٢ طعن رقم ٨٤٠ لسنة ٤٩ ق.



الرغبة فى الشفعة وذلك لأن الشفيع فى هذه الحالة يكون قد حفظ حقه بتسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة.

الفرع الثانى

أسباب سقوط الحق فى الشفعة

للشفعة أسباب تسقط بها، على أنه يجب أن يلاحظ أنه لا يجوز الخلط بين مسقطات الشفعة وموانعها، والمانع من الشفعة يلغى الحق فيها ابتداء، والموانع لا تنقر إلا بنص القانون، أما مسقطات الشفعة فإنها تلغى الحق فيها بعد ثبوته أو حتى قبل ذلك. ولكنها تنقر إما بالاتفاق، أو تقع بسبب عدم القيام بإجراء من إجراءاتها فى الميعاد الذى نص عليه القانون.

وقد نصت المادة ٩٤٨ مدنى على الأسباب التى يسقط بها الحق فى الشفعة بقولها: يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

الحالة الأولى : تنازل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع:

نصت المادة ٩٤٨ مدنى على أن حق الشفيع يسقط إذا نزل عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. فالنزول عن الحق فى الشفعة جائز. وهو جائز فى أى وقت حتى صدور الحكم النهائى بالشفعة، فمتى صدر الكم النهائى ثبت للشفيع الحق فى ملكية العقار ولا يستطيع الشفيع أن ينزل عن حقه بعد ذلك. إنما قبل الحكم بالشفعة وفى أى مرحلة من مراحل إجراءاتها فإن النزول سائغ. بل أن القانون قد أجاز صراحة النزول عن الشفعة حتى قبل البيع، إذ بذلك يطمئن المشتري وهو مقدم على الشراء أن العقار المبيع لن يخرج عن ملكه إلى ملك المشتري مما يؤدي إلى استقرار التعامل.

والتنازل عن الشفعة كما يكون صريحاً فإنه يكون ضمناً. والتنازل الصريح هو الذى يدل دلالة مباشرة على انصراف إرادة الشفيع إلى التنازل عما له من حق فى طلب الأخذ بالشفعة، كأن يحزر به إقرار ويوثق. أما التنازل



الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة فهو الذى يستدل عليه من ظروف الحال. وإثبات النزول الضمنى يجوز أن يتم بكل الطرق لأنه استنتاج لإرادة النزول بواسطة القرائن المستفادة من واقع الحال. وفى هذا قضت محكمة النقض أن التنازل صراحة أو ضمناً عن استعمال حق الشفعة هو استثناء من الأصل العام عدم جواز التوسع فى تفسيره. فتنازل الشفيع عن حق الشفعة فى البيع الصادر من جاره لا يفيد بذاته أنه تنازل عن استعمال هذا الحق فى البيع الصادر من المشتري إلى الغير^(١).

الحالة الثانية: انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع:

وفقاً لنص المادة ٩٤٨ مدنى فإن حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. ومعنى ذلك أن الشفعة لا يمكن طلبها إذا سجل عقد البيع ومضى على تسجيله أربعة أشهر. والحكمة من ذلك أن ملكية المشتري يجب ألا تظل غير مستقرة مدة طويلة، فحدد المشرع حداً زمنياً أقصى لإعلان الوضعية^(٢) وهى أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع الذى يجيز الشفعة. فإذا لم يكن قد سجل فرفع المشتري على البائع دعوى صحة التعاقد وسجل صحيفتها فإن ميعاد الأربعة أشهر لسقوط حق الشفيع لا يبدأ احتسابه إلا من يوم تسجيل الحكم أو التأشير به لا من يوم تسجيل صحيفة الدعوى^(٣). وقد جعل المشرع اقتضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع قرينة قاطعة على علم الشفيع بالبيع فيسقط حقه حتماً بمجرد انقضاء هذه المدة وهى ميعاد سقوط فلا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع وتسرى فى حق

2024/2025

(١) نقض مدنى ٢٥-٤-١٩٨٢ طعن رقم ١٥١٥ لسنة ٤٨ ق.
(٢) د. عبد المنعم البدرأوى: المرجع السابق، ص ٤٧٨، نقض مدنى ١٣-١٢-١٩٨١ طعن رقم ٢٠٣٣ لسنة ٥٠ ق.





الكافة حتى الغائب وناقص الأهلية، وتحسب من اليوم التالى للتسجيل بالتقويم الميلادى.

الحالة الثالثة: الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون:

١- عدم إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالبيع، على الشفيع إذا ما أنذره البائع أو المشتري بالبيع أن يعلن عن رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً وإلا سقط حقه فى طلب الشفعة.

٢- طبقاً لنص المادة ٢/٩٤٢ يجب على الشفيع أن يودع خزنة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد سقط حق الأخذ بالشفعة وهذا السقوط من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣- طبقاً للمادة ٩٤٣ مدنى ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار ويكون ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة ٩٤٢ مدنى وهو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها.

٤- انقضاء خمسة عشر سنة من وقت البيع إذا كان لم يسجل. إذ لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع فإن حق الشفيع فى الشفعة يظل قائماً ولا يسقط إلا بانقضاء خمسة عشر سنة على البيع ما لم يقم المشتري بتسجيل البيع فيسقط حق الشفيع بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع ولا يحل العلم اليقيني محل الإنذار. ومن ثم فإنه عند تخلف الإنذار يظل للشفيع الحق فى الأخذ بالشفعة لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ البيع الذى لم يسجل.



الحياة

الحيازة هي سلطة أو سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه^(١)، سواء كانت هذه السيطرة أو السلطة تمتد إلى الشئ في كل منفعه ومظاهره، أم كانت تقتصر على بعضها، وذلك بنية مباشرة أو اكتساب حق من حقوق الملكية عليه.

والحيازة على هذا النحو هي مجرد سيطرة فعلية واقعية على شئ بصرف النظر عما إذا كانت في نفس الوقت مستندة إلى حق من الحقوق أم لا، والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق. فإن كان حق ملكية، تكون السيطرة الفعلية عن طريق أعمال مادية هي الأعمال التي يقوم بها المالك في استعماله لحق الملكية، وتتسع الحيازة - في القانون الحديث - لجميع الحقوق العينية (٢)، التي تقبل بطبيعتها هذه الحيازة. ولكن الحيازة إذا كانت تتسع لجميع الحقوق العينية القابلة لها، فإنها لا تتسع لغير الحقوق العينية ولا ترد من ثم على الحقوق الشخصية، غير أنه يستثنى من ذلك الديون الثابتة في سندات لحاملها، إذ

(٢) راجع تطور الحياة ، د. السنهوري: الوسيط ح ٩ ، ص ٧٨٦-٧٨٨ ، د. جمال زكي: ص ٥٠٨.





يندمج الدين فى هذه الحالة فى السند فيعتبر حائز السند حائزاً للحق الثابت فيه.

كذلك لا تتسع الحياة للحقوق التى ترد على الأشياء غير المادية، ولا على مجموعات الأموال، سواء كانت قانونية كالتركات أو فعلية كالمحل التجارى أو المصنف، فهذه الأشياء غير قابلة للحياة.

وسواء كانت الحياة تستند إلى حق الحائز أو لا تستند إلى حق، فالقانون يحميها لذاتها، ويرجع ذلك لاعتبارات الأمن والاستقرار للنظام فى المجتمع، التى تقتضى منع الاعتداء على الأوضاع الواقعية القائمة بالفعل.

وسوف نعرض للحياة فى ذاتها، ثم نبين أثرها فى اكتساب الملكية.

المطلب الأول : الحياة فى ذاتها .

المطلب الثانى : آثار الحياة .

المطلب الأول

2024/2025

الحياة فى ذاتها 2024/2025

2024/2025

تقسيم :

للحياة عنصران أحدهما مادية قوامه الأعمال المادية التى ينطوى عليها استعمال حق من حقوق الملكية التامة أو الناقصة على الشئ، والآخر معنوى قوامه نية الحائز فى القيام بهذه الأعمال لحساب نفسه، أو فى عبارة أخرى نية الاستئثار بالحق الذى يستعمله.

وتكتسب الحياة بتوافر هذين العنصرين، وتفتقد بفقدتهما، ولكن يشترط لإنتاج الحياة أثرها خلو هذين العنصرين من العيوب. وهى تتصف باقترانها بحسن النية أو بسوءها، والقانون على أى حال يوفر لها نوعاً من الحماية بصرف النظر عن استنادها أو عدم استنادها إلى حق، وبصرف النظر عن اقترانها بحسن النية أو بسوء النية. وسوف نتناول هذه النقاط من خلال فرعين.



الفرع الأول ماهية الحيازة

أسلفنا أن الحيازة عنصرين أحدهما مادي وهو الإحراز أو السيطرة المادية، والثاني معنوي وهو القصد .

العنصر المادي :

العنصر المادي للحيازة هو مجموع الأعمال المادية التي تكونها، وهي تختلف باختلاف الشيء الذي ترد عليه والحق الذي يقصد حيازته. فإن كان هذا الحق ملكية تكون العنصر المادي من السيطرة التي تكون للمالك على ما يملكه، ومباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك عادة في ملكه من استعمال واستغلال وإجراء التصرفات المادية فيه. فإن كان الحائز يستعمل حقاً آخر كحق انتفاع أو حق ارتفاق، فالسيطرة المادية على هذا الحق تكون باستعماله عن طريق الأعمال المادية التي يقتضيها استعمال.

2024/2025

وفي جميع الأحوال لابد من عمل مادي إيجابي يستحوذ به الحائز على الشيء. فلا يكفي مجرد التمكن من الاستحواذ، بل لابد من الاستحواذ فعلاً والسيطرة المادية (١).

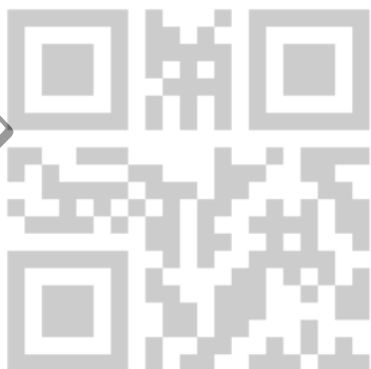
2024/2025

2024/2025

وكما يسيطر الحائز سيطرة فعلية على الشيء محل الحيازة بنفسه، فإنه قد يجوز بواسطة غيره، متى كان هذا الغير يأتّم بأمره وخاضعاً لسلطته وإشرافه، كخادم أو تابع آخر له، فتباشر السيطرة المادية بالوساطة (٢). وهذا ما نصت عليه المادة ١/٩٥١ مدني «١- تصح الحيازة بالوساطة، متى كان

(١) «وضع اليد واقعة مادية العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً، فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه». نقض مدني ١٩٦٩/١٢/١٦، طعن رقم ١٦٢ لسنة ٣٥ ق س ٢٠ ص ١٢٦٧.

(٢) د. السنهوري : الوسيط حـ ٩، ص ٧٩٥، د. جمال زكي: ص ٥١٠، د. محمد عمران - ص ١٧٤.



الوسيط يباشرها باسم الحائز، وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة».

ولغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من يمثله قانوناً (م ٩٥٠ مدنى) فيباشر باسمه السيطرة المادية الولى أو الوصى أو القيم، وإذا كان الحائز شخصاً معنوياً فإن الذى يباشر باسمه السيطرة المادية هو من يمثله قانوناً.

على أن السيطرة المادية بالوساطة لا تقتصر على حالة التابع بل يمكن أن تكون لمن يستعمل الشئ لمصلحته، كالمستأجر أو المستعير الذى يباشر السيطرة المادية بدلا من المؤجر أو المعير.

العنصر المعنوى :

للحيازة عنصراً معنوياً إلى جانب العنصر المادى، فلا يكفى لتحقيق الحيازة السيطرة المادية، بل يجب إلى جانبها توافر عنصر معنوى هو عنصر القصد أو النية. أى يكون الحائز قاصداً أن يستعمل الحق لحساب نفسه، سواء كان حق ملكية أو انتفاع أو ارتفاق أو رهناً ^{2024/2025} حيازة، فهو - العنصر المعنوى - ^{2024/2025} النية لدى الحائز فى حيازة الشئ لمباشرة هذا الحق، واكتسابه عليه لحسابه الخاص، وبدون توافر هذه النية لا تكون الحيازة قانونية أو حقيقية منتجة لآثارها رغم ما قد يتوافر من أعمال مكونة للركن المادى.

وعلى ذلك فمن يجوز بوصفه مستأجراً أو مستعيراً أو وكيلاً لا يملك أن يدعى توافر النية ^(١) لديه فى الظهور بمظهر المالك لأن عقد الإيجار أو

(١) « لم يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقى الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاءه مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائى قد خلا من شئ من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون. نقض مدنى ١٩٨١/١٢/١٩ طعن رقم ١٨٨٨ لسنة ٤٩ ق س ٣٢ ص ٥٥٨.



العارية أو الوكالة يمنعه في الأصل من هذه النية وينكرها عليه. ومن ثم لا يعتبرون حائزين قانونيين بالنسبة للأشياء التي تكون تحت يدهم لعدم توافر النية في العمل لحساب أنفسهم.

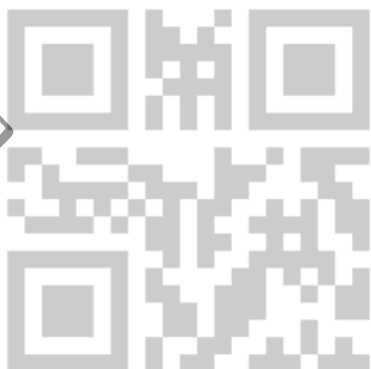
والعنصر المعنوي على خلاف العنصر المادي لا يجوز مباشرته بالوساطة بل يتعين أن يتوافر لدى الحائز ذاته. فالقصد أو النية لا بد لها من تميز. ومن ثم فقديم التميز من صغير غير مميز أو مجنون أو معتوه، لا مناص من الاعتداد بنية النائب القانوني عنه، بأن يباشر هذا النائب الأعمال الداخلة في مضمون الحق الذي يحوزه لصالح عدم التمييز وبنية اكتساب هذا الأخير للحق^(١). وقد نصت المادة ٩٥٠ مدني بقولها «يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية».

والعنصر المعنوي للحيازة مفترض، وليس على من له السيطرة المادية على الشيء أن يقيم الدليل على نيته في العمل لحساب نفسه، بل يقع على من ينازعه في حيازته أن يقيم الدليل على انتفاء هذه النية وأنه يباشر السيطرة المادية بالوساطة لحساب غيره تبعاً له أو تنفيذاً لعقد أبرمه معه، وعلى ذلك نصت المادة ٢/٩٥١ مدني «٢- عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه، فإن كانت استمرار الحيازة سابقة افتراض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادى بها».

انتفاء العنصر المعنوي في إتيان الرخص وأعمال التسامح:

تنص المادة ١/٩٤٩ مدني على أنه «لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على

(١) د. السنهوري: الوسيط حـ ٩ ص ٨٤٢، د. حسن كيرة: الحقوق العينية، ص ٤٤٧. د. مصطفى الجمال: ص ٢٦٢.



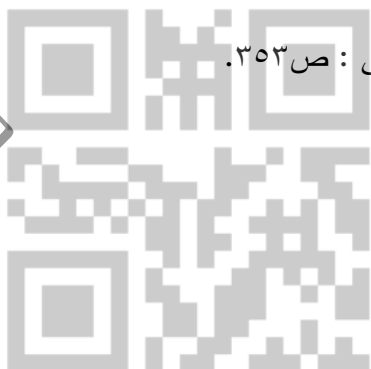


سبيل التسامح». ذلك أن إتيان الرخص لا يتوافر فيها عنصر الحيابة. وأعمال التسامح ينتفى فيها العنصر المعنوى للحيابة^(١).

والعمل الذى يأتية الشخص على أنه مجرد رخصة من المباحات هو عمل يكون للشخص الحرية التامة فى أن يأتية أو لا يأتية، فإذا أتاه لم يكن لأحد أن يمنعه فهو فى إتيانه لهذا العمل لا يتعدى على حق أحد، فلا هو حاز حقاً لأحد ولو مجرد حيابة مادية، كما لم تتوافر عند قصد استعمال الحق لأحد، ومن ثم لا تقوم الحيابة بإتيان هذه الرخصة لتخلف عنصرها. مثال ذلك أن يفتح شخص منوراً أو يفتح مطلاً على المسافة القانونية، فهو فى ذلك يستعمل رخصة من المباحات ولا يتعدى على ملك جاره. ولذلك فإنه لا يستطيع ادعاء أنه حائز لحق ارتفاق بالمطل على نحو يحول بين الجار وبين البناء على حدود ملكه.

كما لا تقوم الحيابة على عمل يتحملة الغير على سبيل التسامح، والمقصود بأعمال التسامح الأعمال التى تتضمن اعتداء على حق الغير ولكن هذا الغير يتسامح فلا يعترض على هذا العمل لأنه لا يضر منه، فأعمال التسامح بهذا المعنى تقوم على أساس ترخيص ضمنى من صاحب الحق. لذلك لا يستطيع من يستفيد من هذا التسامح أن يدعى أنه قد قصد الظهور بمظهر صاحب حق فيما كان محلاً للتسامح، ولا يتوافر لديه من ثم العنصر المعنوى فى الحيابة، فكثيراً ما يكون مرور الجار فى أرض جاره أو فتح مطل على مسافة أقل مما حدده القانون عملاً من أعمال التسامح بين الجيران، فلا تكتسب ارتفاقاً بالمرور أو بالمطل مهما طال المدة.

(١) د جمال زكى : الحقوق العينية ص ٥١٥ ، د منصور مصطفى : ص ٣٥٣.



وتقدير ما إذا كان العمل يدخل فى أعمال التسامح أو يعتبر استعمالاً لحق يوفر الحيابة القانونية للقائم به فيرجع إلى قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض ما دام تقديره مستساغاً^(١).

الحيابة القانونية والحيابة العرضية :

تكون الحيابة قانونية أو حقيقية إذا توافر لها عنصران، العنصر المادى والعنصر المعنوى، أما إذا فقدت الحيابة عنصرها المعنوى فإنها تكون حيابة عارضة. فقد يتوافر للشخص السيطرة المادية على الشئ ولكن ينتفى قصده فى اعتبار نفسه صاحب الحق عليه أو تنتفى نيته فى استعمال الحق لحساب نفسه. فيسمى حائزاً عرضياً.

فالحياة العرضية : هى سيطرة مادية تكون لشخص على شئ بإذن من صاحب الحق عليه - كتابع أو خادم أو عامل - أو بمقتضى عقد معه - كمستأجر أو المستعير أو الوكيل - أو بناء على حكم القاضى - كالسنديك والحارس القضائى - أو بنص القانون - كالولى أبا كان أو جداً - فكل من هؤلاء يستعمل الشئ وينتفع به ويديره ويكون له عليه سيطرة مادية ولكن يباشرها لحساب مالكه^(٢).

والحائز العرضى : كل شخص انتقلت إليه بناء على عقد أو حكم أو نص فى القانون السيطرة المادية على الشئ من حائزه ليباشرها لحسابه وبإسمه.

(١) لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من استيفاء الحيابة للشروط التى يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة. نقض مدنى ١٩٨٠/١٢/١٨ طعن رقم ١٧٠ - لسنة ٥٠ ق - س ٣١ - ص ٢٠٥٣.

(٢) «حيابة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حياة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته مجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن كسب بالتقادم على خلاف سنده». نقض مدنى ١٩٨١/٥/١٩ طعن رقم ٦٥٧ لسنة ٤٨ ق، س ٣٢ ، ص ١٥٣٨

والفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية تفرقة بالغة الأهمية. فمن ناحية تقتصر دعاوى الحيازة فى الأصل على أسباب الحيازة القانونية وحدهم دون الحائزين العرضيين وإن كان المشرع يخرج عن هذا الأصل بتحويل المستأجر وهو مجرد حائز عرضى دعوى الحيازة، ومن ناحية ثانية فإن الحيازة القانونية وحدها هى التى تقضى إلى كسب الحقوق العينية، أما الحيازة العرضية فلا تكسب أى حق عينى طالما هى باقية على صفتها العرضية ومهما مضى من مدة عليها. وعلى ذلك تنص المادة ١/٩٧٢ مدنى «ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده». فعقد الإيجار هو سند المستأجر فى حيازته العرضية ويتضمن فى نفس الوقت اعترافاً بحق حائز العين المؤجرة وهو المؤجر، فلا يستطيع المستأجر تملك العين المؤجرة بالتقادم المكسب إذ أنه لا يحوز لنفسه بل يحوز لحساب المؤجر.

تحول الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية :

إذا بدأت الحيازة عرضية فإن ذلك لا يحول دون تحولها إلى حيازة حقيقية وهذا ما يعبر عنه بتحويل الحيازة العرضية إلى حيازة حقيقية أى تغيير نية الحائز والظهور بمظهر صاحب الحق. فبعد أن كان الحائز يحوز لحساب غير تغيرت نيته وحاز لحساب نفسه، فعندئذ تتحول حيازته من عرضية إلى حقيقية.

وقد نصت المادة ٩٧٢ مدنى على أنه «١- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة. ٢- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغير.

فالأصل كما تقضى المادة ١/٩٧٢ مدنى أن الحيازة بدأت عرضية تظل كذلك، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، إلا أنه يجوز مع ذلك أن تتغير صفة حيازته وتتحول إلى حيازة قانونية إما بفعل الغير ، أو

بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك^(١). وهنا يزول سند الحيازة العرضية بتغيره أو بإهداره كلية، ليقوم في الحالتين بدلاً منه سند أو سبب جديد لحيازة قانونية.

فتغير الحيازة العرضية وتحولها إلى حيازة قانونية يكون بأحد أمرين:

١- **فعل الغير** : ويكون فعل الغير الذى يغير صفة الحيازة تصرفاً قانونياً ناقلاً للملكية - بيع ، هبة - يصدر للحائز العرضى فيغير صفة حيازته ويحولها إلى حيازة قانونية فإذا لم يكن كذلك فلا يمكن أن يترتب عليه تغيير صفة الحائز.

وقد يكون مالكاً أو غير مالك، فإذا كان مالكاً انتقلت الملكية إلى من كان قبل حائزاً عرضياً، وأصبح تبعاً لذلك مالكاً للشئ الذى كان يحوزه. أما إذا كان غير مالك فالرأى الراجح فى الفقه - والذى نؤيده^(٢) - يرى أن الحائز فى هذه الحالة سيئ النية يعلم أنه يتعامل مع غير مالك، ومن ثم يتخذ من هذا التصرف ذريعة لتغير سبب الحيازة بنفسه لنفسه، أو بإرادته وحدها خلافاً لحكم القانون فلا يكفى هذا التصرف لتغير صفة حيازته.

2024/2025

٢- **تغير صفة الحائز بفعل يصدر منه هو**: قد تتغير صفة الحائز بفعل يصدر منه هو فيه إنكار لحق المالك « لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على

(١) « لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزعم إنكار الملكية على صاحبها واستثناؤه بها دونه». نقض مدنى ١٩٨٧/١٢/٣٠ طعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥١ ق.

(٢) د جمال زكى : ص ٥٢١ ، د منصور مصطفى : ص ٣٨٦ ، د حسن كيرة: ص ٤٥٢ ، د محمد عمران : ص ١٨٠ ، وعكس ذلك د السنهورى: الوسيط - د ٩ ص ٨٤٩ ، حيث يرى سيادته أن هذا التغيير يتم حتى ولو كان الحائز سيئ النية.

أن ذا اليد الوقتية مزعم إنكار الملكية على صاحبها واستثنائه بها دونه»^(١).
 كأن يدعى الحائز العرضى ملكية العين فى دعوى يرفعها على المالك، أو فى
 دعوى يرفعها المالك عليه يطالبه فيها برد العين التى امتنع عن ردها له،
 مدعىاً - الحائز - ملكيته لها، وإن كان لا يستلزم أن يتخذ الإنكار صورة
 النزاع القضائى، بل يكفى أن يعلن الحائز المالك بادعائه ملكية العين بإنذار
 رسمى أو حتى بكتاب مسجل^(٢).

والحائز العرضى الذى يغير حيازته بفعله لا يحصل على سند جديد
 لحيازته، بل يقتصر على إهدار سند حيازته العرضية لتكون حيازته الجديدة
 دون سند، وعلى أى حال إذا تم تغيير صفة الحيازة العرضية وتحولها إلى
 حيازة قانونية بأى طريق من الطريقين المتقدمين، فإن هذا التغيير لا ينتج أثره
 إلا من تاريخ تحققه. لذلك لا يبدأ سريان التقادم المكسب للحق العينية إلا من
 تاريخ هذا التغيير الذى حول الحيازة قانونية (م ٢/٩٧٢ مدنى).

وتغير صفة الحيازة العرضية لا يفترض أياً كانت طريقة التغيير، بل
 على من يدعى حصوله إقامة الدليل على ذلك. وهذا ما يقرره المشرع بنصه
 على أن تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقيم
 الدليل على عكس ذلك.

على أنه إذا كانت الحيازة استمرار لحيازة سابقة افتراض أن هذا
 الاستمرار هو لحساب البادئ بها (م ٢/٩٥١ مدنى).

(١) نقض مدنى ١٩٧٧/١/٤ طعن رقم ٢٥٩ لسنة ٤٢ ق ، س ٢٨ ، ص ١٤٧.

(٢) «يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين المؤجرة مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو
 بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزعم إنكار الملكية
 على المالك والاستثناء بها دونه». نقض مدنى ١٩٧٦/١١/٢٣ طعن رقم ٤٠٣
 لسنة ٤٠ ق ، س ٢٧ ، ص ١٦٢٧.



الفرع الثانى

عيوب الحيازة وصفاتها

(انتقالها - فقدھا)

إذا كانت الحيازة تقوم بتوافر ركنيها المادى والمعنوى، فإن ترتيبها لآثارها قد يتعطل نتيجة لما يشوبها من عيوب. وقد حددت المادة ٢/٩٤٩ مدنى هذه العيوب بنصها إلى أن الحيازة «إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.

عیب الإكراه :

يجب أن تكون الحيازة هادئة أما إذا شابها إكراه كانت حيازة معيبة، ومن ثم غير صالحة لإنتاج آثارها القانونية والإكراه الذى يعيب الحيازة هو الإكراه الذى يحصل الحائز عليها به. فتكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه أو عدم الهدوء إذا حصل عليها بالقوة أو بالتهديد، وتظل مشوبة به طالما بقى الحائز محتفظاً بها دون أن تنقطع القوة أو التهديد الذى حصل عليه به. أما إذا انقطع الإكراه الذى اقترن بالحيازة وصارت خالية منه أصبحت منذ انقطاعه حيازة هادئة وتصلح لإنتاج آثارها القانونية. أى أن الإكراه عيب مؤقت يزول بانقطاع الإكراه. وهو أيضاً عيب نسبي لا يستطيع التمسك به إلا من وقع عليه الإكراه.

وإذا بدأت الحياة هادئة أو أصبحت كذلك فلا يلحقها عيب الإكراه إذا اضطر الحائر لاستعمال القوة للاحتفاظ بها ضد من يحاول انتزاعها منه. وفي هذا قضت محكمة النقض بأنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حياة الطاعن للأرض استناداً إلى مجرد توقيع الحجز، وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصلح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئاً من ذلك

بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شروط الهدوء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (١).

٢ - عيب الخفاء :

الحيازة لا ترتب آثارها إذا كانت معيبة بالخفاء. والمقصود بالخفاء أن يكون الحائز قد مارس حيازته خفية عن صاحب الحق الذي يحوزه. فالمفروض أن الحائز يحوز الحق كما يحوزه صاحبه، وصاحب الحق لا يتخفى في حيازته له. وليس معنى الخفاء أن تكون الحيازة علنية ظاهرة للكافة، إنما يكفي أن تكون ظاهرة لمن لهم مصلحة في معرفتها.

وأغلب ما يتحقق الخفاء في حيازة المنقولات، إذ يكون من السهل إخفاؤها عن أنظار من يعينهم الأمر. أما العقارات فمن النادر تصور الخفاء في حيازتها (٢).

وعيب الخفاء عيب نسبي ومؤقت كبقية عيوب الحيازة فهو عيب نسبي بمعنى أنه لا يتمسك به إلا من خفيت عليه الحيازة مع عدم إمكانه العلم بها. فلا يمكن الاحتجاج بها عليه بالتالي. ^{2024/2025} بينما تكون هذه الحيازة صحيحة منتجة ^{2024/2025} لآثارها في حق غيره ممن كانت ظاهرة وعلنية بالنسبة إليهم. وهو عيب مؤقت يزول بظهور الحيازة وتصبح بزواله صالحة لإنتاج آثارها القانونية، فيبدأ التقادم لمصلحة الحائز منذ زوال الخفاء عن حيازته.

٣ - عيب اللبس أو الغموض :

ويجب أخيراً أن تكون الحيازة واضحة لا يشوبها غموض أو لبس وإلا كانت حيازة معيبة غير صالحة لإنتاج آثارها القانونية. وتكون الحيازة مشوبة بالغموض أو اللبس إذا أحاطت بها ظروف تثير الشك في حقيقة قصد الحائز،

(١) نقض مدني ١٩٨١/٦/٧ طعن رقم ١٠٨١ لسنة ٤٨ ق ، س ٣٢ ص ١٧٥٤.
(٢) د. السنهوري : الوسيط ، ص ٨٥٠ ، د. حسن كيرة : ص ٤٥٩ ، د. جمال زكي : ص ٥٢٧.

وهل يحوز لحساب نفسه لتتوفر له الحيازة القانونية، أم يحوزه لحساب غيره، فلا تكون له سوى الحيازة العرضية. أى أن عيب اللبس أو الغموض يصيب العنصر المعنوى فى الحيازة دون عنصرها المادى.

مثال ذلك إذا وضع الشريك المشتاع يده على الشئ الشائع كله، فإن وضع يده يحتمل أن يكون لحساب شركائه فيما يتعلق بحصصهم، كما يحتمل أن يكون لحساب نفسه (١)، كذلك الشأن فى حيازة الوارث لأموال التركة حيث يحتمل أن تكون حيازته لحساب نفسه أو لحساب الورثة جميعهم. وبالمثل فى حيازة الخادم أو الزوجة لمنقولات المخدم أو الزوج المتوفى، على أن توافر اللبس فى هذه الأمثلة رهين بعدم توافر ظروف تقطع بأن الحائز يحوز لحساب نفسه. فإذا توافرت مثل هذه الظروف فإن عيب اللبس لا يكون متوافراً. كما لو اتخذ الحائز عملاً يعارض به صاحب الحق فى حقه. مثال ذلك ما إذا جابه الشريك على الشيوع شركائه بأن يحوز لنفسه.

وعيب اللبس أو الغموض عيب مؤقت يزول بانتفاء الغموض أو اللبس عن طريق أعمال يقوم بها الحائز تظهر فى وضوح أنه يحوز لحساب نفسه لا لحساب غيره. كما أنه عيب نسبى (٢) بمعنى أنه لا يتمسك به إلا من التبس عليه أمر الحيازة وكان فى ظروف الحيازة ما يوقع فى اللبس، مما يؤدي إلى منع الاحتجاج عليه بهذه الحيازة، أما من لم يلتبس عليه أمرها فيحتج عليه بها إذ لا يستطيع التمسك بالتباسها على غيره.

(١) « إن كانت الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها إلا أنه نظراً لأن يد الحائز للحصة الشائعة تخالط يد غيره من الشركاء المشتاعين بما يشوب الحيازة بالغموض والإبهام، فإنه يتعين على الشريك المشتاع الذى يحوز حصة غيره بنية التملك بأن تقوم حيازته على مناهضة حق المالك ومناقضة بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح». نقض مدنى ١٩٨٧/١٢/٣٠ طعن ٣٨٠ لسنة ٥٤ق.

(٢) يرى جانب من الفقه انه عيب مطلق وليس نسبى لأنه يلحق العنصر المعنوى وذلك خلاف للإكراه والخفاء الذين يتصفان بالنسبة. د. جمال زكى : ص ٥٧١.

الحيازة بحسن نية والحيازة بسوء نية :

إذا ما توافرت عناصر الحيازة وكانت خالية من العيب فإن الحائز بعد ذلك قد يكون حسن النية. وقد عرضت المواد ٩٦٥-٩٦٧ من القانون المدنى لبيان متى يكون الحائز حسن النية ومتى يكون سيئ النية.

الحائز حسن النية : تنص المادة ٩٦٥ مدنى على «١- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير، إلا إذا كان الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم». ويفهم من ذلك أن الحائز لحق من الحقوق يعتبر حسن النية إذا كان يعتقد حيازته لهذا الحق لا تتطوى على اعتداء على حق للغير. مثال ذلك أن يشتري شخص عيناً من آخر معتقداً أنه هو المالك، وتسلم العين من البائع فإنه يحوز حق الملكية ويكون فى حيازته إياه حسن النية ما دام يعتقد أنه قد اشترى من مالك، وذلك سواء كان البائع مالكاً حقيقة أم لا.

2024/2025

وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة النص مباشرة، إلا أن العبارة تحتل 2024/2025 أوسع من ذلك فقد يجعل الحائز 24/2024هـ يعتدى على حق الغير، ولكنه مع ذلك يعلم أن الحق الذى يحوزه ليس له (١). مثال ذلك الاستيلاء، فقد يعتقد شخص أن منقولاً معيناً غير مملوك لأحد. فيحوزه قاصداً أن يملكه بالاستيلاء ففى هذه الحالة يكون الحائز للمنقول حسن النية.

وإذا كان المشرع يعتبر أن الحائز حسن النية إذا كان يجهل أن حيازته للحق يعتدى على حق لغيره، إلا أن هذا الحائز إذا ارتكب خطأ جسيم فى هذا الشأن فإن المشرع يعتبره سيئ النية. فمن يشتري عقاراً من شخص لم يقدم له أى مستند على ملكيته لهذا العقار يكون قد ارتكب خطأ جسيم. ومن ثم يعتبر

(١) د السنهورى : الوسيط ٩ ، ص ٨٦٥.

سيئ النية بالرغم من أنه قد يكون جاهلاً فعلاً أنه يشتري من غير مالك لأن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية^(١).

والعبرة في تقدير حسن النية بنية الحائز ذاته، غير أنه إذا كان الحائز عديم الإرادة وكان يحوز عن طريق ممثله، فإن العبرة تكون بنية هذا المثل، وقد نصت المادة ٩٦٥/٢ على ذلك صراحة بالنسبة للشخص المعنوي. «٢- إذا كان الحائز شخصاً معنوياً فالعبرة بنية من يمثله».

ولا يطلب من الحائز أن يثبت حسن نيته، فحسن النية مفترض، ومن يدعى العكس عليه إثباته، وعلى ذلك نصت المادة ٣/٣٦٥ «حسن النية يفترض دائماً ما لم يقدّم الدليل على العكس. ومن ثم فالحائز ليس عليه أن يثبت حسن نيته وإنما من يدعى العكس أن يثبت أن الحائز كان يعلم فعلاً أنه بحيازته يعتدى على حق الغير.

وقد نصت المادة ٩٦٦ مدني يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه ~~الحياز من غيره~~ يتبين من هذا النص أن هناك حالتين يعتبر فيهما الحائز سيئ النية ولو كان يعتقد أن له حقاً في حيازته.

الأولى : إعلان الحائز في صحيفة الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس له. ففي هذه الحالة يعد الحائز سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فيما لو تبين أنه لم يكن صاحب حق.

الثانية : إذا اغتصب الحائز بالإكراه الحيازة من غيره يعتبر سيئ النية، ولو كان يعتقد فعلاً أنه صاحب الحق على الشيء فلو اعتقد شخص أنه مالك عقاراً معين يحوزه غيره فاغتصبه منه فإنه يعتبر سيئ النية.

(١) «مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٩٦٥ مدني أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير ولا يخالطه أى شك في هذا، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً في جهله بأنه يعتدى على حق الغير». نقض مدني ١٩٦٨/١٠/٢٩، طعن رقم ٤٤٧ لسنة ٣٤ ق، س ١٩ ص ١٢٨٧.

وتبقى الحيازة محتفظة بصفقتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يتم الدليل على عكس ذلك (م ٩٦٧ مدنى) فإذا كانت الحيازة قد بدأت بحسن نية - وهو مفترض - فإن الحائز يظل معتبراً حسن النية حتى يقوم صاحب الحق بإثبات تحقق علمه بأنه يعتدى على حق الغير.

وإذا ثبت أن الحائز سيئ النية، فإنه يبقى حائزاً سيئ النية وتنتقل حيازته بصفقتها هذه إلى وارثه، فيعتبر الوارث سيئ النية مثل مورثه إلى أن يثبت حسن النية (م ١/٩٥٥ مدنى).

انتقال الحيازة وفقدانها :

يقصد بانتقال الحيازة إفادة الحائز من حيازة سلفه الذى تلقى عنه العين المحوزة، بحيث يضم مدة حيازة هذا السلف إلى مدة حيازته، لتكون منها مدة واحدة وانتقال الحيازة بهذا المعنى يتم بأحد طريقين : الميراث وهو انتقال الحيازة إلى الخلف العام. والاتفاق وهو انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص.

انتقال الحيازة إلى الخلف العام :

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تنتقل الحيازة من الحائز إلى الخلف العام بحكم القانون كما تنتقل إليه أمواله ودون حاجة إلى تسليم فعلى بمجرد الوفاة (١). فالمورث هو والورثة يكونون شخصية قانونية واحدة بالنسبة لوضع اليد. ومن ثم لا يبدأ الوارث فى حيازة جديدة بل تنتقل إليه حيازة المورث ذاتها بصفاتها، معيبة أو سليمة، بحسن نية أو بسوء نية.

وهذا ما نصت عليه المادة ١/٩٥٥ مدنى «تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها». فإذا كانت الحيازة عند المورث مشوبة بعيب، كأن كانت حيازة خفية أو بالإكراه أو غامضة، تنتقل إلى الوارث مشوبة بهذا العيب، وإن كان الوارث يستطيع - كما كان المورث كذلك - أن يزيل هذا العيب.

(١) د. السنهورى : الوسيط ، ج ٩ ، ص ٨٧٧.



وإذا كان المورث حسن النية في حيازته، انتقلت الحيازة إلى الوارث مقترنة بحسن النية، إلى أن يعلم أن حيازته اعتداء على حق الغير. أو يعلن بصحيفة الدعوى فيصبح بهذا العلم أو ذاك الإعلان سيئ النية. أما إذا كان المورث سيئ النية انتقلت الحيازة إلى الوارث مقترنة بسوء النية، ولكن يستطيع الوارث أن يثبت أن حسن النية لا يعتقد أن في حيازته مورثه اعتداء على حق الغير.

وما دامت حيازة الوارث استمرار لحيازة المورث، فتضم مدة حيازة المورث إلى مدة حيازة الوارث ما دامت للوارث فائدة من هذا الضم، كما إذا كان مقتضى مدة معينة لرفع دعاوى الحيازة أو التقادم المكسب (١).

انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص :

يقصد بالخلف الخاص في نطاق الحيازة، كل من يجب على الحائز أن يسلم أن يسلم له العين أو يتخلى له عن حيازتها، إما تنفيذ الالتزام في ذمته بتسليمها إليه أو بالتخلى له عن حيازتها، وإما نتيجة لانحلال سنده كفسخه أو إبطاله أو الرجوع فيه. وتنتقل الحيازة إلى الخلف الخاص بالاتفاق بينهما على نقلها، الذي قد يكون انتقالاً مادياً نتيجة للتسليم الفعلي، أو انتقالاً معنوياً نتيجة للتسليم الحكمي، أو انتقالاً رمزياً نتيجة للتسليم عن طريق التمكين منه.

والانتقال الفعلي للحيازة يكون بتسليم العين المحوزة تسليماً فعلياً، ويكون ذلك عندما يكون في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق

(١) «قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يجتمع به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق مما باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه من هذا السلف». نقض مدني ٢٨م/٢ ١٩٧٨ طعن رقم ٦٧١ لسنة ٤٤ ق. س ٢٩، ص ٦١٥.

الوارد عليه الحيابة، ولو لم يكن هناك تسليم مادی للشئ موضوع هذا الحق، (م ٩٥٢ مدنى). أما الانتقال المعنوى للحيابة يكون بتسلم العين المحوزة تسليمياً حكماً يتم بمجرد تغيير النية وقد نصت المادة ٩٥٣ مدنى على « يجوز أن يتم نقل الحيابة دون تسليم مادی إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه فى الحيابة أو استمر الخلف واضعاً يده لحساب نفسه».

والانتقال الرمزى للحيابة يكون عن طريق التمكين من هذه الحيابة فتسليم السندات المعطاة مع البضاعة المعهودة لها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضاعة ذاتها (م ١/٩٥٤ مدنى) على أنه إذا اجتمعت الحيابة الرمزية مع الحيابة الفعلية، بأن سلمت تلك السندات إلى شخص وسلمت البضاعة المعطاة عنها السندات إلى شخص آخر واقتربنا بحسن النية، فضلت الحيابة الفعلية م ٢/٩٥٤ مدنى.

وحيابة السلف لا تنتقل إلى الخلف الخاص، بل تبدأ له حيابة جديدة مستقلة عن حيابة سلفه تتميز بصفات الخاصة التى قد تختلف عن الصفات التى كانت عليها عند السلف (١) ويترتب على كون حيابة الخلف الخاص حيابة جديدة وليست استمرار لحيابة سلفه، أن توجد حيازتان أحدهما حيابة السلف والأخرى حيابة الخلف الخاص. وإن كان يجوز لهذا الأخير ضم مدة حيابة سلفه (٢) إلى مدة حيازته إذا كانت له مصلحة فيه. فالخلف الخاص بالخيار وفقاً لمصلحته بين أن يضم حيابة سلفه أو لا يضمها. م ٢/٩٥٥ مدنى. على أنه يشترط لإجازة ضم الخلف الخاص حيابة سلفه إلى حيازته ألا

(١) د السنهاورى: الوسيط ح ٩ ص ٩٨١، د جمال زكى: الحقوق العينية ص ٥٣٩.

(٢) «مفاد هذا إن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيابة سلفه يقتضى انتقال الحيابة إلى الخلف الخاص على نحو يمكنه معه من السيطرة الفعلية على الشئ ولو لم يسلم تسليماً مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً، يستوى إن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه، أو بالاشتراك بينهما». نقص مدنى ١٩٧٩/٤/٣٦، طعن رقم ٤٤٧ لسنة ٤٦ ق . س ٣٠ . ص ٣٠٢.

يكون هذا السلف مالكاً وقت تصرفه إلى خلفه، أما إذا كان السلف مالكاً فعلاً بأى طريق من طرق الملكية فإنه يبقى هو المالك له دون خلفه الخاص الذى لا يملكه منه إلا بتسجيل سنده أو بالتقادم الناشئ عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها (١).

فقد الحيازة :

إذا كانت الحيازة توجد بتوافر عنصرىها المادى والمعنوى فإنها تزول بفقدتهما أو بفقد إحداهما ولو بقى الآخر فيفقد الحائز حيازته إذا فقد عنصرى الحيازة معاً نتيجة اتفاق، فتنقل بمقتضاه إلى خلف خاص يبدأ حيازة جديدة، أو بإرادة الحائز وحده إذا تولى عن سيطرته المادية على الشئ بنية ترك حيازته.

وقد يفقد الحائز العنصر المعنوى فقط، وهذا يترتب عليه أيضاً فقد الحيازة الحقيقية، مثال ذلك أن يبيع الحائز الشئ الذى ترد عليه حيازته، ثم يظل مع ذلك واضعاً يده عليه كمستأجر له. فمع أن السيطرة المادية لا زالت للحائز، غلا أنه لا يجوز بقصد التملك بل بصفته مستأجراً. فبعد أن كانت حيازته حقيقية تحولت عرضية، وقد يفقد الحائز السيطرة المادية على الشئ الذى ترد عليه حيازته، وإن كان هذا لا يعنى دائماً فقد العنصر المادى فى الحيازة. فإذا كان فقد السيطرة المادية راجعاً إلى فعل الغير، فإن ذلك لا يحول بين الحائز وبين المطالبة باسترداد حيازته شريطة أن يباشر دعواه فى خلال السنة التالية لفقدتها ، وكذلك فإن الحيازة لا تنقضى إذا حال دون مباشرة السيطرة المادية مانع وقتى. ومع ذلك فإن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة، إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية م ٢/٩٥٧ مدنى.

(١) نقض مدنى ١٩٨٨/٢/١٠، طعن رقم ٨١٧ لسنة ٥٣ ق.



المطلب الثاني

آثار الحيازة

تقسيم : يرتب المشرع على الحيازة آثاراً كثيرة يعينها منها أساساً أثران، الأول منها ما يخص العلاقة بين المالك والحائز ، والثاني ما يتعلق باكتساب الحق العيني الذي كان الحائز يظهر بمظهر صاحبه.

وقبل أن نعرض لهذين الأثرين نشير إلى أن المشرع قد حمى الحيازة في ذاتها بدعاوى الحيازة الثلاث وهي دعوى استرداد الحيازة التي نص عليها في المواد ٩٥٨-٩٦٠ من القانون المدنى، وتحمى الحائز الذى انتزعت الحيازة منه عنوة أو خلسة ، ودعوى منع التعرض وتحمى الحائز التى تعرضت حيازته للاعتداء أو التهديد م ٩٦١ مدنى، ودعوى وقف الأعمال الجديدة وتحمى الحائز الذى توشك حيازته أن تتعرض للاعتداء أو التهديد من جراء أعمال بدأت ولم تتم.

2024/2025

هذه الدعاوى تحمى الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا كانت تستند إلى حق قائم قانوناً أو لا تستند إلى ذلك^{2024/2025}، كما أن لها طابع الاستعجال، نظراً لما تنسم به إجراءاتها من بساطة وسرعة كما أنها دعاوى خاصة بحيازة الحقوق الواردة على العقار وحدها دون حيازة الحقوق الواردة على المنقول. وتدرس دعاوى الحيازة عادة في نطاق قانون المرافعات وإن كان جانب من الفقه يتناول هذه الدعاوى بالتفصيل في مؤلفات القانون المدنى (١).

وعلى ضوء ما سبق نعرض للأثرين الهامين للحيازة في فرعين متتاليين:

(١) د السنهاورى: الوسيط ، ج٩ ، ص٩٠٣ - ٩٤٩ ، د مصطفى الجمال: ص٢٧٧-٢٨٣.



الفرع الأول

العلاقة بين الحائز والمالك

إذا لم يفلح الحائز في اكتساب الحق العيني على الشيء الذي كان يحوزه، سواء بالحيازة أو بالتقادم على حسب الأحوال وقضى لخصمه بالحق في استرداد الشيء، فإن الأمر قد يقتضى أن يسترد الحائز من المالك المصروفات التي قد يكون أنفقها على الشيء عندما كان في حيازته.

وقد يجد المالك عند رجوعه على الحائز بدعوى الاستحقاق أن ملكه قد هلك أو تلف في يد الحائز. فيسأله حينئذ عن هلاكه أو تلفه. وعلى ذلك بفرض أولاً استرداد الحائز للمصروفات، ثم كسب الثمار، فمستوليته عن الهلاك أو التلف.

استرداد الحائز للمصروفات :

فرق الشارع في تحديد ما يلتزم المالك برده من المصروفات بين الضرورية منها والنافعة والكمالية. فقد نص في المادة ١/٩٨٠ مدنى «على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية ولو كان الحائز سيئ النية. لأنها نفقات لازمة لحفظ الشيء ولولاها لهلك أو تلف، والمالك كان سيقوم بها لو ظل الشيء في حيازته»^(١).

أما المصروفات النافعة فهي التي كان من الممكن عدم القيام بها، ولكنها مع ذلك أدت إلى زيادة قيمة الشيء. وقد أحال المشرع في شأنها إلى قواعد الالتصاق حيث نص في المادة ٢/٩٨٠ على «٢- أما المصروفات النافعة فيسرى في شأنها أحكام المادتين ٩٢٤، ٩٢٥ مدنى. وهذه المواد تفرق بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية. فيلزم المالك أن يرد للحائز حين النية إما ما أنفق على العين، وإما مبلغا يساوى ما زاد في ثمن العين نتيجة لما

(١) د. السنهورى : الوسيط ، ج٩ ، ص ٩٧٣ ، د. جمال زكى ، ص ٥٤٦ ، د. عمران : ص ١٨٦.



أنفقه. أما الحائز سيئ النية فيطلب منه إزالة ما أحدثه أو استبقائه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة أو مبلغاً يساوى ما زاد فى قيمة العين بسبب هذه التحسينات.

أما المصروفات الكمالية فليس للحائز أن يطالب بشئ منها ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشئ إلى حالته الأولى، إلا إذا اختار المالك أن يستبقئها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة م ٣/٩٨٠، وإذا كان الحائز وقت تلقيه الحيازة قد أدى إلى سلفه ما أنفقه من مصروفات يستطيع أن يطالب بها المالك الذى يسترد ملكه، على أن يثبت الحائز ما دفعه (م ٩٨١ مدنى).

ويجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بتلك المصروفات التى يلتزم بدفعها للحائز أو خلفه كأن ينظره إلى أجل، أو يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية، على أن يقدم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذ هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصصاً منها فوائد بها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

كسب الحائز حسن النية للثمار :

الأصل يقضى بمسئولية الحائز عن ثمار الشئ الذى يجب عليه رده على أساس أنه ما دامت الملكية أو الحق العيني قد ثبت على الشئ لشخص آخر، فتكون ثمار الشئ بالتالى من حقه بحيث يلتزم الحائز برد هذه الثمار أو مقابلها. بالإضافة إلى التزامه برد الشئ ذاته. ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة للحائز حسن النية إذا جعل له الحق فى تملك الثمار رغم التزامه برد الشئ الأصلى إلى صاحبه. ويجد هذا الاستثناء حكمته فى اعتبارات تتعلق بالحائز حسن النية (١)، الذى يفترض استهلاكه لثمار ما يجوز ما دام يعتقد أنه مالكة.

(١) د جمال زكى : ص ٥٤٩ .

ويكسب الحائز الثمار مادام حسن النية م ١/٩٧٨ مدنى، ولو لم تكن حيازته مقترنة بسبب صحيح، الذى لا يعتبر فيما يتعلق بكسب الثمار شرطاً مستقلاً عن حسن النية. ويقصد بحسن النية الحائز فى نطاق كسب الثمار ليس فقط جهله بأنه تلقى العين من غير مالكةا، بل جهله كذلك بما قد يشوب سنده من عيوب (١).

فلا يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يعلم أن التصرف الذى نقل العين إليه باطل أو قابل للإبطال أو للفسخ. فمعنى حسن النية فى تملك الثمار أن يعتقد الحائز أنه يملك العين التى أنتجت هذه الثمار ملكاً صحيحاً لا تشوبه شائبة، وأن ملكية العين قد انتقلت إليه من مالكةا انتقالاً صحيحاً باتاً، فأصبح هو المالك للعين وتبعاً لذلك أصبح مالكةا للثمار (٢).

وقد نصت المادة ٢/٩٧٨ على أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها وأما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً. والثمار الطبيعية هى التى ينتجها الشئ دون تدخل الإنسان والثمار المستحدثة هى الثمار الصناعية التى تنتج بعمل الإنسان. وهذه أو تلك يملكها الحائز بفصلهما عن الأرض. أما الثمار المدنية وهى مبالغ النقود التى يدرها الشئ فإن الحائز يملكها يوماً فيوماً ما دام الحائز باقياً على حسن نيته، فإذا انقطع حسن النية أو انتهت الحيازة لم يملك الحائز منها إلا ما كان مستحقاً يوم انقطاع حسن النية أو انتهاء الحيازة.

مسئولية الحائز سيئ النية عن جمع الثمار :

إذا كان الحائز حسن النية يكسب الثمار، فإن الحائز سيئ النية يلتزم بردها أو التعويض عنها لأنه يعلم أنه لا حق له فى ثمار الشئ يخوله قبضها

(١) د السنهورى الوسيط ٩ ، ص ١١٧٨ ، د مصطفى الجمال : ص ٣٠١.

(٢) د السنهورى : الوسيط ، ج ٩ ، ص ١١٨٣.

أو التفريض في قبضها. لذا فقد تشدد المشرع في معاملته فقرّر مسؤوليته عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها على السواء م ٩٧٩ مدنى.

والحائز سيئ النية يلتزم برد الثمار التي قبضها، وهو ملزم بردها عيناً إن كانت لا تزال موجودة، فإن كان استهلكها يرد قيمتها من وقت قبضها. وهو يلزم أيضاً برد قيمة الثمار التي قد يكون قصر في قبضها إذ هي الثمار التي كان المالك يجنيها لو أن الشئ كان في حيازته. وهو ملتزم بدفع الفوائد عن الثمار التي يلتزم بردها بالسعر القانونى من وقت قبضها أو من الوقت الذى كان من المفروض أن يقبضها فيه (١).

وإذا كان الحائز سيئ النية يلتزم برد الثمار، فإن المالك يلتزم بأن يرد إليه قيمة المصروفات التي أنفقها فى إنتاجها كأجر العمل ومصروفات الصيانة وما يتقل من ضرائب ورسوم وتكاليف أخرى.

وقد تستهلك الثمار فيستحق عنها تعويض أو تكون الثمار مبلغاً من النقود هو ريع الشئ. وفى هذه الحالة تصبح الثمار ديناً فى ذمة الحائز تجوز المطالبة به مع الشئ أو استقلالا ~~في ٢٠٢٤/٢٠٢٤~~ وفى هذه الحالة لا يكون هذا الدين ديناً دورياً متجدداً، فلا ينقضى بالتقادم إلا بمضى خمس عشر سنة من تاريخ استحقاقه.

مسئولية الحائز عن هلاك العين أو تلفها :

يفرق القانون فى هذا الشأن بين مسؤولية الحائز حسن النية ومسئولية الحائز سيئ النية. إذا كان الحائز حسن النية ويعتقد أن الشئ المملوك له، فإنه ينتفع به كما ينتفع المالك بملكه. فله أن يستعمله وأن يستغله ولا يكون مسئولاً قبل المالك عن أى تعويض بسبب انتفاعه بالشئ. وفى ذلك تنص المادة ٩٨٣ على «إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشئ وفقاً لما يحسبه

(١) د السنهاورى : الوسيط ، ج ٩ ص ١١٩٢ ، د حسن كيرة : ص ٤٦٦ ، د مصطفى الجمال : ص ٣٠١ .

من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع، بل لا يكون الحائز مسئولاً عما يصيبه الشيء من هلاك، أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف م٩٨٣/٢ مدنى.

ويرى جانب من الفقه (١) أن هذه القاعدة تقتصر على هلاك الشيء فى يد الحائز لسبب أجنبى، أما إذا هلك الشيء بخطئه فالواجب تطبيق القواعد العامة ويكون الحائز مسئولاً عن التعويض. فى حين يرى البعض (٢) - ونؤيده - أن الحائز حسن النية لا يسأل عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك راجعاً إلى فعله إذ لا يمكن اعتبار ذلك خطأ منه ما دام يعتقد أنه هو المالك وأنه ليس فى حيازته اعتداء على حق الغير.

أما إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً فى يد من يستحقه م٩٨٤ مدنى، شأنه فى ذلك شأن المدين إذا هلك محل الالتزام فى يده بعد اعداره بتسليمه، على إن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق حتى إذا تبين أن الشيء كان يهلك أيضاً ولو بقى فى يد المالك.

الفرع الثانى

كسب الحقوق العينية

يترتب على الحيازة إذا ما توافر لها عناصرها مضافاً إليها شروط أخرى اكتساب الحق. فحيازة المنقول بحسن نية وبسبب صحيح سبب فى اكتساب ملكيته. وإذا اقترن بالحيازة سبب صحيح وحسن نية واستمرت مدة قصيرة فإنه

(١) د السنهورى: الوسيط، ج-٩، ص ٩٧٨، د جمال زكى: ص ٥٥٢، د عمران: ص ١٨٨.

(٢) د الصدة: ص ٦٩٣، د منصور مصطفى: ص ٤٤١.

يترتب عليها اكتساب الحق بالتقادم القصير، أما إذا استمرت الحيازة مدة طويلة فإنه يترتب عليها اكتساب الحق أيضاً وهو ما يسمى بالتقادم الطويل. وسنعرض أولاً لكسب الحقوق العينية على المنقول كسباً فورياً بالحيازة ثم لكسب الحقوق العينية بالتقادم .

الغصن الأول

الحيازة فى المنقول سند الملكية

تنص المادة ٩٧٦ مدنى على «١- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً علنياً على منقول أو سنداً لحامله، فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته. ٢- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتبار الشئ خالياً من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها. ٣- والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك.

2024/2025

هذا النص يتناول قاعدة شهيرة تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند للملكية فيكسب الحائز ملكية المنقول وأيضاً الحق العيني موضوع الحيازة عليه مجرد حيازته له متى كان حسن النية، واستند فى حيازته إلى سبب صحيح، بحيث تعتبر الحيازة وحدها بهذين الشرطين سبباً لكسب الملكية فى المنقول، لأن الحائز يكسب بها ملكية المنقول الذى حازه لو كان من سلمه إليه غير مالك له وعجز من ثم تصرفه عن نقل الملكية.

وتملك المنقول بالحيازة على هذا النحو أمر تقتضيه لا سرعة التعامل فى المنقول فحسب، بل أيضاً استقرار التعامل والثقة فى المعاملات المالية. إذ يتعذر فى أغلب الحالات إعداد محررات تثبت التصرفات التى ترد على المنقول، فلا بد من الركون إذن إلى حيازة من يريد التعامل معه باعتبارها علامة ظاهرة لحقه على المنقول الذى يحوزه^(١).

(١) د/ السنهورى الوسيط : ٩ ، ص ١١١٧ ، د/ حسن كيره : ص ٤٧٥ ، د/ جمال زكى : ص ٥٧٢ .



(١) « وكان الظاهر أن مقصود الحكم من استفادة إلى قاعدة الحياة في المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتب المطبوعة باعتبارها منقولة مادياً يجوز حيازته لإجازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون » نقض مدني ١٢/٥/١٩٦٦ طعن ٣٥٦ لسنة ٣٢ ق ، ١٧ ص ١١٤ .

(٢) د/ السنهوري الوسيط : ٩ ص ١١٢٧ ، د/ جمال زكي : ص ٥٧٢ ، د/ محمد عمران : ص ١٩٢ .

ويدخل فى نطاق تطبيق المادة ٩٧٦ مدنى الحقوق العينية على المنقولات بشرط أن يكون الحق العينى على المنقول قابلا للحيازة. ويقبل الحيازة من الحقوق العينية حق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله ورهن حيازة المنقول وحق الامتياز على المنقول، فكما أن مشتري المنقول من غير مالكة يكسب الملكية بحيازته، كذلك من يترتب له حق انتفاع أو رهن حيازي على المنقول من غير مالكة يكسب الانتفاع أو الرهن بحيازته. ويعتبر مؤجر العقار فى حكم الحائز بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة. وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى الفندق، ويكون من ثم لكل منهما الامتياز على تلك المنقولات أو هذه الأمتعة. ولو كانت مملوكة للمستأجر أو للنزيل.

الشرط الثانى : الحيازة

يجب لتطبيق القاعدة حيازة المنقول حيازة قانونية. والحيازة القانونية مفترضة مع قيام الحيازة المادية اذ وجود الركن المادى فى الحيازة قرينة على توافر ركنها المعنوى. وتوافر الركن المادى يتحقق بوجود ذات المنقولات المراد اكتساب الحق العينى عليه تحت يد الحائز. ويجب أن تكون الحيازة فعلية، وهى التى تتحقق بتسلم المنقول ماديا، أما الحيازة الحكيمة ومثالها ترك المنقول مع البائع على سبيل الإيجار فلا تكفى. وكذا الحيازة الرمزية كتسليم سند النقل أو مفاتيح المنقول لا يكفى ليرتب عليها القانون أثرا فى اكتساب الملكية (١).

(١) د/ حسن كيرة : ص ٤٧٩ ، د/ جمال زكى : ص ٥٧٤ ، د/ محمد عمران : ص ١٩٣ ، د/ منصور مصطفى : ص ٤٤٦ ، وعكس ذلك السهنورى الوسيط ص ١١٣٤ ، د/ البدرأوى : ص ٥٤٧.



ويجب ذلك لانطباق القاعدة أن يتعلق الأمر بحيازة صحيحة خالية من العيوب، لا إكراه فيها ولا لبس ولا تحتل على أنها من أعمال التسامح^(١)، وأن يتوافر لدى الحائز فيه الحيازة لحسابه لا لحساب الغير.

الشرط الثالث : السبب الصحيح

يجب للإفادة من الأثر المكسب لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز أن تكون حيازة الحائز للمنقول بسبب صحيح، وهذا الشرط يبين بوضوح من نص المادة ١/٩٧٦ مدنى حيث تقول «من حاز بسبب صحيح منقول».

والسبب الصحيح كما يعرفه الفقه هو كل تصرف قانونى صادر من غير صاحب الحق ويكون من شأنه نقل الحق لو أنه كان صادرا من صاحبه الحقيقى. مثال إذا اشترى شخص منقولا من غير مالكه، أو إذا باع شخص أحد منقولاته ببيعين متعاقبين إلى شخصين مختلفين، ولم يتسلم المشتري السابق وإنما تسلمه المشتري اللاحق، فيعتبر البيع لهذا المشتري الأخير صادرا من غير مالك، لذلك يصلح هذا البيع سببا صحيحا لتملك المشتري اللاحق للمنقول الذى يحوزه طالما أنه حسن النية²⁰

2024/2025

الشرط الرابع : حسن النية :

لا يكفى للتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وجود سبب صحيح بيد الحائز، بل ينبغى فضلا عن ذلك أن يكون حسن النية والمقصود به اعتقاد الحائز أنه إنما يتلقى الحق على المنقول من صاحبه الذى يملك التصرف فيه، وليس المقصود بحسن النية الحائز جهله بكافة ما يشوب التصرف الذى انتقلت به الملكية إليه من عيوب، فقد يكون التصرف مشوبا

(١) «لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين، وإنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها، ولا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون انقطاع، وإنما يكفى أن يستعمله المالك فى العادة، وعلى فترات متقاربة منتظمة» نقض مدنى ١٩٧٣/٢/٨ طعن رقم ٣٨٧ لسنة ٣٧ ق. س ٢٤ ص ١٧٥.

وحسن النية المعتقد به فى شأن حياة المنقول هو حسن النية وقت بدء الحياة م ١/٩٧٦ مدنى، فإذا بدأت الحياة بحسن نية فلا عبرة بسوء النية الطارئ بعد هذا البدء، إذ الأثر المكسب لحياة المنقول أثر فوري. فيعتبر الحائز مالك المنقول أو صاحب الحق العيني عليه فور بدء حياته بحسن نية مادام بيده سبب صحيح. فلا تأثير لسوء نيته بعد ذلك على ما تم له اكتسابه فعلا من حق عيني بالحياة.

إذا توافرت الشروط السابقة فإن حيازة المنقول تنتج أثرها المكسب أى تكسب الحق العينى الذى تلقاه بالسبب الصحيح. وزيادة فى حماية الحائز افترض الشارع قيام سبب صحيح لمصلحته، كما افترض الشارع قيام سبب صحيح لمصلحته، كما افترض حسن نيته، بحيث يتعين على المالك الذى يريد استرداد منقولة أن يثبت انعدام السبب الرئيسى كما أن عليه أن يثبت المملوك على سوء نيته وقت حيازته له (١).

2024/2025

آثار القاعدة :

- يترتب على حياة المنقول متى توافرت الشروط السابقة أثران: أثر مكتسب، فيصبح الحائز بمقتضاها مالكا للمنقول أو صاحب الحق العيني عليه. وأثر مسقط نص المشرع عليه بقوله «إذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توفر لدى الحائز في اعتبار الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية خالصة منها م ٢/٩٧٦ مدني.

(١) «الذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون وان ملكيته له مهددة بالزوال، فان استدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها والتي لا تؤدى إلى ما استخلصه منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون» نقض مدنى ١٩٧٣/٤/١٩، س ٢٤، ص ٦٤٤.



فلحيازة المنقول إلى جانب الأثر المكسب لها أثر مسقط إذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتبار المنقول خاليا من الحقوق العينية فانه يكسب ملكية هذا المنقول خالصة من هذه الحقوق. وعلى ذلك إذا اشترى شخص منقولا وكان هذا المنقول مثقلا بحق امتياز فانه يكسب ملكيته خالصة من الامتياز الذي يتقله إذا كان حسن النية يجهل وجوده، ولا يستطيع الدائن صاحب حق الامتياز أن يتبع المنقول بين يدي المشتري لاستيفاء حقه من ثمنه^(١).

وإذا كان الفرض السابق كسب الحائز بمقتضى حيازته ملكية المنقول خالصة من الامتياز المقرر عليه مادام كان يعتقد أنه تلقى المنقول من ماله وأنه اخل من الامتياز فان الحائز المنقول قد يكتسب ملكيته أو الحق العيني عليه عن طريق تصرف قانوني من صاحبه، وهنا تفيد حيازة رغم ذلك في إسقاط ما قد يظهر أن المنقول كان مثقلا به من قيد أو تكليف عيني يجهله الحائز، وحينئذ لا ترتب الحيازة إلا أثرا مسقط فحسب، إذ الفرض أن الحيازة مكتسبة من الأصل الحق العيني على المنقول بالتصرف القانوني فلا يحتاج إلى الأثر المكسب للحيازة.

ومادام اكتساب الحائز الحق العيني لا يستند إلى الحيازة وإنما يستند إلى تصرف قانوني، فمقتضى ذلك أن السبب الصحيح في ترتيب الأثر المسقط للحيازة المنقول لابد وأن يأخذ مدلولاً مختلفاً عن مدلوله في شأن ترتيب الأثر المكسب لهذه الحيازة. إذ يصح مدلول السبب الصحيح في شأن ترتيب الأثر المسقط هو التصرف القانوني الصادر من صاحب الحق والذي من شأنه نقل الحق العيني على المنقول إلى المتصرف إليه، إذا كان هذا التصرف خاليا من الإشارة إلى ما يكون مثقلا للمنقول من قيد أو تكليف عيني.

(١) د/ حسن كيره : ص ٤٨٤ ، د/ جمال زكى : ص ٥٨٠.

أما حسن النية في شأن ترتيب الأثر المسقط للحيازة فهو اعتقاد الحائز خلوا لمنقول مما يثقله من قيد أو تكليف عيني، وعلى ذلك فالحائز الذي يتلقى ملكية المنقول من مالكه بتصرف قانوني جاهلا بوجود قيد أو تكليف عيني يثقله يكتسب ملكية المنقول بالتصرف القانوني، ويتخلص من القيد أو التكليف العيني الذي يثقل المنقول بمقتضى الحيازة وأثرها المسقط.

مثال ذلك إذا باع المشتري المنقول الذي اشتراه أصلا وقبل الوفاء بكامل الثمن، فتملكه لمشتري الثاني إذا كان حسن النية يجهل بوجود امتياز البائع الأصلي عليه خاليا من هذا الامتياز آذ تنتج حيازة هذا المشتري للمنقول إثرها المسقط لهذا الامتياز.

حكم خاص بالمنقولات المسروقة أو الضائعة :

- أراد المشرع ألا يترتب على حيازة المنقول المسروق أو الضائع الأثر المكسب الذي يترتب على حيازة المنقول متى اقترنت بالسبب الصحيح وحسن النية. فنص في المادة ٩٧٧ على «١- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله سرق منه أن يسترده من يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة».

فإذا كان المنقول قد فقد أو سرق من صاحبه، فإن استرداده ممن يكون حائز له بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة. فيجب إذا توافر عدة شروط لأعمال الحكم الوارد في المادة ٩٧٧/مدنى.

الشرط الأول : أن يتعلق الأمر بمنقول وقد ساوى المشرع في الحكم بين المنقول والسند لحامله. فإذا كان المال المفقود أو الضائع منقولا أو سند لحامله أمكن إعمال الحكم الوارد في المادة ٩٧٧ مدنى.

الشرط الثانى : سرقة المنقول أو فقدته، فإذا لم يكن المنقول قد سرق أو فقد فلا محل لإعمال الحكم الوارد في المادة ٩٧٧. والمقصود بالسرقة هنا



المعنى المحدد لها في القانون الجنائي. فلا يجوز قياس خيانة الأمانة أو النصب على السرقة (١).

ويعتبر المنقول ضائعاً إذا فقد صاحبه بإهمال أو دون إهمال منه، ويعتبر كذلك أيضاً إذا كان فقد المنقول يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة المالك فيه.

الشرط الثالث : أن يباشر مالك المنقول حقه في استرداد المنقول المفقود أو الضائع في مدة أقصاها ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع. والمشرع قد حدد المدة بثلاث سنوات، وهي مدة سقوط لا مدة تقادم، لذلك لا يرد عليها ما يرد على مدة التقادم وقف أو انقطاع، وتسرى هذه المدة في مواجهة الكافة ولو كانوا ناقصي الأهلية.

فإذا كان حائز المنقول المسروق أو الضائع حسن النية فلمالكة أن يسترده على ما بيّننا في خلال ثلاث سنوات من تاريخ السرقة أو الضياع.

2024/2025

فإذا كان حائز المنقول المسروق أو الضائع سيئ النية فلمالكة المنقول أن يسترده منه ولو بعد انقضاء الثلاث سنوات بل له أيضاً استرداده ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة، لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بمضي المدة اللهم إذا كان هذا الحائز قد تملكه بمضي المدة.

وتنص المادة ٢/٩٧٧ مدني على أنه «فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية من سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذي دفعه» بهذا النص أراد المشرع أن يكفل قدرأ أكبر من الحماية للحائز حسن النية، إذا وجد في مركز قانوني خاص يجعله جديراً بالحماية. فهو ليس حسن النية فقط، أي لا يعلم أن المنقول مسروق أو مفقود،

(١) د/ السنهوري الوسيط : ٩ ، ص ١١٥٨ ، د/ منصور مصطفى : ص ٤٤٨ ، د/ حسن كيره : ص ٤٨٧.



بل اشترى هذا المنقول فضلا عن ذلك فى سوق أو مزاد أو ممن يتجر فى مثله. وهذه ملابسات خارجية تضاف إلى حسن نيته توجب أن تكون حماية القانون له أكثر فاعلية. ومن ثم فقد أعطى لهذا الحائز الحق فى مطالبة مالك المنقول أن يجعل له الثمن الذى دفعه.

والعبرة تكون بما دفعه الجائز فعلا من ثمن، ويدخل فى ذلك بالإضافة إلى الثمن ما أنفقه الحائز من مصروفات فى شرائه. بل ويدخل فى ذلك أيضا ما أنفقه الحائز من مصروفات ضرورية وفقاً لنصوص المواد ٩٢٤ ، ٩٢٥ مدنى.

الفصل الثانى كسب الحقوق العينية بالتقادم

نوعا التقادم :

التقادم سبب من أسباب كسب الملكية وسائر الحقوق العينية الأصلية الأخرى بالحيازة المستمرة لمدة حددها القانون. والأصل فى الحيازة إذا استمرت مدة خمس سنة أنها تكسب الملكية دون حاجة إلى أى شرط آخر فى الحائز. غير أن المشرع قد انقص المدة المذكورة إلى خمس سنوات إذا توافرت فى الحائز شروط معينة. واكتساب الملكية بهذا المعنى يسمى «التقادم». والأساس القانونى الذى يبنى عليه نظام التقادم المكسب كما هو راجح فى الفقه المصرى هو اعتبارات تتعلق بالصالح العام والرغبة فى استقرار المراكز القانونية.

ومن التقادم المكسب ما يسمى بالتقادم المكسب ذو المدة الطويلة وآخر يسمى التقادم المكسب القصير ونعرض لها على التوالى.

أولاً : التقادم المكسب الطويل :

شروط التمسك بالتقادم المكسب:

يجب توافر شروط التمسك بالتقادم المكسب منها ما يتعلق بالحقوق التى يجوز اكتسابها بمضى المدة، ومنها ما يتعلق بالحيازة ومنها أخيراً ما يتعلق بالمدة.

الحقوق التي يجوز اكتسابها بمضى المدة :

تنص المادة ٩٧٢ مدنى على أنه من جاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكا له أو جاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

يتضح من هذا النص أن الحقوق العينية وحدها هي التي يجوز اكتسابها بمضى المدة، سواء وردت على عقار أو منقول. وأول هذه الحقوق حق الملكية. كما يجوز اكتساب باقى الحقوق العينية الأصلية الأخرى بمضى المدة كحق الانتفاع وحق الاتفاق فيما عدا الارتفاقات غير الظاهرة، وهى التى لا توجد علامة خارجية تدل عليها (١). أما الحقوق الشخصية فلا يجوز اكتسابها بمضى المدة باستثناء السند لحامله إذ يجوز لحائزته تملكه إذا ما اقترضت حيازته له بالسبب الصحيح وحسن النية.

2024/2025

ويجب أن يكون الشئ الذى يرد عليه الحق قابلا للتعامل فيه. فمن الأمثلة ما لا يقبل التعامل فيه فلا تنتقل ملكيته ومن ثم لا يجوز تملكه بالتقادم (٢). ومن ناحية أخرى يجب أن يكون الشئ قابلا للحيازة، إذا أن التملك بالتقادم يفترض أن الشئ قد خضع للحيازة مدة طويلة. وعلى ذلك لا يكسب المالك العام بالتقادم لأنه غير قابل للتعامل فيه، كما لا يكسب المجموع من المال كالتركة بالتقادم لأنه غير قابل للحيازة.

وبموجب القانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ فان أموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة

(١) د/ حسن كيره : ص ٤٨٩ ، د/ مصطفى الجمال : ص ٣٠٤ ، د/ محمد عمران: ص ٢٠٩.

(٢) د/ السهنورى الوسيط ٩ ص ١٠٠١.

للمؤسسات العامة أو الهيئات وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية لا يجوز تملكاً بالتقادم الطويل أو القصير ولا كسب أى حق عيني عليها^(١)

أما عن حق الإرث فإن المادة ١/٩٧٠ مدنى نصت على أنه «فى جميع الأموال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة». وقد يفهم من هذا النص أن حق الإرث يكتسب بالحيازة إذا دامت مدتها ثلاث وثلاثين سنة. ولكن الفقه مجمع أن هذا النص معيب لأن التركة باعتبارها مجموعاً من المال لا تقبل الحيازة، ويكون النص على كسب حق الإرث بالتقادم الذى مدته ٣٣ سنة مخالفاً للقواعد الأساسية فى الحيازة. والحقيقة أن حق الإرث^(٢) لا يسقط إذا لم يطالب به الوارث خلال ثلاث وثلاثين سنة. فهذا التقادم مسقط لا مكسب، فإذا لم يرفع الوارث دعواه لتقرير حقه فى التركة بمثل مضى ثلاثة وثلاثون سنة على وفاة المورث، كان لبقية الورثة التمسك بسقوط دعوى بالتقادم^(٣).

ويلحظ أنه قد صدر فى ٢٤ مارس ١٩٦٤ قانون السجل العيني ليحل فى المستقبل محل قانون الشهر العقارى الشخصى المعمول به حالياً، ومتى طبق السجل العيني فإنه سوف يصبح من المستحيل اكتساب أى حق على عقار على خلاف ما هو ثابت فى السجل^(٤).

(١) «من الواجب توافر نية التملك لمن يبقى حماية جديدة بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم، فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها وكسب أى حق عيني عليها بالتقادم» نقض مدنى ١٩٧٧/١١/٩. طعن ٤٦٨ لسنة ٤٤ ق ص ٣٨ - ص ١٦٣٩.

(٢) د/ السنهورى: ص ١٠٠٧، د/ البدراوى: ص ٤٨٦، د/ جمال زكى: ص ٥٥٥

(٣) «حق الرث لا يكسب بالتقادم إنما تسقط دعوى الإرث بمضى ٣٣ سنة وللوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط

القانونية لمدة خمس عشرة سنة» نقض مدنى ١٩٧٥/٥/١٣ لسنة ٤٠ ق.

(٤) د/ مصطفى الجمال : نظام الملكية ، ص ٣٠٧.

٢ - الحيابة :

- الحيازة الصحيحة الخالية من العيوب شرط أساسى للتملك بمضى المدة (١)، فيجب أن تكون الحيازة قانونية، أى يتوافر لها عنصريها المادى والمعنوى فالحيازة العرضية لا تصلح أساساً لاكتساب الحقوق العينية بالتقادم مهما طالّت مدتها. فالمستأجر أو المودع لديه لا يملك أبداً أحدهما العين المؤجرة أو الشئ المودع بمضى المدة، إلا أن تتغير صفتها بفعل يصدر من الحائز فى مواجهة المالك يدل على تغير نيته أو بفعل يصدر من الغير، فتعتبر منذ هذا التحول فقط صالحة لتكون حيازة مفضية لاكتساب الحقوق العينية بمضى المدة، فمن هذا الوقت يمكن البدء فى حساب مدة التقادم (٢).

ويجب أن تكون هذه الحيازة سليمة وخالية من العيوب فالحيازة القانونية التى يعيها الإكراه أو الخفاء أو اللبس لا يمكن الاحتجاج بها مهما طالّت مدتها، على من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التيس عليه أمرها. ولكن إذا زالت هذه العيوب تصبح الحيازة صحيحة من وقت هذا الزوال. فإذا مضت من هذا الوقت المدة القانونية أمكن اكتساب الحقوق العينية بالتقادم والتمسك به ضد من كانت الحيازة معينة فى مواجهته أصلاً.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣ - المدة :

المدة شرط أساسى للتملك بالتقادم. وتثير المدة كشرط لازم للتمسك بالتقادم عدة مسائل. فى كيفية حسابها وبدء سريانها، ووقف التقادم وانقطاعه، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالتقادم المسقط.

(١) «يكفى للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته». نقض مدنى ١٩٨٣/١/٦. طعن رقم ٤٨٩ لسنة ٥٢ ق، س ٣٤، ص ١٣٠.

(٢) «لما كانت مدة حيازة الطاعنين التى تلت صدور حكم القسمة، لا تكفى لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون». نقض مدنى ١٩٨٠/٦/١٠ طعن رقم ٨٥٧ لسنة ٤٤ ق س ٣١ ص ١٦٩٨.

حساب المدة :

تنص المادة ٩٧٣ مدنى على أنه « تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكتسب» معنى هذا أن هذا المشرع أحال إلى القواعد المنصوص عليها فى التقادم المسقط.

وبالرجوع إليها نجد المادة ٣٨٠ مدنى تنص على «تسبب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها». فالיום الأول الذى تبدأ به الحيازة لا يدخل فى حساب مدة التقادم ويدخل فيها اليوم الأخير والعبرة فى هذا الشأن بالتقويم الميلادى لا الهجرى .

وإذا كان المالك مالكا تحت شرط واقف فلا تسرى مدة الحيازة المكسبة فى حقه إلا منذ تحقق الشرط، والحال كذلك إذا كان حق المالك حقا احتماليا، كحق الموصى له قبل وفاة الموصى، فلا تسرى مدة الحيازة المكسبة فى حقه إلا منذ أن يصبح محققا (١)، وعلى ذلك نصت المادة ٣٨١ مدنى.

2024/2025

وقد نصت المادة ٩٧١ مدنى فى شأنه إثبات مدة الحيازة على أنه «إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة مابين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس. وبناء على هذا النص إذا أثبت الحائز أن حيازته قد بدأت فى وقت معين وأنه لا يزال حائزا، افترض استمرار الحيازة فى المدة الواقعة بين بدء لحيازة ونهايتها. والقرينة القانونية التى نص عليها فى المادة ٩٧١ مدنى ليست قاطعة، بل يجوز للمالك أن يثبت عكسها بأن الحيازة وإن استمرت طوال هذه الفترة إلا أنه

(١) د/ السنهورى الوسيط ٩، ص ١٠١٧، د/ مصطفى الجمال : ص ٣٠٧ ويحيل القضاء الفرنسى وجانباً من الفقه الى القول بأن مدة التقادم تبدأ من وقت الحيازة لا من وقت الذى يتحقق فيه الشرط والذى تصبح فيه الملكية نافذة. انظر د/محمد عمران : ص ٢١٢.

قد طرأ عليها أثنائها ما يعييبها ويجعلها غير صالحة لإنتاج الأثر الذي رتبته عليها القانون (١).

وقف التقادم :

فيما يتعلق بوقف التقادم نجد أن المشرع بعد أن أحال في وقت التقادم المكسب على القواعد التي وضعها لوقف التقادم المسقط م ٩٧٣ مدنى، قضى فى المادة ٩٧٤ مدنى بأنه «أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه. فاستبعد بهذا القاعدة التى تقضى بأن الوقف لانعدام الأهلية أو نقصها لا يسرى على التقادم المسقط الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات م ٢/٣٨٢. لتخضع بذلك التقادم المكسب عدا هذا الاستثناء لقواعد الوقف فى التقادم المسقط.

فيفق التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان البائع أدبيا. وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب م ١/٣٨٢ مدنى.

والمشرع بهذا قد قضى بصفة عامة^{2024/2025} بوقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا. إلا أنه لم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر، بل تركها لقاضى الموضوع يقرر بعد ذلك ما يعتبر وما لا يعتبر من قبيل الموانع التى تحول بين الدائن وبين المطالبة بحقه^(٢).

ومن هذه الموانع القوة القاهرة فقد يستحيل معها على صاحب الحق المطالبة بحقه. ففيها يقف التقادم ما بقيت هذه الاستحالة قائمة. كذلك يقف

(١) «متى كانت المنازعة التى آثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزة لاحقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكتسبة لملكية الحائز فانه لا يعتد بها» نقض مدنى ١٩٦٧/٢/٧، طعن رقم ٢٦٦ لسنة ٣٣ ق. س ١٨ ص ٣٠٦.

(٢) د/ محمد على عمران : «وقف التقادم وانقطاعه» العلوم القانونية والاقتصادية ع ٢ س ١٤ - ١٩٧٢ ص ٣٢٤.



سريان مدة التقادم بين الزوجين بالنسبة للدعاوى التي يرفعها كل منهما على الآخر.

فرابطة الزوجية مانع من الموانع الأدبية التي تحول دون المطالبة بالحق. ويظل هذا المانع قائماً ما بقيت علاقة الزوجية قائمة. كما تعتبر أيضاً العلاقة بين الخادم والمخدوم فى بعض الحالات مانعاً أدبياً يترتب عليه وقف سريان مدة التقادم.

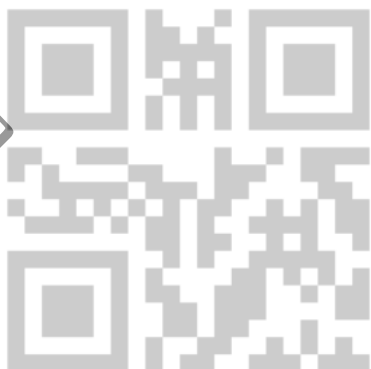
أما العلاقة بين الأصل والوكيل فقد نصت عليها المادة ١/٣٨٢ صراحة، كذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب. فالعلاقة القائمة بين الأصل ونائبه تمثل مانعاً يتعذر معه على كل منهما مطالبة الآخر بما له من حق قبله. وتقف مدة تقادم هذه الدعاوى ما بقيت الوكالة قائمة شريطة أن تكون هذه الدعاوى مما ينتج عن علاقة الوكالة القائمة بينهما.

ويعتبر سبباً لوقف التقادم جهل صاحب الحق وجود حقه بغير تقصير منه^(١). فالجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق^(٢) ولا تقصيره. وإن كان هناك من يذهب عكس ذلك بالقول بأن الجهل بالحق لا يعتبر مانعاً يترتب عليه وقف سريان مدة التقادم، إلا إذا كان العلم بالحق مستحيلاً، وهنا يقترب من فكرة القوة القاهرة. لذلك فالرأي الذي نؤيده^(٣) يرى أنه لا محل للقول بعدم سريان مدة التقادم إذا كان صاحب الحق لا يعلم به، إلا إذا كان عدم العلم مرده إلى قوة القاهرة أو سبب أجنبي، وهو التحفظ الوحيد الذي تمليه قواعد العدالة.

ويترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي يتحقق فيها سبب الوقف وتعود مدة التقادم إلى السريان من جديد متى زال السبب الذي أدى إلى

(١) د/ السنهورى الوسيط ٩ ص ١٠٣٦، د/ جمال زكى : ص ٥٥٩، د/ محمد عمران : ص ٢٢٣.

(٢) د/ محمد عمران : وقف التقادم وانقطاعه ص ٣٣٢.



وقفها. ويدخل في حساب المدة بطبيعة الحال ما يكون قد انصرم منها في الفقرة السابقة على الوقف.

انقطاع التقادم :

- يفترض التقادم المكسب وضع يد الحائز على العين طيلة المدة التي حددها القانون، وعدم مطالبة مالك العين بها طيلة هذه المدة فإذا فقدت تلك الحيازة أو قامت هذه المطالبة، تخلف أحد الشرطين اللازمين لكسب الحق بالتقادم وانقطع التقادم بتخلفه، وزال أثر المدة التي انقضت على الحيازة. فإذا انقطع التقادم بفقد الحيازة كان الانقطاع طبيعياً، وإذا انقطع بمطالبة المالك كان الانقطاع مديناً. يضاف إليها اعتراف الحائز بحق المالك، الذي يعتبر سبباً آخر لانقطاع التقادم مديناً.

الانقطاع الطبيعي : تنص المادة ٩٧٥ مدني «ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدتها ولو بفعل الغير. غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعواه باستردادها في الميعاد.

2024/2025

2024/2025

من هذا النص يتبين أن انقطاع التقادم بفقد الحيازة إما أن يكون بفعل الحائز اختياراً وإما أن يكون بغير إرادته. فإذا كان الحائز قد تخلى عن حيازته مختاراً، فإن التقادم ينقطع بمجرد هذا الخلق، وتزول المدة السابقة نهائياً حتى ولو عاد الحائز إلى حيازة الشيء ومهما كانت فترة تخليه عنه قصيرة (١).

أما إذا انتزعت منه الحيازة رغم إرادته أو دون علمه، فلا ينقطع التقادم، ويزول أثر المدة السابقة، إلا إذا استمر انتزاعها سنة كاملة.

وللانقطاع الطبيعي أثر مطلق، فلا ينقطع لتقادم فقد بالنسبة إلى من انتزع الحيازة وحدة، بل أيضاً بالنسبة إلى كل ذي مصلحة في قطع التقادم.

(١) د/ السنهوري الوسيط ٩ ص ١٠٥٨، د/ جمال زكي : ص ٥٦١، د/ محمد عمران : ص ٢٢٩.

الانقطاع المدني : يقع الانقطاع المدني بعمل قانوني، قد يصدر من المالك بالمطالبة بحقه، وقد يصدر من الحائز بالاعتراف بحق المالك.

(أ) **المطالبة القضائية** : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية^(١) وذلك برفع المالك أو صاحب الحق دعوى الاستحقاق أو دعوى الاعتراف بحقه على حائز العين أو الحق العيني عليها، يطالبه بالملكية أو بالحق العيني. فهذه المطالبة تدل على رغبة المالك في المطالبة بما له من حق. وهي قطعة للتقادم حتى ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة مكانا أو نوعا أو حتى ولاية. وعلى ذلك نصت المادة ٣٨٣ مدني «..... فيقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة».

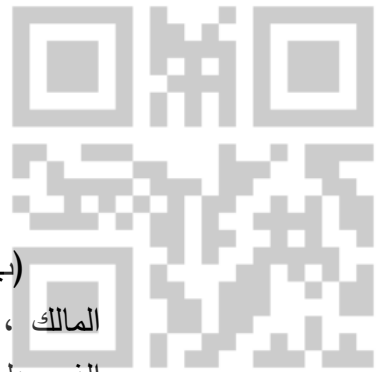
ولكن لا يكفي لقطع التقادم المطالبة الودية ولو بكتاب مسجل، ولا الإنذار على يد محضر، ولا اتخاذ الإجراءات التحفظية، بل ولا إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل التي لا تتعلق بموضوع المحق.

ويجب أن تكون صحيفة الدعوى صحيحة ومستوفية لكل الشروط^(٢) المنصوص عليها في قانوننا حتى يترتب عليها أثر في قطع التقادم. أما إذا شاب صحيفة الدعوى بطلان فإنها لا تكون قاطعة للتقادم. كذلك إذا ترك الدائن الخصومة وفقا للقانون أو حكم بسقوط الخصومة، ألغيت جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى^(٣). وزال تبعا لهذا انقطاع التقادم الذي ترتب عليها واعتبر كأن لم يكن. وكذلك إذا رفضت الدعوى لسبب لا يرجع إلى موضوع الحق ألغيت صحيفة الدعوى وزال أثرها في قطع التقادم.

والانقطاع المدني هنا نسبي في أثره على نقيض الانقطاع الطبيعي فلا يفيد منه سوى من قام به، ولا يضار سوى من إليه.

(١) «انقطاع التقادم الكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائما حتى يقضى في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم» نقض مدني ١٩٧٥/١/١٤ طعن ٢٨٤ لسنة ٤٢ ق. س ٢٧ ص ٦٤١.

(٢) م ١٤٣، ١٣٧ مرافعات.



(ب) إقرار الحائز : وينقطع التقادم المكسب أيضا بإقرار الحائز بحق المالك ، ويكون هذا الإقرار صريحا وقد يكون ضمنيا، والإقرار الصريح هو الذي يدل بطريقة مباشرة على رغبة الحائز فى الاعتراف بما للمالك من حق. والإقرار الضمني هو الذي يستدل عليه من كل عمل يقوم به الحائز يكون مفيدا لمعنى الإقرار. مثال ذلك مفاوضة الحائز للمالك فى دفع تعويض له عن العين أو دفع الحائز الضرائب عن العين لحساب المالك أو تسليم الحائز ثمار العين للمالك. وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن الطاعة قد قبلت بمقتضى محضر الجرد المذكور استلام الأرض محل النزاع بوصفها وصية على المطعون ضده الثانى تأسيسا على أنه المالك لها بالميراث عن والدته وهو ما يعد منها تنازلا عن التقادم المدعى باكتماله قبل ذلك المحضر. و إذا عول الحكم المطعون فيه على دلالة هذا المحضر فى رفضه الادعاء بتملك الطاعة لتلك الأرض بالتقادم الطويل يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى هذا الخصوص (١).

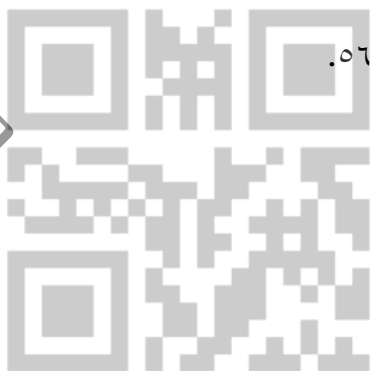
2024/2025

ويتربط على الإقرار انقطاع التقادم، فتزول المدة التى انقضت قبل حصوله ويبدأ على أثره تقادم جديد مدته خمس عشر سنة، لأن الحائز يصبح بهذا الإقرار سيئ النية، حتى ولو كان قد بدأ حيازته بحسن النية، وكان التقادم القصير ساريا لمصلحته قبل إقراره (٢). بل أن لإقرار الحائز أثر أبعد من ذلك، إذ قد لا يكون للحائز بعد ذلك أن يتمسك بالتقادم المكسب لأن الإقرار يتضمن اعترافا منه بحق المالك، فإذا ظل بعد ذلك حائزا فانه لا يجوز لنفسه بل لحساب الغير. وتكون حيازته تبعا لذلك عارضة. ولا أثر لها فى التملك بمضى المدة (٣).

(١) نقض مدنى ١٩٨٦/٥/١٩ طعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٥٢ ق.

(٢) د/ السنهورى الوسيط : ٩ ص ١٠٥٤.

(٣) د/ محمد عمران : ص ٣٣١، عكس ذلك د/ جمال زكى ص ٥٦٨.



أحكام خاصة بالتقادم المكسب :

تنص المادة ٣٨٧ مدنى « ١ - لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. ٢ - ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية». والقاعدة الواردة بالمادة ٣٨٧ مدنى تنطبق على التقادم المكسب. فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به من له مصلحة فيه. ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، بيد أنه لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأنها لا تنظر أوجه جديدة لم يسبق الدفع بها أمام محكمة الموضوع.

والذى يتمسك بالتقادم المكسب هو الحائز ويجوز لدائنيه أيضا التمسك به، وهذا ما نصت عليه المادة ٣٨٧ مدنى. وعندما يتمسك به الدائن فهو إنما يستعمل حقوق مدنيه عن طريق الدعوى غير المباشرة. فالدائن يعتمد على أن مدينه قد تملك العين بالتقادم وأن له تبعاً لذلك أن ينفذ عليها. هذا من جهة أما الأخرى فنص المادة ٣٨٧ مدنى صريح فى أن للدائن أن يتمسك بالتقادم إذا لم يتمسك به المدين أو الحائز إذا كان الأمر متعلقا بالتقادم المكسب. ولا يقصر الحق فى التمسك بالتقادم على دائنى الحائز فقط، بل لكل ذى مصلحة أن يتمسك به. فيجوز للبائع إذا كان لا يزال دائنا للمشتري يتمكن من التنفيذ بالثمن على العقار المبيع.

كما تنص المادة ٣٨٨ مدنى على أنه « ١ - لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون. ٢ - وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرابهم».



فلا يقع صحيحا النزول عن الحق في التمسك بالتقادم قبل ثبوته، ولا يثبت الحق في التمسك بالتقادم إلا بعد اكتمال مدته. أما قبل ذلك فليس للحائز سوى مجرد أمل. فإذا نزل الحائز عن حقه في التمسك بالتقادم قبل البدء فيه وقع النزول باطلاً. أما بعد ثبوته فإنه يقع صحيحا.

أما في أثناء سريان التقادم، فإن ذلك يعتبر إقراراً بحق المالك يترتب عليه عدم الاعتداد بما مضى من مدة لتبدأ بعد ذلك تقادم جديد مختلف عن الأول. وليس للنزول عن الحق في التمسك بالتقادم شكل خاص، كما أنه قد يكون صريحا أو ضمنيا. ولما كان النزول عن الحق في التمسك بالتقادم يعتبر تصرفا قانونيا، لذا يجب أن يتبع في إثباته القواعد العامة في الإثبات.

ثانيا : التقادم المكسب القصير في العقار :

التقادم القصير يرد على العقارات وحدها، فلا تكسب به الحقوق العينية على المنقولات لأن هذه الحقوق إما أن تكتسب اكتساباً فورياً بمجرد الحياة إذا توافرت شرائط أعمال قاعدة الحياة في المنقول سند الحائز، وإما أن تكتسب بالتقادم الطويل عند تخلف هذه الشروط 2024

2024/2025

وقد نص المشرع على اكتساب الحقوق العينية العقارية بالتقادم بقوله « إذا وقعت الحياة على عقار أو حق عيني وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات»، م ١/٩٦٩ . من هذا النص يتبين شروط اكتساب الحقوق العينية بالتقادم القصير وهي ثلاث السبب الصحيح، وحسن النية، وامتداد الحياة خمس سنوات.

الشرط الأول : السبب الصحيح :

عرف المشرع في المادة ٣/٩٦٩ السبب الصحيح في اكتساب الحقوق العينية العقارية بالتقادم القصير بأنه «.... سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحب للحق الذي يراد كسبه بالتقادم» فالسبب الصحيح هو



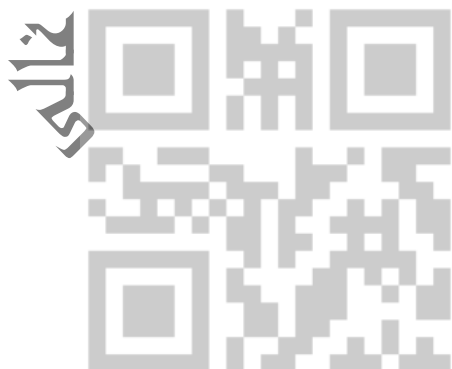
تصرف قانونى يصدر من غير صاحب الحق ويكون من شأنه نقل الحق لو أنه كان صادرا من صاحب الحق. فالسبب الصحيح تصرف ناقل بطبيعته للحق ولا ينقضه ليحقق هذا الأثر إلا صدوره من غير صاحب الحق.

وبناء على ذلك يخرج من عداد السبب الصحيح كل ما يعتبر واقعة قانونية مثل الإرث. فلا يستطيع الوارث حسن النية أن يستند غالى الإرث كسبب صحيح يمتلك بمقتضاه بالتقادم القصير عقار كان فى حيازة المورث. ولكن إذا كانت حيازة المورث مبنية على سبب صحيح أصلا يفيد الوارث من ذلك ويصح له التمسك بالتقادم القصير بناء على هذا السبب الصحيح وليس بناء على الإرث وحده.

وإذا كان السبب الصحيح تصرف قانونى فيجب أن يكون من شأن هذا التصرف نقل الحق العيني، أى يكون من التصرفات الناقلة، لذلك يخرج - فى الأصل - عن عداد السبب الصحيح كل التصرفات الكاشفة، كالقسمة والصلح والأحكام القضائية (١).

2024/2025 وإذا كان التصرف القانونى 2024/2025 السبب الصحيح - غير مسجل فهل يمكن اعتباره سببا صحيحا يكتسب به الحائز الحق إذا ما اقترن بحسن النية، أم أنه يجب تسجيل هذا التصرف القانونى حتى يمكن اعتباره سببا صحيحا. أثارت هذه المسألة خلاف فى الفقه المصرى فى ظل التقنين الملغى وقبل صدوره قانون التسجيل الصادر سنة ١٩٢٣، وقانون الشهر العقارى الصادر سنة ١٩٤٦. فلما صدر القانون المدنى الجديد نصت المادة ٣/٩٦٩ على أنه السبب الصحيح... يجب أن يكون مسجلا». وبذلك حسم المشرع الخلاف

(١) د/ السنهورى الوسيط : ٩ ص ١٠٩٢ ، د/ منصور مصطفى : ص ٤٢٢ د/حسن كيره : ص ٤٩٢.



وأصبح التسجيل لازماً حتى يمكن أن يعتبر التصرف القانوني سبباً صحيحاً^(١).

غير أنه من الواضح أن اشتراط التسجيل السبب الصحيح يؤدي إلى ندرة اكتساب الحقوق العينية الأصلية العقارية بالتقادم القصير، لأن التسجيل لا يسمح به في الشهر العقاري إلا إذا كان سند المنصرف نفسه مسجلاً أو كان حقه ثابتاً في الأصل.

ولا يعتبر التصرف الباطل بطلاناً مطلقاً سبباً صحيحاً، فهو تصرف لا وجود له، ولا يترتب عليه اكتساب الحق وفقاً لقواعد التقادم المكسب القصير إذ ما اقترن به حسن النية. في حين يعتبر التصرف القابل للبطلان سبباً صحيحاً. وإذا كان التصرف القانوني الناقل للملكية معلقاً على شرط واقف فإنه لا ينفذ إلا من وقت تحقق الشرط، وعلى ذلك فإنه لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً إلا من هذا الوقت. أما إذا كان التصرف معلقاً على شرط فاسخ فإنه ينفذ منذ البداية، ويصلح باعتباره سبباً صحيحاً.

2024/2025

2024/2025

الشرط الثاني : حسن النية :

لا يكفي أن يتوافر لدى الحائز السبب الصحيح، بل يجب فضلاً عن ذلك أن يكون حسن النية. وحسن النية يعني أن يجهل الحائز أنه يتعامل مع غير مالك. أما إذا كان على علم بذلك^(٢)، أو كان جهله به يرجع إلى خطئه

(١) « لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون في قد خلص إلى انتفاء صفة الحائز عن الطاعة الأولى على ما يثبت من أنها لم تسجل عقد شرائها كما لم يصدر لصالحها حكم بصفة عقد البيع المذكور، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النص عليه بهذا السبب على غير أساس». نقض مدني ١٩٨٦/٣/٢٧ طعن رقم ٢١٣٦ لسنة ٥٢ ق .

(٢) «يكفي لانتفاء حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي مجرد شك المتصرف إليه حين تلقى التصرف في اعتقاده بأن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، وكان التصرف على حسن نية فيه المتصرف إليه أو سوء نية هو من مسائل الواقع التي تنتقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغاً. نقض مدني ١٩٨٦/٥/١٨ طعن رقم ٨٥ لسنة ٥١ ق .



الجسيم فإنه لا يعتبر حسن النية. ولا كون له تبعا لذلك التمسك بالتقادم المكسب القصير.

والأصل أن حسن النية دائما مفترض ما لم يقيم الدليل على العكس م ٣/٩٦٥ مدنى فعلى من يدعى العكس تحمل عبء الإثبات سواء نية الحائز. ويتحقق إثبات سوء النية أساسا بإثبات علة الحائز أن يعتدى على حق الغير أى بأنه تلقى الحق من غير صاحبه (١). وغير أن إثبات هذا العلم قد يكون عسيرا، لذلك يسر المشرع إثبات سوء نسبة الحائز عن أحد طريقين آخرين، إثبات الخطأ الجسيم من جانب الحائز، وإثبات اغتصاب حيازة العقار بالإكراه (٢).

وقد حدد المشرع الوقت الذى يعتمد فيه بحسن النية للتمسك بالتقادم القصير فإنه وقت تلقى الحق (٣) م ٢/٩٦٩. فإذا تعلق الأمر بحق عينى أصلى عقارى فينبغى لاكتسابه بالتقادم القصير أن يكون الحائز حسن النية وقت تسجيل السبب الصحيح لا وقت صدوره. فالمشرع لا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق فحسب، ولذلك فإذا كان الحائز حسن النية وقت تسجيل السبب الصحيح فلا عبرة بما يطرأ بعد ذلك من سوء نية فيكون له رغم ذلك التمسك بالتقادم القصير إذا توافرت باقى شروطه. وإذا كان سيئ النية وقت تسجيل السبب الصحيح فلا ينفعه حسن نية السابق وقت صدور هذا السبب فلا يملك إذن التمسك بالتقادم القصير رغم توافر باقى شرائطه.

(١) نقض مدنى ١٩٨٨/٤/٢٦ طعن رقم ٧٩٢ لسنة ٥٥ ق.

(٢) د/ السنهورى الوسيط ٩ ص ١١١، د/ منصور مصطفى : ص ٤٢٧، د/ حسن كيره : ص ٥٠٠.

(٣) «من المقرر فى القانون المدنى القديم وقتنه المشرع فى المادة ٢/٩٦٩ من القانون المدنى أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق». نقض مدنى ١٩٧٠/٤/٣٠ طعن رقم ٢٦ لسنة ٣٦ ق ، س ٢١، ص ٧٤٨.



الشرط الثالث : الحيابة والمدة :

الحيابة قاسم مشترك بين كل من نوعى التقادم الطويل والقصير ويجب أن يكون هذه الحيابة سليمة وخالية من العيوب. وأن يتوافر لها عنصريها المادى والمعنوى (١). بيد أنه يجب أن ترد الحيابة هنا على عقار أو على حق من الحقوق العينية العقارية. أما إذا أوردت الحيابة على منقول وتوافر لدى الحائز بالإضافة إلى الحيابة فى المنقول بحسن نية سنة الحائز.

والمدة هى الأخرى قاسم مشترك بين كل من نوعى التقادم الطويل والقصير. غاية ما فى الأمر أن المدة اللازمة هنا لاكتساب الحق بالتقادم القصير هى خمس سنوات خلافا للتقادم الطويل ومدته خمسة عشر سنة. فمدة الخمس سنوات لا تكفى ولو كانت مقترنة بحيابة صحيحة للتملك بالتقادم، والمدة القصيرة، بل يجب أن يضاف إليها السبب الصحيح وحسن النية.

2024/2025

وإذا توافرت الشروط اللازمة لاكتساب الحق بالتقادم وتمسك به الحائز ^{2024/2025} قضت به المحكمة. وهذا يعنى أن المحكمة ^{2024/2025} لا تقضى به من تلقاء نفسها. وإذا تمسك الحائز بالتقادم لحسنى ولم تكن شروط متوافرة فلا يكون للمحكمة أن تقضى بالتقادم الطويل حتى ولو كانت شروط متوافرة (٢). وللتمسك بالتقادم أثر

(١) «إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين باكتساب مورثهم - المشتري الذى قضى الفسخ عقد شرائه فى ملكية أعيان النزاع موضع اليد المدة الطويلة، وانتهى إلى أن حيازته عرضية غير مقترنة بنية التملك فلا تصلح سببا لكسب الملكية بالتقادم - إذ أن وضع يده كان مستند إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن وقيمة الإصلاحات التى أجراها، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه فان النص على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله» نقض مدنى ١٩٧٧/٣/٣٠ طعن ٤٢٩ لسنة ٤٢ ق.

(٢) «إن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم الخمسى لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتل الإبهام ولا يغنى عنه التمسك بالتقادم الطويل لأن لكل منهما شروطه وأحكامه». نقض مدنى ١٩٨٣/٦/١٦ طعن ١٠٨ لسنة ٥٠ ق.

رجعى فيعتبر الحائز مالكا لا من وقت الذى يتمسك فيه بالتقادم أو بحكم له به، بل من وقت بدء الحيازة. ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها (١) :
أن الحائز لا يلتزم برد الثمار حتى ولو لم يمتلك هذه الثمار استقلالاً بالقبض أو بالتقادم.

إذا رتب الحائز لا يلتزم برد الثمار حتى ولو لم يمتلك هذه الثمار استقلالاً بالقبض أو بالتقادم.

إذا رتب الحائز خلال مدة التقادم حقاً عينياً على العين التى حازها ثم تملكها بعد ذلك بمضى المدة، فإن هذا الحق يصبح باتاً ونافاً للحائز يعتبر مالكا منذ بدء حيازته.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. السنهورى : الوسيط ح ٩ ص ١٠٧٤ ، د. محمد عمران ، ص ٢٤٢.

١٥٠



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الباب الثانى أحكام حق الملكية

تمهيد وتقسيم:

لما كانت الحقوق العينية الأصلية متنوعة ومتعددة، فإن السلطات التى تخولها ليست واحدة، إلا أنه مهما تنوعت السلطات التى يخولها الحق فإنها لا تخرج عن الاستعمال والاستغلال والتصرف. لذلك كان من الطبيعى أن يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية الأصلية جميعاً، إذ هو الحق الذى يجمع فى يد صاحبه هذه السلطات الثلاث معاً. وهو على هذا النحو يعتبر أساس الحقوق العينية التى تنفرع عنه، ذلك أن هذه الحقوق لا تخول إلا إحدى هذه السلطات الثلاث أو اثنتين منها. لذلك فإن لدراسة حق الملكية أهميته من حيث تيسير مواجهة تلك الحقوق.

وقد عنى القانون المدنى المصرى بحق الملكية وأفرد له باباً مستقلاً، تكلم فيه عن حق الملكية بوجه عام، حيث عرض لنطاقه ووسائل حمايته، وللقيود التى ترد عليه، ثم عرض للملكية الشائعة، وتكلم فى فصل مستقل عن أسباب كسب الملكية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وقد تعرضنا فى الباب الأول لأسباب كسب الملكية، أما فى هذا الباب فنعرض لحق الملكية بوجه عام، حيث يقتضى الوقوف على ماهيته أن نحله كى يتبين الأساس الذى يقوم عليه، والخصائص التى يتميز بها هذا الحق، والعناصر أو المكونات التى ينطوى عليها، والنطاق الذى يباشر فيه المالك حقه، ثم نعرض للقيود التى ترد على الملكية لننتهى إلى الملكية الشائعة فنبين أحكامها. وذلك فى ثلاث فصول على التوالى:

الفصل الأول : حق الملكية بوجه عام.

الفصل الثانى : القيود التى ترد على الملكية.

الفصل الثالث : الملكية الشائعة.

١٥٢



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الأول

حق الملكية بوجه عام

لم يعرف القانون المدنى المصرى الملكية، وإنما تنص المادة ٨٠٢ منه على أن «لمالك الشئ وحده فى حدود القانون، حق استعماله، واستغلاله والتصرف فيه». ويلاحظ على هذا النص أنه يستوعب كل عناصر حق الملكية، أى السلطات التى تكون للمالك على الشئ وهى الاستعمال والاستغلال والتصرف.

والتعريف يبرز أن حق الملكية مقصور على صاحبه إذ يبدأ النص بعبارة «لمالك الشئ وحده» وهذا يعنى أن حق الملكية حق جامع مانع^(١)، أى شامل لكل السلطات الممكنة ومقصور على صاحبه، وهى أبرز خصائص حق الملكية. كما أن النص بقوله أن المالك يزول حقه فى حدود القانون يقرر أن حق الملكية ليس مطلقاً بل مقيداً. ولفظ القانون الوارد فى النص هنا مطلق يشمل كل حكم قانونى يقيد من سلطات المالك^(٢) أياً كان مصدره سواء كان التشريع أم العرف أم أية قاعدة من قواعد القانون.

2024/2025

وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نعرض فى الأول منهما لنطاق حق الملكية، أما المبحث الثانى فخصائص هذا الحق.

(١) د السنهاورى : الوسيط ح ٨ ص ٦٦٠، د توفيق فرج: ص ٥٧.

(٢) قضت محكمة النقض «مؤدى نص المادة ٨٠٦ مدنى أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك فى استعماله إياه يجب أن يعمل فى حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأى التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية». نقض مدنى ٢١-١١-١٩٨٢ طعن رقم ٢٢٣٣ لسنة ٥١ ق س ٣٣ ص ٩٨٤.

المبحث الأول نطاق حق الملكية

يتحدد نطاق حق الملكية بمدى سلطات المالك، ومحل حق الملكية. فسلطات المالك تشكل النطاق المعنوي لحق الملكية^(١) ومحل حق الملكية يشكل النطاق المادي لهذا الحق. ونبحث كل من النطاقين في مطلب مستقل.

المطلب الأول النطاق المعنوي لحق الملكية (سلطات المالك)

نصت المادة ٨٠٢ مدنى على أن لمالك الشئ وحدة، فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وقد أبرز هذا النص العناصر التى يتميز بها حق الملكية، فإذا أصبحت هذه العناصر فى يد شخص واحد، كانت له الملكية التامة.

فالمادة ٨٠٢ مدنى تجعل لمالك الشئ استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وهذه السلطات يعتبرها الفقه عناصر حق الملكية. ولا يخرج عمل يقوم به المالك عن أن يكون مباشرة لإحدى هذه السلطات أو تمهيدا لمباشرتها.

2024/2025

أولاً: الاستعمال:

يقصد بالاستعمال سلطة المالك فى استخدام ملكه فيما هو قابل أو صالح له من أوجه الاستخدام، وفى الحصول من وراء ذلك على الخدمات أو المنافع غير الثمار والمنتجات الممكن استخلاصها منه.

واستثناء الثمار هو الذى يفرق بين الاستعمال والاستغلال^(٢)، فاستعمال المنزل يكون بالسكن فيه، والسيارة بركوبها، أما تأجير أى منهما فلا يعتبر

(١) د. عبد الناصر العطار: شرح أحكام الملكية، طبعة ١٩٩٠، ص ١٣.
(٢) هناك جانب من الفقه يفرق بين الاستعمال والاستغلال ليس على أساس نتيجة القيام بعمل معين بل على أساس شخص من يقوم بهذا العمل، د. أحمد سلامه: المرجع السابق، ص ١٠٣.



استعمالاً بل استغلالاً إذ هو يخول المؤجر الحصول على الأجرة وهي من الثمار.

غير أن الأمر لا يعرض دائماً بهذا الوضوح، فقد يصعب الفصل بين الاستعمال والاستغلال خاصة فيما يتعلق بالأرض الزراعية، إذ يصعب تصور إمكان استعمالها بغير زراعتها والحصول على ثمارها. وإن كان من الجائز استعمال المالك للأرض الزراعية من غير استغلال، ويكون ذلك بغرض التنزه أو ركوب الخيل أو الصيد (١)، إذا أنشأ ملجأً أو مستشفى على وجه التبرع دون أن يقصد استغلال شيء من ذلك (٢).

أما التفرقة بين الاستغلال والتصرف فهي واضحة إلا فيما يتعلق بالأشياء التي لا تقبل الاستعمال المتكرر، أي التي تستهلك بمجرد الاستعمال، فتقرير حق استعمال عليها للغير يتضمن في نفس الوقت نقل ملكيتها إليه، إذ أن استهلاك الشيء لا يكون إلا للمالك.

على ذلك فالاستعمال هو استخدام شيء في الغرض الذي أعد له، وبحسب ما تسمح به طبيعته، وللمالك حرية اختيار الطريقة التي يستعمل بها حقه. ويدخل في ذلك أيضاً حرية المالك في عدم الاستعمال (٣). وإن كان القانون لا يرتب - في الأصل - جزاء على عدم استعمال المالك لملكه من حيث إسقاط حقه بعدم الاستعمال، إلا أنه نظراً لأن الملكية وظيفة اجتماعية فنجد أن المشرع يتدخل ويضع جزاء في حالة عدم استعمال المالك لملكه. والمثال الواضح لذلك قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة في مصر (٤).

(١) د / حسن كيره : المرجع السابق ص ٧٥ ، د / منصور مصطفى المرجع السابق ص ٢٦ ، د / الصدة : المرجع السابق ، ص ٣٧.

(٢) د / السنهوري : الوسيط ٨ ص ٤٩٧ ، د / إسماعيل غانم : المرجع السابق ص ٤٦.

(٣) د / حسن كيرة : المرجع السابق ص ٧٧ ، د / توفيق فرج : المرجع السابق ص ٩٧.

(٤) حرم المشرع في المادة ٨ من القانون ٤٩ لسنة ٧٧ بشأن إيجار الأماكن إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد عن أربعة أشهر، واعتبر في حكم



ثانياً: الاستغلال:

العنصر الثاني من عناصر الملكية هو الاستغلال، وهو الحق في ثمار الشئ ومنتجاته. فلمالك الشئ حق الاستغلال عن طريق الحصول على ما يغله ثماراً ومنتجاتاً. وليس في نصوص القانون تعريف للثمار، ولكن المادة ٩٧٨ مدنى تشير إلى تقسيمها إلى نوعين :

الأول : الثمار المادية وهى ما يغلها الشئ طبيعياً دون تدخل من جانب الإنسان مثل كلاً المراعى الطبيعية ونتاج الحيوان وصوف الأغنام، وإما أن يتدخل الإنسان فى إنتاجها كالمزروعات وتسمى ثماراً مستحدثة.

الثانى : أما النوع الثانى فتشمل الثمار المدنية وهى عبارة عما يغله الشئ من دخل نقدى يقوم الغير بالوفاء به نظير انتفاعه بالشئ كإيجار المبانى والأراضى الزراعية (١) وفوائد رؤوس الأموال.

والثمار أياً كان نوعها . طبيعية، مدنية . هى كل ما يتولد عن الشئ فى مواعيد دورية دون مساس بجوهر الشئ ذاته. فهناك شرطان لكى يعتبر ما يغله الشئ ثماراً، هما الدورية، وعدم المساس ^{2024/2025} بالجوهر، أى عدم الانتقاص من الأصل. على أن لا يشترط فى الدورية أن تكون فى مواعيد متقاربة، فقد يكون ذلك على فترات متباعدة، كما أن عدم المساس بجوهر الشئ ذاته ليس بالخصيصة المطلقة، فالمزروعات تعتبر ثماراً رغم أنها تؤدى بمرور الزمن إلى استنفاد خصوبة الأرض.

إبقاء خالياً التعمد فى إعدادها للاستغلال وأجاز للمحافظ أن ينبه على المالك لإعداد البناء للاستغلال من مهله يحددها، وهذا قيد خطير على سلطة الملاك تبرره المصلحة العامة، أن أحسن استخدام هذا أو على الأقل وضع موضع التطبيق العملى. راجع البحث المشار إليه، د/ نبيلة رسلان: ص ١٢٨ ومابعداها. (١) يلاحظ أن قوانين إيجار الأماكن قد حددت الاجرة بحيث لا يكون للمالك الحرية فى أن يحصل من ملكه على كل التجار المدنية التى كان يمكن أن يقلها. وكذلك مايفرضه قانون الإصلاح الزراعى من تحديد أجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة.

2024/2025



أما المنتجات فهي ما يغله الشئ دون أن يكون هذا بصفة دورية مع استهلاك مادته. ذلك مثل المواد التي تستخرج من المحاجر غير المستغلة والمعادن التي تستخرج من المناجم، وفي هذا كله يلزم ألا يكون لما يؤخذ صفة الدورية وأن يستهلك من جوهر الشئ ومادته وينتقص منها.

على أنه قد يكون للإرادة دخل في تغير وصف المنتجات أو الثمار، فقد يتم إعداد الشئ بطريقة تجعله يغل بصفة دورية، وفي هذه الحالة تعتبر المنتجات ثماراً رغم اقتطاعها من مادته. ويطلق الفقه على الثمار في هذه الحالة ثماراً بالتخصيص، نظراً لأن الإرادة تتدخل في إعداد وتخصيص الشئ بحيث تجعل منتجاته دورية منتظمة، فالدورية هي العلامة المميزة للثمار^(١).

ومهما يكن من أمر التفرقة بين الثمار والمنتجات ومدى مرونتها، ولكنها ليست بذى أهمية فيما يتعلق بحق المالك، فلأخير الحق في الحصول عليها جميعاً دون تفريق، إذ هو يحصل على الثمار بما له من سلطة الاستغلال، ويحصل على المنتجات باعتبارها تمثل أجزاء من ملكه نفسه. لذلك تنص المادة ٨٠٤ مدنى «على أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك»^{2024/2025}

2024/2025

ولكن تبدو التفرقة بين الثمار والمنتجات حين تتوزع الملكية وتتجزأ سلطاتها بين المالك والغير، بحيث يكون للغير سلطة استغلال الشئ، كما هو الشأن في حق الانتفاع، حيث يكون للمنتفع أن يستعمل الشئ وأن يستغله ولكن ليس له إلا الحق في الثمار فقط دون المنتجات، ذلك أن المنتجات إنما تقتطع من الشئ وبالتالي تعد تصرفاً فيه لا يملكه المنتفع، ولهذا فإن للتفرقة بين ما يعد ثماراً وما يعد منتجاتاً أهميتها في هذه الحالة، إذ لو قيل أن ما يغله الشئ يعد ثماراً، كان لصاحب حق الانتفاع أن يحصل عليه بوصفه ثماراً.

(١) د / توفيق فرج : المرجع السابق ص ١٠١ ، د / حسن كيره المرجع السابق ص ٧٨ .



بل وتبدو أهمية التفرقة بين الثمار والمنتجات كذلك فى حالة وضع الغير يده على الشئ المملوك، إذ لو أفلح المالك فى استرداد ملكه، فإن الحائز لا يكون ملزماً برد ما سبق له قبضة من ثمار مادام حسن النية، فالحافز إذن قد يكسب الثمار، ولكنه لا يكون له حق فى المنتجات.

ثالثاً : التصرف:

السلطة الثالثة أو العنصر الثالث فى حق الملكية هو التصرف، وهذا ما أوضحتة المادة ٨٠٢ من التقنين المدنى. وللتصرف فى خصوص سلطة المالك على الشئ الذى يملكه مدلول أوسع من معناه الفنى الدقيق. فالتصرف بمعناه الدقيق يقصد منه نقل ملكية الشئ أو إنشاء حق عينى آخر عليه. ولكن فيما يتعلق بسلطة المالك فتشمل التصرف القانونى والتصرف المادى^(١).

والتصرف المادى هو العمل المادى الذى ينال من مادة الشئ وهو على هذا النحو يختلط بالاستعمال^(٢). فللمالك بما له من سلطة جامعة على الشئ أن يتصرف فيه مادياً، فيأتى جميع الأعمال المادية التى ترمى إلى استهلاك الشئ أو إعدامه أو يحول صورته بتحويله^(٣) لا رجعة فيه، وسلطة التصرف المادى فى الشئ^(٣) على هذا النحو تعتبر عنصراً خالصاً لحق الملكية يميزه عن غيره من الحقوق العينية. فجميع الحقوق العينية تخول صاحبها سلطة الإفادة من شئ مملوك للغير على نحو يتفاوت مداه من حق إلى آخر، ولكن

(١) د / جمال زكى : ص ٣٣ ، د / حسن كيره : ص ٨٠ ، د / الصدة : ص ٣٠.

(٢) د / السنهورى : الوسيط ٨ ص ٥٠١ وهو يدخل التصرف المادى فى نطاق استعمال الشئ، واستبقى للتصرف فى هذا المقام معناه المألوف وهو التصرف القانونى الذى ينقل الملكية أو حقاً عينياً آخر. نفس الاتجاه الذى يقصر التصرف فى خصوص سلطة الملك على التصرف القانونى د / أحمد سلامه : ص ١٢٧.

(٣) هناك اتجاه فى الفقه يقصر المقصود بالتصرف فى خصوص الملكية على التصرف المادى، على أساس أن المالك وحدة صاحب الحق فى المساس بمادة الشئ، د / محمد على عرفه : ص ٢٠٤ ، د / شفيق شحاته : فقرة ٩٣ ، د/البدرأوى : ص ٢٦.

بشرط المحافظة على مادة الشيء، فالمنتفع يستعمل الشيء ويستغله ولكنه يلزم بالمحافظة عليه ورده عند انتهاء حق الانتفاع (١).

ولا يقتصر حق المالك على القيام بأعمال المادية على الشيء ولكن له كذلك القيام بكافة التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زوال حقه كلياً أو جزئياً. فيستطيع أن ينقل حقه كله إلى شخص آخر بمقتضى تصرف ناقل للملكية كالبيع أو الهبة. ويستطيع كذلك أن يرتب للغير على الشيء حقاً عينياً يجرى الملكية كحق انتفاع أو ارتفاق أو يقيدها كرهن.

وسلطة المالك في التصرف القانوني سلطة كاملة تشمل الرقبة والمنفعة معا (٢) لذلك فهي أوسع مدى مما لغيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى، إذ الأخيرة لا تخول أصحابها إلا سلطة تقتصر على استعمال الشيء واستغلاله بدرجات يختلف بحسب مايتسع كل حق من هذه الحقوق، فيما تكون رقبة الشيء للمالك. فصاحب حق الانتفاع مثلاً له سلطة التصرف في هذا الحق ولكن هذه السلطة تقف عند حد التصرف في منافع الشيء، لأن حقه يقتصر على هذه المنافع ولا يمتد إلى الرقبة. أما المالك فيستطيع التصرف في رقبة الشيء ومنفعته جميعها، بل أنه هو وحده الذي يملك التصرف في الرقبة، وتصرفه هذا ينقل الملكية ذاتها إلى مالك غيره فلا تعود له إلا بسبب جديد من أسباب كسب الملكية. أما التصرف كعنصر من عناصر الملكية فانه لا ينقل الملكية من المالك إلى غيره، بل يستبقى المالك ملكه ويسترد العنصر المتصرف فيه بلا سبب جديد بل بمجرد انقضاء حق الغير (٣).

وإذا كان الأصل أن للمالك سلطة التصرف المادي وسلطة التصرف القانوني في ملكه إلا أن هناك أحوالاً تنقيد فيها تلك السلطة.

(١) انظر المادة ٩٩ مدني، المادة ٩٩٥ مدني، وبالنسبة لحق الاستعمال وحق المسكن يطبق الحكم الخاص بالانتفاع.

(٢) د / إسماعيل غانم : ص ٥٢ ، د / حسن كيرة : ص ٨١ ، د / الصدة : ص ٣٠.

(٣) د / السنهوري : الوسيط ٨ ص ٥٠٢ .

فسلطة التصرف المادى قد يحد منها تقرير حق للغير، مثل ذلك تقرير حق انتفاع لشخص على الشئ يتمتع معه على المالك أن يتصرف فى الشئ تصرفا ماديا طوال مدة الانتفاع (م ٢/٩٩٤ مدنى) أو أن يرتب لشخص آخر حق الانتفاع بالشئ خلال مدة انتفاع الأول.

ومثل ذلك أيضا تقرير حق ارتفاق على العقار لا يجوز معه لمالك هذا العقار أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة (م ١٠٢٣ / ١ مدنى).

أما سلطة التصرف القانونى فقد تنقيد فى حالات استثنائية أو يحرم المالك منها بصفة مؤقتة وذلك بمقتضى نص فى القانون أو بموجب تصرف قانونى، وبالطبع فهذا التقيد يرد على خلاف الأصل. من ذلك أنه لا يجوز لأى شريك فى ملكية الأسرة أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا (م ١/٨٥٣ مدنى) ومن ذلك أيضا ما يقتضى به قانون الإصلاح الزراعى فى خضوع ما يوزع من الأرض على صغار الفلاحين، من أنه لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بالتعهد كاملا. كما أنه يجوز أن يتعهد أو الوصية شرط يقضى بمنع المالك من التصرف فى ملكه إذا كان هذا الشرط مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة. وهو الشرط المانع من التصرف وقد عنى المشرع به لما من أهمية عمليه وقانونيه.

نخلص من ذلك أن معانى الاستعمال والاستغلال والتصرف قد تتداخل فى حق الملكية، ولا مناص من تداخلها طالما كان للمالك أن يباشر على ملكه كل السلطات التى تسمح بها طبيعة الشئ المملوك له وأحكام القانون. فضلا عن أن هذه المصطلحات ليس لها معانى محددة دقيقة.

لذلك يرى جانب من الفقه (١) وتؤيده أن ينص على أن للمالك التصرف فى ملكه والحصول على كل منفعه سواء كانت باستعمال الشئ المملوك أم

(١) د / جميل الشرقاوى : الحقوق العينية الأصلية - حق الملكية طبعة ١٩٧٤ ص ١٦، د / عبد الناصر العطار : ص ١٨.

باستغلاله أم بالتصرف فيه على أن يترك للفقهاء بعد ذلك ضرب الأمثلة على هذه المنافع.

على أن يلاحظ أنه إذا كان للمالك استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه، فهذا حق له وليس واجب عليه، إلا إذا فرض عليه القانون استعمالاً أو استغلالاً أو تصرفاً معيناً. وبالتالي فللمالك في حدود القانون ألا يستعمل ملكه وألا يستغله وألا يتصرف فيه. كأن يغلق مسكنه، ولا يؤجره ولا يتصرف فيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك. بل للمالك المنقول أن يتركه فيصير ماله مباحاً لا مالك له حتى يستولى عليه آخر فيتملكه بالاستيلاء.

ولمالك العقار أن يتخلى عنه، كما لو كان المالك شريكاً في عقار على الشيوع وأراد أن يتخلص من نصيبه في نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والتكاليف المفروضة عليه، فيتخلى عن حصته، وعندئذ تؤول بقوة القانون إلى شركائه الآخرين الذين يتحملون النفقات ويفقد المتخلى بذلك ملكيته.

وإن كان يصعب إجبار المالك على الانتفاع بكافة ما يملك من الأمور ^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} لا تقوت بها ضرورة (١)، أما إذا كان ترك الانتفاع بالشئ المملوك تقوت به ضرورة يهلك بها مال أو نفس، ففي هذه الحالة يجبر المالك قضاء على الانتفاع بملكه أو تمكين غيره من الانتفاع به.

لذلك يرى جمهور الفقهاء أن ملك الأعيان لا يقبل الإسقاط، أي الخروج من الملك إلى غير الملك، فمن عمد إلى أرض له وقال هذه تكون حبساً لا ينتفع بها، لجاز أن يشبه هذه السائبة فلا يجوز شرعاً، لما فيه من ضياع المال، ويختلف هذا عن الوقف، لأن الوقف فيه خروج من ملك البشر إلى ملك الله عز وجل.

(١) « حكم الملك ولا بد التصرف للمالك في المملوك باختياره، ليس لأحد ولاية الجبر عليه لضرورة، ولا لأحد ولاية المنع عنه وأن كان يتضرر به. إلا إذا تعلق به حق الغير فيمنع من التصرف من غير رضا صاحب الحق » البدائع ج ٦ ص ٢٦٣.

ويبدو أن الفقه الإسلامى لا يعتبر استعمال المالك لملكه، واستغلاله وكافة أوجه التصرف فيه، حقا للمالك فحسب، بل واجبا عليه يقدر القضاء مداه فى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، ويسبق بذلك فقه القانون.

المطلب الثانى

النطاق المادى لحق الملكية

(محل حق الملكية)

يراد بالنطاق المادى لحق الملكية بيان الحدود المادية لهذا الحق. وقد نصت المادة ٨٠٣ مدنى على أنه : « ١ - مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. ٢ - وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً وعمقا. ٣ - ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكيه سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها».

ويؤخذ من هذا النص أن محل الملكية ينصب أساسا على أصل الشئ المملوك، ويدخل فى هذا الأصل كل ما يعد من عناصره الشئ الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف، كما يشمل حق الملكية كذلك ما يتفرع عن الشئ من ثمار ومنتجات.

الفرع الأول

ملكية السطح ووضع الحدود

أسلفنا أن كثيراً ما يؤدى تلاصق الأراضى إلى قيام مشاكل فى خصوص تعيين حدود الملكيات المتجاورة. لذلك نصت المادة ٨١٣ مدنى على أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لا ملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شرکه بينهما.

ودعوى تعيين الحدود، دعوى عينية عقارية من اختصاص القاضى الجزئى الواقع فى دائرته الأراضى المتلاصقة أيا كانت قيمتها «م ٢/٤٣ مرافعات». وهى لا تسقط بالتقادم لأن سببها هو التلاصق بين أملاك الجيران، غير أن دعوى إعادة الحدود التى طمست تتقادم بمضى خمس عشره سنه، فإذا

تقادتت تعين رفع دعوى جديدة لتعيين الحدود، وقد تختلف عن الحدود الأولى لاكتساب أحد الملاك المجاورين جزءا من الأرض بالتقادم أو غير ذلك (١).

وترفع دعوى تعيين الحدود من المالك أو الملاك المتلاصقين، وصاحب حق الانتفاع والمحتكر وناظر الوقف والدائن المرتهن رهن حيازة، وترفع ممن يملك حق الإدارة، لأنها عمل من أعمال الإدارة ما لم تختلط بنزاع فى الملكية فتشترط أهلية التصرف.

ويعين خبير لفحص مستندات الملكية ومسح الأراضى المتلاصقة ثم رسم الحدود على الطبيعة وتحرير محضر بذلك. ويعتبر محضر التحديد ملزما لمن يوقع عليه من الملاك المتجاورين ما لم يطعن فيه. كما يعتبر ملزما إذا صدقت عليه المحكمة ولم يطعن فى حكمها أو طعن وصار حكمها نهائيا (٢).

على أن يلاحظ أن هناك farkا بين وضع الحدود وبين التسوير أو التحويط. فالإجبار يرد على وضع الحدود ولا يرد على التسوير والدليل على نص المادة ١/٨١٨ تنص على «ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط

2024/2025

2024/2025

ملكية العلو

ملكية العلو :

يترتب على أن لمالك الشئ كل ما يعد من عناصره الجوهرية أن ملكية الأرض تشمل السطح وما فوقه علوا.

وملكية العلو تفيد أن حق المالك استعمال الفراغ الذى يعلو أرضه استعمالا معقولا، ويكون هذا الاستعمال بصفة أساسيه بطريق البناء أو الغراس أو الزرع، أو تمكينا لوصول الضوء والهواء.

(١) د / السنهورى الوسيط ٨ ص ٧٤٣، د / أحمد سلامه ص ٩٠ .

(٢) «تقتصر مهمة القاضى فى دعوى الحدود على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين المتجاورين، طالما لا نزاع جدى حول الملكية كلها لعقاره أو حول العقار» نقض مدنى ١١/٦ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٥٧ س ٥١ ق.

وبناء على ذلك يكون من حق المالك أن يمنع غيره من المزامحة في هذا الاستعمال، فإذا مالت أشجار الجار بحيث احتلت قدرا من العلو الذي يستعمله جاره فحجبت الضوء أو الهواء، كان من حق هذا الأخير أن يطلب قطع هذه الفروع حتى ولو لم يصبه ضرر، فمجرد شغل قدر من الفضاء الذي يستعمله يعتبر اعتداء على حقه^(١).

ويصدق ذات القول على البناء إذ يكون من حق الجار أن يطلب إزالة الجزء من الحائط الذي يميل نحو ملكه فهو يشغل جزءا من الفراغ الذي يستعمله.

وعلى هذا يكون للمالك أن يبني فوق أرضه أو يغرس بها إلى أى ارتفاع شاء بشرط ألا يزيد عن الحد المفيد في التمتع بملكه. ولايحد من سلطاته في ذلك إلا ما تقضى به القوانين واللوائح، مثل التى تتعلق بالمباني والتنظيم والتي تورّد قيوداً في هذا الصدد، وتلك التى تتعلق بإمداد الأسلاك الكهربائية أو التليفون أو بالطائرات.

2024/2025

2024/2025

ملكية العمق :

تشمل ملكية السطح ما تحت السطح عمقاً، فلا يقتصر حق الملكية على السطح فقط وإلا لما أمكن للمالك أن يفيد على نحو جدى بالأرض التى يملكها.

وحق المالك في العمق هو حق ملكية، فالرأى استقر على امتداد الملكية إلى الحد الذى يمكن معه الانتفاع بالعمق انتفاعاً فعلياً، وهو ما عبرت عنه المادة ٨٠٣/٣ بالحد المفيد في التمتع. ويكون ذلك على الأرض عن طريق الحفريات وإقامة المباني والمنشآت في باطن الأرض. ولما كان القانون يخول للمالك الانتفاع بما تحت السطح إلى الحد المفيد، فإن له أن يمنع غيره من

(١) د/ السنهورى الوسيط ٨ ص ٥٧١، د/ أحمد سلامة: ص ٩١ د/ اسماعيل غانم : ص ٤٥، د/ توفيق فرج : ص ١١١.

التدخل كذلك متى تعارض هذا مع انتفاعه على هذا النحو. ولهذا يكون له مثلاً أن يطلب قطع جذور أشجار الجيران التي تدخل أرضه، بل أنه إذا قام بقطعها وهو في سبيل قيامه بالحفريات، فإنه لا يكون مسئلاً^(١).

وترتبطاً على ذلك تنص المادة ١/٨٨٢ التي تنص^(٢) بأنه الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك الرقبة. تعتبر نتيجة لملكية العمق. فالقرينة الموجودة بهذه المادة لا تقتصر على مجرد تملك العمق بل تمتد إلى ما يوجد بداخل العمق، يستوى أن يكون منشآت أو غيرها.

ولملكية العلو والعمق حدودها، فهي تثبت لمالك الأرض الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً كما هو صريح النص ١/٨٠٣. وعليه فهو لا يملك من الفضاء الذي يعلو أرضه ولا من الطبقات التي تحتها إلا ما يستطيع أن يستخدمه، وليس له في خارج هذا النطاق أن يمنع الغير من استخدام العلو والعمق. لهذا لا يكون لمالك الأرض أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق حيث لا تكون له مصلحة في منعه، وإلا كان متعسفاً في استعمال حق الملكية^(٣).

وفيما عدا الحد المقيد للتمتع بالأرض علواً وعمقاً فإننا نصير بصدد أشياء مشتركة لا تعد ملكاً لأحد، ويكون للجميع الاستفادة منها. إلا أن تحديد هذا الحد ليس أمراً ثابتاً، لذا يترك لقاضي الموضوع الذي يقدر مدى العلو أو العمق الذي يعتبر مفيداً لصاحب الأرض. وهو في كل هذا يستتير بالظروف المحيطة والغرض الذي أعدت له الأرض وطبيعة الأشياء وعرف الجهة.

(١) د / شفيق شحاتة، ص ٢٩ ، د/ حسن كيره ص ٨٤ ، د / أحمد سلامة : ص ٩٣.

(٢) أورد المشرع هذا النص في الفصل الخاص بأسباب كسب الملكية وبالذات تحت عنوان الاستيلاء على المنقول ليس له مالك.

(٣) الأعمال التحضيرية ج ٦ ص ١٨ ، د / توفيق فرج : ص ١١٣ ، د/جمال زكي : ص ٤٧.

فصل ملكية السطح عما فوقها أو تحتها :

إذ كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، فإنه يجوز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها. ويكون ذلك بمقتضى تشريعات خاصة أو بمقتضى اتفاق «م ٣/٨٠٣ مدنى». فيجوز للمالك إن شاء أن يخول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل، أو يخوله الحق فى إقامة هذه المنشآت وتملكها «م ٢/٩٢٢». وفى مثل هذه الحالات تكون ملكية السطح منفصلة بمقتضى الاتفاق عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها . حسب ما إذا كانت المنشآت فوق الأرض أو فى جوفها . ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام. وماحق الحكر وحق التعلّى إلا ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح.

وقد قضت محكمة النقض^(١) أنه إذ كان من المقرر قانوناً بالمادتين ٨٠٣ ، ٢/٩٢٢ من القانون المدنى أنه وإن كان الأصل أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها إلا أنه يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها، وكان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى السابقة قد انحصر فى النزاع حول ملكية الأرض وحدها ولم يفصل الحكم الصادر منها فى نزاع حول البناء بينما تمخض النزاع فى الدعوى الماثلة حول الحق فى البناء المقام على تلك الأرض استنادا إلى اتفاق خاص بذلك، فإن كلا من الدعويين تختلف عن الأخرى موضوعا وسببا، وبالتالي فإن الحكم فى الدعوى السابقة الذى اقتصر على الفصل فى ثبوت ملكية الأرض لا يجوز حجية تمنع من نظر الدعوى المثلية فى خصوص النزاع حول الحق فيما أقيم على تلك الأرض من بناء. ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد التزم صحيح القانون.

(١) طعن رقم ٩٠٦ لسنة ٥١ ق فى ٢٤ /٤/ ١٩٨٦ .

كما يجوز بمقتضى القانون أن تتفصل ملكية السطح عن ملكية ما فوقها وما تحتها وهذا هو الشأن بالنسبة لقانون المناجم والمحاجر .

استثناء ملكية المناجم والمحاجر :

استثنى المشرع من القاعدة الخاصة بملكية الشخص لما فوق الأرض وما تحتها المواد المعدنية التى توجد فى المناجم والخامات التى توجد فى المحاجر . عدا مواد البناء . حيث اعتبرها من أموال الدولة . فقد نصت المادة ٣ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٥٧ على أنه «يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية (١) بالمناجم فى الأراضى المصرية أو المياه الإقليمية، ويعتبر كذلك من هذه الأموال خامات (٢) المحاجر . عدا مواد البناء . والأحجار الجيرية والرملية والرمال التى توجد فى المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير .

وقد حدد هذا القانون المقصود بالمواد المعدنية وكذلك خامات المحاجر، وأعتبرها من أموال الدولة نظرا لأهميتها باعتبارها من عناصر الثروة الوطنية التى تخضع للملكية الخاصة. ^{2024/2025} ^{2024/2025} ملكية الدولة على المواد المعدنية الموجودة بالمناجم أو المحاجر، أما المنجم أو المحجر ذاته وهو باطن الأرض الذى توجد فيه المواد، فيظل مملوكا لصاحب الأرض، بحسب الأصل فى

(١) المواد المعدنية هى « المعادن وخاماتها، والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما فى حكمها، والفخور والطبقات والرواسب المعدنية التى توجد على سطح الأرض أو فى باطنها، وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها. (م ١١ من القانون ٨٦ لسنة ٥٦).

(٢) خامات المحاجر هى «مواد البناء والرصف ولأحجار الزخرفية وخامات المون والبلاط، ولأحجار الصناعة، والدولوميت، ورمال الزجاج وما يماثلها (م ٣/١١ من القانون).



ملكية العمق، ولم أن يستعمله أو أن يستغله في أغراض أخرى غير استخراج المواد المعدنية أو الخامات^(١).

وبعد أن كان للأفراد والشركات الخاصة حرية الكشف عن المواد المعدنية وحق البحث عنها، وفقا لقواعد معينة في القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الذي قرر لمالك الأرض التي توجد فيها تلك المواد أولوية ومزايا أخرى في خصوصها. صدر القانون ٧٣ لسنة ١٩٦٣ الذي أنهى تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء، التي تبحث للأفراد أو الشركات الخاصة. ليرخص لوزير الصناعة في إسناد استغلال المناجم والمحاجر المشار إليها إلى شركات القطاع العام. وبهذا خرج عن نطاق النشاط الخاص الكشف أو البحث أو الاستغلال فيما يتعلق بالمواد المعدنية في المناجم، وفيما يتعلق بالجبس والرمال البيضاء في المحاجر، ومع ذلك يجوز فيما يظهر «أن يرخص القانون لوزير التجارة والصناعة في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة، ولو كانت في القطاع الخاص أو كذلك أجنبية» (م ٥٠ من القانون ٧٣ لسنة ٦٣).

2024/2025

2024/2025
الفرع الثاني

2024/2025

شمول الملكية للملحقات والثمار والمنتجات

إذا كانت الملكية تشمل الشيء المملوك وتمتد في شأن الأرض إلى ما يوجد فوقها من علو أو تحتها من عمق. فمنطقياً أن هذه الملكية تمتد كذلك إلى عناصر الشيء الجوهري. وعلى ذلك تنص المادة ١/٨٠٣ مدني «لمالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهري بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير».

(١) قضت محكمة النقض «ملكية الدولة بالنسبة للمناجم قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها، بقاء هذه الأماكن مملوكة لصاحب السطح في الحدود المقررة قانوناً، التزام المرخص له باستغلال المنجم بتعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بملكه وأي ضرر بسطح الأرض» نقض مدني ١٩٧٣/١٢/٣٠ طعن رقم ٢٢٢ س ٣٨ ق .



وحق المالك على هذه العناصر يمارس بناء على نفس السبب الأصلي للملكية، لأن الفرض أنها أجزاء جوهرية من الشيء محل الملكية^(١). فليست ملكية هذه العناصر إذن منفصلة عن ملكية الشيء نفسه حتى يتلمس لاكتسابها وممارسة سلطاته عليها سبب قانوني جديد مستقل عن السبب الأصلي.

كذلك فإن حق الملكية لا يرد على الشيء نفسه بعناصره الجوهرية فحسب بل يمتد فضلا عن ذلك إلى ملحقاته. وهذا ما نصت عليه المادة ٨٠٤ مدني «لمالك الشيء الحق في كل ماره وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق ينص بخلاف ذلك».

أولاً : الثمار :

هي ما ينتجه الشيء بشكل دوري دون أن ينقص من أصله. أو هي ما ينتجه الشيء من غله متجددة. وهي تتميز بخاصيتين أحدهما أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة متساوية أو متقاربة أو متباعدة. والثانية أن فصلها لا يمس أصل الشيء ولا ينقص منه على المدى القصير^(٢).

2024/2025

والثمار قد تكون طبيعية، أي ينتجها الشيء بطبيعته، كالكلأ والعشب^{2024/2025} ونتاج الحيوان^(٣). وقد تكون صناعية أي ينتجها الشيء بجهد مادي من الإنسان كالمحاصيل الزراعيه وحرير دودة القز، وقد تكون مدنيه، أي ينتجها الشيء عند استغلاله بأحد الأعمال القانونية، أي هي ما يغله الشيء من دخل نقدي كأجرة العقارات وأرباح الأسهم والفوائد.

(١) د / حسن كيره : المرجع السابق ص ٨٨ .

(٢) «الحكم في دعوى سابقة بالريع، جواز الرد عليه كمستند في دعوى الريع اللاحقة رغم أنه لا حجية للحكم السابق في الدعوى» نقض مدني ١٥/١٠/١٩٧٤ طعن رقم ٣٣٩ س ٣٩ ق.

(٣) د / إسماعيل غانم : ص ٦٩ ، د/ منصور مصطفى ص ٢٩ .



والثمار الطبيعية والصناعية تسمى بالثمار المادية، وهي تعتبر مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء، أما الثمار المدينة فتعتبر مقبوضة يوما بيوم «م ٩٧٨ مدنى».

ثانيا : المنتجات :

وهي ما يخرجها الشيء بشكل غير دورى أو على نحو ينقص من أصله، أو ما يخرجها الشيء من غله غير متجددة، كمعادن المناجم وأحجار المحاجر، وأقسام الإيراد المرتب مدى الحياة لأنها تنتقص من أصل الشيء إلى أن ينفذ بموت صاحب الإيراد (١).

ويملك صاحب الشيء منتجاته، ما لم يكن هناك نص يقضى بغير ذلك كالنصوص الخاصة بملكية الدولة لمعادن المناجم.

ونظرا لان صاحب الشيء يملك منتجاته، كما يملك ثماره، فان التفرقة بين الثمار والمنتجات ليس لها أهمية فيما يتعلق بحق الملكية. لكن لها أهمية فيما يخص حق الانتفاع، لأن صاحب حق الانتفاع لا يملك منتجاته وقد يملك ثماره عند جنيتها، كما أن حائز الشيء حسن النية يملك ثماره من يوم قبضها ولا يملك منتجاته، وما يجريه منها بالنسبة للثمار يعتبر من أعمال الإدارة (٢).

2024/2025

ويجوز أن تتفصل ملكية المنتجات أو الثمار عن ملكية الشيء. كمالك يرخص لغيره فى استخراج الرمال أو الأحجار من أرضه فيملك المرخص له هذه المنتجات، أو يؤجر أرضه لغيره يملك المستأجر الثمار الناتجة من زراعتها (٣).

ثالثاً : الملحقات :

أما الملحقات فهي ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء أو التمتع به. على أى وجه كان، طبقا لما تقضى به طبيعة الشيء أو عرف الجهة أو إرادة

(١) د / السنهورى الوسيط ج ٨ ص ٩٥٠ .

(٢) د / إسماعيل غانم : ص ٦٩ ، د / أحمد سلامة : ص ١٠٠ .

(٣) د / لبيب شنب : الوجيز فى الحقوق العينية الأصلية، طبعة ١٩٩١ ، ص ٢٥٨ .

الأفراد. أو هي ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعاً للأصل وملحقاته بحيث لو فصل عنه لا يؤدي الغرض منه.

ومن أمثلة ذلك حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص، فمالك الأرض يملك العقارات بالتخصيص التي تلحق بها (١) وله أيضاً حقوق الارتفاق التي تخدمها.

كما يكون له كافة ما يعد من ملحقات الشيء التي ترتبط بالشيء على نحو طبيعي أو صناعي وتعد توابع لازمه له. فمالك الشيء يفترض أنه مالك لما يلحق به على هذا النحو.

على أنه إذا كان للمالك الملحقات باعتبارها متفرعة عن الشيء فإن له هذا ما لم يوجد اتفاق أو نص يخالف ذلك «م ١/٨٠٤». فقد يوجد سند يثبت سند ملكية ما يعد شيئاً لمالك آخر.

وتبدو الأهمية البالغة لامتداد الملكية إلى الملحقات عند نقل ملكية الشيء إلى الغير ببيعه أو عند ترتيب حق عيني تبقى عليه. وفاء لدين من الديون كالم يرد اتفاق ٢٠٢٤/٢٠٢٥ - أن البيع والرهن يرد كل منهما على الشيء وملحقاته معاً (٢).

لذلك تنص المادة ٤٣٢ مدني في شأن البيع على أنه «يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة الشيء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين» كما تنص المادة

(١) «إذ أغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض وما عليها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، وقدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه». نقض مدني ١٩٨٣/٣/٢ طعن رقم ١٥٨٢ س ٥٢ ق، س ٣٤ ص ٦٢١.

(٢) «قضى بأن المبيع ينتقل إلى المشتري بحالته التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذا كان الثابت أن البائع قد حرصاً عن عقد البيع ينفى وجود أي ارتفاق للعقار المبيع، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشتري رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس» نقض ١٩٧٠/١/١٥ طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق.

١٠٣١ مدنى «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك».

المبحث الثانى

خصائص الملكية

يقال عادة أن حق الملكية له خصائص ثلاث. فهو حق جامع مانع، وهو حق دائم، وأنها حق مطلق. ولم تكن هذه الخصائص فى وقت مضى محل جدل أو تردد، إلا أنها الآن محل نظر، ليس فقط لأنها خصائص تصح فى قانون تسوده النزعة الفردية، ولكن أيضاً لأن هذه الخصائص أو بعضها ليس مما يصدق عليه وصف الخصيصة على وجه الدقة ^(١)، أى وصف المميز للملكية عن غيرها من الحقوق.

• الملكية حق جامع مانع:

تلك هى الخصيصة التى يتميز بها حق الملكية عن غيره من الحقوق. فالأصل فيه أنه حق جامع لكافة السلطات التى يمكن استخلاصها من الشئ، من استعمال واستغلال وتصرف ^(٢)، فهى جميعا تكون للمالك وحده الذى يحصل على المزايا التى تخولها له سلطات الحق، فلا يكون لغيره تلك المزايا. فلا يمكن أن تثبت كل السلطات على كل الشئ، لكل من الشخصين، إذ يقوم التعارض بينهما، وإن كان هذا لا يمنع من أنه قد يوجد لشخصين أو أكثر على نفس الشئ حقوق مختلفة كما إذا أنشأ المالك لآخر حقا بالانتفاع، فرغم من تقرير حقوق الانتفاع على الشئ وهو حق عيني متفرع عن الملكية فإنها تظل محتفظة بهذه الخصيصة الأساسية. وتفصيل ذلك أن ملكية الرقبة وهى الملكية

(١) فى هذا المعنى : د /أحمد سلامة: ص ٥٩ ، د/ حسن كيره : المرجع السابق ، ص ٦٤ ، د/ توفيق فرج : المرجع السابق ، ص ٦٠ .

(٢) د/ إسماعيل غانم : المرجع السابق ص ٣٩ ، د/ أحمد سلامة : ص ٦١ .

التي تبقى للمالك بعد تقرير حق انتفاع على الشئ للغير يصدق عليها وصف الملكية، ورغم أنها لا تشمل سلطتي الاستعمال والاستغلال طوال مدة بقاء حق الانتفاع، إذ لازال حق مالك الرقبة قابلا لأن يمتد فيشمل كافة السلطات على الشئ عند انقضاء حق الانتفاع (١).

فالملكية جامعها لكل السلطات التي يخولها الحق لصاحبه، ولا يحد من مزاولته لهذه السلطات إلا قيد يفرضه القانون أو تشترطه الإرادة حيث يجوز لها ذلك. فقد يلزم القانون في نطاق الأراضي الزراعية المالك بزراعة محاصيل معينة أو يمنعه من زراعة محاصيل أخرى، كما يلزمه في نطاق المساكن المعدة للاستغلال أو الاستعمال مجموعة من القيود التشريعية التي تنص عليها قوانين الإيجار المختلفة (٢). وإلى جانب هذه القيود القانونية قد يتصور وجود قيود اتفاقية من شأنها الحد من سلطات المالك الجامعة أو منع استعمالها طوال مدة معينة، كما هو الحال في شأن شروط المنع من التصرف.

ويترتب على أن الملكية حقا جامعاً. أن من يدعى أن له سلطة أو سلطتين من هذه السلطات أو أن هناك قيوداً يحد من واحدة منها يكون مدعياً خلاف الأصل ويكلف بإثبات ادعائه. أما المالك فلا يكلف بداءة بنفي هذا الادعاء فحقه جامع حتى يثبت العكس. أما النتيجة الثانية المترتبة على أن حق الملكية حق جامع أن كل فصل لسلطة الاستعمال أو الاستغلال أولهما معا إنما يكون أمراً عارضاً مؤقتاً بالضرورة ومآله إلى الزوال. فتجتمع كل العناصر من جديد في يد المالك (٣).

(١) « حق الانتفاع مؤقت ينتهي بإنهاء الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل عد مقرر الحياة المنتفع وينتهي على أي حال بموت المنتفع وفقاً لما تنص به المادة ٩٩٢ مدني نقض مدني ٨٧/١٢/٣ طعن رقم ١٥٩٨ لسنة ٥٥ ق.

(٢) د/ حمدي عبد الرحمن : شرح قوانين إيجار الأماكن ط ١٩٨٢ ص ١٢٠. د/نبيلة رسلان : القيود على حرية التأجير والاستئجار ط ١٩٨٩ ص ١٢٠.

(٣) د / السنهوري : الوسيط ج ٨ ص ٥٢٩، د/ احمد سلامه : المرجع السابق ص ٦٣، د/ توفيق فرج: المرجع السابق ص ٦٢.



أما أن الملكية حق مانع فيعنى أنها حق مقصور على صاحبه فلا يجوز لشخص أن يشارك المالك في ملكه ولا أن يتدخل فيه، ومن ثم للمالك أن يمنع الغير من استعمال ملكه أو الإفادة منه، ولو لم يعد عليه من ذلك أى ضرر^(١). وهذا ما عبرت عنه المادة ٨٠٢ مدنى بقولها أن لمالك الشئ وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

على أن هذا الحق الاستثنائى المانع يمكن أن يقيد بما يكون للغير من حق فى أن يقيد من بعض هذه المزايا بموجب القانون أو الاتفاق. ومن ذلك ما يقرره القانون أن لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف، يكون له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف (م ٨١٢ مدنى) ^(٢).

ونرى - وكما يذهب البعض ^(٣) - أنه إذا كان للشئ خصيصة معينة يتصف بها فان لازم ذلك أن ينفرد هذا الشئ بهذه الخصيصة، بحيث تمنع غير ذلك من الاختلاط به. وعلى ذلك ^(٤) فإن القول بأن الملكية حقا جامعا يفيد أن مضمون الحق أوسع من مضمون أى حق آخر. ولكن هذا المضمون مسألة نسبية قد يعترف بها فى تشريع وقد تنقيد فى تشريع آخر.

وكذلك الحال بالنسبة لصفة المنع فهى ليست بقاصرة على حق الملكية وأن كان يبررها أن المنع فى حق الملكية أكثر بروزا من المنع فى غيره من

(١) د / الصده : الحقوق العينية ص ١٨ .

(٢) سنرى تفصيلا هذه الحالات عند الكلام على القيود التى ترد على حق الملكية .

(٣) د / أحمد سلامة : ص ٦٢، د / منصور مصطفى : حق الملكية فى القانون

المدنى طبعة ١٩٦٥ ص ١١.





الحقوق، لأن حق الملكية هو أوسع الحقوق نطاقا فقصوره على صاحبه يكون أبلغ أثرا.

هل الملكية حق دائم؟

الخصيصة الثانية التي يبرزها غالبية الفقهاء هي أن الملكية حق دائم. والواقع أنه لا شيء يدوم في هذا العالم. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾^(١).

الدوام فيما يتعلق بحق الملكية معنيان : أولهما أن هذا الحق يدوم بدوام محله، وثانيهما أنه لا يسقط بعدم الاستعمال^(٢). وسنبين حقيقة هذين المعنيين، ثم نبحث بعد ذلك فيما إذا كان من الجائز الاتفاق على توقيت حق الملكية.

أولاً : بقاء الملكية ببقاء الشيء :

أول معنى يقول به الفقهاء للدوام في هذا الخصوص ينظر فيه الى حق الملكية ذاته وأنها باقية ما بقى الشيء الذي ترد عليه ولا تنقضى إلا بهلاكه^(٣). والملكية بهذا المعنى هي الملكية في ذاتها مجردة عن شخص المالك. حقا أن شخص المالك قد يتغير نتيجة التصرف في الشيء أو نتيجة انتقال الميراث أو نتيجة اكتسابه بالتقادم، لكن تغير شخص المالك يفيد انتقال الحق لا انقضائه. وحتى إذا ما تخلص هذا المالك عن الشيء بنية النزول عن الحق، فإن هذا التخلي لا ينهي الحق بل يظل قائما حتى يستولى عليه شخص آخر فينقل

(١) سورة القصص آية ٨٨ ج ٢ .

(٢) Ripert et Boulanger: Traité de droit. civil d'après planiol, T2, 1957 p. 700.

(٣) وفي هذا يتفق الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي، فالملكية تدوم بدوام العين المملوكة، يستوى أن تكون الملكية تامة أم ملكية ناقصة. الفروق للقرافي ج ٤ ص ٢١٣، كشاف القناع ج ٤ ص ١٣٤.



الحق اليه. فالملاك يتوالون على ملكية الشئ الواحد بعد الآخر دون أن يتخلل هذا التوالى أى فترة يكون فيها الشئ بغير مالك (١).

وهذا المعنى يعكس فكرة قانونية رومانية تقادمت وغير معبرة عن الحقيقة، كما أنه لا يتفق مع أحكام القانون الوضعى (٢).

ثانياً : الملكية لا تسقط بعدم الاستعمال :

الفقه ينظر إلى دوام الملكية من ناحية أخرى، هى مزاوله الحق. بمعنى أن وجود حق الملكية مستقل عن مزاولته.

فلا يمكن أن يسقط بعدم الاستعمال، وفى هذا تنفرد الملكية عن سائر الحقوق المالية الأخرى، شخصيه كانت أو عينيه. وإذا كان المشرع فى التقنين المدنى لم ينص على هذه القاعدة بصريح النص، إلا أنها مستفادة ومستخلصه من سكوته عن النص على سقوط الملكية بالتقادم وقيامه بالنص على سقوط الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية بعدم الاستعمال لمدة خمس عشر سنه إذ أن هذه الحقوق الأخيرة حقوق مؤقتة (٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

على أنه إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال، فإنه ينقضى إذا اقترن عدم الاستعمال بحيازة الشئ من جانب الغير حيازة تتوافر فيها شروط التقادم المكسب، فحق الملكية لا يسقط بالتقادم ولكنه يكسب بالتقادم المكسب.

(١) د/ السنهورى : الوسيط جـ ٨ ص ٥٣٥ ، د / حسن كيره : ص ٦٧ ، د/الصدّة:

ص ١٩، د/ جمال زكى : ص ٣٩ ، د / أحمد سلامة: ص ٦٣.

(٢) يرى أ.د/ السنهورى، إن حق الملكية مرتبط بالوجود القانونى للشئ لا بالوجود المادى له ، ص ٥٣٥ ، وفى ذات المعنى د / حسن كيره : ص ٦٨.

(٣) د / حسن كيره : المرجع السابق : ص ٧٢ ، د / السنهورى: الوسيط جـ ٨

ص ٥٣٧، د / عبد المنعم البدرأوى : شرح القانون المدنى، الحقوق العينية

الأصلية ط ٢ سنة ١٩٥٦ فقرة ٢٠٧.

نخلص من ذلك أن التقادم المسقط لا يسرى على الملكية^(١)، فمجرد إهمال المالك في مباشرة سلطاته ولو لمدة طويلة لا يكفي سبباً لفقد الملكية، يجب أن يقترن إهمال المالك بتوافر شروط التقادم المكسب لمصلحة آخر. ودوام الملكية على هذا المعنى هو القاعدة المسلم بها في كثير من القوانين الوضعية ومنها القانون المصري.

والحقيقة أن بقاء الملكية رغم عدم الاستعمال وهو القاعدة المقررة في القانون الوضعي لا يقوم على أساس من جوهر الملكية، وإنما هو بقية من بقايا حقه الإطلاق التي كانت تتميز بها الملكية فيما مضى، أما وقد زال الكثير من مظاهر إطلاق حق الملكية فليس ببعيد أن يتقرر في يوم ما إسقاط الملكية^(٢) على الأقل فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، إذ لم يستعمل المالك ملكه مدة معينة تمشياً مع ما للملكية من وظيفة اجتماعية.

ونرى أنه إذا كان القانون الوضعي يقضى بدوام الملكية وبقائها مهما طال مدة عدم الاستعمال، فإن هذا في الواقع لا يقوم على أساس من جوهر الملكية. وأنه من الأفضل أن يتقرر تشريعياً إسقاط حق المالك، على الأقل فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج إذا لم يقم المالك باستعمال ملكه مدة معينة من الزمن.

(١) قضت محكمة النقض «حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره ولو لم ينفذ ولا يجوز إطرأحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم بشروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية». نقض مدني في ١٩/١/١٩٨٠ طعن رقم ٩٤٤ لسنة ٤٧ ق، س ٣١ ص ٣٦.

(٢) هناك في القانون المصري حالات قرر فيها المشرع إسقاط حق الملكية جزاء الإهمال مانص عليه قانون الإصلاح الزراعي من أنه إذا أهمل من وزعت عليه الأرض ولم يقم ببذل العناية الواجبة في زراعتها، فانه يجوز إلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه، مالم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. م ٣/١٤ من قانون الإصلاح الزراعي بعد تعديل بالقانون ٥٥٤ لسنة ١٩٥٥.

ثالثاً : مدى وجود الملكية المؤقتة :

يرتب بعض الفقهاء على صفة الدوام التي لحق الملكية بالمعنى الأول هو أن الحق يدوم بدوام محله، أن هذا الحق لايجوز توقيته بزمان معين، فلا يصح أن يتفق شخصان على نقل ملكية عين كي تظل الملكية للمتصرف إليه مدة معينة ثم تعود بعد ذلك إلى المتصرف (١). ويرى آخرون أن التوقيت يتنافى مع طبيعة حق الملكية والعناصر المكونة له، لأن هذا الحق يخول صاحبه سلطة إعدام الشئ ولهذا يكون الاتفاق على التوقيت باطلا، إذ يستطيع المتصرف إليه أن يهدم الشئ قبل فوات المدة المتفق عليها فيصبح حق المتصرف لغوا (٢).

ولا نعتقد خلافاً لما يذهب إليه البعض أن من طبيعة حق الملكية ما يحول دون توقيته بزمان معين. فيصح أن يتفق على نقل الملكية لمدة معينة، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون أن يباشر المتصرف إليه سلطته في إعدام الشئ عادت الملكية إلى المالك الأصلي. غير أن هذا الغرض لا يتصور وقوعه في الحياة العملية. لأن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يجعل حق المالك الأصلي في استعادة الملكية بعد انقضاء الأجل المحدد خاضعا لأهواء المالك المؤقت، إذ يكون لهذا بمقتضى ماله من سلطة التصرف المادى بوصفه مالكا أن يعدم الشئ قبل حلول الأجل. لذلك فمن السهل تجنب هذا الخطر من جانب المالك باتباع وسيلة قانونية تحقق الغرض، أى تهئ لشخص من الغير الحصول على منافع ملكية معينة مدة معينة، وذلك بأن يرتب للمتصرف إليه حق الانتفاع بالشئ، وهو لايتضمن سلطة التصرف بل على المنتفع واجب المحافظة على الشئ (م ٩٩٠ مدنى).

(١) هذا بخلاف الحقوق العينية الأخرى، فهي جميعا تقبل التوقيت بل إن أكثرها يتحتم فيه التوقيت بنص القانون م ٩٩٣، ٩٩٨، ١٠٢٦ مدنى.

(٢) د / السنهورى: الوسيط ج ٨ ص ٥٣٩، د/ جمال زكى : المرجع السابق ص ٣٩، د / شفيق شحاته: ص ١٠١، مازو : فقرة ١٣٤٨.

يتضح مما سبق أنه ليس من جوهر الملكية إذن ما يحول منطقيا دون توقيتها، وإنما الأمر مرجعه اعتبارات عملية تعرض حق المتصرف للخطر. فيمكن أن تقوم بجانب الملكية الدائمة ملكية مؤقتة دون إخلال بفكرة الدوام، الذي يعتبر من خصائص الملكية، لا من جوهرها.

ومن صور الملكية المؤقتة حالة ما إذا خول المالك أجنبيا الحق في إقامة منشآت على أرضه، وفي تملك تلك المنشآت. كأن يأذن المؤجر للمستأجر بالبناء على أرضه، على أن تكون للمستأجر ملكية المبنى مدة الإيجار، وبذلك يكون للمستأجر ملكية مؤقتة إلى أن ينتهي الإيجار^(١) والقول بغير ذلك يتعارض مع نص المادة ١/٩٢٢ التي تجيز الاتفاق على أن تكون ملكية المبنى لغير مالك الأرض «المستأجر في هذا الفرض». فلا مناص من الاعتراف للمستأجر طيلة مدة الإيجار بملكه ما يقيمه من مبانى على الأرض المؤجرة، لتؤول عند انقضائها إلى المؤجر وفقا لبنود الاتفاق، مقابل تعويض أو بغير تعويض.

وإن كان البعض يسلم بذلك، أى بإمكان توقيت الملكية إلا أنه يرفض اعتبار مثل هذه النصوص تطبيقا لمبدأ عام فحواه جواز الاتفاق على توقيت حق الملكية، وإنما يعتبرها استثناء على مبدأ عام لا يجيزه^(٢).

2024/2025

نخلص من ذلك أنه فيما يتعلق بخاصة الدوام التي لحق الملكية أن هذه الخاصية ليست مستمدة من جوهر هذا الحق وإنما هي خاصة تقتضيها الاعتبارات العملية.

الملكية حق مقيد وليست حقا مطلقا :

(الوظيفة الاجتماعية للملكية):

- ١٨٤- لكلمة إطلاق حق الملكية عدة معان. فقد يطلق ويراد به ما يخوله من سلطات للمالك فى استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه، دون

(١) د / إسماعيل غانم : ص ٣٨ ، د/ منصور مصطفى : ص ٢٦، د الصده: ص ٢٣ ، د/ احمد سلامة ص ٧٤.

(٢) د / جمال زكى : المرجع السابق ، ص ٤١.

مراعاة لمصلحة الغير والمجتمع.. وقد يراد به أنه حق جامع مانع أى مقصور على صاحبه، وقد يراد به أنه حق غير محدد من حيث مدته بمعنى أنه دائم.

وقد يقصد بإطلاق الملكية الاحتجاج به فى مواجهة كافة وذلك بالمقابلة إلى الحق الشخصى الذى يعتبر حقاً نسبياً لا يحتج به إلا بين الدائن والمدين. والواقع أن معنى الإطلاق على هذا النحو ليس قاصراً على الملكية وحدها، بل أنه ينصرف إلى الحقوق العينية جميعها التى يحتج بها على مواجهة كافة^(١).

والواقع أن خصيصة الإطلاق فى الملكية أصبحت أمراً لا يستقيم بعد أن اندثرت النزعة الفردية، التى كانت تعطى لصاحب حق الملكية سلطة الانتفاع بالشئ والتصرف فيه بطريقه مطلقه ولو كان ذلك بطريقه تعسفية. فحق الملكية لم يعد حقاً مطلقاً، إذ بدأت المصلحة الخاصة تتراجع أمام المصلحة العامة، فإشباع مصالح الفرد وبالذات أنانية المالك لم تعد كل شئ، بل أن هناك مكاناً هاماً لإشباع المصالح الاجتماعية.

ويترتب على أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو حق له وظيفة اجتماعية نتائج أهمها أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة، فالمصلحة العامة هى التى تقدم، فما ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبيل المصلحة العامة. ومثل ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة فى مقابل تعويض عادل.

أما حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية من حق المالك فإن هذه المصلحة الخاصة هى التى تقدم. بعد أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً. فالقيد هنا تقرر لا للمصلحة العامة بل للمصلحة الخاصة، وهذه النزعة الحديثة يظهر أثرها فى أمرين:

١- على المالك أن يمتنع عن استعمال حقه فيما يضر الغير ضرراً غير مشروع والذى يطلب هنا هو عمل سلبى، وتطبيقاً لذلك يجب على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، والحد المقصود هنا هو مضار الجوار غير المألوفة.

(١) د / احمد سلامة : المرجع السابق ، ص ٧٩ هامش / ٣ .

٢- يجوز للغير أن يتدخل فى انتفاع المالك بملكه لمصلحة خاصة، هى أولى بالرعاية من مصلحة المالك. وتطبيقاً لذلك يجوز للمالك المجاورين أن يستعملوا المسقاه أو المصرف المملوك لجارهم، فيما تحتاج إليه أراضيهم من رى أو صرف، ويعطى حق المجرى وحق المسيل كما يعطى حق المرور^(١).

وإذا كانت الفكرة التى تسود القانون المصرى الآن ترى أن الملكية لم تعد حقاً مطلقاً، ينبغى إلا أنه ينبغى أن نراعى من ناحية أخرى أن صياغة النصوص القانونية الحالية ما يفهم منه أن الأصل هو بقاء سلطات الملك، وأن الخروج على هذا يكون فى حدود ما يقضى به القانون. والدستور الذى نص على «الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظائفها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى، وفى إطار خدمة التنمية دون انحراف أو استغلال. ولا يجوز أن تتعارض فى طريق استخدامها مع الخير العام للشعب.

2024/2025

وعلى ذلك فوفق نص الدستور فإن الوظيفة الاجتماعية للملكية أصبحت أصلاً يعمل دائماً به حتى فى الأحوال التى لم يرد فيها نص، كما وأن نص الدستور يلزم المشرع العادى فى أى عمل مقبل ينظم به حق الملكية.

بل أن المشرع يستطيع أن يفرض على المالك التنظيم الذى يراه متفقاً مع مصلحة الجماعة، كأن يرسم له صورة معينة من الصور لاستغلال ملكه^(٢). كما يستطيع أن يعيد توزيع الثروات وأن ينزع ملكية ما يراه متجاوزاً الحد

(١) الأعمال التحضيرية ٦٥ ص ١٠-١٢.

(٢) راجع كتابنا فى القيود التشريعية ص ١٢٧ وما بعدها حيث تعرض لمجموعة من القيود التى تقيد من حق الملكية لصالح المستأجر، نقص مدنى ١٩٦٩/٢/٤ س ٢٠ ص ٢٤٧ طعن رقم ٥٦ لسنة ٣٥ ق حيث قضت « تحديد سعر جبرى لسعه معينة وفرض قيود على حرية المشتري هذه السلعة فى التصرف فيها بقصد تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين ومنع المضاربة فيها، لاينفى ملكية المشتري السلعة لها.

المقبول، بل أنه قادر على تعطيل إحدى السلطات التي يخولها حق الملكية مدته معينة أو تقرير قيد دائم عليه، أو تحميل المالك بأداء يقوم به، كما فعل المشرع المصري بالنسبة للتسويق التعاوني وإلزام أصحاب الحيازة أن يقدموا للدولة قدراً معيناً من نتائج ملكيتهم.

الخلاصة :

عرضنا للخصائص التي تذكر عند ذكر الملكية من أنها مانعة جامعته، وأنها دائمة، ومطلقه. ورأينا أن كونها مانعة جامعته ليست بميزة قاصرة على حق الملكية بل هي صفة تثير الحماية القانونية لأي حق من الحقوق.

أما صفة الدوام فرأينا أن القانون وأن كان يعترف بفكرة الدوام، وأن للشخص حق اكتساب الحقوق العينية ومنها حق الملكية، والاحتفاظ بها بصفة دائمة، لأنها من مستلزمات حياته وجزءه في حب التملك، إلا أن مبدأ الدوام يصطدم بمسألة تهم المجتمع بأسره، وهي أن عدم استعمال المالك لملكه مدة من الزمن، يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، وينافي ما للملكية من وظيفة اجتماعية. أي أن كونها دائمة بالمعنى الثلاثي التي تتميزها معنى الدوام هي أيضاً ليست مستمدة من جوهر الملكية، وإنما هي مسألة تشريعية متغيرة تتأيد أو تنفي على ضوء التنظيم التشريعي لأحكام الملكية. أما خصيصة الإطلاق فهي لم تعد مناسبة تماماً في ظل الأنظمة التي تسودها النزعة الاجتماعية.

والحقيقة أن الأمر كله مرجعه تغير النظرة إلى حق الملكية، فالملكية من حيث المضمون هي أوسع من مضمون أي حق آخر، ولكن الملكية ليست سوى حق من الحقوق لا أكثر ويرد عليها ما يرد على سائر الحقوق من أن مضمونه وحدوده يحددها القانون بحسب ما يراه معبراً عن مصلحة الجماعة.

2024/2025



الفصل الثانى

القيود التى ترد على الملكية

تمهيد وتقسيم:

لم يعد حق الملكية حقاً مطلقاً، بل صار للملكية وظيفة اجتماعية لهذا وضعت قيوداً على السلطات التى يخولها هذا الحق، وهى قيود كثيرة يخطئها الحصر. ومرد ذلك إلى أن حق الملكية هو وحده - من الحقوق العينية الأصلية - الذى يعطى صاحبه كل السلطات الشاملة المقصورة على الشئ، من هنا لم يكن بد من تقيد هذه السلطات مخافة أن تتقلب بين يدى المالك إلى تحكم أو تفويت لمصلحة الجماعة، أو يعطل بعض مصالح الأفراد المشروعة أو يعوق استغلال بعض الثروات والملكيات الأخرى على نحو صالح مفيد. وقد ازدادت هذه القيود فى العصر الحديث على أثر اتجاه الدول وجه الاشتراكية.

وإذ نورد فى هذا المجال القيود الواردة على حق الملكية، فإنما نقصد بها القيود التى تحد من سلطات المالك فيما يملك. على أن هناك قيوداً أخرى على حرية التملك ذاتها. من هذه القيود الأخيرة ما روعى فيه الصالح الوطنى، مثل الحد من حرية تملك العقارات بالنسبة للأجانب^(١)، ومنها ما روعى فيه الحد من الإقطاع وسيطرة رأس المال، مثل القيود التى أوردتها قوانين الإصلاح الزراعى،^{2024/2025} والتى تضع حداً أقصى لا يصح مجاوزته لملكية الأراضى الزراعية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، ووضع قيود تعلق بتجزئة الملكيات الصغيرة^(٢). ومن القيود التى يراعى فيها أيضاً مصلحة

2024/2025

(١) حظر القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها، كما حظر القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء كأصل عام، إلا أنه أجاز ذلك استثناء فى المادة ٢ منه فى حالات محدده، راجع فى ذلك د. توفيق فرج : ص ١٢٥ - ١٣٩.

(٢) القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الذى عدل بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١. ثم صدر بعد ذلك القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ فجعل الحد الأقصى للملكية الفردية خمسين فدان، كما جعل الحد الأقصى لملكىة الأسرة مائة فدان. راجع فى تطور التشريع فى مجال تحديد الحد الأقصى لملكىة الأسرة د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٦٢٠ وما بعدها. د. حسام الأهوانى: أصول القانون الزراعى. طبعة ١٩٧٥ ص ٥٣.



الجماعة القيود على حق الملكية ذاته فى مجال البناء وهى القيود الواردة فيما يمكن تسميته بتشريعات المباني أو تشريعات البناء والهدم والعلاقة بين المالك والمستأجر، ومنها تقيد من سلطة المالك فى التشديد، سلطته فى الهدم أو عدم الهدم، بل حريته فى التملك ذاته^(١)، وكذا الأحكام الخاصة بالتراخيص. مثل هذه القيود وغيرها يرد على حق الملكية قبل قيامه يمنع من قيامه أو تضع حداً لسعة قيامه.

أما القيود التى نعينها هنا هى القيود الواردة على سلطات المالك، والأصل أن القانون هو الذى يملك تقيد سلطات المالك غير أن للإرادة إلى جانب ذلك سلطاناً تملك به مثل هذا التقيد فى حدود معينة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يكثر فى العمل من شروط المنع من التصرف.

وعلى ذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: القيود القانونية.

المبحث الثانى: القيود الإرادية.

المبحث الأول

2024/2025

2024/2025

القيود القانونية

أنواع القيود القانونية:

يعنى القانون بوضع قيود على سلطات المالك، هذه القيود لا يتسع التقنين المدنى إلا للقليل الهام منها، أما أغلبها فتجده فى كثير من القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة التى يصدرها المشرع بقصد الحد من سلطات الملكية تحقيقاً لمصلحة عامة أو رعاية لمصلحة خاصة. وقد حرص المشرع على التنبيه على هذا الوضع فى المادة ٨٠٦ من التقنين المدنى حيث

(١) راجع كتابنا فى آثار عقد الإيجار طبعة ١٩٨٩ ص ٧، القيود التشريعية المرجع السابق ص ١٣٠.

قضت «على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين^(١) والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية: وهى الأحكام التى ضمنها المشرع ما تخيره من قيود للتقنين المدنى ونص عليها فى المواد».

من هذا يتضح وبحسب ما أشار نص المادة ٨٠٦ مدنى إلى أن القيود القانونية تقسم بحسب المصلحة المقصودة من فرضها إلى قيود مقررة للمصلحة العامة وأخرى مقررة للمصلحة الخاصة.

أما عن القيود المقررة للمصلحة العامة فقد وردت فى تشريعات متعددة وهى من الكثرة بحيث يصعب حصرها، ومن أمثلتها القيود المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، قوانين الآثار، والقوانين المتعلقة بالأماكن المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة^(٢). وردم البرك والمستنقعات، وتحديد المساحات التى تخصص لأنواع معينة من المزروعات، ووقاية المحاصيل الزراعية، إلى غير ذلك من القيود التى وردت فى تشريعات خاصة هى من التنوع والكثرة بحيث يضيق هذا المقام عن ذكرها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أما القيود المقررة للمصلحة الخاصة فهى تنقرر حماية لمصلحة خاصة جديرة بالرعاية، كالقيود المفروضة رعاية لصالح الملكيات المجاورة، والقيود الخاصة بمياه الرى والصرف فى الأراضى الزراعية. على انه يلاحظ أن الشارع فى تقريره لهذا النوع من القيود ولا يضع نصب عينه المصلحة الخاصة وحدها،

(١) أشار إليها التقنين المدنى فى المادة ٨٢٢ على أن «المصانع والآبار والآلات التجارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تتشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها».

(٢) النص فى المادتين ٨٠٢، ٨٠٦ مدنى على أن «لمالك الشئ فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وأن يراعى فى ذلك ما نقض به القوانين والمراسيم واللوائح..» يدل على أن استعمال حق الملكية كان ولا يزال مقيدا بمراعاة أحكام القانون ومن ثم فلا يكون للقيود التى أوجبها قانون الإصلاح الزراعى أن تؤثر على عقود بيع الأراضى الزراعية القائمة وقت صدوره. نقض مدنى ١٩٧٣/١٢/٢٠ طعن رقم ١٤٢، ١٦٦ لسنة ٣٧ ق. س ٢٤ ص ١٣٢٠.

بل لا زال للمصلحة العامة دورها الأساسي، إذ أن مقتضيات المصلحة العامة هي التي تدفع المشرع إلى التدخل يفرض تلك القيود المتعلقة بالمصلحة الخاصة.

القيود القانونية وحقوق الارتفاق:

التقنين المدني يورد قيوداً عامة على الملكية. أغلب هذه القيود تحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر أو ترد على كل من العقارين فتحد من منفعة كل منهما لصالح العقار الآخر على سبيل التبادل. من ذلك القيود الخاصة بالرى الزراعى كحق الشرب المقرر لمالك الأرض المجاورة على المسقاة الخاصة، وقيد المسافة التي تجب مراعاتها بين المطلات وملك الجار وغيرها والقيود الناتجة عن الحق المقرر لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فى المرور بالأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها. وعلى هذا النحو تشتهب هذه القيود بحقوق الارتفاق وتكاد تختلط بها^(١). لأن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار يملكه شخص آخر (م ١٠١٥)، ومع ذلك فلا زال هناك فرق جوهري بينهما.

2024/2025

2024/2025

فالقيود القانونية الواردة على الملكية قيود عامة تنطبق على كافة الملكيات التي توافرت فيها الشروط التي تنص عليها القانون، فهي تمثل النطاق العادى لحق الملكية أو لكل حق ملكية تحيط به ظروف معينة يواجهها القانون، أما حق الارتفاق فهو مجرد قيد خاص ببعض الملكيات دون البعض، يرد كعبء استثنائى يتحمل به عقار معين لخدمة أو فائدة عقار آخر معين. فالقيود القانونية للملكية أذن تمثل الوضع القانونى العادى للملكية، بينما تمثل الارتفاق الخروج من هذا الوضع العادى وإنشاء وضع استثنائى خاص بملكية معينة^(٢). فيقيد القانون المالك بترك مسافة محددة عند فتح مطل مواجه لملك

(١) د. إسماعيل غانم: المرجع السابق ص ٧٣، د. حسن كيرة: ص ٩١، د. توفيق فرج: ص ١٤٣، د. الصدة: ص ٥٣.

(٢) يأخذ بهذه التفرقة د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٦٣٩، د. إسماعيل غانم، ص ٧١، د. توفيق فرج: ص ١٤٣، د. الصدة: ص ٥٣، د. حسن كيرة ص ٩١، على

الجار قيد قانوني لا ارتفاق، أما إذا استحصل مالك من جاره على الحق في فتح مظل مواجهه على أقل من هذه المسافة، فمعنى ذلك تحميل ملك الجار بعبء استثنائي زائد، أى بارتفاق.

والواقع من الأمر أن مرجع التفرقة بين القيود القانونية للملكية وبين حقوق الارتفاق هو اختلاف في المصدر بينهما. فالأولى مصدرها المباشر دائماً القانون. وصفته العامة المجردة مما يجعل من هذه القيود حدوداً عامة لنطاق حق الملكية. بينما حقوق الارتفاق مصدرها دائماً فعل الإنسان المادى أو الإرادى، وصفته الخاصة ثابتة لتعلقه بملكية معينة بالذات، مما يجعل منها أشياء استثنائية فيها معنى الزيادة على القيود العامة المقررة بمقتضى القانون نطاقاً لحق الملكية. ولهذه التفرقة نتائج هامة سنعرض لها على وجه خاص عند دراسة حقوق الارتفاق.

لذلك عنى المشرع فى التقنين المدنى بالفصل بين العقود القانونية التى ترد على الملكية مخصص لها المواد ٨٠٨ وما بعدها فى الباب المخصص لحق الملكية، وبين الحقوق الارتفاق التى خصص لها المواد ١٠١٥ وما بعدها فى الباب المخصص للحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أن كان المشرع قد أشار فى المادة ٨٠٦ مدنى إلى أن القيود القانونية التى تتعلق بالملكية يمكن تقسيمها بحسب نوع المصلحة المقصودة من فرضها إلى قيود مقررة للمصلحة العامة وأخرى مقررة للمصلحة الخاصة. إلا أن التقسيم الذى سنتبعه فى دراسة هذه القيود يستند إلى الخصيصة الأساسية لحق

أن هناك فريق من الفقه يفرق بين القيد الخاص بالمسافة الواجب مراعاتها بين المطلات وملك الجار والقيد المتعلقة بالرى والمرور، فيرى فى الأول قيداً قانونياً، فيما يرى فى الثانية ارتفاعات قانونية، وذلك بدعوى أن القيد الأول لا يعطى للمالك سلطه القيام بأى عمل على عقار الجار. أما القيود الأخرى فتحول هذه السلطة: د. عبد المنعم البدرأوى: فقرة ٧٨، د. عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ٩١، فيما يرى رأى آخر أ الأعباء القانونية المفروضة على سلطات المالك بقوة القانون بغير حقوق ارتفاق بالمعنى الحقيق طالما أنها تماثل ف مضمونها حقوق الارتفاق التى تنشأ بإرادة الأفراد. د. شفيق شحاتة، بند ٣٣٠، د. مصطفى الجمال ص ٢١٤ بند ١٣١.

الملكية وهو أنه حق جامع لكافة السلطات الواردة على الشيء، ومانع لغير المالك من الاستفادة من ملكه^(١).

وعلى ذلك فالقيود التي ترد على الملكية أما أن تحد من سلطات المالك فتمنعه من القيام ببعض الأعمال أو تفرض عليه أعمالاً يتعين القيام بها. وأما أن تحد من استئثار المالك بملكه فتبيح للغير في أحوالاً خاصة أن يشاركه الاستفادة منه رغماً عنه. وكما أن المالك قد يسأل عن تعويض الغير عما يصيبهم من ضرر نتيجة لاستعماله لملكه، وهو قيد عام تتعدد تطبيقاته، لذلك يدرس دراسة خاصة.

وبذلك نتحدد موضوعات هذا المبحث على الوجه التالي:

المطلب الأول: القيود التي تحد من سلطات المالك.

المطلب الثاني: القيود التي تحد من استئثار المالك بملكه.

المطلب الثالث: مسؤولية المالك في استعمال ملكه.

المطلب الأول

القيود التي تحد من سلطات المالك

2024/2025

الفرع الأول

2024/2025

قيود المسافات

الأصل أن كل مالك أن يبنى في نطاق الأرض المملوكة له ولو كان ذلك على حافة ملكه، وأن يفتح في بنائه ما يشاء من فتحات للنظر أو التهوية أو الإضاءة على أن القانون قد يحد من سلطة المالك في هذا الشأن وذلك رعاية منه لمصلحة الجيران التي تقتضى بضرورة توفير حرية وسكينة السكن لكل منهم. لذلك يفرض القانون قيود متبادلة على كل منهم في شأن ما يملك أحداثه من فتحات في بنائه. هذه القيود تختلف ما إذا كان المقصود بالفتحات مجرد التهوية والإضاءة وتسمى المناور، وما إذا كان مقصود بها النظر وتسمى المظلات.

(١) د. إسماعيل غانم: الحقوق العينية ص ٧٣.

المطلات:

المطلات فتحات تمكن من النظر إلى الخارج كالنوافذ والشرفات. والمطلات نوعان: مطلات مواجهة وهي التي تسمح بنظر ملك الجار مباشرة، وهذا يفترض أن يقع عقار الجار كله أو بعضه في مواجهة الفتحات.

وعلى ذلك فإن البلكونات الخارجة عن البناء، أى البارزة تعتبر مطلات مواجهة للعقارات المقابلة لها من أية ناحية من النواحي الثلاث. لأن الشخص يمكنه أن ينظر إليها دون حاجة إلى الانحناء إلى الخارج.

ومطلات منحرفة وهي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالاتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج.

وقد فرض المشرع قيد المسافة على المطل المواجه والمطل المنحرف معه. إلا أن قدر المسافة يختلف باختلاف ما تسمح به من أطلال على ملك الجار. إذ ينبغي أن يقيد فتح المطلات التي تسمح بإطلال مباشر مستقيم على ملك الجار بمسافة أطول مما يقيد به فتح المطلات التي لا تسمح إلا بإطلال منحرف، فالأولى تسبب مضايقة أكبر من الثانية. لذلك نص المشرع في المادتين ٨١٩، ٨٢٠ مدنى على أنه «لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاسى المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة، ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل ينحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر من حرف المطل».

مفاد هذا أن من حق الجار أن يكون له مطل على حارة شريطة أن تراعى المسافة التي حددها المشرع فى هاتين المادتين^(١). مع ملاحظة أنه لا

(١) «لما كان ذلك وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعين ماهية المطلات التي أقامها الطاعن ووجه مخالفتها للقانون، ولم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكم الموضوع من تملكه الأرض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهى دفاع جوهرى من شأنه أن



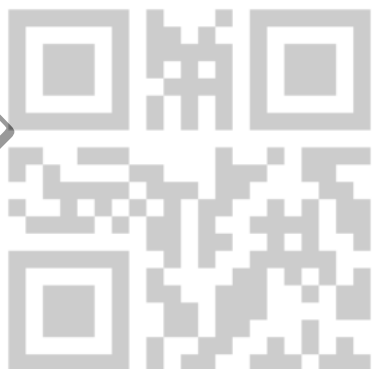
عبرة بالنسبة لفتح المطلات بنوعيتها أن يكون ملك الجار الذى تسمح بالإطلال عليه بناء أو أرض زراعية أو أرض فضاء^(١).

وما دام قيد المسافة فى فتح المطلات مقرر لمصلحة الأملاك الخاصة من العقارات المجاورة، الطبيعى أنه يجوز فتح المطلات على الطريق العام مباشرة دون تقيد بالمسافة المنصوص عليها فى المادتين ٨١٩، ٨٢٠ مدنى، بل أن المادة ٨٢٠ / ٢ نصت على « يرتفع الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام ».

وإذا فتح المطل مع مراعاة المسافة القانونية فهو لا يتضمن أى تعد على ملك الجار، ولا يجوز للجار طلب سده، ولكن يجوز له أن يقيم بناء على حدود ملكه، وليس لصاحب المطل أن يعترض على ذلك مهما طاللت المدة على فتح المطل فليس له أن يتمسك بأنه قد اكتسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل، إذ أن فتح المطل مع مراعاة المسافة القانونية ليس إلا استعمالاً لرخصة فلا يصلح أساساً للحيازة.

24/2025 أما إذا فتح المطل دون مراعاة المسافة القانونية كان للجار أن يطلب سده، ولكن يجوز للقاضى فى هذه الحالة أن يكتفى بتحويله إلى منور بسد الجزء الأسفل منه، بحيث تصبح قاعدته أعلى من قامة الإنسان. على أنه إذا فتح المطل دون تقيد بالمسافة القانونية واستمر هذا الوضع مدة خمسة عشر عاماً، اكتسب المالك بذلك حق ارتفاق بالمطل على الجار، ويترتب عليه أنه لا يمكن سد المطل، ويحتتم على الجار أن يراعى المسافة القانونية عند البناء فى

صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالتصور». نقض مدنى فى ١٣/١/١٩٨٨ طعن رقم ١٥٦٢ لسنة ١٩٥١ ق.
(١) «طلب سد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرض فضاء. باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل». طعن رقم ٦٩٩ لسنة ٤٧ ق، ١٥/١/١٩٨١ س ٣٢ ص ٢٠٧.



ملكه أو فتح مطلات فيه^(١). وعلى هذا نصت المادة ٢/٨١٩ مدنى: «إذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل. وقد صرحت المذكرة الإيضاحية بوجوب الأخذ بهذا الحل أيضاً فى المطل المنحرف إذ ما كسب بالتقادم»^(٢).

المناور:

يقصد بالمناور الفتحات التى يراد عن طريقها مجرد مرور للهواء ونفاذ الضوء دون النظر والأطلال على الخارج، أى دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور. وهذا النوع من الفتحات لا يمس حرمة الجار أو حرمة الشخصية داخل ملكه، لذلك فلا ضرر من فتحها فى بناء مقام على حافة الحد الفاصل بين الملكين، دون التقيد فى شأنها بمسافة معينة.

ولكى تعتبر الفتحات مناور يلزم أن تكون قاعدتها مرتفعة عن القامة العادية للإنسان^(٣) إذا وقف على أرض الحجره التى فيها المنور، أى دون أن يستخدم شيئاً يقف عليه. وقد نصت بذلك المادة ٨٢١ مدنى «لا يشترط أية

2024/2025

(١) د. إسماعيل غانم: ص ٧٩، د. توفيق فرج: ص ١٩٦، د. حسن كيرة، ص ١١٨، د. جمال زكى: ص ٨٨، د. مصطفى الجمال: ص ٢٣٨. كما قضت محكمة النقض «إذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالطل وجب عليها أن تبين من حكماً جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره، ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، طعن رقم ٣١٩ لسنة ٥١ ق - ١٩٨١/١٢/٣١ - س ٣٢ ص ٢٥٠١.

(٢) الأعمال التحضيرية ج ٦ ص ٦٨.

(٣) «النص فى المادة ٨٢١ مدنى على أنه لا يشترط أية مسافة لفتح المنور وهى التى تطو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتاد دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقاً لذلك المعيار. ولما كان الحكم المطلوب فيه قد اعتبر القامة المعتادة هى ١٨٠ سم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون» طعن رقم ١٩٩٣ لسنة ٥٠ ق فى ١٩٨١/٤/٢٣ س ٣٢ ص ١٢٢٨.

مسافة لفتح المناور، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتاد، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ الضوء، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور.

ومتى استوفى المنور هذا القيد فلا يجوز للجار طلب سده، لأنه على هذا النحو لا يتضمن تعدياً على ملاك الجار وإنما يعتبر رخصة من الرخص تجيز لصاحبها الاستمرار فى انتفاعه بالنور ولا تحول دون الجار وإقامة بناء على الحائط الفاصل ما بين ملكه وملك الجار صاحب المنور ولو أدى ذلك لسد المنور^(١) دون أن يكون للآخر أن يعترض على ذلك مهما طالبت المدة على وجود المنور، إذ أن إتيان الرخص لا يصلح أساساً للحيازة ولا للتمسك بالتقادم المكسب (م ٩٤٩).

لذلك يحسن ترك مسافة حتى تبقى المناور تؤدي وظيفتها إذا أقام الجار بنائه وإذا كان من المقرر أن للمالك فتح المناور على حافة ملكه وليس للجار أن يعترض عليها، فإن ذلك مشروط بالقيد العام الذى يرد على الحقوق كافة وهو القيد الذى يتضمن مبدأ عدم جواز التعسف فى استعمال الحق. فيكون للجار أن يطلب سد المناور إذا أساء المالك استعمالها، كما إذا اعتاد أن يعتلى ما يمكنه من الأطلال من المنور على ملك الجار، أو اعتاد أن يلقي نه مخلفات منزله فتسقط فى ملك جاره.

2024/2025

الفرع الثانى

القيد الخاص بالحائط الفاصل

الحائط الفاصل هو الذى يفصل بين بناءين^(٢)، والحائط الفاصل قد يكون مملوكاً ملكية مفرزة لواحد من مالكي البناءين، وقد يكون مملوكاً معاً. وحينئذ تكون ملكيته ملكية شائعة.

(١) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٧٩١، د. إسماعيل غانم ص ٧٧ د. حسن كيرة ص ١١٨، د. توفيق فرج ص ١٩٧، د. مصطفى الجمال ص ٢٤٠.

(٢) أن فصل بين أرضين أو بين أرض وبناء لما كان فاصلاً بالمعنى الذى يقصده المشرع من الأحكام التى أوردها بهذا الشأن. الأعمال التحضيرية ج ٦ ص ٦٤.

وقد أورد التقنين المدني نصوصاً شاملة للحائط الفاصل بنوعيه في المواد ٨١٤ وما بعدها، استمد بعض أحكام هذا الوضع من القانون المدني السابق ومن الشريعة الإسلامية ومن بعض التقنيات الأجنبية.

ويعتبر اشتراك الجارين في ملكية الحائط الفاصل صورة خاصة للملكية الشائعة، إذ هو من قبيل الشيوع الإجباري، ومن ثم كان يقضى المنطق أن يربحاً دراسة الحائط المشترك إلى حين الكلام عن الملكية الشائعة، ولكننا نؤثر أن نتكلم عن الصورتين معاً حتى يجئ البحث مكتملاً وتكون المقارنة أكثر يسراً.

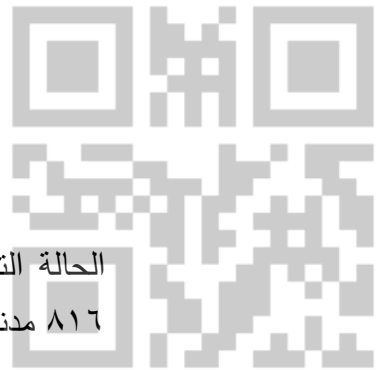
ويبدو أن نفس الاعتبار هو الذي دفع التقنين إلى الحديث عن الصورتين في موضع واحد تحت عنوان «القيود التي ترد على حق الملكية». بين في المواد من ٨١٤ - ٨١٦ أحكام الحائط الفاصل إذا كان مشتركاً، أما الحائط الفاصل المملوك ملكية خاصة فقد نص عليه في المادة ٨١٨ منه.

الحائط المملوك ملكية خاصة لأحد الجارين:

نص المادة ٨١٨/١ على أنه «ليس للجار أن يجبر جاره على تحوير ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة ٨١٦ مدني»^(١). وتحوير المالك يراد به إنشاء سياج فاصل بينه وبين ملك الجار، وهو بهذا المعنى يختلف عن وضع الحدود، لأنه إذ كان للجار أن يجبر جاره على وضع حدود لأملكها المتلاصقة فليس له أن يجبره على تحوير ملكه^(٢). كذلك ليس أن يجبر صاحب الحائط على الاشتراك فيه حتى ولو دفع تعويض مقابل اشتراكه، لمالك الحائط مطلق الحرية في قبول اشتراك الآخر معه في الحائط أو عدم قبوله، وذلك فيما عدا

(١) هذا الحكم مأخوذ من الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة ٦٩ من مرشد الجيران على أنه «لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على أن يعطيه جزءاً من حائطه أو من الأرض القائم عليها الحائط».

(٢) د. أحمد سلامة. المرجع السابق ص ٢٠٩. د. الصدة، المرجع السابق ص ١٢١.



الحالة التي ينفرد فيها أحد الشركاء بتعليق الحائط المشترك طبقاً لحكم المدة ٨١٦ مدنى.

والجار الذى يملك الحائط الفاصل ملكية خالصة يكون له وحده أن يباشر عليه سلطات المالك، غير أن المشرع قد أورد قيداً على حق هذا الجار فى أن يتصرف فى الحائط بالهدم، حيث تقول المادة ٢/٨١٨ «مع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوى إذا كان هذا يضر بالجار الذى يستر ملكه بالحائط». ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً لنظرية التعسف فى استعمال الحق.

وهذا النص الذى يحرم مالك الحائط الفاصل من سلطة الهدم مشروط أعماله بتوافر ثلاث شروط:

الأول: أن يكون ملك الجار مستتراً بالحائط، ومعنى الاستتار أن يكون ملك الجار مسوراً من جهات ثلاث أخرى ويكون الحائط رابعها.

ويجب ثانياً: أن يكون من شأن هدم الحائط أن يضر بالجار^(١). وينتفى الضرر إن كانت أرض الجار المسورة أرض فضاء غير مبنية، فيكون لمالك الحائط هدمه ولو لم يوجد عذر قوى يبرر الهدم.

ويجب ثالثاً: لحرمان المالك من سلطته فى الهدم ألا يوجد للهدم «عذر قوى» وعلى ذلك فالقيد يسقط إذا كان للمالك عذر قوى فى هدم الحائط، كأن يتبين أن به عيباً، أو أراد أن يهدمه ليبنى بناء أكبر يستغله بدلاً من الحال. وفى مثل هذه الحالات فإن الهدم يضر بمصلحة الجار ولكن الهدم يكون أيضاً من حق المالك ولذلك يرجح بين المصلحتين ويضحى بأقلهما أهمية. وهذا يترك لتقدير قاضى الموضوع. والحقيقة أن نص المادة ٢/٨١٨ ليس إلا تطبيقاً

(١) د. إسماعيل غانم: ص ٨٠، د. الصدة: ص ١٢٢، د. البدروى: ص ١٢٣. فى حين يرى أ.د. أحمد سلامة أن الاستثنائين يفترض الهدم ومن ثم فليس كلامهم أمراً مستقلاً بل هم أمر واحد: ص ٢١١.



لإحدى حالات التعسف في استعمال الحق التي نص عليها المشرع في المادة الخامسة فقرة «ب» من التقنين المدنى.

والقيد السابق لا يعرض إلا بالنسبة للهدم الاختيارى، فإذا انهار الحائط من تلقاء نفسه أو انهدم نتيجة حادث جبرى^(١)، أو تعين هدمه تطبيقاً للوائح والقوانين، فلا يجوز للجار أن يشكو مدعياً أن صاحب الحائط لم يراع القيد ولم يلتزم به، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المالك إعادة بناء الحائط حتى ولو عرض أن تكون نفقات البناء مناصفة بينها أو عرض أن يتحملها وحده.

ويلاحظ أن القيد الذى تضمنته المادة ٢/٨١٨ قيد يحد من سلطة المالك فى الهدم فقط ولكنه لا يحد من سلطته فى الاستئثار بملكه، بمعنى أن له وحده الاستفادة من الحائط بأن يسند إليه بناء أو يضع فيه عوارض خشبية أو غير ذلك. أما الجار المستتر فليس له شئ من ذلك، فليس له من الحائط سوى الانتفاع السلبي الناشئ عن وجوده. غير أنه إذا باشر مثل هذه الأعمال المادية وتوفر فيها معنى التعدى، ولم يتبين من الظروف الملابس أن مالك الحائط كان متسامحاً، فإن الجار يمكن أن يكسب أحد حقين حسب الصفة التى قام بالأعمال على أساسها. فإن قام بها بوصفه شريكاً فى ملكية الحائط فإنه يكتسب ملكية مشتركة فيه^(٢)، وأن قام بوصفه صاحب حق ارتفاق عليه كسب هذا الحق، وفى الحالتين لا يحق لمالك الحائط أن يطلب الإزالة.

الحائط الفاصل المشترك:

أسلفنا أن الحائط الفاصل بين ملكين متلاصقين أما أن يكون مملوكاً للمالكين معاً على الشيوع، وإما أن يكون ملكاً خالصاً لأحدهما.

(١) د. شفيق شحاته: المرجع السابق ص ٣٨٥، د. البدروى المرجع السابق ص ١٣١، د. أحمد سلامة: ص ٢١٠، د. الصدة: ص ١٢٣.
(٢) د. البدروى: ص ١٣٢، د. الصدة: ص ١٢٣، د. إسماعيل غانم: ص ٨٠، د. السنهورى الوسيط ٨: ص ١٠٠٧، د. أحمد سلامة ص ٢١٠.





وتكلمنا عن الحائط المملوك ملكية خالصة. أما إذا كانت ملكية الحائط الفاصل مشتركة بين الجارين فإن الشيوخ فيه يكون شيوخاً إجبارياً تبعياً.

ويكون الحائط مشتركاً إذا أقامه الجاران على حدود ملكهما بنفقات مشتركة. أو كان مملوكاً ملكية خالصة لأحد الجارين ثم اتفقا بعد ذلك على إشراك الجار الآخر في ملكيته. وقد يتحقق اكتساب الملكية المشتركة في الحائط الفاصل بطريق الالتصاق. ويكون ذلك إذا أقام أحد المالكين الحائط وحده ولكنه لم يجعل سمكه كله في ناحية بل كان بعض سمك الحائط على أرض جاره^(١).

وقد يكون الميراث من بين أسباب المشاركة في الحائط، فإذا اقتسم الورثة التركة واختص أحدهم أو أكثر بأحد البنائين وأختص شخص آخر أو أكثر بالبناء الثاني فإن ذلك الحائط يصبح مشتركاً. وقد تكسب المشاركة في ملكية الحائط الفاصل بطريق التقادم المكسب ولكن لا يتحقق ذلك إلا إذا توافرت في حياة الجار الشروط التي نصت عليها المادة ٩٤٩، وبوجه خاص إلا يكون استعمال الجار للحائط الفاصل مبنياً على تسامح المالك.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

حيث تتوافر واحد من الأسباب المتقدمة تكسب المشاركة في ملكية الحائط. أما عند فقدانها يكون على من يدعى المشاركة أن يقدم الدليل على ما يدعيه. وقد تدخل المشرع وأقام قرينة لصالحه أوردها في المادة ٨١٧ مدني «الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقد دليل على العكس».

(١) د. إسماعيل غانم ص ٢٨٥. وعكس ذلك د. السنهوري الوسيط ص ٩٩٠. أحمد سلامة ص ٢١٣ حيث يرى أن الحائط في هذه الحالة يكون مملوكاً لشخصين ملكية مفرزة لكل بقدر السمك الواقع في أرضه ما لم يستفيد الباني من الرخصة التي تخولها المادة ٩٢٨ مدني فيصبح الحائط الفاصل كله مملوكاً ص له ملكية مفرزة.



وقد بينت المذكرة الإيضاحية^(١) شروط قيام هذه القرينة فذكرت أنه يشترط حتى تقوم هذه القرينة شرطان:

(١) أن يكون الحائط فاصلاً بين بناءين فلا يكفي أن يكون فاصلاً بين أرضين أو بين أرض وبناء.

(٢) أن يكون الحائط قد فصل بين البناءين منذ إنشائه، فإذا لم يوجد وقت إنشاء إلا بناء واحد، ثم قام بعد ذلك بناء آخر ملاصق استتر بالحائط فأصبح هذا الحائط جزءاً من البناء الأول فإن القرينة لا تقوم، ويعتبر في وضعه الجديد فاصلاً بين بناءين ومملوكاً ملكية خالصة لصاحب هذا البناء.

وبتوافر الشرطين تقوم القرينة القانونية على أن الحائط مشترك، إلا أنها قرينة بسيطة يجوز لمن تقوم ضده أن يثبت عكسها، أي يثبت أن الحائط ملك خالص له، أو يثبت أنه استقل باستعمال الحائط والإنفاق على إصلاحه مدة خمسة عشر سنة فتملكه بالتقادم^(٢). أو يستدل بعلامات ظاهرة تفيد أن الحائط قسماً من البناء لا استعمال أحد الجارين فحقه^(٣) إلى غير ذلك مما يؤدي إلى سقوط القرينة، وإذا تعارض القرائن يكون لقاضي الموضوع أن يرجح أيهما^(٤)، فإن قضى بالمشاركة انطبعت الأحكام الخاصة بها.

حقوق الشركاء والتزاماتهم:

تقضى المادة ٨١٤ مدنى على أنه:

١- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له، وأن يضع عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

(١) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ٦٤.

(٢) د. عبد المنعم الصدة: ص ١١٥.

(٣) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٩٩٢، د. أحمد سلامة: ص ٢١٤ د. حسن كيره: ص ٢٥١.

٢- فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذى خصص له عادة، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء، كل بنسبة حصته فيه.

هذا النص يحدد حقوق والتزامات كل شريك فى استعمال الحائط المشترك وفقاً لأحكام الشيوخ الإجماعى التبعى^(١)، وما يقتضيه من أنه لا يجوز أن يترتب على استعمال أحد الشركاء للحائط تعطيل حقوق شريكه. فالمشرع يجيز لكل شريك أن يستعمل الحائط المشترك ولكن يقيد هذا الاستعمال بقيدين:

الأول: أن يكون الاستعمال متفقاً مع الغرض الذى أعد له الحائط، والغرض الذى أعد له هو من ناحية استتار الجار به، ومن الأخرى. وضع عوارض يسند عليها سقف بنائه^(٢). ومن ثم يكون غير متفق مع هذا الغرض أن يفتح الجار فى الحائط مناوور أو مطلات، فهذا يتعارض مع الاستتار الذى يقيم الحائط من أجل تحقيقه. فإذا فعل الجار ذلك حق لشريكه أن يطلب سد الفتحات مع التعويض إن كان له مقتضى، إلا إذا توافرت فى جانب الجار شروط التقادم المكسب^(٣).

24/2025 **المقيد الثانى:** هو ألا يحمل الجوار^{4/3} الحائط فوق طاقته أو يضع عليه أكثر من نصف الثقل الذى يتحمله، وما يقال عن العوارض يقال عن وإذا وقع التخلل صحيحاً أصبح الحائط مملوكاً ملكية مفرزة للشريك الآخر.

تعليق الحائط المشترك:

للمالك أن يستعمل الحائط المشترك بحسب الغرض الذى أعد له، ولكن قد تقتضى الإفادة من الحائط تعليته حتى يستر سطح البناء أو الطبقات الجديدة التى يراد إنشاؤها. لذلك نصت المادة ٨١ مدنى على:

(١) يترتب على هذا الشيوخ الإجماعى أنه لا يجوز لأى من الشريكين أن يطلب قسم الحائط، كما لا يجوز له التصرف فى حصته الشائعة استقلالاً عن العقار الذى يملكه، ولا يجوز توقيع الحجز على الحصة الشائعة استقلالاً.

(٢) د. إسماعيل غانم: ص ٢٨٦، د. توفيق فرج: ص ١٨٧.

(٣) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٩٩٠، د. أحمد سلامة: ص ٢١٥.

١- للمالك إذا كان له مصلحة جديد في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ من التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.

٢- فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً ليتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد عن سمكه في ناحيته على قدر الاستطاعة، وبظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.

تواجه هذه المادة حالة تعلية الحائط المشترك، وقد يتفق الشريكان على التعلية فيتحمل كل منهما نصيبه في نفقاتها. ولكن إذ لم يتفق الشريكان جاز لأى منهما أن يستقل بالقيام بالتعلية بشروط.

أول هذه الشروط أن تكون له مصلحة في التعلية، كأن يريد بناء طابق **تفوق طبقات بنائه القائم فعلاً.** 2024/2025

2024/2025

أما الثانى: ألا تلحق التعلية بالشريك الآخر ضرراً بليغاً، ومثال الضرر البليغ أن يكون من جراء أعمال التعلية أن تصيب بناء الجار بخلل الحفر التي يحدثها الجار في الحائط ليهيئ فيها مكاناً لدولاب أو مدفأة أو أنبوبة مياه غاز أو ما نحو ذلك^(١).

أما التزام الشريك فهو المساهمة في نفقات الصيانة والتجديد والإصلاح بنسبة حصته في الحائط، بشرط أن تكون هذه الأعمال ضرورية لاستمرار الانتفاع بالحائط بحسب الغرض الذى أعد له. ويجوز لأى منهم أن يجبر الآخرين على المساهمة في هذه النفقات ما دامت ضرورية لاستعمال الحائط.

(١) د. الصدة: المرجع السابق ص ١١٦، د. توفيق فرج: ص ١٨٧، د. محمد على عمران: الحقوق العينية الأصلية طبعة ١٩٨٩ ص ٣١٤.

ويترتب على ذلك أنه إذا كان الحائط يصلح للغرض الذى خصص له، لكن مصلحة أحد الشركاء اقتضت تجديده فإن هذا الشريك وحده هو الذى يتحمل نفقات هدمه وإعادة بنائه.. والحال كذلك إذا كانت حاجة الحائط إلى الترميم أو التجديد ترجع إلى خطأ أحد الشركاء^(١).

والترزام الشريك بدفع نصيبه فى النفقات التزام عيني، ومن ثم فهو يستطيع التخلص منه إذا تخلص من حصته فى الحائط. ولكن هذا مشروط بألا يكون هو الذى تسبب بخطئه فى حدوث الخلل الذى وقع للحائط. أما الشرط الثانى أن يسبق عن حصته فى الحائط هدمه لبنائه المستند إليه وإلا كان التخلي محقق له مصلحة على حساب شريكه فى الحائط لأنه يخلصه من الالتزام بدفع النفقات فى حين أنه لا يزال ينتفع بالحائط^(٢).

أو يترتب على هدم الحائط تمهيداً لبنائه انهيار هذا البناء^(٣). أما الشرط الثالث: هو أن ينفق الشريك وحده على التعلية وعلى صيانة الجزء المعلى، فإذا تمت التعلية دون هدم للحائط تحمل نفقات التعلية، وإذا اقتضت هدم الحائط تحمل هو نفقات إعادة بناء الحائط كله^(٤).

2024/2025

2024/2025

أما الشرط الأخير: أن يعمل الشريك ما يلزم حتى لا تؤثر التعلية على متانة البناء وهى مسألة يستعان فيها بأهل الخبرة.

ورغم انفراد الشريك بتجديد الحائط - سواء فى صورة إبقائه مع زيادة علوه أو هدم الجزء الأصلى وبناء الحائط بشكل أكثر ارتفاعاً - فإن الحائط المجدد يظل مشتركاً فى غير الجزء المعلى، دون أن يدفع الجار لهذا الشريك تعويضاً عن الفرق فى القيمة بين الحائط القديم والجديد. وذلك لأن مصلحة

(١) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ٦٥.

(٢) د. السنهورى الوسيط ص ٩٩٧، د. أحمد سلامة: ص ٢١٧.

(٣) د. السنهورى الوسيط ص ٨، ٦٩٩، د. إسماعيل غانم: ص ٢٨٧، د. الصدة ص ١١٩، د. أحمد سلامة: ص ٢١٧، محمد عمران ص ٣١٦.

(٤) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ٩٥.

الشريك وحده هي التي دعتة إلى تجديد الحائط، فهو الذى يتحمل كل ما يترتب على التحديد.

وإذ كان الجزء المعلى يصبح ملكاً خالصاً للشريك الذى قام بالتعلية إلا أن الشريك الآخر قد يصبح فى المستقبل فى حاجة إلى الإفادة من الجزء المعلى. لهذا خوله المشرع حق الاشتراك فى الجزء المعلى جبراً عن مالكة حيث نصت المادة ٨١٦ مدنى على أن «للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكاً فى الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه بقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة. وهذه هى الحالة الوحيدة التى يخول فيها المشرع الجار حق الاشتراك فى ملكية الحائط الفاصل جبراً عن مالكة. وحق الاشتراك فى الجزء المعلى لا يسقط بالتقادم^(١)». فتجوز المطالبة به فى أى وقت، حتى بعد انقضاء خمس عشر سنة من تاريخ التعلية.

المطلب الثانى

2024/2025

القيود التى تحد من استئثار المالك بملكه

2024/2025

تقسيم:

إذ أنشأ مالك الأرض مسقاة أو مصرف فهى ملك خاص^(٢) له (م ١/٨٠٨ مدنى)، وله وحده الاستئثار بالانتفاع بها وأن يمنع غيره من استعمالها فيما تحتاجه أرضه من رى أو صرف. كما أن مالك الأرض له أن يستأثر بالانتفاع بها وأن يمنع غيره من استعمالها فى مرور مياه ريه أو صرفه أو فى المرور خلالها إلى الطريق العام. غير أن تقرير هذا الأصل من شأنه أن يضر بالغير الذى لا يجد كفايته من المياه لبعدها عن موره أو عن مصرفه، كما

(١) د. السنهورى الوسيط ٨: ص ١٠٠١ د. الصدة: المرجع السابق ص ١١٩، د. أحمد سلامة: ص ٢٢١، د. إسماعيل غانم: ص ٢٨٨.

(٢) حرية مالك الأرض فى إنشاء المسقاة أو المصرف الخاص فى أرضه ليست مطلقة. بل يحد منها القيود التى تضمنها قانون الرى والصرف.

يؤدي إلى استحالة أو عرقلة استعمال واستثمار بعض الأراضي لانحباسها عن الطريق انحباساً كلياً أو جزئياً.

لذلك فقد خرج التقنين المدني على هذا الأصل وقرر لمثل هذه الأراضي حقوقاً من الشرب والمجرى والمسيل والمرور. وهي جميعاً قيوداً تحد من استئثار المالك بملكه بتمكين غيره من الاستفادة منه. وسوف نعرض أولاً القيود الخاصة بالرى والصرف، ثم للقيود الخاص بالمرور القانوني.

الفرع الأول

القيود الخاصة بالرى والصرف

عنى المشرع بتنظيم القواعد المتعلقة بالرى والصرف، وكان أول تشريع شامل عم لها هو القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣، وقد ألغى هذا التشريع وحل محله تشريع جديد هو القانون ٧٤ لسنة ١٩٧١، الذي أدخلت عليه تعديلات لاحقة ولكنه ظل هو التشريع الأساسى فى المسائل المتعلقة بالرى والصرف.

2024/2025

ولن نتعرض لأحكام هذا القانون ما عدا ما اتصل بها بالقيود المفروضة فى التقنين المدني على الملكيات الخاصة لمصلحة الأراضي المجاورة بتحويل تلك الأراضي حق الشرب والمجرى والصرف أو السيل. وقد نصت المادة ١٥ من قانون الرى على أنه «إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه رياً كافياً أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص موجود فى أرض الغير.....»

مؤدى هذا النص أنه يجب لقيام مثل هذا الحق استحالة أو تعذر رى الأرض أو صرفها رياً أو صرفاً كافياً إلا بتقريرها.

وفيما يلى نتناول شروط قيام كل من هذه الحقوق فى ضوء الأحكام التى نص عليها القانون فى المواد ٨٠٨ وما بعدها مكمله بأحكام قانون الرى والصرف:



١- حق الشرب:

حق الشرب هو حق الشخص في رى أرض من مسقاة خاصة مملوكة لجاره. وقد نصت على ذلك المادة ٢/٨٠٨ على أنه «يجوز للمالك المجاورين أن يستعملوا المسقاة الخاصة فيما تحتاجه أراضيهم من رى، بعد أن يكون مالك المسقاة قد استوفى حاجته منها. وعلى المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع بها».

هذا النص أنه يتضمن قيداً على حق المالك في أن يستأثر باستعمال مسقاته لصالح الجيران. وهو قيد عادل نظراً لحاجة المالك المجاورين إلى تلك المياه لرى أراضيهم، خاصة وأن المياه مصدرها الترع والقنوات ومباح للكافة التمتع بها، وبذلك يقرر المشرع حق الشرب القانوني للأرض المجاورة على المسقاة الخاصة المملوكة للغير. وأن كان هذه الاستفادة مشروطة بقيد نص عليه المشرع في المادة ٢/٨٥٨ وهو الجوار.

2024/2025

فيثبت حق الشرب للأرض المجاورة. ولما كان المشرع لم يحدد المقصود بالجوار، هل هو جوار المملوكة ذاتها أم جوار الأرض الموجود بها المسقاة فقد اختلف الفقه. فذهب رأى ونفضله^(١) أن المقصود هو جوار الأرض، تأسيساً على أن لفظ الجوار ورد مطلقاً في النص ومطلق الجوار يتحقق بجوار الأرض التي تخترقها المسقاة من ناحية، فضلاً عن أن هذا التفسير يتفق وحاجات الرى الزراعى. بينما ذهب رأى آخر^(٢) إلى أن المقصود بالمالك المجاورين هو المالك الملاصقون للمسقاة، لأن حق الشرب باعتباره قيداً استثنائياً يرد على الملكية لا بد وأن يفسر تفسيراً ضيقاً.

(١) د. السهورى الوسيط ص ٧٢٠، د. إسماعيل غانم: ص ٨٥ د. الصدة: ص ٧٤، د. البدرأوى: ص ٣٩٧، د. منصور مصطفى ص ٦٦، د. مصطفى الجمال: ص ٢٣٠.

(٢) د. محمد على عرفه ج ١ فقرة ٢٠٨، د. حسن كيرة ص ٩٨، د. توفيق فرج ص ١٦٥.

وقد فرض المشرع على الملاك المجاورين بمقتضى ما لهم من حق الشرب القانونى أن يساهموا فى نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها. ولا يحق لهم هذا الاستعمال إلا بعد أداء ما يجب عليهم من هذه النفقات، ويراد بنفقات الإنشاء النفقات اللازمة لشق المسقاة، فلا يكون على الملاك المجاورين تعويض مالك المسقاة عن قيمة الجزء من الأرض التى شقت فيه، لذلك فإن هؤلاء يصبحون شركاء فى ملكية المسقاة، بل تظل الملكية خالصة للمالك^(١). ومن أجل هذا المالك مقدما فى استعمال المسقاة على هؤلاء جميعاً، فلا يستعملوا المسقاة إلا بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها.

٢- حق المجرى:

يتقرر حق المجرى لمالك أرض بعيدة عن حدود المياه، فيخوله القانون أن يأخذ غير أرض الجار ما يكفى لرى أرضه. وعلى ذلك نصت المادة ٨٠٩ مدنى «يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمن بأرضه المياه الكافية لرى الأراضي البعيدة عن مورد المياه. بشرط أن يعرض عن ذلك تعويضاً عادلاً».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فحق المجرى - وفقاً لهذا النص - يقصد به مرور المياه لرى أرض بعيدة عن موردها عبر أرض مملوكة لشخص آخر. ويشترط لثبوت هذا الحق أن تكون الأرض بعيدة عن موارد المياه. سواء كان هذا المورد مورداً عاماً كترعة عامة مثلاً. وفى هذه الحالة ينبغى الحصول على ترخيص من وزارة

(١) قضت محكمة النقض بأن «مفاد أن الحق الذى يتولد من ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاة فى أرض الغير فيجرى بها المياه توصللاً لاستعمالها فى رى أرض الجار هو حق المجرى والشرب وهو الحق المقرر بالمادتين ٨٠٨، ٨٠٩ من القانون المدنى، وتقدير هذا الحق يختلف عن حق الملكية فالحياسة باستعمال المسقاة فى الرى ركوناً إلى ذلك الحق تعتبر حياسة بسبب معلوم غير أسباب كسب الملكية مما ينتقى معه فيه تملك أرض المسقاة، وتبقى هذه الحياسة المتجردة من هذه النية غير صالحة للتمسك بالتمسك مهما طال أمدها إلا إذا حصل تغيير فى سببها. نقض مدنى ١٩٨٠/٢/٢١ طعن رقم ٤٥٥ لسنة ٤٩ ق س ٣١ ص ٥٧٣.

الأشغال لأخذ المياه من التربة العامة طبقاً لما يقضى به قانون الرى والصرف^(١)، إذ لا معنى لثبوت حق المجرى طالما لم يكن للطالب به حق أخذ المياه.

وقد يكون مورد المياه تربة أو مسقاة خلصه مملوكة للغير. وفي هذه الحالة أيضاً يجب أن يكون لمالك الأرض المراد ربيها حق أخذ المياه من المسقاة الخاصة، أما بمقتضى حق للشرب المنصوص عليه فى المادة ٨٠٨، وأما بمقتضى اتفاق بينه وبين المالك^(٢).

ولا يشترط لثبوت حق المجرى أن تكون المياه المراد تمريرها منها ضرورية لرى أرضه، بل يكفي أن تكون مطلوبة لريها رياً كافياً، فيثبت حق المجرى ولو كان هناك سبيل آخر لرى الأرض كما لو كان لمالك الأرض بئر يستخرج منها الماء ولكنها غير كافية لرى الأرض وزراعتها على النحو المعتاد^(٣).

وقد قرر المشرع لمالك الأرض المقام عليها المجرى الحق فى تعويض ~~2024/2025~~ ^{2024/2025} هذه الحالة ~~2024/2025~~ ^{2024/2025} الأشخاص الذين لحقهم ضرر من تقرير هذا الحق، سواء كان هو الجار أم شخصاً آخر، كما يشمل التعويض الأضرار التى تترتب على شق المجرى سواء كان هذا من حيث حرمان صاحب الأرض من الانتفاع بالجزء الذى يرد عليه المجرى، أم من حيث الأضرار الأخرى أيا كان نوعها، طالما كانت ناشئة عن شق المجرى. ويلاحظ

(١) انظر المادة ٣٩ من القانون ٧٤ لسنة ١٩٧١.

(٢) د. إسماعيل غانم: ص ٨٦، د. مصطفى الجمال ص ٢٣١، د. توفيق فرج ص ١٦٧. قارن أيضاً: د. حسن كيرة ص ١٠٠.

(٣) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ٤٤، المادة ١٥ من قانون الرى والصرف ١٩٧١ التى نقلكم عن تعذر الرى أو الصرف على وجه كاف.

أن إجراءات الحصول على هذا الحق وتقدير التعويض تخضع لنفس القواعد التي نص عليها قانون الري والصرف بصدد حق الشرب^(١).

٣- حق الصرف أو المسيل:

حق الصرف هو حق مالك الأرض الزراعية في تصريف المياه الزائدة عن حاجة أرضه. وقد عرضت المادتين ٨٠٨، ٨٠٩ لهذا الموضوع مع الأحكام الخاصة بحق الشرب وحق المجرى. وله حالتين:

١- الحالة الأولى ويعمل في شأنها ما ورد بالنسبة لحق الشرب فيجوز للملاك المجاورين لمصرف خاص أنشأه صاحبه طبقاً للوائح الخاصة، أن يستعملوه فيما تحتاجه أراضيهم من صرف، وذلك بعد أن يكون صاحبه قد استوفى حاجته منه. ويتفق الفقه في هذه الحالة على قصره حق الصرف على الملاك المجاورين لأرض صاحبه.

٢- الحالة الثانية وهي التي تقابل حق المجرى، فأنها تتعلق بصرف مياه الأرض البعيدة عن المصرف العمومي. وفي هذه الحالة يوجب القانون على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر في أرضه مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي. وحق الصرف في هذه الحالة يختلف عن حق المجرى. ذلك أن حق الصرف يقتصر على الحالة التي يتم فيها الصرف في مصرف عمومي. ويكون على الجار البعيدة أرضه عن المصرف العام أن ينشئ مصرفاً خاصاً على نفقته في أرض الجار المصرف العام.

(١) قضت محكمة النقض «صاحب الأرض الذي يرى أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه رياً كافياً والذي تعذر عليه التراضي مع مالك الأرض التي يمر بها المجرى، بطلب إلى المحكمة أو جهة الإدارة المختصة لتقرير هذا الحق له وبيان الكيفية التي يكون بها إنشاء المجرى وتحديد التعويض الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له إذ أن تقرير هذا الحق لا يكون إلا مقابل تعويض عادل». نقض مدني ١٩٥٦/١١/١١ طعن رقم ٤٠ لسنة ٣١ ق، س ٢١ ص ١٠٤٩.

وإذا ما تقرر هذا الحق، حق الصرف أو المسيل ألزم مالك لأرض البعيدة عن المصرف العام بتعويض صاحب الأرض التي يمر فيها المصرف، طبقاً للأسس التي أوردناها في حق المجرى.

وقد وضع القانون على عاتق المنتفعين بهذه الحقوق - الشرب والمجرى والمسيل أو الصرف - عدة التزامات تكفل عدم الأضرار بالأرض المحملة بها، وتضمن تحقيق الغرض من تقريرها وهو رعاية الاستثمار الزراعي^(١).

ونصت عليها المادة ٨١٠، ٨١١ من التقنين المدني وتنص الأولى «أنه على إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء أكان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أو عن سوء حالة الجسور فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً كافياً عما أصابه من ضرر». كما تنص المادة ٨١١ مدني «إذ لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الدورية، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحدة منهم».

الفرع الثاني

2024/2025

القيد الخاص بالمرور القانوني

2024/2025

عرضنا فيما تقدم لطائفة من القيود التي ترد على سلطة المالك في الاستئثار بملكه، وهي القيود التي تتعلق بالرى والصرف. وهنا سنعرض لقيد يرد على حق الملكية العقارية ويؤدى أيضاً إلى تعطيل استئثار المالك بملكه على مسطح معين منه، وهو ما يعرف بقيد المرور القانوني أو بحق المرور. وهو قيد عام، أى يحمل الملكية الزراعية وملكية أراضي البناء^(٢)، ويستوى فيه

(١) قضت محكمة النقض «تعتبر مسقاة كل قناة أو مجرى، معدة لرى أراضي بلد أو بلدين أو لرى أرض لمالك واحد أو لعائلة مشتركة ولو كانت المسقاة فى زمام عدة بلاد، وتعتبر المساقى جميعها أملاك خصوصية والمنتفعون بها هم المكلفون بتطهيرها وصيانتها ويجوز للحكومة عند التأخير فى تطهيرها أن تطهرها على نفقة هؤلاء المنتفعين» نقض مدني ١٩٧٠/٦/١١ س ٢١ ق ص ١٠٤٩.

(٢) د. السنهورى الوسيط ص ٧٥٧، د. إسماعيل غانم: ص ٩٠ د. الصدة ص ٩٤، د. منصور مصطفى ص ٧٣، د. أحمد سلامه: ص ١٦٥.

أن تكون الأرض مملوكة لفرد من الناس، أو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، بل أنه بحسب الرأي الغالب^(١) يتقرر المرور على أرض مملوكة ملكية عامة متى كان المرور لا يتعارض مع الغرض الذى خصص له هذا المال. وقد نصت المادة ٨١٢ على هذا القيد وأوضحت أحكامه حيث قالت:

١- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف، إذ كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدم اللزوم لاستغلال أرضه واستعمالها على وجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك نظير تعويض.

ولا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضرراً وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك.

٢- على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣- ولا يثبت حق المرور الذى تقرره هذه المادة إلا لصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام، لذا فإن لهذا الحق شروط يلزم توافرها لقيامه، كما أن له أحكام سنتكلم عن كل منها ثم فى انقضائه.

شروط وجود حق المرور:

١٩٨- انحباس الأرض عن الطريق العام هو شرط وجود الحق القانونى فى المرور. ومن ثم يخضع هذا الحق فى وجوده ومداه لاستعمال العقار واستغلاله. ويشترط ألا يكون هذا الانحباس راجعاً إلى فعل المالك.

أولاً: معنى الانحباس: لا يثبت حق المرور القانونى إلا لصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أى يشترط ألا يكون للعقار اتصال بالطريق العام

(١) د. محمد على عرفه: ص ٢٨٨، د. السنهورى: ص ٧٦٢، د. البدرائى ص ٣٨٥، د. حسن كيرة: ص ١١٠، د. أحمد سلامه: ص ١٦٧.



بأن يكون محاطاً من جميع الجهات بأرض الجيران، أى انحباساً كلياً. وكذلك يثبت إذا كان العقار لا يتصل بهذا الطريق إلا بممر غير كاف لاستغلاله أو استعماله، أى انحباساً جزئياً. ويعتبر المرور غير كاف إذا كان لا تيسر الوصول منه إلى الطريق العام إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة (م ١/٨١٢) كأن يكون الممر الذى يوصل بين الأرض الزراعية والطريق العام لا يكفى إلا لمرور المشاة، فلا يمكن أن يستعمل لمرور الماشية أو العربات، أما إذا كان الممر لا يتطلب إلا نفقة معقولة تتناسب مع قيمة العقار أو كان غير مريح، فلا يتحقق الانحباس، وكفاية الممر أو عدم كفايته مسألة وقائع تخضع لتقدير قاضى الموضوع^(١).

وما دام هناك ممراً كافياً يستعمله المالك فعلاً للوصول إلى الطريق العام فلا يقبل منه القول بأن الانحباس يتحقق فى أرضه، حتى ولو لم يكن مستنداً فى هذا الاستعمال إلى سند قانونى. فليس للمالك أن يطالب بحق المرور القانونى إذا كان لديه ممر كاف يستعمله بناء على حق ارتفاق متنازع فيه، أو بناء على مجرد تسامح من جانب الجار. بل يكون طلب المالك حق المرور القانونى فى هاتين الحالتين سابق لأوانه طالما لم يحرم عليه المرور فى أرض الجار نتيجة لأبطال سند الارتفاق أو عدول الجار عن تسامحه^(٢).

(١) لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام إلا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق، بل يكفى لتحقيق هذه الحالة وفقاً لنص المادة ١/٨١٢ أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه عز كاف بحي لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، وهو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاؤه على أسباب سائغة» طعن رقم ٤٠١ لسنة ٤٩ ق فى ١٩٧٤/١٢/٣١ س ٢٥ ص ١٥٤٧.

(٢) د. محمد على عرفه ج ١ ص ٢٩٢، د. شفيق شحاته ص ٣٥٤ د. البدرأوى: ص ٣٨٢، د. إسماعيل غانم: ص ٢٩٢، د. الصدة. ص ٩٥ وعكس ذلك من يرى أن للمالك حق المرور القانونى فى هذه الحالة باعتبار أن مروره فى أرض الجار على سبيل التسامح لا يثبت له حق يحميه القانون. د. السنهورى الوسيط: ص ٧٥٦، د. منصور مصطفى: ص ٧٥، د. محمد عمران: ص ٣١٢، مصطفى الجمال: ص ٢٢٠.



ثانياً : يجب أن يكون الممر ضرورياً لاستعمال العقار واستغلاله:

لما كان حق المرور يخضع في وجوده ومداه الحاجات استعمال العقار واستغلاله، لهذا كانت العبرة في تقدير لزوم الممر ومدى كفايته بطبيعة أهمية الاستعمال أو الاستغلال الذي أعد له العقار. وفي هذا تقول المادة ٨١٢ مدنى «يكون له حق المرور في الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف». فالأراضى الفضاء أو المبنية للسكن إذ توافر لها ممر لا يصلح إلا لمرور المشاة لا تعتبر محبوسة، ولا يكون لمالكها أن يطالب بحق المرور القانونى. ولكنه لا يكون كافياً لأرض زراعية. والأرض التى أنشئ عليها مصنع تحتاج إلى ممر كاف لمرور عربات النقل الكبيرة مما لا تحتاج إليه الأرض التى تستغل للزراعة.

وما دام أن العبرة بحاجات استعمال العقار واستغلاله فإن التعديل أو التغيير فى طريقة الاستعمال أو الاستغلال قد يؤدى إلى ثبوت حق المرور أو الحد من مداه أو انقضائه. فإذا كان هذا التعديل أو التغيير قد ترتب عليه أن أصبح الممر الموجود غير كاف لمواجهة الاحتياجات الجديدة، فإن المالك يحق له أن يطالب بممر يكفى الاحتياجات، ولكن يشترط لذلك أن يكون استعمال الممر الأول فيما يحتاجه الاستغلال الجديد من شأنه أن يكبد المالك نفقات باهظة لأى تتناسب مع قيمة العقار أو يحمله مشقة. وعلى العكس لو غير الجار طريقة الاستغلال تضيق منها، ولم يعد فى حاجة إلى كل الممر، جاز له أن يطلب تضيق الممر بحيث يتناسب مع طريقة الاستغلال الجديدة^(١).

ثالثاً: يجب ألا يكون الانحباس راجعاً إلى فعل المالك:

إذ كان المشرع لم يذكر فى المادة ٨١٢ مدنى سبب الانحباس الذى بمقتضاه يكون للمالك حق المرور القانونى، فالمسلم به فقهاً أنه لا محل

(١) د. منصور مصطفى: ص ٧٣، د. إسماعيل غانم: ص ٩١، د. الصدة: ص ٩٧.

لتطبيق المادة ٨١٢ إذا كان انحباس الأرض قد نشأ عن فعل مالئها. مثل ذلك أن يشغل بالبناء الممر الذى كان يصل الأرض بالطريق العام، أو يتنازل عن حق ارتفاق بالمرور كان مقررأ لأرضه. ويقضى المنطق بتطبيق ذات المبدأ فى حالة ما إذا كان سبب انقضاء الارتفاق الذى كان مقررأ للأرض هو التقادم المسقط، فالانحباس فى هذه الحالة إنما نشأ عن فعل المالك بإهماله استعمال الارتفاق، فلا يثبت نتيجة له حق قانونى فى المرور بالأراضى المجاورة.

أحكام حق المرور:

إذا توافرت الشروط السابقة ثبت الحق فى المرور بقوة القانون، لأن الأخير ربت حق المرور على حالة واقعية هى حالة الانحباس، وعلى ذلك يثبت هذا الحق بقوة القانون بمجرد توافر الانحباس، فإذا تعذر ذلك اتفاقاً مع الجار تولت المحكمة تعيين الممر وطريقة المرور، ذلك نظير تعويض الجار عما يصيبه من ضرر.

ثبوت الحق فى المرور بقوة القانون بتحقيق الانحباس:

2024/2025

يثبت الحق فى المرور بمجرد توافر حالة الانحباس، ويستمر بقاؤه ما دامت الأرض محبوسة عن الطريق العام، وليس للمطالبة بتقرير حق المرور أو السكوت عن المطالبة به أثر فى وجوده. فالمطالبة ضرورية لتعيين الممر وطريقة المرور، ولكن الحق فى المرور ثابت بمجرد توافر حالة الانحباس.

يثبت الحق فى المطالبة بالمرور القانونى لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، ويثبت الحق أيضاً لمن يكون له حق عيى على العقار المحبوس، كالمنتفع وصاحب حق الاستعمال أو السكنى وبالعكس لا يثبت هذا الحق لأصحاب الحقوق الشخصية كالمستأجر، فهؤلاء ليس لهم سلطة مباشرة فى استعمال الشئ أو استثماره ومن ثم يتعين أن تكون المطالبة بواسطة مدينهم^(١).

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٧٥٧، د. إسماعيل غانم: ص ٩٥، د. مصطفى الجمال ص ٢٢٢.

تعيين الممر وطريقة المرور:

أن تحديد نطاق المرور وتعيين الممر وطريقة المرور فيه قد يتم بالاتفاق بين مالك الأرض المحبوسة وبين مالك الأرض المجاورة. فإن لم يتيسر هذا الاتفاق رفع الأمر للقضاء، الذي يقوم بتعيين الممر وطريقة المرور وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة ٨٠٢ مدنى. وهى تقضى بأن الحق فى المرور لا يستعمل «إلا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضرراً وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك». وبأنه لا يكون غلا بالقدر اللازم للاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف.

فيجب على القاضى أن يختار للممر عقاراً محاوراً يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور فى العقارات المجاورة، وأن يعين له موضعاً من هذا العقار يتوفر فيه هذا الاعتبار. ويتحقق ذلك عدة بالمسافة الأقصر، وإن كان يمكن أن تكون المسافة الأطول أخف ضرراً فيتعين الأخذ بها.. أما التحديد الثانى الذى يجب أن يراعيه قاضى الموضوع أهو أن يكون المرور «بالقدر اللازم لاستغلال الأرض المحبوسة واستعمالها على الوجه المألوف». فالشارع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذى يتطلبه استعمال هذا العقار واستغلاله. ولم يشترط القانون طريقة معينة للمرور، فمن الممكن أن تكون بواسطة طريق على سطح الأرض وهو الغالب، وبصح أن يكون نفق فى باطن الأرض، أو قنطرة تعبر مياه خاصة.

وإذا كان نطاق المرور يتحدد كما أسلفنا اتفاقاً أو قضاء، إلا أنه قد يتحدد عن طريق الحيازة^(١). فقد لا ينظر مالك الأرض المحبوسة هذا الاتفاق أو القضاء ويقوم مباشرة بالمرور فى أرض الجار . وفى هذه الحالة يكون لمالك هذه الأرض الأخيرة أن يطلب إلى القضاء نقل المرور إلى أرض أخرى مجاورة

(١) د. مصطفى الجمال: ص ٢٢٦.

إذ كان المرور فيها أخف ضرراً، أو أن يطلب تعيين موضع آخر للمرور في أرضه يكون أخف ضرراً من الموضع الذى اختاره مالك الأرض المحبوسة. ولكن إذا سكت عن المطالبة بما يكون له من ذلك، واستمر مالك الأرض المحبوسة يستعمل حقه فى المكان الذى اختاره وبالطريقة التى مارسه بها بإجماع الفقه وإن ثار خلاف بعد ذلك على تبرير الحكم^(١).

على أن اكتساب الحق فى ممارسة المرور فى مكان معين بطريقة معينة بالتقادم المكسب لا يكسب الحق فى المرور ذاته بالتقادم، بحيث إذا زال الانحباس انقض هذا الحق ذاته.

مقابل المرور:

لا يثبت حق المرور دون مقابل وإنما نظير مقابل تعويض عادل وهذا ما نصت عليه المادة ١٢/١. والتعويض العادل هو الذى يعرض المالك عن الضرر الذى يسببه إيجاد ممر فى أرضه. فلا يدخل ضمن عناصر تقدير التعويض النفع الذى يعود على مالك الأرض المحبوسة نتيجة اتصالها بالطريق

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فإذا اتفقا الطرفان على مقدار التعويض كان ذلك، أما إذا اختلفا وجب اللجوء إلى القضاء لتحديده، ولم يشترط التقنين المدنى أن يكون دفع التعويض مقدماً، فيجوز للمحكمة أن تحدد الطريق إما دفعا مقدمه دفعة واحدة أو على أقساط دورية متجددة أو غير متجددة. ولمالك الأرض التى تقرر عليها حق

(١) ذهب البعض أن القول بأن يكتسب بالتقادم فى هذه الحالة هو موضع المرور وطريقته وليس حق المرور فى ذاته. د. محمد على عرفه ص ، وذهب رأى آخر إلى أن ثبوت حق مالك الأرض المحبوسة يرجع إلى سقوط حق مالك الأرض التى يباشر عليها المرور فى الأغراض. د. حسن كيرة ص ١١٢، د. إسماعيل غانم ص ٩٥، د. الصدة: ص ١٠١ د. السنهورى الوسيط: ص ٧٧٤، د. محمد عمران: ص ٣٢٤. وذهب ثالث إلى أن ذلك يثبت لمالك الأرض المحبوسة ليس هو الحق فى المرور وإنما هو حق ارتفاق جديد. د. شفيق شحاته ص ٣٥٦، البدرأوى ص ٣٨٥.

المرور أن يمنع صاحب الأرض المحبوسة من المرور إلى أن يدفع التعويض المستحق..

وتتقدم دعوى المطالبة بالتعويض بمرور خمس عشر سنة من تاريخ استحقاقه إن كان قد قدر مبلغاً إجمالياً، وإذ كان على أقساط دورية متجددة سرى عليه التقادم الخمس الذى نصت عليه المادة ٣٧٥ مدنى.

الانحباس الناشئ عن تجزئة العقار بناء على تصرف قانونى:

بعد أن نصت المادة ٨١٢ فى فقرتها الأولى على حق مالك الأرض المحبوسة فى المرور فى الأرض المجاورة، نصت فى فقرتها الثانية على أنه «إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء تصرف قانونى، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء».

هذه الفقرة تتناول حالة يكون فيها العقار متصلاً بالطريق العام، ثم يبرم ماله تصرفاً قانونياً يؤدى إلى تجزئة. كأن يبيع المالك جزء من العقار، أو يبيع العقار كله إلى عدة مشترين أو يكون العقار مملوكاً على الشيوع فيقسم بين الملاك^(١).

إن كان من شأن هذه التجزئة أن تحبس جزءاً من العقار عن الطريق العام، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى الأجزاء الأخرى يصل الجزء المحبوس بهذا الطريق فإن حق المرور بهذا الجزء ينقرر على الأجزاء الأخرى. وعلة هذا الحكم أن الانفصال عن الطريق العام فى هذه الحالة سببه عمل إرادى من جانب مالك العقار المحبوس، فلا يجوز أن يتحمل الملاك المجاورون قيلاً على حقوقهم من جراء هذا العمل أما إذ لم يكن من المستطاع إيجاد ممر كاف للجزء المحبوس فى أجزاء العقار الأخرى، فتسترد القاعدة

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٧٦٩، د. إسماعيل غانم: ص ٩٨، د. الصدة: ص ١٠٦.

العامة في تحديد الممر سلطانها، ويكون تعيين الممر في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً من العقارات المجاورة^(١).

نخلص من ذلك بأن الحق في المرور في حالة الانحباس المترتب على تجزئة عقار هو مرور قانوني طبقاً للمادة ١/٨١٢، ويأخذ كل أحكام هذا المرور دون المرور الاتفاقى .. وأن المادة ٢/٨١٢ تقتصر على مجرد التعديل في أحكام الفقرة الأولى من المادة ٨١٢ فيما يتعلق بتحديد الأماكن التي يتم فيها المرور.

وإن كان الرأي السالف والذي يؤسس حق المرور في هذه الحالة على القانون^(٢) هو الرأي الذي نرجحه، إلا أن الرأي الذي يقف عنده الفقه المصري هو أن المصدر المباشر لحق المرور في هذه الحالة هو التصرف القانوني، وأن كان الفقه بعد ذلك قد اختلف في كيفية استتباط المرور الاتفاقى من التصرف القانوني.

فالبعض يسنده إلى الالتزام بالضمان المترتب على التصرف^(٣)، أو إلى الالتزام بتسليم المبيع وملحقاته إذا كان التصرف بيعاً^(٤).

2024/2025

وذهب البعض إلى إسناد الحق الاتفاقى في المرور إلى الإرادة الضمنية أو المفترضة للتصرف^(٥). بينما ذهب البعض إلى الاستناد إلى المادة ٤٨/٢ التي تقضى بأن «لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته»^(٦).

(١) قضت محكمة النقض بأنه إذا لم يتيسر الحصول على ممر كاف في أجزاء العقار الآخر، فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق في الحصول على الممر الكاف في أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٨١٢، نقض مدنى ١٩٧٤/١٢/٣١ طعن رقم ٤٠١ س ٣٩ ق.

(٢) د. محمد على عمران: ص ٣٢٣، د. مصطفى الجمال: ص ٢٢٥.

(٣) د. السنهورى الوسيط ص ٧٧١، د. أحمد سلامة: ص ١٨٦.

(٤) د. محمد على عرفه: ص ١١٩، د. البدرأوى: ص ٣٨٩.

(٥) د. حسن كيرة: ص ١١٣.

(٦) د. إسماعيل غانم ص ٩٩، د. الصدة: ١٠٧، د. منصور مصطفى ص ٧٦.



المطلب الثالث

مسئولية المالك فى استعمال ملكه (التزامات الجوار)

التعريف بها:

إذ كان الأصل أن للمالك الحرية فى استعمال ملكه، فإنه يجب ألا يغلو فى استعماله هذا، فهناك التزامات تترتب على علاقته بجيرانه وهى ما جرى التعبير عنها بالتزامات الجوار، تجعل المالك مسئولاً عما يؤدى إليه استعماله لحقه من أضرار فاحشة تصيب الجار، والتزامات الجوار فكرة قديمة نادى بها فقهاء الشريعة الإسلامية، ألا أنها اتخذت أهمية خاصة فى العصر الحديث نظراً لتطور الحياة فى المجتمع وازدياد النشاط الاقتصادى وما أدى إليه من كثرة المصانع والمحال العامة المقلقة للراحة والتي تبعث الضوضاء والدخان والروائح وغير ذلك مما يؤذى الجار ويقلق راحته.

لهذا وبالرغم من أن فكرة حسن الجوار مسألة ذات طابع أخلاقى، إلا أن القانون يرقى بها إلى مصاف الالتزامات القانونية، فتجعل المالك مسئولاً إذ ^{2024/2025} ~~أصل~~ ^{2024/2025} بمعنى مساءلة عما يسببه استعماله لحقه من أضرار فاحشة للجار، رغم أنه فى مثل هذه الظروف يباشر حقه ولا يتعسف فى استعماله إياه. ومن ثم كانت مسؤولية المالك فى هذه الحالة مسئولية يملئها التضامن الاجتماعى بين الملاك المتجاورين. فهى قيد استعمال حق الملكية دعت إليه الظروف فى الجماعة^(١).

ويختلف الحكم بالنسبة لهذه الالتزامات التى تقع على عاتق الجار وغرضها التضامن فى الجماعة عن الحالة التى يسأل فيها المالك طبقاً للقواعد

(١) د. إسماعيل غانم: ص ١٠٦، د. أحمد سلامة: ص ١١٣، د. توفيق فرج: ص ١٤٦، د. الصدة: ص ٦٤، د. شفيق شحاته: ص ٨٦، د. السنهورى الوسيط ج ١ ص ٨٣٢ هامش ٤، د. جمال زكى ص ٦٥، د. البدروى: ص ١٢٣، د. عبد المجيد مطلوب، التزامات الجوار، مقال العلوم القانونية س ١٩٧٦ ع ٢ ص ٥٠٠.





العامة في المسؤولية، كما يختلف عن الحالة التي يسئ فيها المالك استعمال حقه.

فلكي تحدد حالة مضار الجوار غير المألوفة يجب تمييزها عن غيرها من الصور التي تلتبس بها، ثم نعرض بعد ذلك لمعيار الغلو في استعمال حق الملكية وجزاء المسؤولية عن هذا الغلو.

التزامات الجوار . التفرقة بينها وبين المسؤولية والتعسف:

بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية يسأل المالك إذا ثبت ارتكابه خطأ ترتب عليه ضرر بالغير. وهو يسأل في هذه الحالة مهما كان الضرر ولو كان يسيرا طالما تحققت شروط المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. فإذا تجاوز المالك الحدود الموضوعية أو الخارجية^(١) لحقه تحققت مسؤوليته. كأن يجاوز حدود ملكه فيبنى في أرض الجار، أو يفتح مطلا في المسافة الممنوعة قانونا، أو يترك المياه تسيل من مصنعه إلى ملك الجار فتصيبه بتلف.

2024/2025

كما تتحقق مسؤوليته إذ أخل بأى التزام فرضته عليه اللوائح والقوانين،^{2024/2025} كما إذ أدار محلا مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة أو خطرا دون أن يحصل على رخصة في إدارته، ودون أن يراعى الاشتراطات التي أوصتها اللوائح في هذا الشأن، فإنه يكون قد ارتكب خطأ. فإذا ترتب على هذا الخطأ ضرر لحق الجيران كان عليه أن يعرض هذا الضرر.

وكما تتحقق مسؤولية المالك في هذه الصور بناء على خطأ مفروضا أو مفترض، وذلك إذا ما توافرت في حقه شروط المادة ١٧٦ الخاصة بمسؤولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر، أو المادة ١٧٧ الخاصة بمسؤولية حارس البناء عن الضرر المترتب عن انهدامه كليا أو جزئيا، أو المادة ١٧٨ الخاصة بمسؤولية حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي

(١) د. أحمد سلامة: ص ١١٢، د. الصدة: ٦٢.



يتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر. فالمالك في هذه الصور قد ارتكب خطأ بانحرافه عن سلوك الشخص المعتاد فأضر الجار فيكون مسئولاً عن تعويض أى ضرر يصيب الجار مهما قل هذا الضرر، وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية^(١).

هناك صورة ثانية تتحقق فيها مسؤولية المالك أيضاً طبقاً للقواعد العامة كما تتحقق مسؤولية غير من الأشخاص. وفيها يلتزم الشخص الحدود الموضوعية المرسومة لحقه، فهو يستعمل حقه في هذه الحدود ولا يخرج عنها، ولكنه يتعسف في هذا الاستعمال، أى يكون استعمال حقه استعمالاً غير مشروع بإحدى الصور الثلاث التي حددتها المادة الخامسة من القانون المدني وهي:

(أ) إذ لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(ب) إذ كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وبذلك النص يكون المشرع قد جرى على تعداد معايير معينة للتعسف دون إمكانية إضافة غيرها لها^(٢). فلا يعتبر استعمال الشخص لحقه منطوياً على تعسف إلا إذا توفر في شأنه إحدى هذه المعايير، وهي قصد الإضرار بالغير، رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً، عدم مشروعية المصلحة. وقد راعى المشرع في تحديد لهذه المعايير المعيار العام في الخطأ وهو السلوك المألوف للشخص المعتاد.

(١) د. السنهوري الوسيط ٨ ص ٦٨٧، د. توفيق فرج: ص ١٤٦.

(٢) غالبية الفقه المصري يميل إلى أن صور التعسف التي قررها المشرع قد وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، بحيث يتمتع القاضى بحرية تقدير الأحوال التي يعتبر فيها صاحب الحق متعسفاً في استعمال حقه، مستهدياً في ذلك بالمعايير التي وصفها المشرع. انظر في ذلك د. فيصل ذكي عبد الواحد، أضرار البيئة في محيط الجوار. طبعة ١٩٨٨ ص ٣٧٣ وما بعدها. حيث أشار إلى هذه الأغلبية.

أول هذه المعايير وهو قصد الإضرار بالغير: فالقانون لا يقر الحق لصاحبه إلا تحقيقا لمصلحة، لا لكي يتخذ منه وسيلة للإضرار بالغير^(١).

وهذا الضابط وإن كان يقوم على ناحية شخصية هي قصد الإضرار بالغير، إلا أنه يقاس مع ذلك بالمعيار العام للخطأ، أى السلوك المألوف للشخص العادى.

فيعد المالك متعسفا لو أقام حائط على حافة ملكه لمنع النور والهواء عن ملك جاره دون أن يكون له فى ذلك نفع ظاهر. كذلك يعد الجار . أيا كانت صفته مالكا أو مستأجرا أو شاغلا بسيط للعين . متعسفا فى استعمال حقه، أو إذا كان قد استخدم أجهزته الكهربائية بدرجة أكثر إفراطا وفى أوقات غير ملائمة كأواخر الليل أو فى وقت الظهيرة بهدف مضايقة جاره المريض أو الذى يمتنن عملا لا يطيق الجلبة.

نخلص من ذلك أن استعمال الحق غير مشروع إذ كان قصد إحداث الضرر هو العامل الأساسى الذى دفع الشخص إلى استعمال حقه، وحقيقة أن ^{٢٠٢٤} يقصد الإضرار بالجار أمرا ^{٢٠٢٥} لعدم خروجه إلى حيز الماديات المللموسة، إلا أن القضاء غالبا ما يعول فى استخراجه على انعدام المصلحة، معتبرة قرينة على أن الجار لم يقصد من استعماله لحقه سوى الإضرار بجاره^(٢).

(١) د. محمد لبیب شنب: نظرية لالتزام طبعة ١٩٩٠ ص ٣٤٨، محمد عمران: المدخل للعلوم القانونية طبعة ١٩ ص ٢٩٠،

Caboner (J.): Droit civil. 3 Les biens, Les obligations 1980, p.241.

(٢) على أن فتح الباب لا يفيد الطاعن بل أن فتحه يؤدى إلى الوصول إلى عقار المطعون عليهما المذكورين، وذلك دون أن يبين ما إذا كان الطاعن قد استهدف من دعواه فى هذا الخصوص الإضرار بالمطعون عليهما الأولين أو تحقيق مصلحة غير مشروعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، وبالتالي تكون مطالبة بتمكينه من فتح باب على المنور موضوع النزاع استعمالا لحق غير مشروع، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والتصور فى التسبيب» نقض مدنى ١٩٨٨/١/٢٧ طعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٥٤ ق.

رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا، هو الضابط الثانى التى نصت عليه المادة الخامسة ويتحقق ذلك إذ كانت المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. وهو معيار موضوعى بحث، إذ يقوم على الموازنة بين المصالح المقصودة^(١)، والضرر الذى يصيب الغير. وقد طبق الشارع المصرى هذا المعيار فى المادة ٢/٨١٨ مدنى «مع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى إذا كان هذا يضر بالجار الذى يستر ملكه بالحائط»^(٢).

كذلك يعد الشخص متعسفا فى استعمال حقه إذ كان يرمى من وراء استعماله إياه تحقيق مصلحة غير مشروعة. ويتحقق ذلك إذا قصد صاحب الحق من هذا الاستعمال الوصول إلى غاية لا يقرها القانون أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة. مع ملاحظة أن عدم مشروعية استعمال الحق تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب اختلاف مفهوم النظام العام والآداب العامة. ومعيار عدم مشروعية المصلحة يعد معيارا موضوعيا ومرنا فى نفس الوقت إذ أنه يجعل للقاضى سلطة واسعة فى رقابة استعمال الحقوق^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

نخلص من ذلك أن صور التعسف يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السعى إلى مضار الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق فى ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال الحق.

(١) «الحق المخول للمؤجر فى هذا النطاق ينبغى أن يقدر بقدرة، فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التقليد ولا يجوز استغلاله لإساءة استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة. وإذا كان الحكم لم يفصح عن القدر اللازم الذى قرره، فإنه بهذه المثابة قد أعوزه الانضباط، وافترق فيه حس الخصومة، فإنه يكون قاصراً بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى سداد تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يستوجب نقضه» نقض مدنى ١٩٧٨/١١/١ طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ ق.

(٢) انظر تطبيقات أخرى م ٩٢٨، ١٠٢٩، ١٠٢٣ مدنى.

(٣) نقض مدنى ١٩٨٠/١/٢٦ طعن ١٠٨ س ٤٥ ق. أحكام النقض ١٩٨٠ ص ٢٩٧.

الغلو في استعمال حق الملكية (مضار الجوار غير المألوفة):

في الحالتين السابقتين تتحقق مسؤولية المالك طبقاً للقواعد العامة إذ تجاوز الحدود الموضوعية لحقه أو تعسف في استعمال هذا الحق، شأنه في ذلك شأن غيره من الأشخاص. ولكن كثيراً ما يضار الجار باستعمال المالك ملكه استعمالاً مشروعاً دون أن يكون من المستطاع نسبة خطأ ثابت أو مفروض إليه، أو دون أن يكون متعسفاً في استعماله لحقه. فقد يقيم المالك في أرضه مصنعا مع اتخاذ كافة الاحتياطات العلمية الحديثة لمنع الإضرار بالغير، كما يتخذ كافة التدابير التي تقتضيها القوانين واللوائح، ومع ذلك يترتب على تصاعد الأدخنة أو الروائح الكريهة أو الضوضاء منه إنقاص قيمة الملكيات المجاورة أو مضايقات للجيران^(١).

فالمالك في مثل هذه الأحوال قد استعمل حقه ولكن في استعماله إياه أضر بجاره، فهل يكون مسئولا مع أنه لم يرتكب خطأ ولم يتعسف في استعماله لحقه.

24/2025 أجاب المشرع على ذلك وهو 024/2025 تصنيف قواعد المسؤولية إذ نص في 2024/2025 المادة ٨٠٧ على:

١. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
٢. وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق».

(١) د. السنهوري الوسيط ص ٦٩٣، د. إسماعيل غانم: ص ١٠٤، د. توفيق فرج ص ١٤٨، د. الصدة: ص ٦٩.

وإن كان هذا النص يقرر أن على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، إلا أنه أدرك أن الجار قد يصيبه رغم كلا ما يمكن أن يتخذه المالك من تدابير ضرر. ولأنه من الضروري أن يترك أملك فسحة في استغلال ملكياتهم، فيتسامح فيما يحدثه الجيران بعضهم لبعض من ضرر مألوف، وإلا غلت يد المالك عن استعمال حقوقهم، فإن العدل يقتضى ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ضرراً غير مألوف.

فالمسئولية لا تقع على المالك وفقاً لهذا النص من مجرد حصول أضرار عادية، وإنما تتجاوز قدراً معيناً من المضار هو الذى يترتب هذه المسئولية^(١).

فالمادة ٨٠٧ مدنى تورد قيماً على استعمال حق الملكية هو عدم الغلو في استعماله حتى لا يلحق الجار ضرر غير مألوف من جراء ذلك. ومن ثم يكون الغلو خروجاً على الحق وكل خروج يعتبر خطأ يلزم فاعله بالتعويض^(٢).

مقياس الغلو في استعمال الحق: (الضرر غير المألوف):

2024/2025

لكنى تتعدّد مسئولية الجار وفقاً للنص المادة ٨٠٧ مدنى يلزم أ، تكون الأضرار المدعاة تشكل أعباء غير عادية، بمعنى أنها تتجاوز من حيث شدتها واستمراريتها ما يسود في الحى من أعباء. فإذا كان ما يشكو منه الجار من مضايقات لا يتجاوز مدخلاً معيناً للخطورة، فلا يجوز له طلب التعويض عنها، لأن الحياة المشتركة تقتضى وجود قدر معين من الأضرار قبل نهايتها لا يكون لمن تحمله حق التضرر منه. وهذا ما عناه المشرع المصرى في الفقرة الثانية

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٣٨٢ هامش ٤، د. إسماعيل غانم ص ١٠٥، د. أحمد سلامة: ص ١١٥، د. البندراوى ص ٦٠٩، د. الصدة: ص ٦٤.

(٢) «إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرقم قضاؤه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن المرحاض الذى أنشأته المطعون ضدها على أنه مخالف لقيود البناء، وإنما على إنشاءه بالصورة التى أنشئ بها يعتبر غلوا منها في استعمال حقها كمالكه إلى حد قد أخر يملك جاريها الطاعن ضرراً يتجاوز مضار الجوار المألوفة، فإن هذا النفي يعد على غير أساس سليم» نقض مدنى ١٩٦٩/٢/١٣ طعن رقم ١٩ لسنة ٣٥ ق. أحكام النقض س ٢٠ ص ٣١٧.

من المادة ٨٠٧ مدنى «ليس للجار أن يرجع إلى جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذ تجاوزت الحد المألوف».

فالمبدأ الأساسى أو معيار الغلو الذى وضعه النص فهى المالك من أن يغلو فى استعمال حقه إلى حد الضرر بالجار. فهناك إذن شرطان لمسئولية المالك ضرر يصيب الجار، غلو فى استعمال الحق، مع ملاحظة أن غلو المالك فى استعمال حقه وهو عنصر الخطأ فى هذه المسئولية ينظر إليه من خلال الضرر، وذلك خلاف للقواعد العامة التى تجعل من الخطأ والضرر فى المسئولية عنصرين متميزين بحيث ينظر إلى كل منهما على استغلال. ومن هنا كان معيار الغلو فى استعمال حق الملكية هو «الضرر غير المألوف» وهو معيار مرن وموضوعى.

وكون المعيار مرنا يفيد أنه ليس هناك حد معين يجب أن يصله الضرر حتى يقال أنه غير مألوف أو أن التسامح لا يرد عليه، فقد يكون الضرر مألوفاً فى حالة وغير مألوف فى حالة أخرى. حيث يراعى فى تحديد مألوفية الضرر ^(١) أشارت إليها المادة ٨٠٧ مدنى: «على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها إلى الآخر، والغرض الذى خصصت له».

والقاضى هو الذى يقدر ما إذا كان الضرر مألوفاً أو غير مألوف، فهى مسألة وقائع يترك تقديرها لقاضى الموضوع. وهو مقيد فى هذا التقدير باعتبارات الزمان والمكان، فما يعتبر ضرراً مألوفاً فى زمن معين قد يصبح ضرراً غير مألوف فى زمن آخر، وللعرف شأنه فى ذلك بحسب تطور ظروف المجتمع^(٢). فالعادة جرت على أن يتحمل أهل الريف بعض المضايقات لا

(١) الأعمال التحضيرية ج٦ ص ٣٢.

(٢) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٦٩٨، د. الصدة ص ٦٥، د. أحمد سلامة: ص ١٢١، د. محمد عمران: ص ٣٠٤، د. الجمال: ص ٢٠٧، د. عبد المجيد مطلوب: المقال: ص ٥٠٢.

يتحملها أهل المدينة أو لا يتحملون ما يتحملة أهل المدينة من المضايقات. فوضع أكوام الزبل والسماد التي تبعث منها روائح مقززة تشكل بالنسبة لأهل الريف أعباء عادية، إذ من المعتاد قيام أهل الريف بتربية الطيور، وتجميع أكوام السماد أمام منازلهم.

فالذي يقيم في منطقة تهيمن عليها زراعة البقول. لا يمكنه أن يشكو من وجود مستودع للزبل على العقار المجاور. وعلى العكس من ذلك تعد الانبعاثات الصادرة من هذه المضايقات غير العادية متى حدثت في المدينة^(١).

بل لا تقف ظروف المكان عند حد تقويم الأضرار بالنسبة لأهل الريف والمدينة فقط، بل أنها تلعب دوراً كبيراً في تحديد هذا المفهوم في نطاق القرية أو المدينة.

فالمدينة نظراً لكونها تشمل على مناطق صناعية وتجارية وسكنية . هادئة ومتوسطة وشعبية . فإن مفهوم الأضرار يختلف باختلاف طبيعة الحي. فالصخب الناتج عن سير العمل في الورش الميكانيكية يعد من الأعباء العادية لسكان حي صناعي أو تجاري، فيما لا يعد كذلك بالنسبة لسكان حي سكني. بل ما يعد عادياً في حي سكني شعبي لا يعد كذلك في حي سكني هادئ، فالضجة التي تقلق راحة الجار تعتبر ضرراً مألوفاً في حي شعبي مكتظ بالمقاهي والمحال العامة، ويعتبر غير مألوف في حي سكني هادئ.

وإن كان معيار الغلو في استعمال حق الملكية هو الضرر غير المألوف وهو كما أسلفنا معيار مرن فإنه أيضاً معيار موضوعي، لا يعتد فيه بالظروف الخاصة بالجار الذي أصبه الضرر^(٢) من حيث كونه مريض أو حالته النفسية أو العصبية تقتضي الهدوء أو لا تطبيق الجلبة، بمعنى أن الخصائص الفاحشة

(١) د. فيصل زكي: المرجع السابق ص ١٨٤ وما بعدها.

(٢) د. السنهوري: ص ٦٩٧، د. إسماعيل غانم: ص ١٠٧، د. الصدة ص ٦٦،

د. البدرأوى ص ١٢٦، د. توفيق فرج: ص ١٥٠، د. أحمد سلامة: ص ١٢٣،

د. محمد عمران: ص ٣٠٤.

للمضايقات لا يجب تقويمها بمقتضى الحالة الخاصة للجار المضرور^(١). وإن كان في هذه المسألة خلاف فكثير من الشراح يفرقون فيما يتعلق بالظروف الخاصة بالجار المضرور بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية، فيرون وجوب مراعاة الأولى دون الثانية. فإذا كانت هذه الظروف راجعة إلى الغرض الذى خصص له العقار المجاور كانت ظروفًا عادية تجب مراعاتها، كما لو كان العقار المجاور لمصنع قد خصص لى يكون دارا للعلاج.

إذ أن هذا الإعداد يجعل الضرر الذى يصيب العقار من دخان المصنع وضوضائه أكثر مما يصيب غيره من العقارات المجاورة. أما إذا كانت هذه الظروف متعلقة بشخص المضرور، كما لو كان مريضاً أو مرفه الحس، فإنها تكون ظروف استثنائية لا يعول عليها^(٢). ويرى آخرون ونؤيدهم أن الظروف الخاصة بالجار المضرور لا ينظر إليها أياً كان نوعها^(٣)، فالمعيار فى هذا الشأن يجب أن يكون معياراً موضوعياً، لأن فكرة التزامات الجوار قوامها تنظيم مشترك لعلاقات مجموعة من الملاك المتجاورين، ومن ثم فإن القواعد أو المعايير التى يركز عليها يجب أن ينظر منها إلى الطابع العام والذى يسود الملكيات المتجاورة فى مجموعها، لا إلا كل ملكية على حدة. وإن كان هذا لا يمنع من كون الظروف الخاصة للجار المضرور وزنها فى تقدير التعويض بعد أن يتبين أن الضرر يجاوز الحد المألوف على أساس المعيار الموضوعى.

الأسبقية فى التملك أو الاستغلال:

اختلف الفقه حول جواز التمسك بفكرة سبق الوجود من أجل التخلص من المسؤولية عن الأضرار غير المألوفة. فذهب جانب إلى القول إلى أن الأسبقية فى التملك أو الاستغلال تعصم من المسؤولية.

(١) Aubry et Rau: Droit rivil francais, 1975, par ponsard, p.560 no.375.

(٢) د. السنهورى: ص ٦٩٨، د. منصور: ص ٥٧، د. البدرأوى ص ١٢٧، د. توفيق فرج: ص ١٥٧.

(٣) د. إسماعيل غانم: ص ١١٧، د. الصدة: ص ٦٧.

فإذا بنى المالك منزلاً للسكن بجوار مصنع قائماً من قبل فلا يحق له أن يشكو من الأضرار الناتجة عن سير العمل فيه، فقد قبل ضمناً^(١) وجود هذه المضايقات ما يسقط حقه في طلب التعويض. استند هذا الاتجاه أنه من ناحية أن الجار المتضرر يعد مقترفاً لخطأ أو على الأقل يكون هناك خطأ مشترك بينه وبين المالك القديم، وهذا الخطأ يعد سبباً للإعفاء من المسؤولية^(٢).

وقد انتقد هذا الرأي على أساس أنه يؤدي إلى تحكم المالك الذي يبدأ في استغلال ملكه على نحو خاص، فأما أن يختار نوع الاستغلال الذي اختاره من سبقه أو يتحمل الأضرار الفاحشة^(٣).

وذهب جانب ثانٍ إلى^(٤) التفرقة بين ما إذا كانت الأرض المجاورة للمصنع أرض فضاء أو بنى عليها مساكن، وفي الحالة الأولى لا يحق التضرر لأن ثمن الأرض قد روعي فيها أنها تجاور المصنع في حين أنه يجوز التعويض في الحالة الثانية، وقد اعترض على هذا الرأي بأنه ينتهي إلى إلغاء التفرقة التي بدأ منها، فهو يؤدي إلى تحمل فوق الأرض النقص في قيمتها، وهذا أمكر يسوغ له أنه يرجع على صاحب المصنع بتعويض عن فرق الثمن.

وذهبت الغالبية من الفقه^(٥) أن تحديد صفة الأضرار المدعاة، وهل تعد من قبيل الأعباء العادية، أم أنها تخرج عن هذا النطاق، يتم على ضوء طبيعة المنطقة التي يقطن بها الجار المضروب، وهل تعد منطقة صناعية أم سكنية،

(١) د. السنهوري: ص ٧٠١، د. عبد العزيز عامر: حق الملكية ط ١٩٦٧ ص ٥٤.

(٢) راجع أسانيد أخرى لأصحاب هذا الرأي د. السنهوري: ص ٧٠٢.

(٣) د. إسماعيل غانم ص ١٠٥، د. أحمد سلامة: ص ١٢٢، د. محمد عمران: ص ٣٠٦.

(٤) د. البدرأوى: ص ١٢٤.

(٥) د. توفيق فرج: ص ١٥٧، د. لبيب شنب: ص ٢٤٠، د. إسماعيل غانم: ص ١٠٥، د. منصور مصطفى: ص ٥٦، د. محمد عمران: ص ٣٠٧، د. أحمد

سلامة، ص ١٢٢، د. مصطفى الجمال: ص ٢٦٠، د. عبد المجيد مطلوب: المقالة: ص ٥٠٥، الصدة: ص ٦٨.

وبالنسبة للأخير هل تعد منطقة سكنية هادئة أم شعبية، وهذا ما يعرف عند الفقه في مجموعة بنظرية سبق الوجود الجماعى. وعلى ذلك يجب التفرقة بين الأسبقية الفردية والأسبقية الجماعة والاعتداد بالثانية دون الأولى. أى يتعين النظر إلى الصبغة العامة للحى . سبق الوجود الجماعى . فعلى ضوء هذه الفكرة يتم تقويم الأضرار المدعاة وفتح باب التعويض عنه، متى كانت غير عادية.

ويرى البعض^(١) أنه يجب أن يستبعد فكرة سبق الوجود بنوعيتها فى تحديد الأضرار غير العادية، ويعتد بالصبغة العامة للحى وفقا لما تقرره قواعد تنظيم المدن، لأن هذه الفكرة لا تشكل عقبة أمام دعوى التعويض.

جزاء المسؤولية عن المضار غير المألوفة وأثر الترخيص الإدارى:

التزام المالك بألا يغلو فى استعمال ملكه إلى حد يلحق بالجار مضار غير مألوفة هو التزام بامتناع عن عمل. فإذا أخل المالك بهذا الالتزام كان للجار أن يطلب إزالة هذه المضار. ولا يقتصر الجراء على إلزام المالك بالتعويض النقدي، بل أن للجار بصريح نص المادة ٢/٨٠٧ أن يطلب بإزالة هذه المضار، أى تعويضا عينيا عن الإخلال بالالتزام فى الماضى وبتنفيذه عينا للالتزام فى المستقبل. وأزال الضرر يتخذ صور مختلفة بحسب كل حالة. فقد يكون بإزالته نهائيا كغلق مصنع أو هدم مدخنة. وقد يكون بتعديل مصدر الضرر، كنقل الآلة من مكان إلى آخر، أو بامتناع عن مصدر الضرر فى وقت معين، كمنع العمل فى وقت الليل. وقد يحكم بإلزام المالك باتخاذ الاحتياطات التى تكفل منع الضرر. وللقاضى أن يستعين فى ذلك بالغرامة التهديدية إذ توافرت شروطها (م ٢١٣ مدنى). كما يحق للجار أن يطلب الترخيص له بإزالة مصدر الضرر على نفقة المالك إذ توافرت شروط ذلك (م ٢١٢ مدنى).

(١) د. فيصل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٦٠٦.



ولا يتحتم على القاضى أن يجيب الجار المضروب إلى طلب الإزالة، فله سلطة تقديرية فى ذلك، فإن كانت الإزالة يترتب عليها إرهاب للمالك بحيث تسبب له خسارة فادحة، فإن للقاضى أن يحكم بالتعويض النقدي وخاصة إذا كانت الإزالة من شأنها أن تؤدي إلى وقت نشاط ضرورى للاقتصاد الوطنى أو تعطيل عدد كبير من الموظفين والعمال^(١).

على أن الاستغلال الذى تسبب فى الضرر قد يكون مرخصا به من جهة الإدارة. كما هو الحال فى شأن المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة التى يستوجب القانون الحصول على ترخيص إدارى لإنشائها أو تشغيلها. من المسلم أن المالك يظل مسئولا عما ينتج عن الاستغلال من ضرر غير مألوف رغم الترخيص الإدارى. وهذا ما نصت عليه المادة ٨٠٧ مدنى صراحة. فالترخيص الإدارى إنما يمنع لطالبه بعد التحقق من توافر اشتراطات معينة نص عليها القانون ولكنه لا يمس حقوق الغير. ومن ثم لا يمنع القاضى من الحكم بإزالة هذه المضار من حيث المبدأ^(٢).

2024/2025

على أنه يجب أن يلاحظ أنه أن تبين أن الضرر الذى يصيب صاحب المصنع مثلا من إزالته لا يتناسب البتة مع الضرر الذى يصيب الجار من إبقائه (م ١/٥) كان على القاضى أن يرفض طلب الإزالة وأن يكتفى بالحكم بالتعويض النقدي^(٣).

(١) د. أحمد سلامة: ص ١٢٣، د. إسماعيل غانم ص ١٠٩، د. الصدة ص ٧١، د. لبيب شنب ص ٢٤١، د. محمد عمران ص ٣٠٧.

(٢) يرى البعض جعل سلطة القاضى قاصرة على الحكم بتعويض نقدي، لأن الحكم بإزالة مصدر المضار ينطوى على مساس باختصاص الإدارة. د. محمد على عرفه فقرة ١٩٦.

(٣) وهذا رأى جمهور الفقه المصرى.



المبحث الثانى

القيود الاتفاقية

أسلفنا أن القيود التى ترد على سلطات المالك قد تكون قيودا قانونية . وقد عرضنا لها . وقد تكون قيودا اتفاقية. فيجوز بالاتفاق مع المالك تقييد سلطته فى استعمال الشيء أو فى استغلاله.

وأن كان مثل هذا الاتفاق لا يرفع عن المالك كلية سلطته فى استعمال ملكه أو استغلاله ولكنها تضيق نطاق هذه السلطة أو تلك عليه. مع بقائها له.

والحال كذلك بالنسبة لسلطة التصرف والتى هى أظهر السلطات للثلاث التى يخولها حق الملكية لصاحبه وتعتبر من خصائصه الأساسية. فللمالك أن يتصرف كما يشاء فيما يملك، بل ويعتبر الفقه سلطة التصرف من جوهر حق الملكية^(١)، وبقائها له متعلقا بالنظام العام تحقيقا لحرية تداول الأموال فى الجماعة. فلا يجوز الاتفاق على منع المالك من التصرف فيما يملكه، سواء ورد المنع على الشيء وضربه بعدم القابلية للتصرف، أو على إرادة المالك بمنعه من التصرف فيه. 2024/2025

2024/2025

فإذا ورد المنع على الشيء، صار ما يرد عليه حق عينى آخر غير حق الملكية الذى يعرفه القانون ويتعارض تقريره من ثم مع النظام العام. لأن حرية التصرف فى الأموال هى نتيجة لحرية العمل، ومن ثم أحد عناصر الحرية الشخصية. ولا يمكن بالتالى منع المالك من التصرف فيما يملكه إلا بالمساس بشخصيته.

ولذلك لا يجوز بند فى العقد بيع أو رهن مثلا، أو فى وصية، منع المتصرف إليه . مشتريا أو موهوبا له، موصى إليه . من التصرف فيما انتقلت إليه ملكيته، سواء ورد على المال ذاته، أو ورد على إرادة المتصرف إليه. لأنه فى الحالة الأولى يوصف المال بعدم التصرف ويخضعه لنظام لا يعرفه

(١) د. إسماعيل غانم: المرجع السابق ص ٥١.

القانون، وفي الحالة الثانية يفرض على المالك إنقاص من أهليته في غير الحالات التي قررها القانون^(١).

ولهذا ولما كانت مثل هذه الشروط واردة على خلاف الأصل، للمالك الحرية الكاملة في التصرف في ملكه، وحتى لا تحتبس الأموال عن التداول، فهذا يضر بالنشاط الاقتصادي، لذلك لم تكن هذه الشروط في البداية محل قبول في الفقه أو القضاء الذي كان يقضى ببطلان ما يسمى بشرط أو بند المنع من التصرف والذي يدرج في عقد أو وصية ويفرض المتصرف على المتصرف إليه عدم التصرف في المال الذي تنتقل ملكيته إليه بمقتضى ذلك العقد أو هذه الوصية. ولكن إزاء كثرة إيراد هذه البنود ولما تحققه من مصلحة في بعض الحالات، فقد استقر القضاء على إباحة هذه الشروط إذا كانت لفترة قصيرة وتبررها مصلحة جديدة. إلى أن قنن المشرع المصرى هذا القضاء بإجازة الشرط المانع من التصرف إذا استوفى شرائط صحته.

وإن المشرع المصرى قد نص في المادة ٨٢٣ مدنى على الشرط المانع من التصرف محدد شروط صحته وبيننا الجزء الذى يترتب على مخالفته إلا أنه تنظيم مقتضب، من ناحية لا يشمل كافة الآثار التى تترتب على الشرط المانع، كما أن البطلان الذى أقره فى حالة التصرف المخالف طبيعته محل خلاف. وأخيرا لم يبين المشرع ما يلزم للاحتياج بالشرط المانع على الغير.

وسوف نعرض أولا للنطاق الذى يرد فيه هذا الشرط، وشروط صحته كما أقرها المشرع فى مطلب أول. أما الثانى فنحدد فيه الطبيعة القانونية للشرط إذ يسهل بعد ذلك تحديد آثاره.

(١) كتحريم تصرف المالك فى الأرض الموزعة عليه طبقا لقانون الإصلاح الزراعى قبل الوفاء بثمنها كاملا. وكنع الشريك فى ملكية الأسرة من التصرف فى نصيبه لأجنبى منها، ومنع القضاء وأعوانهم من شراء الحقوق المتنازع فيها (م ٤٧١ مدنى).

المطلب الأول

نطاق الشرط المانع وشروط صحته

نطاق تطبيق الشرط المانع من التصرف:

تنص المادة ٨٢٣ مدنى على ما يأتى: «١- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة. ٢- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. ٣- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير».

وفقا لهذا النص فإن التصرف القانونى الذى يتضمن الشرط الإدارى المانع من التصرف هو العقد أو الوصية. وليس هناك صعوبة فى تصور هذا الشرط فى الوصية، فهى تصرف يضيف انتقال الملكية إلى ما بعد الموت، ويصح أن يضمها الموصى شرطا يمتنع مقتضاه على الموصى له الترف فى المال الموصى به.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويصح أن يدرج الشرط فى عقد. والعقد قد يكون معاوضة أو عقد تبرع، وإن كان الأخير هو الأكثر شيوعا من حيث تحقيق مصلحة جدية، سواء تعلق الأمر بهبة أو وصية^(١). أما عقود المعاوضات كعقد البيع مثلا فلا مصلحة جدية للمتصرف إليه فى قبول الشرط المانع من التصرف، وإن كان هذا لا يمنع جواز إدراج هذا الشرط، كاشتراط البائع على المشتري امتناعه عن التصرف فى الشئ المبيع حين لوفاء بكامل الثمن، واشتراط البائع الذى يحتفظ

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٥٠٨، د. إسماعيل غانم: ص ٥٥ د. توفيق فرج ص ٢٠٨، د. أحمد سلامة: ص ١٣٢، د. محمد عمران: ص ٢٩١.

لنفسه بحق الانتفاع على الشيء المبيع امتناع المشتري عن التصرف فيه طوال بقاء الانتفاع. تجنباً للاحتكاك بمالك رقبة آخر غريب^(١).

وإن كان من اللازم أن يرد الشرط في عقد أو وصية، فإنه لا يمكن أن يتقرر بمجرد إرادة الشخص، فلا يكفي أن يقرر المالك من تلقاء نفسه أن بعض ما يملك قد أصبح غير جائز التصرف، إذ لو أبيح له ذلك لكان في استطاعته أن يخرج أمواله من الضمان العام لدائنيه، لأن المنع من التصرف يقتضى عدم جواز التنفيذ على المال الذى حصل المنع من التصرف بالنسبة له.

إذا كان المشرع لم يذكر فى النص إلا العقد والوصية . إلا أن الفقه يرى^(٢) أنه ليس . من حيث المبدأ . هناك ما يمنع من أن يرد الشرط فى تصرف بإرادة منفردة كمن يوجه للجمهور وعدا بجائزة لقيام القيام بعمل معين، وكانت الجائزة عقار، ويشترط فى نفس الوقت منع من يقوم بهذا العمل من التصرف فى العقار.

والشرط المانع فى الغالب يرد كقيد على سلطات المالك، إلا أنه لا يوجد
2024/2025 منع من أن يرد قيداً على حق^(٣) آخر حق الانتفاع بعين معينة، ويشترط عليه عدم التصرف فى هذا الحق خلال مدة معينة، وقد يقصد شخص أن يوفر لآخر أسباب المعيشة طوال حياته، فيتعهد بترتيب إيراد له مدى حياته ويشترط فى تعهده عدم جواز التصرف فى هذا الإيراد^(٤).

ويصح أن يرد الشرط المانع من التصرف سواء بالنسبة إلى العقار أو المنقول، غير أنه إذا ورد فى شأن المنقول فإنه يكون محدود الأثر، لأنه لا يسرى فى حق الغير الذى تنتقل إليه ملكية المنقول بسبب صحيح إذ كان حسن النية.

(١) د. حسن كيرة: ص ١١٢.

(٢) د. أحمد سلامة: ص ١٣٦، د. محمد عمران: ص ٢٩١.

(٣) انظر أمثلة أخرى لهذا الشرط. د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٥٠٨.

وقد يوحى استعمال المشرع المصرى لاصطلاحى «المتصرف والمتصرف إليه» فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٨٢٣ مدنى بأن الشرط لا يرد إلا على تصرف ناقل لحق عيني^(١)، ولئن كان هذا هو الغالب إلا أنه لا يتحتم أن يكون الشرط مصحوبا بنقل حق عيني، لذلك فإنه يكون أدق فى التعبير أن تستبدل باصطلاح المتصرف الذى استعمله الشارع اصطلاح المشترط وأن تستبدل باصطلاح المتصرف إليه اصطلاح الممنوع من التصرف أو المشترك عليه^(٢).

وقد ثار الخلاف على جواز إيراد هذا الشرط فى عقد الرهن، بأن يشترط الدائن المرتهن على مدينه مالك العقار المرهون ألا يتصرف فى العقار طول مدة الرهن وذلك لكى يتجنب الإجراءات اللازمة لتبع العقار إذا تصرف فيه المدين ويتلافى المخاطر التى تنجم عن التطهير^(٣). إلا أن رأى الغالب^(٤) . ونؤيده . يرى أن إدراج مثل هذا الشرط فى عقد الرهن يضر بنظام الائتمان ويحول دون تحقيق الغرض منه، إذ يدرج الدائنون على إبرامه فى عقود الرهن ويصبح بمثابة شرط نموذجيا حماية لهم. وهذا يخل بنظام الرهن الذى يقوم على التوفيق بين حرية المالك فى التصرف بملكه بكافة التصرفات القانونية، وبين ضمان حق الدائن بتحويل حق التتبع. أضف إلى ذلك أن المذكرة الإيضاحية^(٥) للقانون فى باب الرهن قد أعلنت صراحة أنه لا يجوز أن يشترط فى عقد الرهن منع المالك الراهن من التصرف.

(١) د. شفيق شحاته بند ١٠٠، د. منصور مصطفى: ص ١٠٢، د. أحمد سلامة: ص ١٣٦.

(٢) د. السنهورى الوسيط ص ٥٠٨ هامش ٤، د. إسماعيل غانم ص ٥٦، د. الصدة: ص ١٣٩، د. حسن كيرة: ص ١٢٩.

(٣) د. إسماعيل غانم: ص ٥٧.

(٤) د. السنهورى الوسيط ص ٥٠٨ هامش ٢، د. منصور مصطفى ص ١٠٢.

(٥) د. إسماعيل غانم: ص ٥٧، د. أحمد سلامة: ص ١٣٦، د. الصدة: ص ٩٣٨، د. عمران: ص ٢٩٣.

الشروط اللازمة لصحته:

نصت المادة ١/٨٢٣ على أنه «إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة».

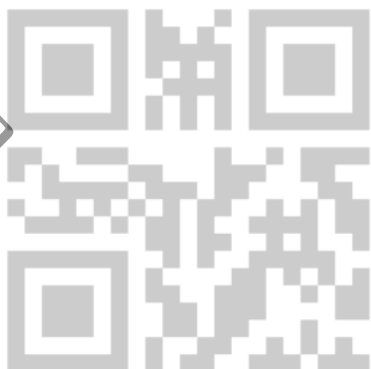
الشرط الأول : أن يكون الباعث مشروعاً:

يجب لصحة الشرط المانع من التصرف أن يكون مبنيا على باعث مشروع. والمقصود بذلك أن يكون هناك مصلحة جدية تدعو إلى إيراد هذا الشرط. وهذه المصلحة يقدرها القاضى^(١)، وقد أعطت الفقرة الثانية من المادة ٨٢٣ معايير وضوابط معينة يستطيع بواسطتها تبين هذه المشروعية حيث نصت «يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير».

فيستوى أن تكون المصلحة المراد حمايتها بمقتضى هذا الشرط هي مصلحة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. فقد يحتفظ المتصرف، كالبائع أو الوأهب لنفسه بالانتفاع بالعين طول حياته، ويشترط على التصرف إليه .^{2024/2025} المشتري أو الموهوب له . ألا يتصرف فى العين خلال تلك المدة. حتى لا تنتقل الرقبة إلى شخص لا يعرفه. وقد يحصل أن يشترط الواجب على الموهوب له ألا يتصرف فى المال المرهون، وذلك حتى يستطيع استرداد هذا المال متى قام لديه سبب يبيح له الرجوع فى الهبة^(٢).

(١) تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها، ومدى معتدلين المدة المحددة لسريانها تدخل فى سلطة قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بين رأيه على أسباب سالفة. نقض ١٩٦٨/٦/٢٧، ١٩ ق ص ١٢٢٤.

(٢) إذا وقع التصرف فى هذه الحالة لوارث اعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك م ٩١٧ مدنى.



وقد تتحقق للمتصرف إليه مصلحة مشروعة في المنع من التصرف كأن يكون الموهوب له صغير السن تنقصه الخبرة أو التجربة، أو كبير ولكنه طائش أو سيئ التدبير، فيشترط الواهب عليه المنع من التصرف في العقار الموهوب حتى يبلغ سنا معينة، يتوفر له فيها الخبرة، أو طيلة حياته حماية لهم من سوء تدبيره أو طيشه^(١).

وأخيرا فقد يقصد من وراء الشرط حماية مصلحة مشروعة للغير^(٢)، وذلك كما في حالة ما إذا كان الانتفاع بالعين مشروطا لمصلحة هذا الغير فقد يهب شخص لآخر مالا ويشترط عليه عدم التصرف في هذا المال ضمانا لدفع إيراد مرتب لمدى الحياة لمصلحة شخص من الغير. كأن يهب الأب مالا ويفرض عليه عدم التصرف ضمانا للوفاء بإيراد مرتب لمدى حياة الأم مثلا. فالشرط مقرر في هذه الحالة لمصلحة الأم، وبذلك تجد لدى الابن من الأموال ما يمكن معه التنفيذ عليه إذا أخل بالتزامه^(٣).

الشرط الثاني : المدة المعقولة:

24/2025 يجب كلك، لصحة شرط المنع 2024/2025 أن يكون مؤقتا. فلا يجوز 2024/2025 أن يكون المنع مؤبدا، أو وفقا لعبارة المادة ١/٨٢٣ «مقصورا على مدة معقولة» والحكمة من ذلك أن المنع المؤبد يخرج المال عن دائرة التداول بصفة نهائية ففيه اعتداء صارخ على مبدأ حرية تداول الأموال^(٤).

(١) د. توفيق فرج: ص ٢٠٣، د. جمال زكي: ص ٩٣.

(٢) «الحق في الفسخ هنا المستند إلى الإخلال بالشرط المانع، يجد حدة في تحقيق الباعث المشرع، وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تمكين خريجي المدارس الزراعية من العيش الشريف طوال مدة الشرط على أساس تعاوني يتفق وطبيعة دراستهم ويهيئ حسن السبل لرفع مستوى الأداء» نقض مدني ١٩٦٨/٦/٢٧ س ١٩ ق ص ١٢٢٤.

(٣) د. إسماعيل غانم ص ٥٥، د. توفيق فرج: ص ٢٠١.

(٤) د. السنهوري الوسيط ٨: ص ٥١٣، د. إسماعيل غانم: ص ٥٦.

ويعتبر المنع دائما أو مؤبدا، ولو كان مقترنا بمدة معينة، إذا كانت هذه المدة بالنظر إلى ظروف التصرف وملابساته، تجعله في حكم الدائم أو المؤبد. ويقدر قاضى الموضوع فى كل حالة، إذا كانت المدة المقترنة بالشرط تجعله فى حكم المؤبد، ليجرى عليها حكمه، أم يعتبر بوجودها مؤقتا، ومن ثم، صحيحا.

على أن المدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو المتصرف إليه أو الغير. لأن حماية المصلحة المرجوة من المنع من التصرف قد لا تتحقق على وجه كامل إلا باستمرار المنع حياة صاحبها. فإذا أنشأ المتصرف إيرادا مرتبا لمدى حياة المتصرف، أو لمدى حياة أجنبى عن التصرف، يكون طبيعيا أن يستغرق المنع من التصرف حياة المتصرف أو حياة هذا الأخير، وتكون بالتالى، هذه المدة أو تلك، مدة معقولة، ومن ثم جائزة.

وإن كان فى أحوال أخرى لا تقتضى المصلحة المقصودة من الشرط استغراق المنع حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، فلا يجوز اشتراطها طيلة هذه المدة، كأن قصد بمنع التصرف ضمان الوفاء بالثمن، فيكفى تقريره إلى حين الوفاء به، أو قصد به حماية المتصرف إليه من صغر سنه أو قلة خبرته، فيكفى تقريره خلال المدة التى يحصل خلالها نضوجه العقلى أو حصوله على الخبرة اللازمة^(١).

الآثار التى تترتب على عدم توافر الشرطين السابقين:

إذ لم يتوافر الشرطان السابقان، كان الشرط المانع من التصرف باطلا، فإذا كان الباعث الذى بنى عليه شرط المنع من التصرف لا يكفى لتبريره وقع الشرط باطلا. ولما كانت القاعدة التى قضت عليها المادة ١٤٣ مدنى تقضى إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى

(١) د. جمال ذكى: ص ٩٥، د. محمد عمران: ص ٢٩٥.

يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير هذا الشق الذى دفع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

وينطبق حكم هذه القاعدة يؤدي إلى إنقاص التصرف، فالشرط يبطل ولكن التصرف الذى تضمنه يبقى صحيحاً. غير أنه إذا كان الشرط لا ينفصل عن جملة التصرف، بمعنى أن المتصرف ما كان ليبرمه بدون هذا الشرط، فإن التصرف يبطل أيضاً.

وإذا كان المانع من التصرف مؤبداً أو كان لمدة غير معقولة أبقي القاضى الشرط مع إنقاص مدته إلى الحد المعقول. وهذا ما لم يتبين أن التصرف ما كان يتم بغير هذه المدة كلها، أى أن المتصرف ما كان ليرضى إلا بالمدة كاملة، إذ فى هذه الحالة يبطل الشرط والتصرف معاً^(١).

المطلب الثانى

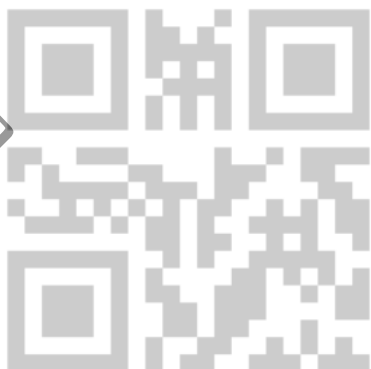
آثار الشرط المانع من التصرف

يحسن قبل تناول آثار الشرط المانع من التصرف أن نبين أولاً الطبيعة القانونية للشرط، إذ فى ضوء هذه الطبيعة يتخذ الآثار التى تترتب على مخالفة الشرط.

الطبيعة القانونية للشرط المانع من التصرف:

اختلف الفقهاء فى هذا الشأن، فذهب رأى إلى القول بأن المشرع طالما سمح للأفراد بالخروج على النظام القانونى للملكية، فأباح اشتراط المنع من التصرف فى الأموال، فذلك من شأنه أن تصبح هذه الأموال متقلة بتكليف عينى فتخرج عن دائرة التعامل^(٢). وقد انتقد هذا الرأى فى أن المال الممنوع من التصرف فيه لم يخرج عن دائرة التعامل، إذ لا زال قابلاً للتعامل فيه فيما

(١) د. السنهورى: ص ٥١٧، د. الصدة: ص ١٤٤، د. توفيق فرج: ص ٢٠٦.
(٢) د. محمد على عرفه: المرجع السابق ص ٣٦٩.



لا يتعارض مع الغرض من الشرط المانع، فيجوز إيجاره وتوارثه وتملكه بالتقادم^(١).

وذهب رأى إلى الشرط المانع من التصرف يتضمن مجرد التزام بامتناع عن عمل، هو التصرف، فإذا تصرف الملتزم بعدم التصرف فإنه يكون قد أخل بالتزامه، وأضاف أن المتصرف يستطيع أن يطلب إبطال التصرف كطريق من طرق التنفيذ العيني^(٢).

ويعيب هذا رأى أن الشرط المانع من التصرف قد يكون مقررا لمصلحة الممنوع من التصرف نفسه، في حين أن الالتزام بامتناع عن عمل يكون مفروضا على المدين . الممنوع من التصرف . لمصلحة الدائن . واتجه جانب من الفقه^(٣) . ونؤيده . إلى أن شرط المنع من التصرف يورد قيда على سلطات المالك، إذ يتضمن تعديلا في النظام العادى للملكية بمقتضى إرادة الأفراد . وهذا التعديل يجب أن يؤخذ في الحدود التى تتفق مع الغرض المقصود منه . فالقانون أم يخول الإرادة هذا السلطان في تعديل نظام الملكية إلا مراعاة لمصلحة مشروعة تقتضى حمايتها مثل هذا التعديل، ومن ثم فإن الشرط يخضع في أحكامه لمقتضيات المصلحة التى دعت إلى تقريره، ولا يعترض على ذلك التكيف بأن المشرع وحده هو الذى يملك تعديل نظام الملكية، لأن المشرع ذاته هو الذى أجاز هذا الشرط بمقتضى نصوص صريحة، بمعنى أنه خول الإرادة سلطة القيام بهذا التعديل.

مدى الشرط المانع من التصرف:

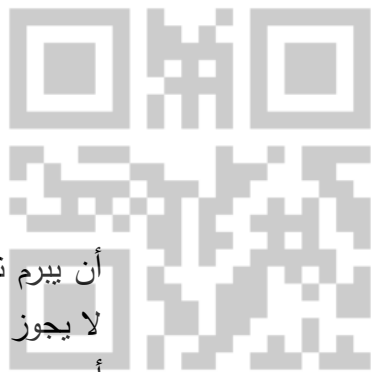
ما دما قد انتهينا أن الشرط المانع يقيد سلطة المالك فى التصرف، فإن المالك يمتنع عليه بمقتضاه أن يتصرف فى الحق تصرفا قانونيا . فلا يجوز له

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٥٢٨ هامش د. منصور ص ١١٢.

(٢) د. شفيق شحاته: ص ١٢٨، د. البدرأوى: ص ٩٩.

(٣) د. إسماعيل غانم: ص ٦٤، د. حسن كيرة: ص ١٣١، د. أحمد سلامة: ص ١٥٥،

د. محمد على عمران: ص ٢٩٤، د. الصدة ص ١٤٧.



2024/2025

(٢) د. البدرأوى: ص ٩٣، د. أحمد سلامة: ص ١٤٨.



التقادم المكسب. إذ الملكية تنقل حينئذ بناء على واقعة مادية، والذي يتمتع على المالك أن يأتيه هو التصرف قانوني أو مادي.

أثر الشرط المانع بالنسبة إلى المالك: بطلان التصرف المخالف:

تنص المادة ٨٢٤ مدني على أنه: «إذ كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا». يتضح من هذا أن بطلان التصرف الذي يصدر من المالك على خلاف ما يقضى به الشرط هو الجزاء الذي يتفق مع الغرض المقصود من منع المالك من التصرف.

على أن هذا لا يعني أن البطلان يتعين تقريره في جميع الحالات التي يتصرف فيها المالك خلافا للشرط، فقد لا يتطلب مضمون الشرط أن يكون الجزاء هو البطلان. مثال ذلك إذ كان الشرط استبدال فحسب، جاز للمالك أن يتصرف في المال الذي يتناوله الشرط، وذلك بشرط أن يستبدل بهذا المال ما لا آخر يحل محله ويصدق عليه ما كان يصدق على الأصلي.

2024/2025

وقد يكون الشرط مانعا من التصرف^{2024/2025} بصفة مطلقة^(١)، ومع ذلك تقتضي الظروف أن يتصرف المالك فيكون تصرفه صحيحا، وهي حالة يؤذن للمالك في التصرف بشرط الاستبدال^(٢). كما لو أصبح المنزل الذي منع المالك من التصرف فيه قليل المنفعة إلى حد ينبغي معه استبداله بقيمة أخرى.

وإن كانت في مثل هذه الحالات يسمح للمالك بالتصرف والاستبدال خلافا للشرط، فإن ذلك يكون تحت رقابة جدية من القضاء الذي يقدر جدية الظروف التي تدعو إلى الإذن للمالك في التصرف وإجراء الاستبدال بحيث تكفل حماية المصلحة التي كانت باعثا على المنع من التصرف^(٣). فإن لم

(١) د. إسماعيل غانم: ص ٦٦، د. الصدة: ص ١٤٩.

(٢) د. منصور مصطفى منصور «نظرية الحل العيني» رسالة ١٩٥٦ ص ٢٠٠.

(٣) د. إسماعيل غانم: ص ٦٦، د. عبد المنعم الصدة: ص ١٤٩، د. منصور: الملكية ص ١١٦.

تكن هناك ظروف تدعو إلى الإذن للمالك في التصرف، فإن التصرف الذي يصدر من المالك خلافا للشرط يقع باطلا كما تقول المادة ٨٢٤ مدني «فكل تصرف مخالف له يقع باطلا». فما طبيعة هذا البطلان الذي تقرره المادة.

بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لهذا النص نجدها تورد بأن «إذا توافر الشرطان اللذان تقدم ذكرهما «مشروعية الباعث، معقولية المدة» فالشرط المانع من التصرف صحيح، فإذا خولف كان التصرف المخالف باطلا بطلانا متعلقا لعدم قابلية المال للتصرف».

وبالرغم من الوضوح الذي صيغت به عبارة المذكرة الإيضاحية واتفاق نص المادة ٨٢٤ مع ما تقول به بأن كل تصرف مخالف للشرط يقع باطلا^(١)، فإن الفقه في مجموعه^(٢) لا يوافق على ما أثبتته المادة للتصرف المخالف وهو «البطلان المطلق». لأن القواعد العامة في البطلان لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط، فالمراد بالشرط المانع من التصرف هو حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه أو الغير، فالأمر يتعلق هنا بمصلحة خاصة، وبالتالي بالبطلان لا يمكن أن يكون مطلقا بل يتقرر لمصلحة من 2024/2025 2024/2025

تقرر الشرط المانع لحمايته^(٣).

وعليه فالأصل في هذا الخصوص أم من يجوز له التمسك بالبطلان هو الشخص الذي تتقرر الشرط لمصلحته. ويصدق هذا على المتصرف وعلى الغير، فمن تقرر الشرط لمصلحته مهما كان هو وحده صاحب الحق في

(١) الأعمال التحضيرية ج٦ ص ٧٧ ويأخذ بهذا الرأي د. السنهوري الوسيط ٨ ص ٢٢٥ د. محمد علي عرفه: ص ٣٦٩.

(٢) د. إسماعيل غانم: ص ٦٧، د. الصدة ص ١٤٩، د. أحمد سلامة: ص ١٥٦، د. محمد عمران ص ٢٩٨، د. البدرأوى ص ٩٩.

(٣) يرى أ.د. إسماعيل غانم أنه لا يمكن تطبيق البطلان النسبي تطبيقا تاما لأنه يتقرر لمصلحة أحد المتعاقدين، في حين أن الشرط المانع قد يكون مقرراً لمصلحة الغير. وللغير الذي ليس طرفا في التصرف المخالف أن يطلب بالبطلان: إسماعيل غانم: ص ٦٧.



التمسك ببطلان التصرف الذى يقع على خلاف ما يقضى به الشرط وكان له أن ينزل عن طلب البطلان فيجيز التصرف^(١).

أثر الشرط المانع بالنسبة إلى الدائنين: عدم القابلية للتنفيذ:

إذ أجاز لدائنى المالك أن ينفذوا بحقوقهم على المال الذى منع من التصرف فيه، فإن ذلك كفىل . فى أغلب الأحوال . بأن يفقد الشرط المانع كل قيمته . لذلك فالفقه يجمع على أن عدم قابلية المال للتصرف فيه نتيجة الشرط المانع نستتبع بطريق اللزوم عدم جواز الحجز عليه . إذ يكفى أن يتمتع المالك عن الوفاء بديونه فيباع الشيء جبراً ليستوفى الدائن حقه من ثم، وبذلك يصل المالك بطريق غير مباشر إلى التصرف فى المال رغم الشرط المانع.

وامتناع اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على المال الذى حصل بشأنه شرط المنع يقوم بالنسبة لكل دائنى من آل إليه هذا المال . فلا عبرة بتاريخ نشوء الدين الذى يراد التنفيذ بمقتضاه، سواء نشأ قبل اشتراط المنع أو بعده^(٢) . ويظل المنع قائماً طوال مدة المنع من التصرف، فإذا انتهت المدة أمكن للمدين أن يتصرف فى المال . على ٢٥/٢٤ هذا الأثر رهين فى وجوده بالغرض المقصود من شرط المنع من التصرف.

ففى الحالات التى لا يقتضى فيها هذا الغرض، يجوز للدائنين أن يباشروا هذا التنفيذ . من ذلك الحالة التى يشترط فيها البائع على المشتري ألا يتصرف فى العقار المبيع قبل الوفاء بالثمن كاملاً، لكى يتجنب البائع إجراءات تتبع فى مواجهة الغير بمقتضى ماله من حق امتياز، وهذا الغرض لا يقتضى تحقيقه حرمان دائنى المشتري من التنفيذ على العقار، فتسجيل حكم مرسى

(١) قضت محكمة النقض بأن جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف هو بطلان التصرف المخالف بطلاناً نسبياً دون حاجة إلى نسخ التصرف الأصيل وفقاً للمادة ٨٢٤ مدنى . ويقتصر التمسك بهذا البطلان على صاحب المصلحة فيه، وليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . نقض مدنى ١٩٧٥/٨/٣١ طعن رقم ٧٥٠ س ٤٠ ق .

(٢) د . حسن كيرة: ص ١٣٤، د . توفيق فرج: ص ٢١١ .

المزاد يترتب عليه تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية بما فيها حق امتياز البائع، بحيث لا يبقى للدائنين إلا حقهم فى الثمن (م ٦٩٠ مرافعات) ومن هنا يكون للبائع أن يستوفى حقه من الثمن دون أن يضطر إلى مباشرة إجراءات البيع^(١).

أثر الشرط المانع بالنسبة إلى الغير:

لأن الشرط المانع من التصرف يورد قيداً على سلطات المالك، حيث يتضمن تعديلاً فى الأحكام العادية للملكية، فإنه يكون واجب التسجيل إذا كان المال الذى يتناوله عقاراً، وهذا من شأنه أن يكفل حماية الغير الذى يتعامل مع المالك فى خصوص العقار الذى يمتنع التصرف فيه، فإذا لم يكن الشرط مسجلاً فلا يحتج به على هذا الغير.

أما إذا كان المال الذى يتناوله الشرط منقولاً فإن قاعدة الحيازة فى المنقول إذا توافرت شروطها تحمى الغير الذى يتعامل مع المالك فى خصوص المنقول ويكون حسن النية، أى يجهل وجود الشرط. فلا يحتج بالشرط على الغير الذى يحوز المنقول بسبب صحيح وحسن نية (م ٢/٩٧٦ مدنى).

2024/2025

(١) د. إسماعيل غانم: ص ٦٩، د. أحمد سلامه: ص ١٦٠، د. الصدة: ص ١٥١.

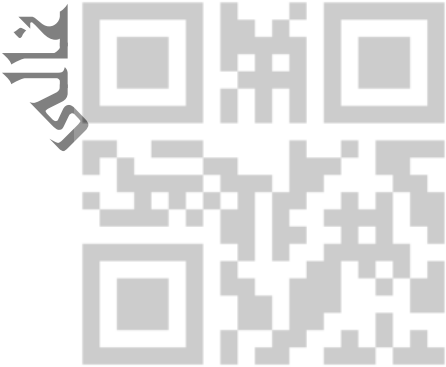


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الثالث الملكية الشائعة

تمهيد وتقسيم:

موضوع هذا الباب هو الملكية الشائعة، والفارق بينها وبين الملكية التي عرضنا لها، أن الأخيرة توصف بأنها شائعة. فالشيوخ حين يلحق بالملكية لا يغير من طبيعتها، بل يبقى الحق، حق ملكية يشتمل على جميع عناصر الملكية، وإن كانت لها بعض أحكامها الخاصة. وعلى هذا انعقد اجتماع الفقه المصري، وهي وجه النظر الذي قطع المشرع المصري أيضا على الأخذ بها، إذ نصت المادة ٨٢٥ «إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع». أضف إلى ذلك أن التقنين المدني حيث تحدث عن الشيوع اتخذ لأحكامه عنوان «الملكية الشائعة».

وإذا كانت الملكية الشائعة «ملكية» فهل هي حق ملكية فردية أو حق ملكية جماعية. أجابت على ذلك المذكرة الإيضاحية^(١) بأن الملكية الشائعة ^{2024/2025} وسط بين الملكية المفردة والملكية المشتركة^{2024/2025} (الجماعية).

2024/2025

فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفردة.

والشئ المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يمتلك كل شريك حصة فيه، وهذا ما يميز الملكية المشتركة (الجماعية).

فالملكية الجماعية: هي ملكية جماعة من الناس لا يملك أى واحد منهم بمفرده لا الشئ المملوك ولا أية حصة فيه، بل الكل يملكون مجتمعين كل الشئ المملوك.

(١) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ٧٨.

الملكية الشائعة: هي ملكية فردية، لأن كل شريك فى الشيوخ يملك ملكية فردية حصته فى المال الشائع، وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة.

فالحصة الشائعة كيان ذاتى يجعلها تتميز عن مجموع المال الشائع على أنه لا يعتبر المال شائعاً إذ كان مملوكاً لشركة لهال الشخصية المعنوية إلا بعد حلها وتصفياتها فتصبح أموالها شائعة بين الشركاء^(١).

نخلص من ذلك أن الملكية أما أن تكون ملكية فردية، أو ملكية جماعية. والملكية الفردية أما أن تكون ملكية مفردة أو ملكية شائعة. ومن ثم تكون الملكية الشائعة هي حق ملكية حقيقة وهي أحد نوعى الملكية الفردية^(٢).

وإن كان وصف الشيوخ قد قرن بالملكية، وإذ كانت كل القواعد التى أوردها المشرع تنظم الملكية الشائعة، إلا أن ذلك لا يعنى أن الشيوخ قاصراً على الملكية بل أنه من الممكن أن يكون أيضاً فى أى حق عيني أصلى متفرع عنها، فيقوم حق انتفاع على الشيوخ. وتطبق على هذه الحقوق ما يطبق على الملكية الشائعة فى الحدود التى لا تعارض فيها مع الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق^(٣).

2024/2025

2024/2025

وفى الملكية الشائعة يتعدد الملاك، وكل سبب منشئ للملكية إذا اتصل بعدة أشخاص فى نفس الوقت يكون سبباً لإنشاء ملكية شائعة، لا فرق فى ذلك بين أن يكون السبب تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية^(٤). وإن كان أهم أسباب

(١) «وكان الثابت فى الدعوى . على ما حصله الحكم المطعون فيه . إن الشركة قائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هي شركة تضامن لم تشهر ومن ثم فهي شركة فعلية وبالتالي فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها وتكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة». نقض مدنى ١٩٨١/١٢/٢٨ طعن رقم ٩٢٤ لسنة ٤٩ ق س ٣٢ ص ٢٤٤٧.

(٢) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٨٠٠.

(٣) «أما الحقوق الشخصية وضماناتها من الحقوق العينية التبعية، فلا يرد عليها وصف الشيوخ بل يرد عليها وصف آخر عند تعدد أصحاب الحق الواحد دون انقسام . هو التضامن الإيجابى وعدم القابلية للانقسام».

(٤) د. إسماعيل غانم: المرجع السابق ص ١١٤، د. أحمد سلامة ص ٢٥١.

الملكية الشائعة هو الميراث، حيث يكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثة متعددين، تنتقل إليهم أموال شائعة. تجد أيضا العقد والوصية من الأسباب التي تنشئ الشيوع، بالإضافة إلى الاستيلاء والالتصاق والشفعة والتقادم يمكن أن ينشئ عنهم أيضا ملكية شائعة^(١).

وينقضى الشيوع كما ينشأ بناء على واقعة أو تصرف قانوني. فقد تتوفر شروط اكتساب الملكية المفترزة، فإذا استطاع شريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين عبارة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون اقتطاع خمسة عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم^(٢). وتنتهى حالة الشيوع أيضا إذا باع الشركاء جميعا وأنصبتهم لأحدهم فقط، أو إذا اتفقوا جميعا أو أغلبيتهم التى ينص عليها القانون على بيع المال المملوك على الشيوع لشخص واحد، فتنتقل إليه الملكية مفترزة. على أن أهم سبب تنقضى به حالة الشيوع هو القسمة، سنعرض لها بإيجاز.

2024/2025

وللشيوع صورتان، شيوع عايدى، وشيوع إجبارى، والمقصود بالشيوع العايدى هو الشيوع الذى لا يكون من طبيعته أن يدوم بل يكون لكل شريك أن يطلب إنهاءه عن طريق القسمة، بل لا يجوز بمقتضى الاتفاق أن يمنع الشريك من طلب القسمة إلى أجل يجاوز خمسة سنين أما الشيوع الإجبارى فيكون من طبيعته أن يدوم، وبالتالي لا يجوز للشريك فيه أن يطلب القسمة، لأن من شأنها أن تخل بالغرض الذى أعد له المال الشائع مثل ذلك السقف فى ملكية الطبقات لا يتصور أن ترد القسمة عليه.

(١) «أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر وفقا للمادة ٨٧٠ مدنى وما بعدها وهى» الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلا عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم بناء على حكم مرسى المزاد . سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة». نقض مدنى ١٩٨٠/٦/٢٦ طعن رقم ١٠٧٧ لسنة ٤٧ ق. س ٢١ ص ١٨٧٢.

(٢) نقض مدنى ١٩٧٨/٢/٢ طعن رقم ١٤٢ لسنة ٤٠ ق س ٢٩ ص ٣٨٦.

نخلص من ذلك أن الملكية الشائعة هي حق ملكية ومن ثم يكون طبيعياً أن يتوافر قدر مشترك بين أحكام الملكية المفردة وأحكام الملكية الشائعة . وهذا القدر المشترك قد تناولناه في المبحث الأول والثاني . ذلك أن الملكية المفردة تمثل الوضع الطبيعي للملكية ومن ثم تعتبر قواعدها هي القواعد العامة في الملكية، وبالتبعية فإن الدراسة في هذا المبحث ستكون قاصرة على الأحكام التي تخص الملكية الشائعة.

وعليه سنعرض فيما يلي للأحكام العامة للشيوع، ثم نعرض لانقضائه، إلى جانب الصور الخاصة للملكية الشائعة نعرض لها بعد ذلك.

المبحث الأول

الأحكام العامة للشيوع

لكل مشتاع سلطات ترد على الشيء المادى ذاته، وهو يمارسها أما بمفرده أو بالاشتراك مع سائر المشتاعين، بشرط ألا يتعارض هذا مع حقوق الآخرين، الذى تثبت لهم حقوقاً متشابهة، لهذا لا يكون للشريك أن يأتى عملاً يضر بحقوق باقى الشركاء^(١). ويطلق على مجموع هذه السلطات لفظ «الحصة الشائعة».

وبيان أحكام الشيوع ينحصر فى دراسة السلطات المقررة لكل مشتاع بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من المشتاعين^(٢). وهى تنحصر فى سلطتى الاستعمال والاستغلال وفى سلطة التصرف. وأهم ما يعرض بصدد انتفاع الشركاء بالمال الشائع هو حفظ المال الشائع، فلكل شريك الحق فى حفظ المال الشائع، كما له حق استعماله، كما أن هناك قواعد لإدارة المال الشائع وسلطات

(١) «للشريك على الشيوع طبقاً للمادة ٨٢٦ مدنى أن يتصرف فى حصة وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها، إلا أن ذلك مشروط بالألا يلحق ضرر بحقوق سائر الشركاء». نقض مدنى ١٩٧٩/٢/٧ طعن ٢٢٩ لسنة ٤٨ ق س ٣٠ ع ص ٤٩٦.

(٢) تنطبق هذه الأحكام سواء كان محل الشيوع مالا منفردا أم مجموعة من الأموال كما يحدث عادة فى الشيوع الناتج عن الميراث.

الشركاء فى هذا الصدد، وتتحمل كل منهم نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر التكاليف. ثم أن للشريك حق التصرف فى الحصة الشائعة...وعلى ذلك ستكون نقاط البحث فى هذا الجزء هى الأولى حفظ المال الشائع، استعمال المال الشائع، إدارته، التصرف فيه.

المطلب الأول

حفظ المال الشائع

تنص المادة ٨٣٠ مدنى «لكل شريك فى الشيوخ الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء». فهذا النص أعطى كل شريك الحق فى أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال الشائع . بغض النظر عن حجم حصته . يستوى فى ذلك أن يوافق بقية الشركاء أو أن يعترضوا. فأعمال للحظ تتم بقصد منع الهلاك عن الشيء أو حمايته، فهى تفيد الشركاء الآخرين، فلا غضاضة فى تخويل كل شريك هذا الحق، وهى وإن كانت حقا لكل شريك فهى واجب عليه أيضا.

2024/2025

وأعمال الحفظ التى يحق لأى شريك القيام بها، قد تكون أعمال مادية وقد تكون أعمالا قانونية. ومثال الأولى إجراء الترميمات الضرورية، تسوير الأرض أو تحويطها، جنى المحصول فى موعده.

وقد تكون أعمالا أو إجراءات قانونية، كالوفاء بدين الدائن المرتهن للعين الشائعة توقيا للتنفيذ عليها، ورفع دعاوى الحيازة ضد من يعتدى على حيازة الشركاء وقطع التقادم المكسب لملكية العين ضد من يحوزها بنية اكتساب ملكيتها. وفى هذا قضت محكمة النقض دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوخ مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء، عملا بنص المادة ٨٣٠ من القانون المدنى^(١).

(١) نقض مدنى ١٩٨١/١/١٥ طعن رقم ٦٩٩ لسنة ٤٧ ق، س ٣٣ ص ٢٠٧.

ولا خلاف حول حق كل شريك فى القيام بأعمال الحفظ، فهو يستند إلى صريح نص المادة ٨٣٠ مدنى، وإن كان الخلاف قد أثار حول أساس هذا الحق، أى بيان الصفة التى يقوم بها الشريك فى حفظ المال^(١)، والذى تؤيده هو ما يذهب إليه غالبية الفقه المصرى^(٢) فى أن الشريك يعتبر نائباً قانونياً عن بقية الشركاء، وأن كان يعترض على ذلك بأن النيابة تنحصر فى التصرفات القانونية وحدها، فإن مثل هذا الاعتراض مردود بأن للولى وللوصى القيام بأعمال الحفظ لأموال القاصر رغم أن هذه الأعمال قد تكون تصرفات قانونية أو أعمال عادية.

أضف إلى ذلك أن الأعمال المادية كالتى تتم عادة عن طريق تصرف قانونى، هو اتفاق الشريك مع من يباشر العمل بنفسه.

نفقات الحفظ والإدارة وسائر التكاليف:

تنص المادة ٨٣١ مدنى نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، ~~يقتضى جمع الشركاء كل بقدر حصته~~ ^{2024/2025} لم يوجد نص يقضى بغير ذلك».

وبلاحظ أنه ليس فى هذا النص ما يخرج عن حكم القواعد العامة، فكل الشركاء فى الشيوع ملاك للمال الشائع، فتقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعاً كل بقدر حصته. وعلى ذلك فننفقات حفظ المال الشائع وهى النفقات التى صرفت فى صيانتها وترميمه أو مصروفات الدعاوى التى رفعت لحفظ المال الشائع، أو غير ذلك من نفقات حفظ تقسم على الشركاء كل بقدر حصته.

(١) ذهب رأى مع المذكرة الإيضاحية أن الشريك فى هذا يتصرف فى حدود قواعد الفضالة أن لم يوافق الشركاء الآخرين على عمله، أم إذا علموا واعترضوا فإن الشريك يرجع عليهم بدعوى الإثراء. الأعمال التحضيرية ج٦ ص ٩٥، د. السنهورى: ص ٨٠٦، د. عرفه: ص ٣٩٤، د. توفيق فرج: ص ٢٢٥ وقریب د. مصطفى الجمال: ص ٢١٧.

(٢) د. البدراوى: ص ١٦٢، د. شفيق شحاته: ص ٨٦٨، د. حسن كيرة: ص ١٦٨، د. الصدة ص ١٧٢، د. أحمد سلامة ص ٢١٨.

نفقات الحفظ في ذلك شأنها شأن نفقات الإدارة والضرائب وأقساط الديون وفوائدها تقسم على الشركاء كل بحسب حصته ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء جميعا على نسبة أخرى أو ما لم يقضى القانون بغير ذلك، مثاله نص المادة ١/٨١٥ فيما يتعلق بالحائط المشترك وهو شائع بين الجارين. وما لم يوجد اتفاق مخالف كإعفاء الشريك المدير منها مقابل أعمال الإدارة.

ويجوز لأى من الشركاء للتخلص من دفع حصته في النفقات أو التكاليف أن يتخلى عن حصته في المال الشائع، وهذه قاعدة عامة مقررة للتخلص من أى التزام عيني، وهو الالتزام الذى يكون سببه ملكية العين^(١). وقد كان المشروع التمهيدى يردف نص المادة ٨٣١ بقوله «لكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشائع». وإن كانت العبارة حذفت إلا أن ذلك لا يمنع الأخذ بحكمها.

فإن تخلى الشريك عن حصة سقطت عنه النفقات. ما لم تكن راجعة لخطئه. وألت ملكية الحصة التى تخلى عنها إلى الشركاء الآخرين كل بقدر حصته^(٢) على أن يسجل سند التولية في العقار.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المطلب الثانى

استعمال المال الشائع

التنظيم التشريعى للاستعمال:

تنص المادة ١/٨٢٦ على أنه «لكل شريك فى الشروع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق ضرر بحقوق سائر الشركاء». فهذا النص يعطى لكل شريك سلطات الملك الثلاثة من استعمال واستغلال وتصرف، ولكن حقه يتقيد فى هذا الصدد

(١) د. السنهورى الوسيط ٨: ص ٨٠٩.

(٢) د. أحمد سلامة: المرجع السابق ص ٢٦٢، د. مصطفى الجمال ص ١٢٧.

بعدم الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين وهي ترد مثل حصته، على العين الشائعة جميعها^(١).

وعلى ذلك إذا قام أحد الشركاء باستعمال الشيء واستغلاله على نحو يتعارض مع حقوق الآخرين، كان لهؤلاء أن يعترضوا على ذلك. ويعد هذا الاستعمال متعارضا مع حقوق الآخرين متى كان يخالف ماهية الشيء، الغاية التي أعد لها، أو يناقض مصلحة مجموع الشركاء في الشيوع دون استعمالهم لحقوقهم.

فإذا وضع أحد الشركاء يده على العين الشائعة أو جزء منها كي يستقل بزراعتها أو البناء عليها، كان للشركاء الآخرين أن يعترضوا على ذلك ويرفعوا دعوى منع تعرض أو وقف الأعمال الجديدة. فحق الشركاء المشتاعين في هذا الاعتراض إنما يستند إلى أن حقوق الشركاء جميعا متعادلة، فهذه وإن تعددت بتعدد أصحابها، إلا أنها ترد جميعا على الشيء الشائع، ولهذا لا يجوز لأى شريك أن يقوم بعمل يترتب عليه المساس بحقوق الشركاء الآخرين.

2024/2025 أما حيث ينم للشريك زراعة الأرض أو البناء عليها فيكون للشركاء الخيار بين أن يطلبوا إزالة الزرع أو هدم البناء وبين إبقائه، وحيث يختارون الإبقاء عليه فإن الزرع أو البناء يغدو مملوكا لهم بنسبة حصصهم على أن يدفعوا للزارع أو البانى نصيبهم فيما تكبده من نفقات، ويتحدد فى هذا النصيب بدوره على أساس الحصص، كما يتحدد مقداره بالنظر إلى وقت الإنفاق. وهذا محض تطبيق للقواعد العامة فى الشيوع، وهو المجمع عليه فقها^(٢).

(١) «متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى بطلب ربع ثلاثة أقدنة شائعة فى أثنى عشر فدانا، فإن مفاد ذلك أن مطالبتهم أنصبت على ربع حصتهم فى مجموع العقار الشائع وذلك أثناء قيام حالة الشيوع وفى حق كل من يثبت أنه كان منتفعا بهذه الحصاة وينسب هذا الانتفاع» نقض مدنى ١٩٦٥/٢٥ طعن ١٣٦ لسنة ٣١ ق، س ١٦ ص ١١٤٥.

(٢) د. السنهورى الوسيط ص ٨١٤، د. إسماعيل غانم: ص ١٢٢ د. توفيق فرج: ص ٢٢٤، د. الصدة: ص ١٦٤، د. أحمد سلامة: ص ٢٦٦، د. حسن كيرة: ص ١٦٧.

أما محكمة النقض فقد اضطرت أحكامها في هذه الحالة على أن متى وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فلا يحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه إنما يحق له طلب القسمة أو مقابل الانتفاع^(١).

وقد انتقد الفقه مسلك محكمة النقض هذا، فإن الاعتبارات العملية وإن كانت تنهض به في ظل القانون القديم، ولكن لم يعد له محل من الناحية القانونية بعد أن قام القانون المدنى الجديد بتنظيم إدارة المال الشائع تنظيماً يكفل منع تعطيل الانتفاع به في حالة اختلاف الشركاء.

التنظيم الاتفاقي للاستعمال (قسمة المهايأة):

تخلصاً من الصعوبات والمشاكل التي تحيط بإدارة المال الشائع، قد يتفق الشركاء في الشيوع فيما بينهم على قسمة المهايأة لمدة معينة، فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك، ويختص كل منهم بجزء مفرز من المال يعادل حصته في المال الشائع. وبذلك يتهيأ لكل منهم أن يحوز مالاً مفرزاً يستعمله بإدارته واستغلاله والانتفاع به 2024/2025

فقسمة المهايأة هي قسمة انتفاع لا قسمة ملكية، فهي اتفاق مؤقت يراد به تنظيم الانتفاع بالمال الشائع. ومن ثم فلا ينتهى بها الشيوع. وقد نظم المشرع المصرى هذا النوع من القسمة في المواد ٨٤٦ إلى ٨٤٩ مدنى ويتضح منها أن المهايأة نوعان . مكانية، ومهايأة زمانية.

المهايأة المكانية: وهي التي يتفق الشركاء فيها على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال الشائع، نازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء (١/٨٤٦ مدنى)، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد عن خمس سنوات فإذا لم تشترط لها مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن

(١) نقض مدنى ١٩٨٤/١٢/٣ طعن رقم ٣٤١ من ٣٩ ق.

الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد م ١/٨٤٦، إنما يجوز بعد انقضاء الخمس سنوات أن يتفق على مدة أخرى مماثلة.

المهاية الزمانية: تنص المادة ٨٤٧ مدنى على أن تكون قسمة المهاية أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. وهى الصورة الثانية من صور المهاية وتسمى بالمهاية الزمانية. وتتأتى عن طريق انتفاع كل شريك بكل المال الشائع مدة معينة من الزمان، وهى تتحدد على أساس نسبة ما يملكه الشريك فى المال الشائع، فمن يملك الربع مثلا ينتفع بالمال لنصف المدة التى ينتفع بها من يملك النصف. ويأتى هذا الانتفاع على سبيل التناوب.

وليس هناك أى قيد يد من اتفاق الشركاء على مدة المناوبة، فبأى وحدة زمنية تتفق وطريقة استغلال المال، شريطة ألا يؤدى الاتفاق على إجبار الشريك على البقاء فى الشيوخ مدة تزيد على خمس سنوات. ولما كانت هذه الصورة من المهاية لا تقوم على أساس انتفاع الشريك بجزء مفرز من المال الشائع فإنها لا يمكن أن تتحول إلى قسمة نهائية مهما طال عليها الأمد^(١).

وهناك فضلا عن ذلك، حالة خاصة نص عليها القانون وهى حالة إذا لم يتم الاتفاق على قسمة المهاية، جاز أن تتم المهاية بأمر من القاضى بناء على طلب أحد الشركاء. وهذه هى المهاية التى تتم أثناء إجراءات القسمة النهائية. فقد نصت المادة ٨٤٩ مدنى على:

١ - للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهاية بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.

(١) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٨٢٢، د. أحمد سلامة: المرجع السابق ص ٢٧٨.



٢- فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها بعد الاستعانة بخبير، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وسواء تمت هذه المهايأة بالاتفاق أو بأمر القاضي، فإنها تختلف عن المهايأة العادية في أنها ليست محدودة بمدة معينة. فهي تظل إلى أن تنتهي القسمة النهائية، لذلك قد تبقى لمدة تزيد عن خمس سنوات^(١).

خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار:

قسمة المهايأة قسمة انتفاع، لذل يمكن تكيفها بأنها إيجار، فيعتبر كل شريك في قسمة المهايأة مؤجراً للشريك الآخر ومستأجراً منه. وبهذا ينتفع الشريك بجزء مفرز في المهايأة المكانية أو بكل المال الشائع في المهايأة الزمانية، فيحصل على نصيب باقى الشركاء في منفعة ما لديه من مال، وذلك في مقابل حصول هؤلاء الباقيين على نصيبه في منفعة ما لديهم من مال.

فقسمة المهايأة تقترب بذلك من الإيجار وعلى ذلك نصت المادة ٨٤٨ مدنى^{2024/2025} «تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات أحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة». ويتأسس هذا الحكم على أن قسمة المهايأة، بصورتها ليست إلا مقايضة منفعة بمنفعة، ومن ثم فهي في حكم الإيجار، لذا ليس من الضروري أن تكون الأجرة نقوداً^(٢).

ومن ثم يكفي أن يتوافر في الشريك المتقاسم أهلية الإيجار، وهى هنا أهلية الإدارة دون أهلية التصرف حتى في الاستئجار إذ هو يعتبر في المهايأة من أعمال الإدارة^(٣).

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٢٨٣، د. الصدة: ص ٢٤٩، د. أحمد سلامة: ص ٢٧٩.

(٢) د. أحمد سلامة ص ٢٦٧.

(٣) د. السنهورى: الوسيط ص ٨٢١، د. إسماعيل غانم ص ١٥٦، د. أحمد سلامة ص ٣٦٨، الصدة ص ٢٤٩.

وبصفة عامة يلتزم كل متهاىء بما يلزم به المستأجر، ويتمتع به من حقوق، فيكون عليه أن يدفع الأجرة وهى هنا منفعة حصته، وأن يستعمل العين فيما أعدت له، وأن يردّها عند انتهاء المدة المتفق عليها^(١). ولكل شريك أن يؤجر من الباطن، وتطبق قواعد الإيجار من الباطن، وكذلك قواعد إثبات الإيجار. فتثبت المهايأة بالبينة والقرائن فيما لا يجاوز عشرين جنيها وإلا وجبت الكتابة أو ما يعادل الكتابة.

وتطبق قواعد الإيجار أيضا من حيث الاحتجاج بالمهايأة على الغير كمشتري المال الشائع، فلا بد أن تكون المهايأة ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع حتى تسرى فى حق المشتري^(٢).

وقد أوردت عجز المادة ٨٤٨ مدنى تحفظ على القواعد السالفة بأن «أحكام عقد الإيجار تطبق على القسم ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة». وعليه لا يسرى على قسمة المهايأة ما تنص عليه قوانين الإصلاح الزراعى من وجوب أن يكون عقد الأراضى الزراعية ثابتا بالكتابة^(٣)، وكذلك ما يتعلق بأن يكون تأجير الأرض الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه، وعدم جواز التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار للغير أو مشاركته فيه^(٤).

(١) «يلتزم الشريك المتهاىء كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدنى من إيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيما بعد انتهاء مؤقتة فى الانتفاع بها وإلا كان غاضبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر». نقض مدنى ١٩٦٩/٢/١١، س ٢٠ ص ٢٩٨.

(٢) «المشتري لحصة شائعة فى عقار من أحد الشركاء على الشيوع أو سجل عقدة قبل تسجيل عقد القسمة المعقود بين هؤلاء الشركاء لا يحتج عليه بهذه القسمة، لأنه وقد انتقلت إليه الملكية بالتسجيل، يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى ترجى بخصوص الحصة التى اشتراها». نقض مدنى ١٩٨٨/٣/٣٠ طعن رقم ٦٠٤ لسنة ٥١ ق.

(٣) م ٣٦ من قانون الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون ١٧ لسنة ١٩٦٣ والقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٦.

(٤) م ٣٢ من قانون الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٦.

فمثل هذه الأحكام قصد بها تهيئة الفرص المناسبة لصغار الزراع وحماية المستأجرين من استغلال الملاك، فلا محل لها فى قسمة المهايأة إذ تتم بين ملاك لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع، فمظنة الاستغلال فيها غير قائمة، ومن ثم فهى أحكام تتعارض مع طبيعة القسمة^(١).

تحول المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية:

أسلفنا أنه يجوز الاتفاق على تجديد قسمة المهايأة بعد انقضاء مدتها. وإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، فإنه يصح أن تظل تتجدد سنة بعد أخرى. فإن دامت خمسة عشرة عاما فإنها تتقلب بمقتضى المادة ٢/٨٤٦ مدنى إلى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وتبرير ذلك^(٢) أن المهايأة المكانية التى تدوم خمسة عشر عاما دون أن يرغب أحد فى إنهاؤها هى خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها، وقد وصلوا إليها فعلا بالتجربة، فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إلا أن يتفقوا مقدما على أن قسمة المهايأة لا تتقلب إلى قسمة نهائية.

24/2025 والفقرة الثانية من المادة ٢/٨٤٦ تنص بتحول المهايأة المكانية التى تستمر خمسة عشرة سنة دون أن ينهيها أحد الشركاء إلى قسمة نهائية، تشترط ذلك بشرطين: أن تمضى على المهايأة المكانية مدة خمسة عشر عاما، وإلا يتفق على استبعاد هذا التحول. ومتى توافر الشرطان تحولت المهايأة إلى قسمة نهائية، يستوى أن تكون المهايأة قد قامت أصلا بناء على اتفاق بين الشركاء، أو اعتبرها القانون قائمة بفعل القرينة التى أتى بها عجز الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ مدنى.

وما دام تحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية إنما يتم بقوة القانون، فلا تكون القسمة النهائية حينئذ قسمة اتفاقية. ومن ثم فلا يجوز نقض هذه القسمة

(١) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٨٢٢، د. إسماعيل غانم ص ١٨١ د. أحمد سلامة ص ٢٦٨.

(٢) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ١٣٩.

بسبب الغبن^(١)، وإذا كان بين الشركاء شخص لا تتوافر فيه الأهلية أو شريك غائب، فإن هذا لا يمنع من تحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية^(٢).

ويرى جانب من الفقه أنه لا حاجة لتسجيل القسمة، إذ كان المال الشائع عقاراً، إذ أنها تتم بقوة القانون وليس بمقتضى اتفاق أو حكم^(٣). غير أننا نفصل ما ذهب إليه البعض^(٤) بوجوب تسجيل هذه القسمة، ككل قسمة حتى يحتج بالملكية على الغير^(٥). فيحرر المتقاسمون عقداً بذلك فإن عارض البعض جاز إقامة دعوى بإثبات هذه القسمة ثم تسجيل الحكم الصادر فيها. وتعتبر القسمة النهائية قائمة من اليوم التالى لانقضاء خمسة عشر سنة لا من يوم بدء المهايأة ولا من يوم صدور الحكم.

المطلب الثالث

إدارة المال الشائع

أهم ما يعرض بصدد انتفاع الشركاء بالمال الشائع هو، إدارة المال الشائع وسلطات الشركاء فى هذا الصدد. وقد تكفل القانون المدنى بتنظيم إدارة المال الشائع إذا تعذر الوصول إلى اتفاق الشركاء، وقد ضمن المشرع هذه لقواعد المواد من ٨٢٧ . ٨٢٩ مدنى ويفرق فى هذا الصدد بين أعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة.

(١) المادة ٨٤٥ التى تجيز نقض القسمة بسبب العين يقتصر حكمها على القسمة الرضائية أو الاتفاقية.

(٢) د. إسماعيل غانم ص ١٨٣، د. الصدة ص ٢٢١، د. سلامة ص ٢٧٥، د. منصور مصطفى ص ١٩٩، عكس ذلك د. السنهورى الوسيط ص ٨١٩.

(٣) د. إسماعيل غانم ص ١٨٤، د. منصور مصطفى ص ١٩٩ وقريب د. الصدة ص ٢٢٥.

(٤) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٨١٩، د. أحمد سلامة ص ٢٧٦.

(٥) «ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التى تحولت إليها قسمة المهايأة حتى يمكن الاحتجاج بالملكية على الغير» نقض مدنى ١٩٦٩/٦/٢٦ س ٢٠ ص ١٠٨٤.

أعمال الإدارة المعتادة:

أعمال الإدارة المعتادة هي تلك التي لا تتطوى على تغييراً جوهرياً في المال الشائع، أو تعديلاً في الغرض الذي أعد له. وهي قد تكون أعمالاً مادية، كما قد تكون أعمالاً قانونية. مثال الأولى زراعة الأرض، ومثال الثانية إيجار المال الشائع. وقد ألحق المشرع أمرين آخرين لهذه الأعمال تعين مدير للمال الشائع، ووضع نظام دائم لإدارة المال الشائع وتنظيم الانتفاع به^(١). وهو ما نص عليه في المادة ٢/٨٢٨ مدني حيث نصت:

«..... ٢- وللأغلبية أن تختار مديراً، كما لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً».

ويجوز لهذه الأغلبية أن تجمع بين الأمرين، تعين مديراً من بين الشركاء أو من غيرهم، ووضع نظاماً لحسن إدارة المال. وإذا تم هذا عد هذا النظام قيد على سلطة المدير، فإن خرج عنه كان متجاوزاً لحدود سلطته. على أنه إذ قام ~~الشركاء بالإدارة دون اعتراض من الباقيين عد وكيلاً عنهم~~^(٢).

2024/2025

إذ لم تقم الأغلبية باختيار مدير، فإن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبه (م١/٨٢٨). فالمشرع قد اكتفى في أعمال الإدارة المعتادة بالأغلبية المطلقة، أي رأى من يملك أكثر من نصف المال الشائع وقت اتخاذ

(١) د. السنهوري ص ٨٢٦، د. أحمد سلامة ص ٢٨٦، د. مصطفى الجمال ص ١٢١.

(٢) «الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقيين عد وكيلاً عنهم، ويلتزم بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله، كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب ونتيجة طوال فترة الوكالة، أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل». نقض مدني ١٩٧٢/٢/١١ طعن ٣١٨ س ٣٧ ق، ص ٦٨٧.

القرار. وليس للأقلية حق التظلم إلى المحكمة ما دام الأمر يتعلق بالإدارة المعتادة. فهذه الأقلية مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الأغلبية، اللهم إذا توافرت شروط التعسف في استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة^(١) (م ٥ من القانون المدني). فإن لم تنجح في إلغاء القرار بدعوى التعسف أو لم تطعن فيه لم يكن أمامها سوى طل القسمة النهائية.

فإذا لم يمكن التوصل إلى قرار من الأغلبية، كان لأي من الشركاء منعا لتعطيل الانتفاع بالمال الشائع، أن يطلب من المحكمة أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة م ١/٨٢٨ كأن تأمر بتأجير الشيء أو تأذن لهذا الشريك بالإنفاق على الأرض إلى أن يتم نضج المحصول، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

أعمال الإدارة غير المعتادة:

أعمال الإدارة غير المعتادة هي تلك التي تقتضى تغييراً أساسياً أو تعديلاً في الغرض الذي أعد له المال. كإعادة بناء منزل لجعله صالحاً للاستعمال، أو تحويل أرض زراعية إلى أرض معيشية^(٢) ٢٠٢٤/٢٠٢٥. ونظراً لخطورة هذه الأعمال فقد استلزم القانون أغلبية خاصة غير الأغلبية العادية التي تستلزم في حالة القيام بأعمال الإدارة المعتادة. هذه الأغلبية العادية التي تستلزم في حالة القيام بأعمال الإدارة المعتادة. هذه الأغلبية هي أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع. تنص المادة ١/٨٢٩ على أن «لشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض

(١) د. إسماعيل غانم ص ٨٥١، د. السنهوري ص ٨٢٧، د. توفيق فرج ص ٢٢٠، د. الصدة ص ١٦٦.

(٢) الأعمال التحضيرية ج ٦ ص ٨٨، د. السنهوري الوسيط ص ٨٣١، د. إسماعيل غانم ص ١٣٢.

الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم لباقي الشركاء».

وإن كان المشرع قد قرر هنا لأغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا ما يروه ويخرج عن حدود الإدارة المعتادة، فإنه يضمن ضمانات يحمى بها مصالح الأقلية المعارضة لقرار الأغلبية السابقة. فيلزم لكى ينفذ قرار الأغلبية أن يعلن إلى باقى الشركاء الذين لم يوافقوا على التعديلات التى تراها الأغلبية. ويكون من خالف الشركاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية (م ٢/٨٢٩).

وللمحكمة عند الرجوع إليها أن تلغى قرار الأغلبية أو تقرها على رأيها. وفى الأولى لها أن تحكم بإزالة ما يكون قد تم بناء على هذا القرار، ويكون ذلك على نفقة من وافق عليه من الشركاء. أما فى الحالة الثانية إذ أقرت المحكمة رأى الأغلبية فإن لها أن تقر ما تراه من تدابير لدفع الضرر عن المخالفين، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالفة من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من تعويضات، إذ ما لحقهم ضرر من جراء تنفيذ القرار الذى أصدرته الأغلبية^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المطلب الرابع

التصرف فى المال الشائع

قد يصدر التصرف فى المال الشائع من جميع الشركاء، كما قد يصدر من أغليبتهم، حيث أجاز المشرع استثناء لمن يملكون ثلاث أرباع المال الشائع أن يتصرفوا فيه. كذلك قد يصدر التصرف من أحد الشركاء فى حصته، أما على الشيوع وأما على حصة مفرزة كما قد يصدر التصرف من أحد الشركاء فى المال الشائع جميعه.

(١) الأعمال التحضيرية ج٦ ص ٩٢، د. توفيق فرج ص ٢٢٤.

ونعرض أولاً للتصرف في المال الشائع من جميع الشركاء أو من أغلبيتهم، ثم في التصرف الصادر من أحد الشركاء، وأخيراً في استرداد الحصة الشائعة.

الفرع الأول

التصرف في المال الشائع من جميع الشركاء أو من أغلبيتهم

التصرف من جميع الشركاء:

للشركاء المجتمعين أن يتصرفوا في المال الشائع أو في جزء مفرز منه بكافة التصرفات المادية والقانونية، ولهم ذلك متى انعقد إجماعهم عليه. فإذا كان التصرف ناقلاً للملكية، كالبيع مثلاً، خرج هذا المال من الشيوع، وإذا كان في بعض المال الشائع فقط، خرج هذا الجزء من الشيوع.

2024/2025

وقد يكون تصرف الشركاء منشأً لحق عيني آخر على المال الشائع، كرهن أو انتفاع مثلاً. وقد حسم ^{المشروع} ٢٥٢٥ حالة الرهن الرسمي بنص المادة ١/١٠٣٩ مدني إذ نصت «يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أي كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته».

أما بالنسبة لغير الرهن الرسمي فالرأي الراجح يرى اعتبار المادة ١/١٠٣٩ مدني تطبيقاً لقاعدة عامة^(١) فتصرف جميع الشركاء، سواء ورد على المال الشائع كله أو على جزء مفرز منه، يظل نافذاً في مواجهتهم، أي كانت نتيجة القسمة، بل ويمكن القول بأن الشريك الذي آل إليه المال الشائع كله بمقتضى القسمة يلتزم بضمان تعرضه الشخصي في كل الحق العيني

(١) د. السنهوري الوسيط ص ٨٣٧، د. جمال ذكي ص ١٢٦، د. توفيق فرج ص ٢٢٨، د. أحمد سلامة ص ٣٠٢، د. مصطفى الجمال: ص ١٢٩، د. عمران ص ٣٤٢.

الذى رتبته، مع شركائه^(١) على العين الشائعة، أو على الجزء المفرز، وليس فقط بقدر حصته، لأن ضمان التعرض غير قابل للتجزئة».

التصرف الصادر من أغلبية الشركاء:

خوّل المشرع أغلبية الشركاء سلطة التصرف فى المال الشائع، فالشركاء الذين يملكون ثلاث أرباع المال الشائع على الأقل أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية (م ٨٣٢ مدنى).

والأغلبية التى يستلزمها القانون للتصرف فى المال الشائع هى ذات الأغلبية التى يقتضيها فى أعمال الإدارة غير العادية. مثال ذلك أن تعرض صفقة رابحة يخشى ألا تعود، أو تكون إدارة المال الشائع معتمدة واستغلاله غير مريح، أو يستدعى ترميم العقار الشائع قرضاً يضمن برهنه^(٢)، أو قد يرد التصرف على جزء مفرز، كبيع جزء من الأرض الشائعة لإقامة بناء على الجزء الباقى منها.

2024/2025

فإذا توافرت الأغلبية والأسباب القوية كان لهم أن يقرروا التصرف فى المال الشائع على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء. ولم يحدد القانون طريقة معينة لهذا الإعلان، وبهذا تلتزم الأقلية برأى الأغلبية، ومع ذلك يجيز القانون لأى من الأقلية أن يتظلم من قرار الأغلبية أمام المحكمة، وذلك خلال شهرين من وقت إعلان التصرف.

وعلى المحكمة أن تقدر الأسباب التى أدت إلى قرار الأغلبية، فإن لم تقتنع بأنها أسباب قوية ألغت هذا القرار، أما إذا اقتنعت فلها أن ترفض طلب إلغاء القرار، وأن القاسمة ضارة بمصالح الشركاء.

وإذا طلب المعارض على تصرف الأغلبية القسمة، كان للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا كانت القسمة ممكنة وليست ضارة بمصالح الشركاء والمادة

(١) د. إسماعيل غانم ص ١٣٥، د. الصدة ص ١٧٦.
(٢) د. الصدة ص ١٧٧، د. جمال ذكى ص ١٢٢.

٨٣٢ مدنى واضحة الدلالة على هذا المعنى «للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف، ما إذا كان التصرف واجباً».

أما إذا تبين للمحكمة أن القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء انتقلت إلى النظر فيما إذا كان التصرف الذى قرره الأغلبية تصرفاً حكيماً تبرره الظروف القائمة^(١)، وليس فيه غبن فادح، فإن رأته كذلك أجازته، وكان للأغلبية أن تجربته وفقاً للقرار الذى اتخذته. وإن لم تقتنع بكونه واجباً ألغته، فلا يكون التصرف بعد ذلك ممكناً إلا بإجماع الشركاء.

الفرع الثانى

التصرف الصادر من أحد الشركاء

قد يتصرف الشريك فى حصته الشائعة، وقد يتصرف فى جزء مفرز من المال الشائع أو فيه كله. وتصرف الشريك فى حصته الشائعة لا يمس بحقوق الشركاء الآخرين، بينما يمس تصرفه فى جزء مفرز من المال الشائع أو فيه كله بهذه الحقوق. لذلك كان من الطبيعى أن يختلف حكم التصرف فى الحاليتين.

تصرف الشريك فى حصته شائعة:

يملك الشريك فى الشيوع حصته شائعة، لهذا يكون له وتصرفه هذا يكون نافذاً فى مواجهة باقى الشركاء دون حاجة إلى موافقة منهم^(٢). وعلى هذا نصت المادة ١/٨٢٦ مدنى «كل شريك على الشيوع يملك حصة ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها».

وتصرف الشريك فى حصته الشائعة يقع صحيحاً وناظراً فى مواجهة شركائه، ولا يكون لهم إلا طلب استرداد هذه الحصة أو الأخذ بالشفعة. ولا

(١) د. السنهورى الوسيط ٨ ص ٨٣٩.

(٢) نقض مدنى ١٩٦٦/٣/٢٤ طعن رقم ٢٩٠ لسنة ٣٢ ق، س ١٧ ص ٧٢٣.

يقتصر على تصرف معين، بل أن للشريك أن يتصرف في حصة شائعة بكافة التصرفات، يقرر عليها حقوقا عينية أصلية كانت أم تبعية، بعوض أم بدون عوض، طالما كان تصرفه لا يمس حقوق الشركاء^(١).

فيجوز أن يكون التصرف ناقلا للملكية كالبيع والهبة، ويجوز أن يكون مقررا لحق من الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية كالانتفاع أو الحقوق العينية التبعية كالرهن، ولكن لا يجوز أن يكون التصرف بتقرير حق ارتفاق، ذلك أن تقرير مثل هذا الحق يجعل العقار الشائع يتحمل به كله، مما يترتب عليه المساس بحقوق الشركاء^(٢).

فإذا كان التصرف في المال الشائع من التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والهبة، فإن هذا التصرف يكون نافذا في مواجهة سائر الشركاء دون حاجة إلى إعلانهم، ويحل المتصرف إليه محل الشريك المتصرف قبل الشركاء، وتكون له كل حقوق الشريك والتزاماته، ويثبت له حق طلب القسمة، ويجب على باقي الشركاء اختصامه في دعوى القسمة. والعبرة في هذا الشأن بتسجيل القسمة، فإذا كان قد سجل حقه قبل تسجيل القسمة الحاصلة بين الشركاء فلا يحتاج عليها بها^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) «تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد عن حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد عن حصة الشريك المتصرف وبحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد عن حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة». نقض مدني ١٩٧٥/١١/١١ طعن رقم ٢١٤ لسنة ٤٠، س ٢٦ ص ١٣٨٨.

(٢) د. السنهوري الوسيط ص ٨٤٧، د. توفيق فرج ص ٢٣١، د. محمد عمران ص ٣٤٥.

(٣) «المشتري لحصة شائعة في عقار من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقدة قبل تسجيل عقد القسمة المعقودة بين هؤلاء الشركاء لا يحتج عليه بهذه القسمة، لأنه وقد انتقلت إليه الملكية بالتسجيل على مقتضى المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري، يكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص الحصة التي اشتراها». نقض مدني ١٩٨٨/٣/٣٠ طعن رقم ٦٠٤ لسنة ٥١ ق.

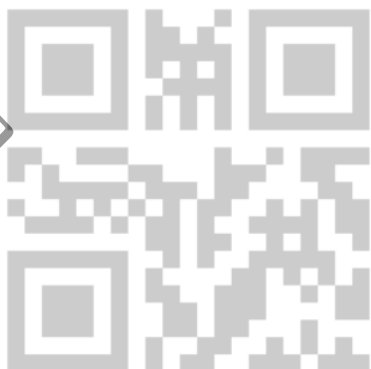
وإذا كان التصرف في المال الشائع بترتيب حق انتفاع، يثبت للمتصرف إليه استعمال المال الشائع واستثماره، بما يتبع ذلك من اشتراكه في أعمال الإدارة المعتادة بحيث يحسب صوته في حساب الأغلبية العادية لها، وفي قسمة المهايأة. أما الرقبة^(١) فتظل للشريك المتصرف وله ممارسة ما يقابلها من سلطات، وهي المتعلقة بالإدارة غير المعتادة والتصرف وطلب القسمة. وإذا تمت القسمة قبل انتهاء الانتفاع انتقل حق المنتفع إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى مالك الرقبة^(٢).

كما يجوز للمالك على الشيوع أن يرهن حصته الشائعة وهنا رسمياً، وإذا حل أجل الوفاء بالدين المضمون فإن ذلك قد يقع قبل القسمة أو بعدها. فإذا حل قبل القسمة ولم يقر الراهن بالوفاء، كان للمرتهن التنفيذ على الحصة المرهونة فتباع جبراً عن صاحبها ويحل من يرسو عليه المزداد مل الشريك الذي بيعت حصته، ويتملك المشتري الحصة الشائعة كذلك. وإذا تمت القسمة بعد حلول الأجل وقيام الدائن بالتنفيذ يفرق بين فرضين: فقد تقع الحصة المرهونة في نصيب الراهن، وفي هذه الحالة يستقر عليها حق الدائن المرتهن، ولا تقع في نصيب الراهن، هنا أورد المشرع لذلك نص المادة ٢٩٠/٢ بأنه «إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبة إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل».

وبالنسبة للرهن الحيازي فقد تنور صوبه خاصة بنقل حيازة الحصة الشائعة، يمكن التغلب عليها بوضع الشيء المرهون رهنًا حيازياً في حيازة شخص آخر غير المرتهن ولو من بين الشركاء فيحوز الحصة المرهونة بصفته

(١) «الملكية المنقلة بحق الانتفاع هي ملكية الرقبة فيجتمع في العقار حقان عينيان، حق الرقبة للمالك وحق الانتفاع للمنتفع» نقض مدني ١٩٨٧/١٢/٣ طعن ١٥٩٨ س ٥٥ ق ١٠٩٣ س ٥٣ ق.

(٢) د. السنهوري الوسيط ص ٨٤٨، د. توفيق فرج ص ٢٣٤.



عدلا ويحوز باقى الحصص بصفته مديرا، فلا يشترط فى الرهن الحيازى أن تنتقل الحيازة إلى المرتهن بل يكفى ألا تظل فى حيازة الراهن^(١).

تصرف الشريك فى حصته مفرزة:

حق الشريك المشتاع حق ملكية يرد على المال الشائع كله ويتحدد بنسبة معينة من مجموع ما يخوله من مزايا، ولكن فى ذات الوقت لكل من الشركاء حق مماثل على المال الشائع نفسه، وعلى ذلك إذا تصرف الشريك منفردا فى جزء مفرز من المال الشائع أو فيه كله، فإنه يتصرف فى حقه ولكنه فى ذات الوقت يتصرف فى حقوق الشركاء.

وقد عرض القانون المدنى لهذا الموضوع فى المادة ٢/٨٢٦ منه «إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة، وللمتصرف إليه إذا كان مجهول أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها ملكية مفرزة، الحق فى إبطال التصرف^(٢)». وقد اختلف الفقه فى اعتبار حكم تصرف أحد الشركاء فى جزء مفرز من المال الشائع فى العلاقة بين طرفيه على ضوء هذا النص.

والرأى الذى نؤيده^(٣) يرى أن تصرف الشريك فى جزء مفرز من المال الشائع يعتبر صحيحا بين طرفيه لصدوره من مالك، ولكنه غير نافذ فى حق باقى الشركاء. فالتصرف ينعقد صحيحا وهو يعتبر كذلك سواء قبل القسمة أم بعدها، كما أن هذا يتفق مع حكم القانون فى هذا الصدد. م ٢/٨٢٦.

ذلك أن حق الشريك فى الشيوع ملكية يرد على المالك الشائع جميعه فى حدود نصيبه، وعلى ذلك فإن تصرفه فى حصته تصرفا صادرا من مالك، أى

(١) د. توفيق فرج ص ٢٣٤، د. الصدة ص ١٩٢، د. عمران ص ٣٤٦.

(٢) د. السنهورى الوسيط ص ٨٧٤، د. إسماعيل غانم، د. توفيق فرج ص ٢٣٨، د. حسن كيرة ص ١٧٧، د. مصطفى الجمال ص ١٣٧.

من شخص يملك التصرف وليس تصرفاً من ملك الغير . فيتعين استبعاد فكرة بيع ملك الغير^(١) . إذ البائع مالك لحصته وتصرفه يقع صحيحاً دون نظر إلى نتيجة القسمة، والقول بغير ذلك يعنى تعليق لصحة التصرف أو بطلانه على نتيجة القسمة وهى أمر لاحق لانعقاده، مع أن بطلان التصرف يجب أن يرجع إلى عيب يلحق به وقت انعقاده^(٢) . وهذا الرأى هو الذى يتفق مع حكم القانون المصرى ذلك أنه إذا وقع الجزء الذى تم لتصرف فيه فى نصيب المتصرف، أستقر عليه حق المتصرف إليه، أما إذا لم يقع هذا الجزء فى نصيبه^(٣) بل وقع فى نصيبه جزء آخر غير ما تم فيه التصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وفى هذه الحالة لا يكون للمتصرف إليه إلا الاستناد إلى أحكام الغلط لإبطال التصرف متى كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة.

وإذا كان التصرف يصح بين طرفيه على النحو المتقدم، فإنه لا ينفذ فى مواجهة باقى الشركاء، فإذا قام أحد الشركاء ببيع جزء مفرز من المال الشائع أو برهنه أو بإنشاء حق عينى آخر عليه، فلا يكون للمشتري أو المرتهن أو صاحب الحق العينى أن يحتج بحقه على بقية الشركاء سواء قبل القسمة أو بعدها. وأن كان للشركاء أن يقرروا التصرف الصادر من شريكهم فيصير نافذاً فى حقهم. وقد يكون هذا الإقرار صريحاً أو ضمناً. كما يكون للشركاء إقرار التصرف كذلك بعد القسمة إذا لم تقع الحصة المبيعة فى نصيب المتصرف.

(١) د. عبد المنعم الصدة ص ١٨٠، د. منصور مصطفى ص ١٧٢.

(٢) د. توفيق فرج ص ٢٣٨، د. مصطفى الجمال ص ١٣٨.

(٣) «بذلك يصبح استمرار المشتري فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من المسند ويكون لمن اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك لمن اشتراه من اختص به ولو لم يسجل عقده، لما هو مقرر من أن عقد البيع ينقل إلى المشتري ولو لم يكون مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع المرتبطة ومنها حقه فى طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند».

نقض مدنى ١٩٨١/١٢/١٣ طعن رقم ٦٨٦ لسنة ٤٨ ق ، س ٣٢ ص ٢٢٧٧.

فإذا لم يصدر منهم هذا الإقرار، انتقل حق المتصرف إليه إلى ما وقع في نصيب من تصرف له. وهذا واضح من نص المشرع على انتقال حق المتصرف إليه إلى ما وقع في نصيب المتصرف يعنى أن التصرف في حصة مفرزة من أحد الشركاء يكون غير نافذ في حق باقى الشركاء.

الفرع الثالث

استرداد الحصة الشائعة

قد يتم التصرف من الشريك في الشيوع إلى أحد الشركاء الآخرين، وقد يتم إلى شخص أجنبي عن الشيوع. ولمنع دخول الأجنبي بينهم في الشيوع خول القانون أيا منهم الحق في الحل محل من يشتري الحصة الشائعة وذلك عن طريق استرداد هذه الحصة في حالة المنقولات، وعن طريق الشفعة في حالة العقارات^(١). وقد أورد المشرع أحكام الاسترداد في مادة وحيدة هي المادة ٨٣٣ مدنى وتنص:

١- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل ^{2024/2025} القسم الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد بإعلان بوجه إلى كل من البائع والمشتري. ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذ هو عوضه عن كل ما أنفقه.

٢ - وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته. وقد بين المشرع في هذه المادة الحالات التي يجوز فيها الاسترداد، وإجراءات، وآثاره.

شروط الاسترداد ونطاقه:

نص المادة ٨٣٣ صريح في أن حق الاسترداد لا يكون إلا في بيع الحصة الشائعة في المنقول المعين أو في المجموع من المال. فلا يجوز

(١) الشفعة سبب عام لكسب الملكية، لذلك فيجاوز موضوع الملكية الشائعة. وسيدرس عند دراسة أسباب كسب الملكية في الكتاب الثانى.

الاسترداد في بيع الحصة الشائعة في العقار المعين ولو كان ذلك العقار هو كل المال الشائع، وإنما يجوز لاسترداد إذ كانت الحصة المباعة حصة شائعة في مجموع من المال، كالمترج أو التركة، وكان هذا المجموع يتضمن عقارات. فإذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة قبل قسمتها، فيثبت الاسترداد لباقي الورثة، إنما يتعين في هذه الحالة أن يكون العقار ضمن مجموع أموال التركة.

ولكي يكون للشريك الحق في استرداد الحصة التي باعها شريك آخر، لابد وأن يكون التصرف ببيع لحصة شائعة، فلا يجوز في غير البيع من التصرفات^(١) ولو كان التصرف معاوضة كالمقايضة، والبيع لابد وأن يكون لجزء شائع فلا يجوز بيع جزء مفرداً أثناء الشروع، إذ البيع غير نافذ في حق سائر الشركاء ولن يصير به المشتري شريكاً معهم فتنتفي الحكمة من تقرير حق الاسترداد.

ويلزم أن يتم البيع بطريق الممارسة وهو البيع الاختياري، فإذا تم البيع جبراً بطريق المزاد العلني ورسا المزاد على أجنبي عن الشركاء، فلا يجوز لهم أن يطلبا الاسترداد، ذلك أن في توافر العلنية في هذا البيع ضماناً لحقوق باقي الشركاء الذين يمكنهم التقدم في المزاد.

وإذا كان المشرع قد اشترط أن يكون التصرف بيعاً اختيارياً لحصة شائعة لثبوت الحق في الاسترداد، فإنه لازم ذلك أيضاً أن يكون التصرف لأجنبي عن الشروع، وعلى هذا لا يجوز الاسترداد إذا كان البيع لأحد الشركاء في الشروع، لأن حكمة تقرير الاسترداد وهي خشية دخول الأجنبي غير متوافرة.

وحق الاسترداد ثابت لكل شريكاً في الشروع وقت البيع، بغیر تفرقة بين شريك أصلي من الشركاء الذين نشأ الشروع بينهم ابتداءً، وشريك عارض تلقى

(١) د. إسماعيل غانم ص ١٥٩، د. توفيق فرج ص ٢٤٥، د. محمد عمران ص ٣٤٨.





حقه في الشيوخ بعد نشوئه بسبب من أسباب كسب الملكية كالإرث أو التصرف من أحد الشركاء الأصليين^(١).

وإذا تعدد الشركاء الذين يرغبون في الاسترداد كان لكل منهم ذلك بنسبة حصته في الشيوخ. وكذلك إذا باع عدة شركاء حصصهم إلى أجنبي واحد، فلا يحق للشركاء الآخرين طلب الاسترداد في بعض الحصص المباعة دون بعض، بل يجب أن يرد الاسترداد على الحصص المباعة جميعاً، حتى تتوافر الحكمة من الاسترداد وهي منع دخول الأجنبي في الشيوخ.

إجراءات الاسترداد:

المشرع في المادة ٨٣٣ قد حدد للشريك المسترد مدة قصيرة حتمية يجب عليها فيها أن يعبر عن رغبته في الاسترداد. وهذه المدة هي ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. فإذا أعلن أي من البائع أو المشتري الشركاء بالبيع، وجب على من يريد أن يسترد منهم أن يعبر عن رغبته في الاسترداد في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان. ولم يشترط المشرع في الإعلان الذي يقوم به المسترد أن يعلن البائع أو المشتري شكل خاص. ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري. وواضح من عبارة هذا النص أن الشارع لم يفرض على المسترد أن يرفع الدعوى خلال مدة معينة. فمدة الثلاثين يوماً هي ميلاد لإعلان الرغبة في الاسترداد، وليست ميعاد لرفع الدعوى. فالمسترد إذا أعلن رغبته في الاسترداد في الميعاد المحدد، فإنه يستطيع أن يرفع الدعوى في أي وقت يشاء إلى أن تقع القسمة^(٢).

(١) المذكرة الإيضاحية ج ٦ ص ٩٨.

(٢) د. السنهوري الوسيط ص ، د. إسماعيل غانم ص ١٦١، د. منصور مصطفى ص ١٥٨، وعكس ذلك من يرى أن دعوى الاسترداد يجب أن ترفع خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة ٨٣٣، د. الصدة ص ١٩٨، نقض مدني ١٩٥٦/٢/١٦ مجموعة أحكام النقض ٧ ص ٢٢٥.



وبلاحظ أن إعلان الرغبة في الاسترداد يجب أن يوجه في الميعاد المحدد إلى كل من البائع والمشتري، فإذا أعلن أحدهما في الميعاد المحدد، ولم يعلن الآخر إلا بعد انقضائه، سقط الحق في الاسترداد.

آثار الاسترداد:

سواء تم الاسترداد بالاتفاق أو بحكم فإنه كما تقول المادة ١/٨٣٣ يحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.

فإذا كان المشتري قد أوفى بالثمن للبائع، وجب على المسترد أن يدفع للمشتري الثمن الذي أوفى به وفوائده من يوم الوفاء. كما يجب عليه أن يدفع للمشتري كل ما تحمله من نفقات كأجر السمسة ورسوم التسجيل وما ساهم به من نفقات في حفظ الأموال الشائعة وإدارتها.

والثمن الذي يلتزم به المسترد هو الثمن الحقيقي. فإذا أدعى صورة الثمن المذكور في العقد كان له أن يثبت هذه الصورة بجميع الطرق طبقاً للقواعد العامة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويكون للمسترد الحق في الثمار التي أنتجها الشيء في المدة ما بين إبرام البيع وتام الاسترداد. وإذا كان البائع قد منح المشتري أجلاً لدفع الثمن فإنه يحق للمسترد أن ينتفع بهذا الأجل.

ولا يعتبر الاسترداد بيعاً جديداً من المشتري للمسترد، وإنما يبقى العقد الأصلي، ويحل المسترد محل المشتري في هذا العقد. وبالتالي فإن المسترد يكون هو الخلف للبائع يتلقى عنه الحصة المبيعة مباشرة، وتستند آثار الاسترداد إلى وقت البيع. فيصبح المسترد كأنه المشتري الأصلي، وعلى لا يحتج عليه بالتصرفات التي أبرمها المشتري في الفترة ما بين البيع وتام الاسترداد. كما لا يتحمل المشتري بأى ضمان نحو المسترد، بل يكون للمسترد

أن يرجع الضمان على البائع، لأنه يحل محل المشتري الأصلي في جميع حقوقه.

وإذا كان المبيع حصة في مجموع من المال، وكان هذا المجموع يشتمل على عقار، فإنه يجب تسجيل الاتفاق الذي يتم به الاسترداد أو الحكم الذي يصدر بالاسترداد، وذلك لكي تنتقل ملكية الحصة الشائعة في العقار من البائع إلى المسترد. ويترتب على وجوب التسجيل أنه لا يجوز الاحتجاج بالأثر الرجعي للاسترداد على الغير الذي تلقى من المشتري بحسن نية حقا عينية على الحصة الشائعة في العقار قبل هذا التسجيل^(١)، أما إذا سجلت صحيفة دعوى الاسترداد، فإن الحكم الصادر بالاسترداد يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية من المشتري بعد تسجيل الصحيفة، سواء كان الغير حسن النية أو سيئ النية، ولا يكون حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل هذا التسجيل (م ١٥ - ١٧ - قانون الشهر العقاري).

المبحث الثاني

انقضاء الشيوع»القسمة«

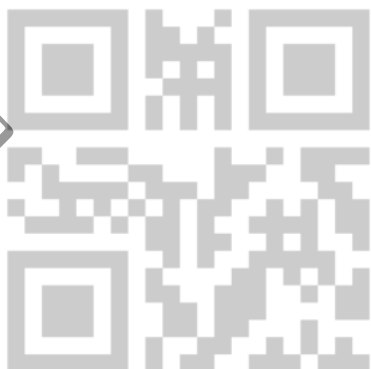
2024/2025

2024/2025

القسمة هي إعطاء كل شريك في الشيوع قدرا يعادل نصيبه في المال الشائع، وقد يتم ذلك بالتراضي بين الشركاء، وإذا لم يتوافر التراضي فإنها تتم أمام القضاء.

ومن هنا فإن القسمة قد تكون رضائية وقد تكون قضائية. وفي الحالتين تكون إما قسمة عينية يختص بمقتضاها، كل شريك بجزء مفرز من العين

(١) د. إسماعيل غانم ص ١٦٤، ويرى سيادته أن المادة ١٥ لم تذكر دعوى الاسترداد صراحة بين الدعاوى التي يتعين تسجيلها، إلا أن الحكم بالاسترداد يتفق والحكم الصادر بإبطال التصرف أو نسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه فيما له من أثر رجعي. وهذا الجامع المشترك يبرر قياس دعوى الاسترداد على دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع التي قضت عليها المادة ١٥.



الشائعة، وأما قسمة تصفية، يختص بمقتضاها لكل شريك بحصة في ثمن العين الشائعة بعد بيعها بالمزاد.

ونقصد في كل هذا القسمة النهائية التي تؤدي إلى إنهاء الشروع، لا القسمة المؤقتة وهي قسمة المهايأة التي تجرى . كما أسلفنا . في أثناء الشروع وترد على منفعة العين الشائعة.

القاعدة أن لكل من الشركاء على الشروع أن يطلب القسمة:

الشروع بطبيعته من شأنه أن يثير المنازعات بين المشتاعين في الكثير من الأحيان نظرا لتشابك حقوقهم على الشيء الواحد. وليس في الإمكان تلافي ذلك بأى تنظيم يضعه المشرع للشروع، وإنما يقتصر أمر التنظيم على منع تعطيل الانتفاع بالمال الشائع، لذلك كان المبدأ العام في الشروع هو حق كل شريك في طلب القسمة حتى يتخلص من الشروع وينفرد بجزء من المال الشائع يرد عليه حقه وحده دون غيره.

وقد نصت المادة ٨٣٤ على هذا الحق بقوله «لكل شريك أن يطلب بفسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشروع بمقتضى نص أو اتفاق».

فإذا كانت القاعدة التي أتت بها المادة ٨٣٤ تقضى بحق كل شريك في طلب القسمة، فقد تكون هناك من الاعتبارات ما يبرر الخروج عليها. وهذه الاعتبارات قد يقرها القانون وقد يقضى بها القاضى، وقد يتفق عليها الشركاء.

فالشريك قد يكون مجبرا على البقاء في الشروع بمقتضى نص في القانون، كالمشأن في الشروع الإجبارى الذى لا يجوز فيه للشركاء أن يطلبوا قسمة المال الشائع، حيث يقضى الغرض الذى أعد له المال الشائع بقاءه على الشروع إذ لا يصلح للاستعمال المعد له إذا قسم (مادة ٨٥٠ مدنى).

والقسمة قد تكون ضارة بمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من الشركة، وقد لا يؤمن ترك تقديره للنائب القانونى عنه، فيجب أن يترك أمر



تقديره للقاضي لذلك نصت المادة ٤١ من القانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بالولاية على المال «إذا رفعت دعوى القسمة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر، فللمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة، أن توقف القسمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل ضررا جسيما».

كما يجوز أن يتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة يستلزمها استثمار معين أو يقتضيها القيام بإصلاح معين، فيلجئون إلى الاتفاق على البقاء في الشيوع هذه المدة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لهم ولمن يأتي بعدهم من خلف عام أو خاص^(١). ويقع الاتفاق على البقاء في الشيوع، عادة، بين جمع الشركاء، إنما ليس ثمة ما يمنع وقوعه بين بعضهم، فيكون الاتفاق ملزما لهم وحدهم دون الباقيين الذين لم يكونوا طرفا فيه^(٢).

وإذا كان المشرع قد أجاز البقاء في الشيوع بناء على اتفاق، فإنه اشترط أن يكون ذلك مؤقتا حتى لا يترتب عليه إلغاء المبدأ العام من حق كل شريك في طلب القسمة، فالفقرة الثانية من المادة ٣٨٤ تقضى «ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين.....» فإذا جاوزت المدة المتفق عليها للبقاء في الشيوع هذا الحد كان الاتفاق ملزما للشركاء لمدة خمس سنوات دون ما يجاوزها. ويرى الفقه الغالب^(٣) أن إنقاص المدة في هذه الحالة

(١) يذهب الرأي الراجح إلى أن نص المادة ٨٣٤ يعتبر استثناء على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مدنى والتي تشترط علم الحلف الخاص بالعقد حتى يكون نافذا في حقه، د. السنهورى الوسيط ص ، د. إسماعيل غانم ص ١٧١، د. الصدة ص ٢٠٢، د. منصور مصطفى ص ١٨٧، غير أن البعض يرى أن الخلف الخاص لا يلزم بالاتفاق إلا إذا كان عالما به وفقا للقواعد العامة منعا للإضرار بهذا الخلف، د. حسن كيرة ص ١٩٩، د. مصطفى الجمال ص ١٦٥.

(٢) د. السنهورى: ص ، د. إسماعيل غانم ص ، د. جمال ذكى: ص ١٥١، د. حسن كيرة ص ١٩٨.

(٣) د. السنهورى ص ، د. غانم ص ، د. حسن كيرة ص ١٩٨، د. توفيق فرج: ص ٢٥١، د. عبد المنعم الصدة ص ، د. منصور مصطفى.

ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في البطلان الجزئي التي نصت عليها المادة ١٤٣ مدني «إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله».

ولكن إذا تبين أن الشركاء ما كانوا ليرتضوا الالتزام بالبقاء في الشيوع لمدة خمس سنوات فحسب فإن اتفاقهم على أجل يجاوز هذه المدة يكون باطلاً كله^(١)، فلا يكفي إنقاص المدة التي يمتنع طلب القسمة خلالها^(٢). وإذا كان لا يجاوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة تزيد على خمس سنوات، فإن ذلك لا يمنع من الاتفاق على تجديد المدة عند انقضائها، مرة بعد أخرى، على ألا يزيد المدة المتفق عليها، في كل مرة على خمس سنوات.

وقد يفرض البقاء على الشيوع بند في التصرف الذي ينقل المال الشائع إلى المتصرف إليهم، مثلاً الهبة أو الوصية، لا في اتفاق الشركاء. ويرى الفقه^(٣) جواز ذلك متى كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات ومبنياً على باعث مشروع، لأن الجوهرى في المادة ٨٣٤^{2024/2025} هو تحديد مدة لا يتجاوز الالتزام بالبقاء في الشيوع فيها وليس ارتضاؤهم الالتزام^(٤).

فإذا لم يكن الشريك ملزماً، قانوناً أو اتفاقاً، بالبقاء في الشيوع، كان له في أي وقت، طلب القسمة، وليس للقاضي إزاءه سلطة تقديرية، بل يجب عليه إجابته.

(١) أعمال التحضيرية ج ٦ ص ١٠١.

(٢) د. يرى جانب من الفقه أنه حتى في هذه الحالة يجب إنقاص المدة إلى خمس سنوات، ويؤسس رأيه على أن هذه الحالة هي تطبيق الفكرة تعديل العقد وليس إنقاص له. د. مصطفى جمال ص ١٤٧.

(٣) د. السنهورى الوسيط ص ٨٨٥، د. إسماعيل غانم ص ١٧٣، د. الصدة ص ٢٠٣، د. منصور مصطفى ص ١٨٨، عكس ذلك د. حسن كيرة ص ٢٠٠، د. جمال ذكى ص ١٥٢.

(٤) يرى جانب من الفقه أن هذا قياس مع الفارق، حيث لا وجه للشبهه بين البقاء في الشيوع والمنع من التصرف.

وللقسمة طرق تتم بها، كما أن لها آثار تترتب عليها، وعلى ذلك نعرض فيما يلي لكيفية إتمام القسمة، ثم نعرض لآثارها.

المطلب الأول

طريقة القسمة

قد يتفق الشركاء على القسمة وفي هذه الحالة تكون القسمة رضائية وتتم بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها. وقد لا ينعقد إجماعهم على القسمة ولا يتراضون فيما بينهم، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القضاء لإجرائها، فتكون القسمة قضائية... والأصل أن تتم القسمة عينية ولكن قد يتعذر ذلك وفي هذه الحالة تكون القسمة بطريقة التصفية.

الفرع الأول

القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية

القسمة الاتفاقية:

نص المادة ٨٣٥ مدني ٢٠٢٤/٢٠٢٥ «للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون». وتقضى المادة ٤٠ من قانون الولاية على المال «على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك... وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة التثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية». ونصت المادة ٧٩ على أنه: «يسرى في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى في شأن قسمة مال القاصر من أحكام».

يتضح من ذلك أنه لا بد أن ينعقد إجماع الشركاء على القسمة، لهذا لا تتم القسمة بالتراضي إذا كان هناك من يعترض عليها مهما كان نصيبه

ضئلاً، وإنما لابد من عرض الأمر على القضاء ليقوم بإجرائها. وتكون القسمة كذلك اتفاقية حتى ولو كان بين الشركاء ناقض الأهلية^(١) أو غائباً طالما أذنت المحكمة للوصى أو القيم أو وكيل الغائب بالاشتراك فى قسمة التراضى، وصدقت على عدالتها طبقاً للمواد ٤٠ ، ٧٩ من قانون الولاية على المال. وتصديق المحكمة إنما شرح لمصلحة الشريك ناقض الأهلية أو الغائب فلا يكون للشركاء الآخرين التمسك بعدم حصوله للتدخل من القسمة^(٢).

والقسمة التى يتفق عليها بعض الشركاء دون البعض، لا يترتب عليها إنهاء الشيوخ إذ يشترط لذلك إجماع الشركاء، ولكن العقد يظل قائماً، ولكنه غير نافذ فى حق من لم يشترك فيها من المشتاعين، ويكون للشريك الذى لم يكن طرفاً فيه عند إبرامه أن يقره متى شاء، وبهذا ينتهى الشيوخ إذ ما أقرها سائر الشركاء الذين لم يشتركوا فيها عند إبرامها.

ولما كانت القسمة الاتفاقية عقد، فإنه يجوز الاتفاق عليها صراحة بين الشركاء، كما يمكن أن يستخلص هذا الاتفاق من الظروف، حيث يكون التعبير عن الإرادة فيها ضمناً.

2024/2025

2024/2025

وهى ما يطلق عليها «القسمة الفعلية». وتتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع

(١) قضت محكمة النقض «بأنه إذا اشترك ناقص الأهلية فى إبرام عقد القسمة، يكون العقد قابل للإبطال لمصلحته، باعتبار أن القسمة من العقود العائدة بين النفع والضرر. ويزول حقه فى التمسك بالإبطال، إذا أجاز العقد بعد بلوغه سن الرشد» نقض مدنى ١٩٦١/٢/٢٤ مجموعة النقض س١٧ رقم ٥٨ ص٤١٢.

(٢) قضت محكمة النقض «لا يجوز لمدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحبسية، إذ أن هذا البطان شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير». نقض مدنى طعن رقم ٣٦١ س٢٢ ق فى ١٩٥٦/٦/٢٨ س٧ ص٧٦٠.

فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم الجزء الذى سبق أن تصرف فيه^(١). على أنه يلاحظ أن هذه القسمة تنطبق عليها القاعدة العامة فى وجوب التسجيل للاحتجاج بها على الغير^(٢) على أنه يكفى فى هذا، ونظرا للطبيعة الخاصة للقسمة الفعلية أن تكون التصرفات المتتابعة التى قام بها الشركاء الواحد بعد الآخر قد تم تسجيلها جميعا^(٣).

نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن:

تنص المادة ٨٤٥ مدنى: «١. يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبارة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة. ٢- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل المدعى نقداً أو عيناً ما نقص من حصته .. واضح أن النص يقصر القسمة للغبن على القسمة الاتفاقية، فالقسمة القضائية محاطة بضمانات تكفل المساواة»^(٤).

ولا بد أن يزيد الغبن عن النقص، فإذا كان الغبن الذى لحق أحد المتقاسمين يعادل خمس نصيبه أو يقل عن الخمس فلا تقبل دعوى الغبن، وتقدير قيمة هذا النصيب وقت القسمة^(٥).

(١) «يعتبر المتقاسم طبقاً لما تنص به المادة ٨٣٤ مدنى مالكا وحده للحصة المفرزة التى آلت إليه من وقت أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها من بقية الحصص». طعن رقم ١١ لسنة ٤٠ ق ١٩٧٥/٢/١٥ س ٢٦ ص ٤٧٨.

(٢) «الغير فى حكم المادة المذكورة هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند الملكية». طعن ٦٠٤ لسنة ٥١ ق فى ١٩٨٨/٣/٣٠.

(٣) د. إسماعيل غانم ص ١٧٩، د. توفيق فرج ص ٢٥٤.

(٤) نقض مدنى ١٩٧١/١/٢١ مجموعة أحكام النقض س ٢٢ رقم ٢٣ ص ١٣٢.

(٥) د. السنهورى الوسيط ص ٩٠٥، د. إسماعيل غانم ص ١٨٠، د. توفيق فرج ص ٢٥٦.

ومتى كان الغبن غير يسير فهو يجعل القسمة قابلة للإبطال أو قابلة للنقض لمصلحة المغبون، حتى ولو لم يشب إرادة المغبون أى عيب آخر. وإن كان الذى يحدث فى العمل هو أن يقتزن الغبن بالوقوع فى غلط^(١). والقسمة القابلة للإبطال تخضع للقواعد العامة فى هذا الشأن فيجوز للمتقاسم المغبون أن يجيزها صراحة أو ضمناً، كما يجوز له أن يطلب إبطالها. ووسيلة ذلك هى دعوى نقض القسمة بسبب الغبن التى يجوز له أن يرفعها سواء كان المال المقسوم عقاراً أو منقولاً والمدعى عليه فى هذه الدعوى هم جميع المتقاسمون.

وقد حددت المادة ٢/٨٤٥ مدة السنة التالية لتمام عقد القسمة لرفع هذه الدعوى، بحيث إذا رفعت بعد مضيها كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد. فميعاد السنة الذى يتعين أن رفع الدعوى خلاله لا يرد عليه الوقف ولا الانقطاع، فهو من مواعيد السقوط.

أما إذا رفعت فى الميعاد فإنه يكون على المدعى إثبات الغبن الذى يدعيه، وله فى ذلك أن يلجأ إلى جميع طرق الإثبات، ومتى نجح حكم القاضى بنقض القسمة واعتبار الشيوخ قائماً^{2024/2025}

2024/2025

ويجوز للمدعى عليه أن يتلافى نقض القسمة إذا أكمل للمدعى ما نقص من حصته .. فيجب تكملة ما نقص من الحصة وذلك إمعاناً فى تحقيق المساواة بين المتقاسمين، فالقسمة تعنى بالضرورة التساوى عند التوزيع، أو التوزيع طبقاً للحقوق الخاصة بالمتقاسمين والتى كانت لهم فى الشيوخ السابق على القسمة، وللمدعى عليه الخيار فى أن يدفع مبلغاً من النقود أو يعطى من الأعيان التى اختص بها بمقتضى القسمة المطعون فيها ما يكمل حصة المتقاسم المغبون. على أن يضاف إليها ثمرات النقض أو فوائده من يوم القسمة حتى يوم الدفع، وكذلك المصروفات التى يكون المغبون قد تكبدها.

(١) فى الشريعة الإسلامية يؤدى الغبن الفاحش فى عقد القسمة إلى فسخه وإعادة التقسيم من جديد على أسس من العدالة، ويكفى الغبن وحده لى يعيب العقد.

القسمة القضائية :

إذ لم يكن الشركاء ملزمين بالبقاء في الشروع، أو لم ينعقد إجماعهم على أن تكون القسمة اتفاقية أو قبول ما أسفرت عنه هذه القسمة. كان لكل من يريد الخروج من الشروع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية (م ١/٨٣٦) حتى تقوم بنفسها بقسمة المال الشائع. وللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها القسمة القضائية إذ كان في الشروع شريك غير كامل الأهلية أو غائب، ولم تأذن لوصية أو القيم أو النائب عنه في الاتفاق على القسمة، أو إذا كانت قد أذنت ولكنها لم ترى التصديق على القسمة الاتفاقية لعدم عدالتها.

المدعى في دعوى القسمة هو الشريك الراغب في الخروج من الشروع، يرفعها على باقي الشركاء. والشريك هو من له حق شائع في المال، سواء كان شريكاً أصلياً أو كان خلفاً عاماً أو خاصاً تلقى ملكية الحق الشائع من السلف^(١).

ولا يعتبر شريك في الشروع من اشترى جزءاً مفرزاً من المال الشائع من أحد الشركاء أثناء الشروع. فلا يصح له رفع دعوى القسمة باسمه، لأن البيع وإن كان صحيحاً بحيث يعتبر هذا المشتري دائناً للبائع، إلا أنه لا يلزم باقي الشركاء^(٢)، فيكون الشريك البائع هو صاحب الحق في رفع دعوى القسمة وهو الذي يجب اختصاصه منها، ولكن الحكم الصادر في دعوى القسمة حجة عليه - المشتري - ولو لم يتدخل فيها^(٣).

(١) المشتري لحصة شائعة في عقار من أحد الشركاء على الشروع إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة المفقودة بين هؤلاء الشركاء لا يحتج عليه بهذه القسمة، لأنه وقد انتقلت إليه الملكية بالتسجيل على مقتضى المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري، يكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص الحصة التي اشتراها. طعن ٦٠٤ لسنة ٥١ ق ١٩٨٨/٣/٣٠.

(٢) القسمة على السجله يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن التقاسم من إنهاء حالة الشروع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بمقتضى القسمة. طعن ٥٩١ لسنة ٤٦ ق. ١٩٨٠/٢/١٣، س ٣١، ص ٤٧٦.

(٣) د. إسماعيل غانم ص ١٨٥، د. حسن كيرة ص ٢١٦، د. مصطفى الجمال ص ١٧٣.



ويجب توجيه الدعوى إلى كافة الشركاء، فإذا أغفل أحدهم لم يكن الحكم الصادر فيها حجة عليه، وإن كان حجة على الباقيين الذين وجهت إليهم الدعوى. ويجوز لمن لم توجه إليه دعوى القسمة من الشركاء أن يتدخل فيها (م ١٥٣ مرافعات)، ويصح إدخاله فيها بناء على طلب المدعى أو المدعى عليه (م ١٤٣ مرافعات) كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخاله من تلقاء نفسها (م ١٤٤ مرافعات).

وقد جعل المشرع الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية ولو تجاوزت قيمة الأموال المطلوب قسمتها نصاب هذه المحكمة باعتبار أن اختصاصها قاصراً على إجراء القسمة وتعجيلاً بهذه الإجراءات. لذلك فهذا الاختصاص الاستثنائي قاصراً على ما تنبئ به القسمة من مشاكل، كتعيين حصة كل شريك من المال الشائع، أو تقرير بيع المال الشائع في المزاد إذا تعذرت قسمته عيناً. أما المنازعات التي تثور بين الخصوم في دعوى القسمة حول ملكية كل منهم، كالمنازعة في مقدار الحصة الشائعة، فهي ليست منازعة في القسمة وإجراءاتها فتخضع للقواعد العامة في الاختصاص النوعي^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وعلى ذلك إذا ثارت منازعة تخرج عن صميم القسمة، وقدرت المحكمة جديتها، وكان الفصل فيها يخرج عن نصابها، تعين عليها أن توقف دعوى القسمة وأن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وتعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، ويستمر وقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعة م ٢/٨٣٨^(٢).

(١) نقض مدنى ١٩٦٢/١/٢٥ مجموعة أحكام النقض س ١٣ رقم ١٦ ص ١٠٤.

(٢) التمسك بوجوب وقف القسمة حتى يفصل نهائياً في الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به. نقض مدنى ١٩٥٦/٥/٣١. مجموعة النقض س ٧ ص ٦٢٢ رقم ٨٥.



الفرع الثانى

طرق إجراءات القسمة القضائية

الأصل أن تكون القسمة عينية، بأن تعين المحكمة الجزئية، لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع. أما إذا كان يترتب على قسمة المال عيناً نقص كبير فى قيمته، أمرت المحكمة بإجراء القسمة بطريق التصفية. ويجوز للمحكمة - كما أسلفنا - أن تأمر بناء على طلب أحد الشركاء إلى أن تتم القسمة.

القسمة العينية :

الأصل أن يقسم المال الشائع حصصاً متساوية على أساس أصغر نصيب، أو يعتمد إلى التجنيب، ثم تفصل المحكمة فى المنازعات التى تقوم بين الشركاء، وتحكم بعد ذلك بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، لتنتهى فى حالات خاصة إلى التصديق على حكم القسمة.

التقسيم أو التجنيب : لا يتولى القاضى بنفسه تقسيم المال إلى حصص أو تجنيبه، بل يندب خبيراً يقوم بقسمة المال الشائع إلى حصص على أساس أصغر نصيب (م/١/٨٣٧) سواء كانت القسمة كلية أو جزئية، تقتصر على بعض المال الشائع أو على بعض الشركاء على الشيوع، ويكون التقسيم فى كل الأحوال على أساس أصغر نصيب فمثلاً إذا كانت أنصبة الشركاء هى النصف والثلث والسدس قسم المال أسداساً^(١).

فإذا تعذر على الخبير تقسيم المال إلى حصص على أساس أصغر نصيب، عليه أن يعتمد إلى التجنيب (م/٢/٨٣٧) بأن يحدد مباشرة لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يساوى حصته فيه. ويجوز للخبير أن يلجأ كذلك إلى التجنيب، ولو أمكن تقسيم المال إلى حصص على أساس أصغر نصيب،

(١) المذكرة الإيضاحية ح ٦ ص ١٢٠.

إذا اتفق جميع الشركاء عليه^(١). فلا يجوز أن تجرى القسمة بطريق التجنيب إلا إذا تعذر تقسيم المال الشائع إلى حصص على أساس أصغر نصيب، أو اتفق جميع الشركاء على التجنيب^(٢).

وقد يرى الخبير تكملة بعض الأنصبة في حالة التقسيم أو بعض الأجزاء في حالة التجنيب بمبلغ من النقود، ويسمى المعدل، لتصير متساوية، حين يتعذر عليه أن يقيم المساواة التامة بين الحصص أو بين الأجزاء، ليكون على من تقع في نصيبه الحصة، أو الجزء الأكبر، أن يدفع المعدل إلى من تقع في نصيبه الحصة أو الجزء الأصغر، فيتساوى الشركاء في اقتسام المال الشائع (م ٨٣٧/٢ مدنى). والعبرة في تقدير قيمة الحصص، أو الأجزاء بوقت القسمة لا وقت بدء الشروع، ولا وقت رفع دعوى القسمة^(٣).

الفصل فى المنازعات: إذا قام نزاع يتعلق بتكوين الحصص، تفصل فيه المحكمة الجزئية، كما تفصل فى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها. فإذا قام نزاع فى غير تكوين الحصص بأن تنازع الشركاء فى تحديد حصصهم^(٤)، وادعى الشريك أن له الثلث مثلاً، فنازعه الشركاء الآخرون، فصلت المحكمة المختصة فى هذا النزاع، فإن كانت هى المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل، وإلا أحالت الخصوم إلى المحكمة

(١) إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب، فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريقة القرعة. نقض ١٩٥٦/٥/٣١ مجموعة أحكام النقض س ٧ رقم ٨٥ ص ٦٢٢.

(٢) د السنهاورى الوسيط ص ٩٢٣، د اسماعيل غانم ص ١٨٨، د منصور مصطفى، ص ١٩١.

(٣) د إسماعيل غانم ص ١٩٠، د جمال زكى، ص ١٦٥.
(٤) لأن فى القسمة معنى الاستبدال والواقف لم يشترط الاستبدال بنفسه فى كتاب الوقف، فيكون ممتنعاً عليه بإذن من القاضى، ومن ثم فلا يكون يعتد بكشف التحديد العرفى الصادر من الواقف فى إنهاء حالة الشروع لصدور هذا التحديد ممن لا يملكه وبغير الطريق الشرعى. نقض مدنى ١٩٦٧/١/٢٦ طعن رقم ٢٩ لسنة ٣٣ ق س ١٨ ص ٢٠١.

المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها، ووقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً في النزاع.

الحكم بإعطاء كل شريك نصيباً مفرزاً: فإذا انتهت المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة المختصة حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.

أما إذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، وإنما كونت على أساس أصغر نصيب، فإن القسمة تجرى بطريق الاقتراع وتقوم المحكمة بإثبات ذلك في محضرها، وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه بطريق الاقتراع.

التصديق: ويراعى أنه إذا كان بين الشركاء غائب أو من لم تتوافر فيه الأهلية، فإنه يجب تصديق المحكمة الابتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً (م ٨٤٠ مدنى) ويقوم حكم المحكمة الابتدائية بتكوين الحصص، عند الطعن أمامها فى حكم المحكمة الجزئية مقام التصديق. فإذا رفضت المحكمة الطعن، كان عليها أن تقاسم المال الشائع على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم.

القسمة بطريق التصفية :

تنص المادة ٨٤١ على أنه «إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطرق المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع».

يتبين من هذا النص أنه إذا لم تمكن القسمة عيناً - كأن كان المال الشائع منقولاً كسفينة - أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد تقسيمه، كأن كان منزلاً تحدث تجزئته نقصاً كبيراً فى قيمته. تقضى المحكمة بإجراء القسمة بطريق التصفية، فبيع المال الشائع بالطرق المبينة فى

قانون المرافعات ثم تقسيم الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء كل بقدر حصته فيه.

على أن تقنين المرافعات لا يتضمن إجراءات خاصة لبيع المال الشائع لعد إمكان قسمته عيناً إلا إذا كان المال عقاراً، ولذلك يرى الفقه^(١)، إذ كان المال الشائع منقولاً، اتباع الإجراءات الخاصة ببيع المنقول المحجوز عليه فيما عدا ما لا يتفق من هذه الإجراءات مع الغرض المقصود من البيع. ويجوز لأى شخص أن يتقدم للمزايدة، ومع ذلك يجوز أن تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع (م ٨٤١).

وإذا رسا المزاد على أحد الشركاء، سواء كانت المزايدة مقصورة عليهم أم لم تكن، يعتبر رسو المزاد قسمة للمال الشائع، لا بيعاً له، ويترتب عليه جميع آثار القسمة^(٢).

أما إذا رسا المزاد على أجنبى من الشركاء، كان رسوه بيعاً منهم إليه. وإن كان الحكم بتقسيم الثمن بين الشركاء تترتب عليه أيضاً فى العلاقة بينهم كافة آثار القسمة. لذلك يذهب الرأى^(٣) إلى وجوب تصديق المحكمة الابتدائية عليه إذا كان بين الشركاء غائب أو غير ذى أهلية.

2024/2025

تدخل الدائنين فى القسمة لحماية مصالحهم:

يهم دائنوا الشركاء أمر قسمة المال الشائع، فيعنى كل شريك ألا تجرى هذه القسمة على نحو يضرهم، كأن يقع فى نصيب مدينهم منقولات يسهل إخفاؤها، فلا يستطيعون التنفيذ عليها استيفاء لحقوقهم، أو جزء مفرز يقل فى

(١) د السنهورى الوسيط ص ٩١٧، د إسماعيل غانم ص ١٩٢، د الصدة ص ٢١٧.

(٢) الحكم بإيقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيله. نقض مدنى ١٩٨٢/١/٢٤ طعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٥٠ق، س ٣٣، ص ١٦٩.

(٣) د السنهورى الوسيط ص ٩١٧، د إسماعيل غانم ص ١٩٣، د جمال زكى ص ١٦٩، د الصدة ص ٢١٨.

قيمته عن حصته في المال الشائع، أو يقصر المزاد في قسمة التصفية على الشركاء دون غيرهم فنقل فرصة ارتفاع الثمن الذي يرسو به^(١). كما يعنى الدائن المرتهن لجزء مفرز ألا يقع هذا الجزء في نصيب شريك آخر غير الذي رهنه، فينتقل حقه إلى جزء آخر لم يتوقعه وقت الرهن.

فدائني كل شريك، إذا علموا بأمر القسمة أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينيا، أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم (م ١/٨٤٢)، وليس لهذه المعارضة شكل خاص وإن كان يجب على الدائن أن يوجه المعارضة إلى جميع الشركاء بما فيهم الشريك المدين له. كما أن الشارع لم يحدد ميعاد معين لهذه المعارضة، فيستطيع الدائن أن يوجهها بمجرد علمه بأن مدينه شريك في مال شائع إلى أن تتم القسمة. ويترتب على المعارضة إلزام الشركاء عند القسمة بإدخال الدائن الذي أعلنهم في جميع إجراءات القسمة (م ١/٨٤٢).

وقد ألقى الدائنون ذوى الحقوق المقيدة على المال الشائع قبل رفع دعوى القسمة - وهم الدائنون الذين لهم رهون رسمية أو حيازية، أو حقوق اختصاص أو امتياز، على المال الشائع وقيدوا حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة 2024/2025 - من المعارضة في قسمته. وعلى الشركاء دون معارضة منهم إدخالهم في إجراءات القسمة.

ويدخل الفقه والقضاء مع هؤلاء الدائنين من اشترى جزءاً مقرراً^(٢) من المال الشائع من أحد الشركاء وسجل عقد البيع قبل رفع دعوى القسمة، لأنه دائن لهذا الأخير بالضمان ومصلحته واضحة في منع تواطؤ الشركاء على

(١) د. السنهوري الوسيط ص ٩٢٠، د. اسماعيل غانم ص ١٩٥، د. جمال زكى ص ١٧٠، د. الصدة ص ٢١٩.

(٢) فإن من اشترى حصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تسجيل حكم بإيقاع البيع أو قبل التاريخ الذي يرتد إليه أثر تسجيله ولم يختصم في إجراءات البيع لا يحتاج بالحكم ولو كان البائع له مختصماً في الدعوى وتنتقل إليه هو ملكية الحصة التي اشتراها دون الراسى عليه المزاد، ويكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة في مواجهة المشتاعين ومن حكم بإيقاع البيع. الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٥٠٤ ١/٢٤/١٩٨٢، س ٣٣ ص ١٦٩.

إعطاء الشريك البائع جزءاً مفرزاً غير الذى باعه له، على أنه يجوز للدائن فى كل الأحوال وطبقاً لقواعد قانون المرافعات أن يتدخل منضمماً إلى مدينه فى دعوى القسمة.

ويترتب على معارضة الدائن أو تدخله فى دعوى القسمة، أن يصبح الدائن طرفاً فى جميع إجراءات القسمة منذ معارضته أو منذ تدخله، فلا تجوز مباشرة هذه الإجراءات إلا فى مواجهته. ومادام الدائن بإدخاله أو دخوله فى دعوى القسمة، قد هيأت له الفرصة كافية لحماية مصالحه بمراقبة إجراءات القسمة، فلا يستطيع بعد أن تمت القسمة أن يعترض عليها^(١).

أما إذا كان الدائن لم يتدخل فى القسمة لأنه لم يعارض، ولم يكن ذا حق مقيد، أو دعى إلى التدخل نتيجة معارضته أو لكونه ذا حق مقيد ولكنه لم يتدخل، وتمت القسمة دون تدخله، فليس له أن يطعن فيها إلا بالدعوى البوليصية، ويتحمل عبء إثبات غش مدينه، وتواطؤ بقية الشركاء معه، لأن القسمة معاوضة^(٢).

المطلب الثانى آثار القسمة

2024/2025

2024/2025

تمهيد :

إذا تمت القسمة، سواء كانت رضائية أم قضائية، عينية أم قسمة تصفية، ترتب عليها أثاران جوهريان، هما إفراز نصيب كل شريك فى المال الشائع، وما يتعلق بهذا الإقرار من أثر كاشف، والأثر الثانى ضمان المتقاسمين بعضهم لبعض ما قد يمنع لأى منهم من تعرض أو استحقاق فى نصيبه المفرز بسبب سابق على القسمة. ونعرض للأثرين كل فى فرع مستقل.

(١) د. السنهورى الوسيط ص، إسماعيل غانم ص، د. الصدة ص.
(٢) إذ أن الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التى لا تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور بما يستوجب نقضه. نقض مدنى ١٩٨٠/١١/٦ طعن رقم ٨٢٩ لسنة ٤٣ ق، س ٣١ ص ١٨٩٩٠.

الفرع الأول

إفراز نصيب كل متقاسم

يترتب على القسمة أن يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع في حدود الحصة التي كانت له على الشيوع. وبذلك يحصل التطابق بين النطاق المادى والنطاق المعنوى للحق، الذى ثبت للشريك منذ تملك فى الشيوع. وتفصيل ذلك أن حق الشريك المشتاع هو حق ملكية، محله المادى الشئ الشائع كله، وإن كان محدداً تحديداً معنوياً بحصة الشريك فى الشيوع. فالقسمة بإفرازها للشريك جزءاً مادياً من المال الشائع يختص به، تقتصر على إيجاد التطابق بين نطاقه المادى لحقه ونطاقه المعنوى^(١). فبعد أن كانت له حصة شائعة تصير تلك الحصة جزءاً مفرزاً من المال الشائع. ولا يكون هذا إلا نتيجة للقسمة^(٢).

فالقسمة لا تنقل للمتقاسم حقاً جديداً لم يكن له من قبل، ولكنها تكشف عن حق مقرر له من قبل. فالقسمة كما يقال كاشفة للحق أو مقررة له وليست منشئة^(٣). وهى تصرف كاشف آية ٢٣ من المادة ٢٠٢ من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٥ 2024/2025. وهو تصرف تقرير وجوده وإنما للتغير فى بعض عناصره على وجه معين، سابق، لا لمجرد تقرير وجوده وإنما للتغير فى بعض عناصره على وجه معين،

(١) د. إسماعيل غانم ص ٢٠٩، د. حسن كيرة ص ٢١٤، د. توفيق فرج ص ٢٦٧، د. الصدة ص ٢٢٣.

(٢) يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يربتها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً. نقض مدنى ١٩٨٧/١٢/٢٣ طعن ٧٤٥ لسنة ٥٤ ق.

(٣) فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية. نقض مدنى ١٩٨٥/١٢/١٢ طعن رقم ١٥٤٧ لسنة ٥٢ ق.

بإزالة العقوبات التي كانت تعترض مباشرته. وهذا التعريف ينطبق تماماً على القسمة^(١).

وإذا كانت القسمة لا تنقل حقاً جديداً إلى المتقاسم^(٢)، وإنما تكشف عن حق ثابت من قبل^(٣)، وإذا كان الإفراز لا يتم إلا بالقسمة، فإن هذا هو ما يعبر عن الحقيقة. أما إذا قيل أن هذا الإفراز يرجع إلى ما قبل ذلك منذ قيام الشيوخ، بمعنى أن المتقاسم كان يملك حصة مفرزة منذ بدء الشيوخ، فإن هذا يخالف الحقيقة، وهذا ما يعرف بالأثر الرجعي، فالأخير يتضمن افتراضاً يتعين التضييق من نطاق تطبيقه بقصره على حدود الفرض من تقريره، وهو حماية كل متقاسم من الحقوق التي تكون قد تقررت على المال الشائع من قبل أحد الشركاء الآخرين^(٤).

وقد نصت المادة ٨٤٣ مدني على هذا بقوله «يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوخ، وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص». والذي يفهم من النص أن المتقاسم كان مالكا ملكية مفرزة للجزء

(١) د. إسماعيل غانم ص ٢١١ وهامش ٢٠٢٤/٢٠٢٥ منها حيث أشار إلى مراجع متعددة للتصرفات الكاشفة. 2024/2025

(٢) يذهب أ. د/ منصور مصطفى إلى أن القسمة بطبيعتها ناقلة لا كاشفة، فوجود حق شائع للمتقاسم قبل القسمة على الجزء المفروز الذي اختص به لا يمنع من القول بأن القسمة ناقلة، فالقسمة لم تنقل إلا الحق الشائع الذي كان لغير المتقاسم على الجزء المفروز الذي اختص به. وباجتماع هذا الحق مع ما كان للمتقاسم من قبل تخلص له الملكية المفروزة. د. منصور مصطفى منصور: تحليل أثر قسمة الأموال الشائعة، فصله في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ١٩٦٤/٦ ص ١٣٢. وفي نفس الاتجاه الاتجاه د. مصطفى الجمال، ص ١٨٢.

(٣) انظر في الأثر المزدوج للقسمة، أثر ناقل وكاشف، د. السنهوري الوسيط حـ ص ٩٥٠.

(٤) من كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تتحدد به محل البيع لا يحتاج به سائر الشركاء في الشيوخ طالما لم تقم القسمة قضاء أو رضا مما يعتبر حق هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع، فإنه ينبغي على هذا أن يثبت لهم حق الشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح نص المادة ٩٣٦ سالف الذكر. نقض مدني ١٩٨٦/١٢/٢٣ طعن رقم ٥٣٨ لسنة ٥١ ق.

الذى آلت إليه بالقسمة، في حين أنه قبل القسمة لم يكن في الواقع مالكا ملكية مفرزة بل كان يملك ملكية شائعة. وبذلك يكون هدف المشرع من وراء الأخذ بفكرة الأثر الرجعى هي حماية الشريك من تصرفات شركائه في الجزء المفرز الذى آل إليه. ولهذا عطلت بعض نتائج الأثر الرجعى حيناً عن طريق التشريع وآخر عن طريق الفقه والقضاء.

فنصت المادة ١/١٠٣٩ مدنى على أنه «يقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أياً كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته».

وقد كان مؤدى القول بالأثر الرجعى للقسمة، أن يعتبر الرهن فيما زاد على حصة الشريك واقعاً على ملك الغير في الجزء المفرز الذى آل إليه، أ، فيما زاد على حصته الشائعة إذ آل إليه العقار المرهون في قسمة التصفية .. كما أن العبرة في تكوين الحصص بقيمة الأموال الشائعة وقت القسمة، وقد كان مقتضى الأثر الرجعى اعتبار القيمة وقت بدء الشيوخ، ويتفق الفقه (١) والقضاء (٢) على أن ثمار المال الشائع قبل القسمة تكون لجميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه، وقد كان مؤدى الأثر الرجعى أن تؤول لكل شريك ثمار الجزء الذى وقع في نصيبه منذ بداية الشيوخ.

نخلص من ذلك أن النثر الكاشف فكرة تتأسس على مبدأ جوهرى في القسمة، المساواة بين المتقاسمين والذى لا يتفق مع تحمل الشريك آثار تصرف شريكه في المال الشائع قبل قسمته.

(١) د. إسماعيل غانم ص ٢١٣، د. الصدة ص ٢٢٥، د. حسن كيرة ص ٢٣٠، د. جمال زكى ص ١٨٤.

(٢) الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوخ من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وإجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقاً في الاستثناء بثمار الحصة التى خصصت له إلا من وقت حصول القسمة. نقض مدنى ١٩٦٥/١١/٢٥ مجموعة أحكام النقض ص ١٦ رقم ١٨٠ ص ١١٤٥.

آثار اعتبار القسمة كاشفة :

يترتب على الأثر الكاشف للقسمة عدة نتائج أهمها عدم اعتبار القسمة سبباً صحيحاً لكسب الملكية أو الحق العيني بالتقادم القصير، لأن السبب الصحيح تصرف ناقل للملكية، أو منشئ للحق العيني موضوع الحيازة، ولا ينقصه لنقلها أو إنشائها سوى صدوره من غير مالك. والقسمة عقد كاشف أو مقرر، يقتصر على الكشف عن ملكية المتقاسم السابقة على إبرامها. وعلى ذلك إذا تلقى الورثة عقار في التركة، واقتسموه فيما بينهم معتقدين أنه ملك لمورثهم، ثم تبين أنه لم يكن مملوكاً له، فلا تنتقل إلى الوارث ملكية الجزء المفرز الذي اختص به ولو استمر حائزاً له مدة تزيد على خمس سنوات. لأن القسمة ولو كانت مسجلة ليست سبباً صحيحاً يجيز كسب ملكية العقار بالتقادم القصير. كما لا يستطيع الوارث التمسك بالميراث - وهو سند ملكيته - سبباً صحيحاً، لأنه ليس تصرفاً قانونياً بل واقعة مادية^(١). أما إذا كان الشركاء قد ابتاعوا العقار الشائع من غير مالكة، وكانوا حسنوا النية يعتقدون في ملكيته له، فإن هذا البيع لا القسمة يعتبر سبباً صحيحاً، يجيز لكل شريك أن يكسب ملكية الحصة الشائعة أو الجزء المفرز بالتقادم القصير المدة.

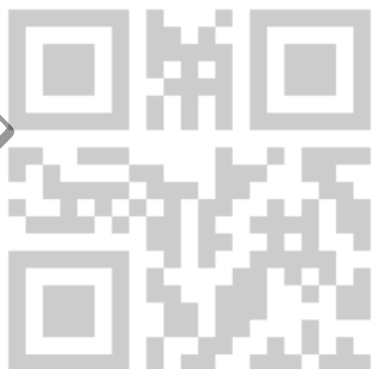
2024/2025

2024/2025

2024/2025

على أن الأثر الهام للقسمة خاص بالتسجيل حيث فرق المشرع في أثر التسجيل بين العقود الناقلة أو المنشئة والعقود المقررة أو الكاشفة. فالأولى لا يترتب أثرها في نقل الملكية أو إنشاء الحق العيني الأصلي، بين أطرافها ولا في مواجهة الغير إلا بالتسجيل (م ٩ من قانون الشهر العقاري). في حين أن الثانية يترتب عليها دون تسجيل أثرها بين أطرافها، ولكن لا يحتج بها على الغير إلا بالتسجيل (م ١٠).

(١) الملكية بالميراث من الوقائع المادية، وكذلك الحال بالنسبة لوضع اليد، فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات.. نقض مدني ١٥/١/١٩٨٠ طعن ٧١٣ لسنة ١٦٢٥، س ٣١، ص ١٦٢.



وعلى ذلك يعتبر المتقاسم بمقتضى القسمة مالكاً فى علاقته بالمتقاسمين للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه، ولكنه لا يستطيع أن يحتج بملكيتة له على الغير إلا بتسجيل القسمة.

والغير هنا هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع. وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. فإذا باع أحد المتقاسمين رغم القسمة حصة شائعة وسجل المشتري عقده قبل تسجيل القسمة، خلصت له ملكية الحصة المباعة^(١)، ويكون له أن يطلب تثبيت ملكيته عليها فى مواجهة بقية المتقاسمين الذين لا يستطيعون الاحتجاج عليه بعقد القسمة غير المسجل أو الذى سجل بعد تسجيل عقد شرائه. ويكون للمشتري، وقد أصبح شريكاً فى الشيوع أن يطلب إجراء قسمة جديدة.

الفرع الثانى

الضمان فى القسمة

2024/2025

تنص المادة ٨٤٤ مدنى على أنه «يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة». وأساس الضمان بين المتقاسمين هو ضرورة تحقيق المساواة بينهم فى حصول كل منهم على ما يوازى حصته الشائعة. ذلك أنه لو تلقى أحد المتقاسمين عيناً معينة ثم حكم لأجنبى بملكية تلك العين أو بجزء منها أو بتكليف عليها لسبب سابق على القسمة، فإن معنى هذا أن المتقاسم لم يتلقى شيئاً أو تلقى نصيباً يقل عن قيمة حصته الشائعة.

وإذا كان المشرع قد نظم أحكام الضمان - تعرض استحقاق، عيوب خفية - فى عقد البيع م ٤٣٩ وما بعدها، فإن التزام البائع بالضمان فيها أعم من التزام المتقاسم، فالأخير وإن التزم بضمان التعرض والاستحقاق إلا أنه لا

(١) المشتري بحصة شائعة فى عقار من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة المفقود بين هؤلاء الشركاء لاحتج عليه بهذه القسمة. نقد مدنى ١٩٨٨/٣/٣٠، طعن ٦٠٤ لسنة ٥١ق.

يتحمل بضمان العيوب الخفية، إذ ليس هناك محل لتحمله بها. فأحكام نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن تغنى عنها، فاكتشاف العيب فيما وقع فى نصيب المتقاسم إنما يدل على غبن لحقه، فيكون له أن يطلب نقض القسمة وليس له أن يرجع بالضمان^(١).

ويرى البعض الرجوع إلى قواعد ضمان التعرض والاستحقاق فى البيع فيما لم يرد فيه نص فى خصومها فى القسمة، إلا ما تعارض من تلك القواعد مع مبدأ الأثر الكاشف أو مع فكرة المساواة بين المتقاسمين^(٢).

شروط الرجوع بالضمان :

تنص المادة ٨٤٤ مدنى على أنه «١- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعرض مستحق الضمان، على أن تكون العبرة فى تقدير الشئ يوم القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

٢- غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأت عنها، ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه».

يتضح من ذلك أن شروط الضمان أربعة، إن تحققت وجب الضمان سواء كانت القسمة اتفاقية أو قضائية، وهى:

الشرط الأول : وقوع تعرض أو استحقاق :

أول ما يستفاد من النص أنه يجب أن يقع التعرض للمتقاسم فعلاً، فلا يكفى أن يعلم بوجود حق للغير قد يقع التعرض له بسببه. فإن وقع التعرض

(١) د إسماعيل غانم ص ٢٥٩، د أحمد سلامة ص ٤٢٠، د جمال زكى ص ١٩٢.

(٢) د السنهورى الوسيط ص ٩٧١، د إسماعيل غانم ص ٢٥٨، د حسن كيرة ص ٢٣٣.

وجب أن يكون تعرضاً قانونياً، إذ المتقاسم شأنه شأن البائع لا يضمن التعرض المادى الصادر من الغير.

والتعرض القانونى هو الادعاء بحق، سواء كان عينياً أو شخصياً بشرط أن يكون نافذاً فى مواجهة المتقاسم، ويكون من شأنه أن ينقص من قيمة ما آل إليه. والغالب أن يتأتى هذا التعرض عن طريق رفع دعوى للمطالبة بالحق المدعى به (١).

وإذا كانت المادة ٨٤٤ مدنى ذكرت أن التعرض يقع من الغير، فإن ذلك لا يحول دون القول بالزام كل شريك متقاسم بالامتناع عما يكون من شأنه الإخلال بحق شريك آخر بالانتفاع بالحصة المفزة التى آلت إليه بطريق القسمة. والتعرض المادى الصادر من الشريك لا خلاف عليه فى الفقه، فإذا آل إلى أحد الشركاء على الشيوع متجراً بطريق القسمة، فلا يجوز لشريك آخر أن يقيم فى نفس المكان أو مكان قريب متجراً ينافسه. وهذا ما يوجب مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود (م ١٤٨ مدنى).

أما تعرض الشريك المتقاسم لشريك آخر المبني على سبب قانونى فقد اختلف الرأى فيه، فذهب رأى (٢) إلى أن المتقاسم لا يلتزم بعدم التعرض القانونى، فلو تبين أن أحد الأموال التى شملتها القسمة كان ملكاً خالصاً لأحد المتقاسمين، فإنه يكون لهذا المتقاسم أن يسترده من زميله الذى آل إليه، ولا يجوز أن تدفع دعواه بالقاعدة التى تقضى بأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .. بينما يذهب رأى آخر ونفضله بأن المتقاسم يلتزم بعدم التعرض، وتكون وسيلته لاسترداد ماله أن يطعن فى القسمة بالغلط فيبطلها، فيتربت على إبطالها أن يعود إليه ماله (٣).

(١) د. السنهورى الوسيط ص ٩٧٣، د. غانم ص ٢٦٠، د. أحمد سلامة ص ٤٢٢، د. جمال زكى ص ١٩٣.

(٢) د. إسماعيل غانم ص ٢٦٣، د. السنهورى ص ٩٧٤، د. جمال زكى ص ١٩٢.

(٣) د. منصور مصطفى ص ٢٢٩، د. أحمد سلامة ص ٤٢٣، د. محمد عمران ص ٣٦٩.

الشرط الثانى : أن يكون التعرض أو الاستحقاق لسبب سابق على القسمة :

يجب لقيام الضمان أن يرجع التعرض أو الاستحقاق إلى سبب سابق على القسمة، بمعنى أن يكون الحق الذى يدعيه موجوداً قبل القسمة، فلا يضمن المتقاسمون ما يطرأ بعد القسمة^(١).

فإذا نزعت ملكية العقار الذى اختص به المتقاسم للمنفعة العامة بعد القسمة أو كسب أجنبى ملكيته أو حق ارتفاق عليه بالتقادم. بعد القسمة ولو بدأ سريانه قبلها لا يستطيع المتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق على بقية المتقاسمين، إلا إذا اكتملت مدته عقب القسمة على نحو لا يكون لدى المتقاسم وقت كاف لقطع التقادم بإجراء يتخذه.

الشرط الثالث : يجب ألا يكون الاستحقاق مراجعاً إلى خطأ المتقاسم :

لا يكون للمتقاسم أن يرجع على بقية المتقاسمين بالضمان إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطئه، كأن يقر لمدعى الاستحقاق بحقه ثم يبين عدم وجود حق له. أو أن يرفع عليه الغير دعوى استحقاق فلا يدخل الشركاء المتقاسمين معه فيها، ويهمل الدفاع فيها فيقضى للمدعى بطلبه ثم يثبت بقية المتقاسمين عدم صحة الدعوى.

الشرط الرابع : ألا تتضمن القسمة بند إعفاء من الضمان :

لا يقوم الضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه، وإن كان لا يكفى لرفع الضمان الاتفاقى أن يرد الإعفاء منه فى عبارات عامة، كما لا يجوز أن يكون الاتفاق على الإعفاء ضمناً، بل يجب أن يكون صريحاً، وأن يكون خاصاً بسبب معين من أسباب الاستحقاق المذكور فيه ويقتصر الإعفاء عليه، وهذا ما عنته المادة ٨٤٤ بقوله «فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها» ويجب أن يدرج فى عقد القسمة ذاتها أو يورد فى محرر مستقل عنها.

(١) نقض مدنى ٢٦/٤/١٩٦٢، مجموعة أحكام النقض س ١٣ رقم ٧٨ ص ٢٦٤.

آثار الضمان :

إذا لم ينجح المتقاسمون في دفع التعرض، وقضى للمتعرض بحقه التزموا بضمان الاستحقاق، أى بتعويض المتقاسم عن نصيبه أو عما نقص منه نتيجة لهذا الاستحقاق.

ويوزع التعويض على جميع المتقاسمون كل بنسبة حصته بما فيهم المتقاسم الذى حدث له التعرض، ذلك لأن الاستحقاق أنقص المال الشائع بالنسبة لجميع المتقاسمين.

ولما كان يقصد بالضمان رفع عبئه عن المتقاسم الذى تحمله بتوزيعه على جميعهم وإعادة المساواة التى اختلفت نتيجة للاستحقاق، فإذا كان أحد المتقاسمين معسر وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين تحقيقاً لذات الفكرة.

وتكون العبرة في تقدير الشئ بقيمته يوم القسمة، على نقيض البيع، الذى تقع فيه قيمة المبيع وقت الاستحقاق (م ٤٤٣/١)، ذلك أن الغرض من الضمان 2024/2025 فى القسم إعادة المساواة بين المتقاسمين 2024/2025 برد المتقاسم ضحية الاستحقاق إلى الوضع الذى يكون فيه ولو كان المستحق فى يده لم يدخل فى موضوع القسمة. ولحق المتقاسم ضحية الاستحقاق فى الضمان، امتياز على ما آل إلى بقية المتقاسمين لا يجوز فيه طلب قسمة المال الشائع.

2024/2025





محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
٧	الباب الأول أسباب كسب الملكية
٨	تقسيم
٩	الفصل الأول أسباب كسب الملكية ابتداءً (الاستيلاء)
١٠	المبحث الأول : شروط تملك المنقول بالاستيلاء
١٣	المبحث الثاني : تطبيقات للاستيلاء كسب مكسب للملكية
٢١	الفصل الثاني أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة (الوصية - الميراث)
٢١	تقسيم
٢١	المبحث الأول : الوصية
٢٢	المطلب الأول : انعقاد الوصية
٢٥	المطلب الثاني : حماية الورثة من الوصايا المستترة
٣١	المبحث الثاني: الميراث
٣٣	الفصل الثالث أسباب كسب الملكية (الالتصاق - العقد - الشفعة - الحيازة)
٣٣	المبحث الأول : العقد
٣٤	المبحث الثاني : الالتصاق
٣٥	المطلب الأول: الالتصاق كسند للملكية
٣٨	المطلب الثاني : الالتصاق كسبب لكسب الملكية
٣٨	الفرع الأول : الالتصاق الطبيعي
٤١	الفرع الثاني : الالتصاق الصناعي
٤٢	الغصن الأول: إقامة مالك الأرض منشآت على أرضه بمواد ليست مملوكة له
٤٥	الغصن الثاني: إقامة منشآت على أرض الغير بمواد مملوكة لمقيم المنشآت
٥١	الغصن الثالث : إقامة منشآت في أرض الغير بمواد غير مملوكة لمقيم المنشآت
٥٣	الغصن الرابع : استبعاد بعض صور الالتصاق
٥٥	الفرع الثالث : التصاق المنقول بالمنقول

2024/2025

2024/2025

٥٦	المبحث الثالث : الشفعة
٥٦	تعريف الشفعة
٦٠	المطلب الأول : أسباب الأخذ بالشفعة
٦٠	الفرع الأول: مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع
٦١	الفرع الثاني: صاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة
٦٢	الفرع الثالث: الشريك في الشيوع
٦٥	الفرع الرابع: الجوار كسبب للشفعة
٦٧	الفرع الخامس: تزامم الشفعاء
٦٩	المطلب الثاني : أحكام الشفعة
٦٩	الفرع الأول : الشروط التي يجب توافرها في الشفيع
٧٣	الفرع الثاني: التصرف الذي يجيز الشفعة
٧٣	الفصل الأول : يجب أن يكون التصرف بيعاً
٧٧	الفصل الثاني: البيع الذي يشفع فيه عند توالي البيوع
٧٩	الفرع الثالث : البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة
٨٢	المطلب الثالث : إجراءات الشفعة
٨٢	الفرع الأول : إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
٨٦	الفرع الثاني : إيداع الثمن
٨٩	الفرع الثالث : رفع دعوى الشفعة
٩١	المطلب الرابع : آثار الشفعة ومسقطاتها
٩١	٢٠٢٤/٢٠٢٥ المطلب الأول : آثار الشفعة 2024/2025
٩١	الفصل الأول : علاقة الشفيع بالمشتري
٩٤	الفصل الثاني : علاقة الشفيع بالبائع
٩٥	الفصل الثالث : علاقة الشفيع بالغير
٩٧	الفرع الثاني : أسباب سقوط الحق في الشفعة
١٠٠	المبحث الرابع : الحيازة
١٠١	المطلب الأول : الحيازة في ذاتها
١٠٢	الفرع الأول : ماهية الحيازة
١١٠	الفرع الثاني: عيوب الحيازة وصفاتها وانتقالها وفقدانها
١١٩	المطلب الثاني: آثار الحيازة
١٢٠	الفرع الأول: العلاقة بين الحائز والمالك
١٢٤	الفرع الثاني: كسب الحقوق العينية
١٢٥	الفصل الأول : الحيازة في المنقول سند الملكية
١٣٣	الفصل الثاني: كسب الحقوق العينية بالتقادم
١٥١	الباب الثاني أحكام حق الملكية

١٥١	تمهيد وتقسيم
١٥٣	الفصل الأول حق الملكية بوجه عام
١٥٤	المبحث الأول : نطاق حق الملكية
١٥٤	المطلب الأول: النطاق المعنوي لحق الملكية (سلطات المالك)
١٥٤	أولاً: الاستعمال
١٥٦	ثانياً : الاستغلال
١٥٨	ثالثاً : التصرف
١٦٢	المطلب الثاني: النطاق المادي لحق الملكية (محل حق الملكية)
١٦٢	الفرع الأول : ملكية السطح ووضع الحدود
١٦٨	الفرع الثاني: شمول الملكية للملحقات والثمار والمنتجات
١٧٢	المبحث الثاني : خصائص الملكية
١٧٢	• الملكية حق جامع مانع
١٨٣	الفصل الثاني القيود التي ترد على الملكية
١٨٣	تمهيد وتقسيم
١٨٤	المبحث الأول : القيود القانونية
١٨٨	المطلب الأول : القيود التي تحد من سلطات المالك
١٨٨	الفرع الأول : قيود المسافات
١٩٢	الفرع الثاني : القيد الخاص بالحائط الفاصل
٢٠١	المطلب الثاني: القيود التي تحد من استئثار المالك بملكه
٢٠٢	الفرع الأول: القيود الخاصة بالرى والصرف
٢٠٧	الفرع الثاني: القيد الخاص بالمرور القانوني
٢١٦	المطلب الثالث: مسئولية المالك في استعمال ملكه (التزامات الجوار)
٢٢٩	المبحث الثاني: القيود الاتفاقية
٢٣١	المطلب الأول: نطاق الشرط المانع وشروط صحته
٢٣٧	المطلب الثاني: آثار الشرط المانع من التصرف
٢٤٥	الفصل الثالث الملكية الشائعة
٢٤٥	تمهيد وتقسيم
٢٤٨	المبحث الأول: الأحكام العامة للشيوخ
٢٤٩	المطلب الأول: حفظ المال الشائع

٢٥١	المطلب الثاني: استعمال المال الشائع
٢٥٨	المطلب الثالث: إدارة المال الشائع
٢٦١	المطلب الرابع: التصرف في المال الشائع
٢٦٢	الفرع الأول: التصرف في المال الشائع من جميع الشركاء أو من أغليبيتهم
٢٦٤	الفرع الثاني: التصرف الصادر من أحد الشركاء
٢٦٩	الفرع الثالث: استرداد الحصة الشائعة
٢٧٣	المبحث الثاني: انقضاء الشبوع «القسمة»
٢٧٧	المطلب الأول: طريقة القسمة
٢٧٧	الفرع الأول: القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية
٢٨٣	الفرع الثاني: طرق إجراءات القسمة القضائية
٢٨٨	المطلب الثاني: آثار القسمة
٢٨٩	الفرع الأول: إفراز نصيب كل متقاسم
٢٩٣	الفرع الثاني: الضمان في القسمة
٢٩٩	الفهرس

